

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقه

فقه المعاملات على المذهب الشافعي
لطلاب الفرقة الثانية
بكلية الشريعة والشعب المناظرة
(الدراسة النصية)

١٤٤٥هـ / ٢٠٢٣-٢٠٢٤م

أولاً: مقرر الدراسة النصية
من كتاب: شرح الإمام جلال الدين المحلي
على متن منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي
في فقه مذهب الإمام الشافعي

تعليق:

- ١- د/ علي منصور عثمان حبيب أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
- ٢- د/ ياسر السيد عبد العظيم أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
- ٣- د/ محمود السيد عويس أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
- ٤- د/ محمد جمعة العيسوي مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

١٤٤٥هـ / ٢٠٢٣-٢٠٢٤م

كِتَابُ الْبَيْعِ^(١)

الْبَيْعُ^(٢): هُوَ كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، فَيَقُولُ اشْتَرَيْتَهُ بِهِ^(٣) فَيَتَحَقَّقُ بِالْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَلَهُمَا شُرُوطٌ تَأْتِي وَالصِّغَةُ الَّتِي بِهَا يَغْقَدُ، وَبَدَأَ بِهَا كَغَيْرِهِ لِأَنَّهَا أَهَمُّ لِلْخِلَافِ فِيهَا، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالشَّرْطِ خِلَافَ تَعْبِيرِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ كَالْغَزَالِيِّ عَنْ الثَّلَاثَةِ بِأَرْكَانِ الْبَيْعِ^(٤). فَقَالَ: (شَرْطُهُ الْإِجَابُ كِبَعْتُكَ وَمَلَكَتُكَ، وَالْقَبُولُ كَاشْتَرَيْتُ وَتَمَلَّكَتُ وَقَبِلْتُ)^(٥) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِدُونِهِمَا؛ لِأَنَّهُ مَنْوُطٌ بِالرِّضَا لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهٍ وَغَيْرِهِ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» وَالرِّضَا حَفِيٌّ، فَاعْتَبَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ فَلَا يَبِيعُ بِالْمُعَاطَاةِ^(٦)، وَيُرَدُّ كُلُّ مَا أَخَذَهُ بِهَا أَوْ بَدَلَهُ إِنْ تَلَفَ^(٧)، وَقِيلَ: يَنْعَقِدُ بِهَا فِي الْمُحَقَّرِ كَرِطَلٍ خُبْزٍ وَحُزْمَةِ بَقْلٍ، وَقِيلَ: فِي كُلِّ مَا يُعَدُّ فِيهِ بَيْعًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالدَّوَابِّ وَالْعَقَارِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرُّوضَةِ وَغَيْرِهَا^(٨).

(وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِيِّ)^(٩) عَلَى لَفْظِ الْبَائِعِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ ذَلِكَ، وَمَنْعَ الْإِمَامِ تَقَدُّمَ قَبْلَتِ، وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ الْمُصَنِّفُ بِجَوَازِهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ مِثْلُهُ وَهَذَا نَاطِرٌ إِلَى الْمَعْنَى، وَالْأَوَّلُ إِلَى اللَّفْظِ.

(١) علق على هذا النص الأستاذ الدكتور/ محمود السيد عويس (أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة)، وغالب ما اعتمدت عليه في التعليق هو مغني المحتاج للخطيب الشربيني (رحمه الله)، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

(٢) عبر المصنف (رحمه الله) بـ "كتاب البيع" تَأْسِيًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ] وتبعاً للرافعي في المحرر، وعبر غيره بـ "كتاب البيوع".

❖ والبيع في اللغة: إعطاء شيء في مقابلة شيء.

❖ وفي الشرع: مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه.

❖ والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة وإجماع الأمة قَالَ اللَّهُ تَعَالَى [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ p: "البيعان بالخيار" وغير ذلك، والإجماع مُنْعَقِدٌ عَلَى ذَلِكَ.

(٣) شرع في ذكر مثال لصيغة عقد البيع؛ ليقع تصويره في الذهن قبل ذكر شروطه.

(٤) كلام الشارح (رحمه الله) يفهم منه أن تعبير المصنف هنا بالشروط، وفي المجموع بالركن لم يكن تبعاً للرافعي، ففي المحرر قال: "لا يصح البيع إلا بالصيغة وهي..."

(٥) هذه أمثلة لصيغة البيع الصريح.

(٦) وصورتها: أن يأخذ المشتري السلعة، ويدفع ثمنها للبائع بدون كلام بينهما، والأمثلة عليها كثيرة.

(٧) والكلام في حق البائع والمشتري على حد سواء، فيرد البائع الثمن، والمشتري السلعة، وما تقدم من أن الرضا خفي والكلام مظهر له هو الدليل على عدم صحة البيع بالمعاطاة.

(٨) ولفظه (رحمه الله) فيها : "وقال مالك : ينعقد بكل ما يعده الناس بيعاً، واستحسنه ابن الصباغ، قلت: هذا الذي استحسنه ابن الصباغ، هو الراجح دليلاً، وهو المختار؛ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ. وممن اختاره: المتولي والبعوي وغيرهما. والله أعلم".

(٩) كأن يقول البائع: بعني هذا الثوب بألف، ويتأخر القبول من البائع فيقول قبلت.

(وَلَوْ قَالَ بَغْنِي، فَقَالَ بَعْتُكَ انْعَقَدَ) الْبَيْعُ (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِدَلَالَةِ بَغْنِي عَلَى الرِّضَا، وَالثَّانِي: لَا يَنْعَقِدُ لِاحْتِمَالِ بَغْنِي لِاسْتِبَانَةِ الرَّغْبَةِ، وَبِهَذِهِ الصِّيغَةِ تَقْدِيرًا لِلْبَيْعِ الضَّمْنِيِّ ^(١٠) فِي أَعْتَقَ عَبْدُكَ عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ، فَإِنَّهُ يَفْتَقُ عَنْ الطَّالِبِ، وَيُلْزِمُهُ الْعَوْضُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ بَغْنِيهِ وَأَعْتَقَهُ عَنِّي، وَقَدْ أَجَابَهُ، وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ مِنِّي فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ فَكَمَا لَوْ قَالَ بَغْنِي فَقَالَ بَعْتُكَ، قَالَهُ الْبَغْوِيُّ ثُمَّ مَا ذَكَرَ صَرِيحٌ.

(وَيَنْعَقِدُ بِالْكُنَايَةِ) وَهِيَ: مَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ بِأَنْ يَنْوِيَهُ ^(١١) (كَجَعَلْتُهُ لَكَ بِكَذَا) أَوْ خُذْهُ بِكَذَا نَاوِيًا الْبَيْعَ (فِي الْأَصَحِّ) هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْإِنْعِقَادِ.

وَالثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ بِهَا؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ لَا يَذَرِي أَخُوَطَبَ بَيْعٍ أَمْ بَعْرِهِ. وَأُجِيبَ: بِأَنْ ذَكَرَ الْعَوْضَ ظَاهِرٌ فِي إِرَادَةِ الْبَيْعِ.

فَإِنْ تَوَقَّرَتْ الْقَرَأَيْنِ عَلَى إِرَادَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَجَبَ الْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ ^(١٢). وَبَيْعُ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِيهِ لَا يَنْعَقِدُ بِهَا ^(١٣) جَزْمًا؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يَطْلَعُونَ عَلَى النَّيَّةِ، فَإِنْ تَوَقَّرَتْ الْقَرَأَيْنِ عَلَيْهِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُهُ.

^(١٤) (وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا) وَلَا يَتَخَلَّلَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ، فَإِنْ طَالَ أَوْ تَخَلَّلَ لَمْ يَنْعَقِدْ كَذَا فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الطَّوِيلُ مَا أَشْعَرَ بِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولِ، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ كَلِمَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. (وَأَنْ يُقْبَلَ عَلَى وَقْفِ الْإِيجَابِ، فَلَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِأَلْفٍ مُكْسَرَةٍ فَقَالَ قَبِلْتُ بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ لَمْ يَصِحْ) وَكَذَا عَكْسُهُ، وَلَوْ قَالَ: بَعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ، فَقَالَ: بَعْتُكَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَصِحْ، وَلَوْ قَالَ: وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ الْمُتَوَلَّى يَصِحُّ، وَنَظَرَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ عَدَدَ الصَّفَقَةِ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةَ، قَالَ فِيهِ: وَالظَّاهِرُ فُسَادُ الْعَقْدِ فِيمَا إِذَا قَبِلَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ خِلَافَ قَوْلِ الْقَالَ بِصِحَّتِهِ اهـ. وَنَبَّهَ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُلْزِمُهُ عِنْدَهُ إِلَّا أَلْفٌ.

^(١٠) الضمني: هو ما يدل عليه اللفظ في غير منطوقه، وذكر المثل عليه بأعتق عبدك عني.

^(١١) فلا بد في استحضار نية البيع مع الكناية بخلاف الصريح لم يحتج، وعليه لو قال لم أنو به البيع فالقول قوله.

^(١٢) لأن القرائن قامت مقام الصريح في الدلالة على إرادة البيع.

^(١٣) يعني بالكناية، فلا بد من الصريح.

^(١٤) بعد ما انتهى من الكلام عن الصيغ الكلامية للبيع (الصريح والضمني والكناية) وذكر الأمثلة على كل منها شرع في بيان شروط الصيغة.

(وَإِشَارَةُ الْأُخْرَسِ) ^(١٥) بِالْعَقْدِ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ (كَالنُّطْقِ) بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَصِحُّ بِهَا، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ الْإِعْتِدَادُ بِإِشَارَتِهِ فِي الْحَلِّ أَيْضًا كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَأَنَّهُ إِنْ فَهِمَهَا الْفَطْنُ وَغَيْرُهُ فَصَرِيحَةٌ أَوْ الْفَطْنُ فَقَطْ فَكِنَايَةٌ ^(١٦)).

(وَشَرَطُ الْعَاقِدِ) الْبَائِعُ أَوْ غَيْرُهُ ^(١٧) (الرُّشْدُ): وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ، وَمَالِهِ، فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الصَّبِيِّ الْمَجْنُونِ وَمَنْ بَلَغَ غَيْرَ مُصْلِحٍ لِدِينِهِ وَمَالِهِ، نَعَمْ مَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لَهُمَا ثُمَّ بَدَّرَ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ عَقْدُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ بَعْدَهُ.

(قُلْتُ: وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ) أَيُّ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْمُكْرَهِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَصِحُّ بِحَقٍّ، قَالَ فِي الرُّوْضَةِ: الْمَزِيدُ فِيهَا هَذَا الشَّرْطُ بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ بَيْعٌ مَالِهِ لَوْفَاءَ دَيْنٍ أَوْ شِرَاءٌ مَالٍ أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِيهِ فَأَكْرَهَهُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ اهـ.

وَلَوْ بَاعَ مَالٌ غَيْرُهُ بِإِكْرَاهِهِ عَلَيْهِ صَحَّ ^(١٨)، قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ كَالصَّحِيحِ فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً غَيْرَهُ بِإِكْرَاهِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْأُذُنِ.

^(١٩) (وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ) ^(٢٠) الْمُصْحَفَ وَكُتِبَ الْحَدِيثُ (وَالْمُسْلِمَ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا فِي مَلِكِهِ لِلأَوَّلِينَ ^(٢١) مِنَ الْإِهَانَةِ، وَلِلثَّالِثِ ^(٢٢) مِنَ الْإِذْلَالِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: [وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا] [النساء: ١٤١] وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمَلِكِ عَنْ كُلِّ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَصْحِيحُ طَرِيقَةِ الْقَطْعِ بِالْأَوَّلِ فِي الْأَوَّلِينَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَبْدَ يُمَكِّنُهُ الْإِسْتِعَاثَةُ وَدَفْعُ الدَّلِّ عَنْ نَفْسِهِ. (إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ عَلَيْهِ) كَأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ، (فَيَصِحُّ) بِالزَّفْعِ شِرَاؤُهُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِإِنْتِقَاءِ إِذْلَالِهِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ مَلِكِهِ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ الْإِذْلَالِ. ^(٢٣) (وَلَا) شِرَاءُ

^(١٥) تقييد الإشارة بالأخرس يفهم منها أنه لا تعتبر من الناطق الإشارة في البيع؛ لقدرته على بيان إرادته باللفظ.
^(١٦) جدير بك أخي القارئ أن توضح ذلك بالإشارة التي يفهمها الجميع، وبالإشارة التي لا يفهمها إلا البعض، دلالة على الصريح والكناية من إشارة الأخرس.

^(١٧) يعني المشتري في عقد البيع، وسواء أكان العاقد (البائع والمشتري) بالأصالة أو النيابة، وفي غير البيع ما يسمى به طرفي العقد كالمؤجر والمستأجر، فالذي يشترط في العاقد للبيع يشترط في غيره من المعاملات.
^(١٨) وصورته: أن يكره مالك الدابة زيدا على بيعها فيصح البيع؛ إذ لا أثر للإكراه هنا بل هو أبلغ في الأذن كما قال قياساً على الطلاق.

^(١٩) حكم شراء الكافر للمصحف وكتب الحديث، وذكر الخلاف فيه.
^(٢٠) وهو غير المسلم مطلقاً حربياً كان أو ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً، وما لا يصح في الشراء لا يصح في غيره مما يكون له اليد عليه.

^(٢١) المصحف وكتب الحديث، ومثلهما كتب التفسير.
^(٢٢) شراء العبد والأمة المسلمين.
^(٢٣) حكم شراء الحربي والذمي للسلاح، وما يصنع منه السلاح كالحديد ونحوه.

(الْحَرْبِيُّ سِلَاحًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ فِي الْمَنَاهِي؛ لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ فِي قَبْضَتِنَا وَبِخِلَافِ غَيْرِ السِّلَاحِ مِمَّا يَتَأْتَى مِنْهُ كَالْحَدِيدِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ جَعْلُهُ سِلَاحًا، وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ يَصِحُّ سَلَمُ الْأَعْمَى أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِهِ أَوْ شِرَائِهِ، فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ رُؤْيَيْهِ، ^(٢٤) وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُصْحَفِ وَشِرَاءَهُ مَكْرُوهٌ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ الْبَيْعُ دُونَ الشِّرَاءِ.

(^{٢٥}) (وَالْمَبِيعُ شُرُوطٌ) خَمْسَةٌ:

أَحَدُهَا: (طَهَارَةُ عَيْنِهِ ^(٢٦)) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْحَمْرِ (وغيرهما مِنْ نَجَسِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» ^(٢٧))، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ» ^(٢٨)) رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ، وَالْمَعْنَى فِي الْمَذْكُورَاتِ نَجَاسَةُ عَيْنِهَا فَالْحَقُّ بِهَا بَاقِي نَجَسِ الْعَيْنِ.

(وَالْمُتَنَجِّسُ الَّذِي لَا يُمَكِّنُ تَطْهِيرَهُ)؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَجَسِ الْعَيْنِ (كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ وَكَذَا الدُّهْنُ) كَالزَّيْتِ وَالسَّمَنِ لَا يُمَكِّنُ تَطْهِيرَهُ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يُمَكِّنُ بَعْضُهُ بِأَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ فِي إِنَاءٍ مَاءٌ يَغْلِبُهُ وَيُحَرِّكُ بِخَشَبَةٍ حَتَّى يَصِلَ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ مَعَ رَدِّهِ بِمَا فِي حَدِيثِ الْفَارَةِ تَمُوتُ فِي السَّمَنِ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْفُوها وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ» وَفِي رَوَايَةٍ «فَأَرِيْقُوهُ» ^(٢٩))، فَلَوْ أُمَكِّنَ تَطْهِيرُهُ شَرْعًا لَمْ يَقُلْ فِيهِ ذَلِكَ.

وَعَلَى إِمْكَانِ تَطْهِيرِهِ قِيلَ: يَصِحُّ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى الثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِلْحَدِيثِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْمَاءِ النَّجَسِ؛ لِأَنَّ تَطْهِيرَهُ مُمَكِّنٌ بِالْمُكَاثَرَةِ، وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْحَرَمِ

^(٢٤) (حكم بيع المصحف من المسلم وشراؤه).

^(٢٥) (بعد ما انتهى من الكلام عن شروط العاقد شرع في ذكر شروط المبيع، التي يجب توافرها وهي خمسة يذكرها من الدليل والتمثيل للتوضيح).

(٢٦) (ويتفرع من اشتراط طهارة العين:

- حكم بيع ما كانت عينه نجسه كالكلب.

- الشيء الطاهر في أصله وتتجس نجاسة لا يمكن إزالتها، وفي بيعه خلاف.

- الشيء الطاهر في أصله ويمكن تطهيره، وهذا في بيعه خلاف.

^(٢٧) (أخرجه البخاري [كتاب البيوع - باب ثمن الكلب] رقم (٢٢٣٧)، ومسلم [كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب] رقم (١٥٦٧).

(٢٨) (أخرجه البخاري [كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام] رقم (٢٢٣٦)، ومسلم [كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام] رقم (١٥٨١).

(٢٩) (أخرجه مالك في الموطأ [كتاب اللقطة - باب: الفارة تقع في السم] رقم (٩٨٤)، والترمذي في السنن [كتاب الأطعمة - باب ما جاء في الفارة تموت في السم] رقم ١٧٩٨، وقال: هذا حديث حسن صحيح .

بِالْمَنْعِ (٣٠)، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِتَطْهِيرٍ بَلْ يَسْتَحِيلُ بِبُلُوغِهِ فُلْتَيْنِ مِنْ صِفَةِ النَّجَاسَةِ إِلَى الطَّهَارَةِ كَالْخَمْرِ تَتَخَلَّلُ.

(الثَّانِي) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ (النَّفْعُ) (٣١) فَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ بِمَالٍ، فَلَا يُقَابَلُ بِهِ، (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ) يَفْتَحُ الشَّيْنِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْفُزَّرَانِ وَالْخَنَافِسِ وَالنَّمْلِ وَنَحْوَهَا؛ إِذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ وَإِنْ ذُكِرَ لَهَا مَنَافِعُ فِي الْخَوَاصِّ (وَكُلِّ سَبْعٍ لَا يَنْفَعُ) كَالْأَسَدِ وَالذَّنَبِ وَالنَّمْرِ، وَمَا فِي افْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لَهَا مِنَ الْهَيْبَةِ وَالسِّيَاسَةِ لَيْسَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَالسَّبْعُ النَّافِعُ كَالضَّبْعِ لِلْأَكْلِ وَالْفَهْدِ لِلصَّيْدِ وَالْفِيلِ لِلْقِتَالِ (وَلَا) بَيْعُ (حَبَّتَيِ الْحِنْطَةِ وَنَحْوَهَا)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا وَإِنْ عُدَّ بِضْمِهِ إِلَى غَيْرِهِ. (وَالَّةُ اللَّهْوِ) كَالطُّنْبُورِ وَالْمِزْمَارِ إِذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا (وَقِيلَ: تَصِحُّ الْآلَةُ) أَيْ بَيْعُهَا (إِنْ عُدَّ رِضَاضُهَا) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ مُكْسَرُهَا (مَالًا) لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا مُتَوَقَّعًا كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ. وَرُدَّ بِأَنَّهَا عَلَى هَيْئَتِهَا لَا يُفْصَدُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَعْصِيَةِ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ) أَيْ جَانِبِ النَّهْرِ (وَالْتُّرَابِ وَالصَّخْرَاءِ) مِمَّنْ حَازَهُمَا (فِي الْأَصَحِّ) لظُهُورِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِمَا، وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ الثَّانِي مِنْ إِمْكَانِ تَحْصِيلِ مِثْلِهِمَا بِلَا تَعَبٍ وَلَا مُؤَنَةٍ.

(٣٢) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ (إِمْكَانُ تَسْلِيمِهِ) بَأَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ لِيُوثِقَ بِحُصُولِ الْعَوَضِ، (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ) (٣٣) وَالْأَبْقِ (٣٤) وَالْمَغْضُوبِ؛ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهَا فِي الْحَالِ (فَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ الْمَغْضُوبِ (لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ) دُونَهُ (صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ) نَظَرًا إِلَى وَصُولِ الْمُشْتَرِي إِلَى الْمَبِيعِ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى عَجْزِ الْبَائِعِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ بَيْعُهُ قَطْعًا، وَلَوْ بَاعَهُ مِنَ الْغَاصِبِ صَحَّ قَطْعًا.

وَلَوْ بَاعَ الْأَبْقَ مِمَّنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ رَدُّهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْمَغْضُوبِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الضَّالِّ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحَيَوَانِ إِنْسَانًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ. (٣٥) (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ) مَثَلًا (مُعَيَّنٍ مِنَ الْإِنَاءِ وَالسِّيفِ وَنَحْوِهِمَا) كَثُوبٍ نَفِيسٍ تَنْقُصُ بِقَطْعِهِ قِيَمَتُهُ؛ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ ذَلِكَ شَرْعًا؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِيهِ لَا يُمَكِّنُ إِلَّا بِالْكَسْرِ أَوْ الْقَطْعِ، وَفِيهِ نَقْصٌ وَتَضْيِيعٌ لِلْمَالِ. (وَيَصِحُّ فِي

(٣٠) أي يحرم شراء كافر داراً في الحرم؛ لمنعه منه كما قال ابن حجر (رحمه الله).

(٣١) المراد هنا المنفعة المعتبرة شرعاً، ولا عبرة بغير ذلك.

(٣٢) الشرط الثالث من شروط المبيع.

(٣٣) الضال: الضائع سواء أكان حيواناً أو مالا، ويشمل جميع صور الضياع والفقد للمال حتى ولو كان بالنسيان لموضعه.

(٣٤) العبد الهارب من سيده.

الثَّوبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ) كَغَلِيظِ الْكِرْيَاسِ^(٣٦) (فِي الْأَصْح)، وَالثَّانِي قَالَ: قَطَعُهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَغْيِيرِ لَعِينِ الْمَبِيعِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي النَّفِيسِ لِرِضَا الْبَائِعِ بِالضَّرَرِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقِيَاسُ طَرْدُهُ فِي السَّيْفِ وَالْإِنَاءِ^(٣٧)، وَمِمَّا يَصْدُقُ بِهِ النِّصْفُ أَوْ مَحْوُهُ مِنَ الثَّوبِ أَنْ يَكُونَ ذِرَاعًا، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ حَيْثُ قُلْنَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ عَلَى شِرَائِهِ، ثُمَّ يَقْطَعَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ فَيَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ. أَمَّا بَيْعُ الْجُزْءِ الشَّاعِ مِنَ الْإِنَاءِ وَنَحْوِهِ فَيَصِحُّ، وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا وَبَيْعُ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَرْضِ يَصِحُّ أَيْضًا لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ فِيهَا بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ بِالْعَلَامَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَكَ أَنْ تَقُولَ قَدْ تَتَضَيَّقُ مَرَافِقُ الْبُقْعَةِ بِالْعَلَامَةِ وَتَنْقُصُ الْقِيَمَةُ، فَلْيَكُنْ الْحُكْمُ فِي الْأَرْضِ عَلَى التَّقْصِيلِ فِي الثَّوبِ، وَسَيَأْتِي بَيْعُ ذِرَاعٍ مُبْهِمٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ^(٣٨).

(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مُزْتَهِنَةٍ) لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا^(٣٩) (وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِهِ كَمَا فِي الْمَرْهُونِ وَالثَّانِي يَصِحُّ فِي الْمَوْسِرِ، قِيلَ: وَالْمَوْسِرُ وَالْفَرْقُ أَنْ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَبَتْ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ حَقِّ الْمُزْتَهِنِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ السَّيِّدُ الْمَوْسِرُ بِبَيْعِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْجَنَائَةِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَقِيلَ: لَا بَلْ هُوَ عَلَى خَيْرَتِهِ إِنْ فَدَى أَمْضَى الْبَيْعِ وَإِلَّا فَسَخَ، وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ صَحَّ جَزْمًا، وَالْفِدَاءُ بِأَقَلِّ الْأَمْزِينَ مِنْ قِيَمَتِهِ وَأَرَشِ الْجَنَائَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ، وَصَوْرُ تَعَلُّقِ الْمَالِ بِرَقَبَتِهِ أَنْ يَكُونَ جَنَى خَطَأً أَوْ شَبَهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعَفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا. (وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ) بِأَنْ اشْتَرَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَلَا تَعَلُّقُ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِهَا. (وَكَذَا تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ) بِرَقَبَتِهِ لَا يَضُرُّ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ تَرَجَّى سَلَامَتُهُ بِالْعَفْوِ، وَالثَّانِي يَضُرُّ لِأَنَّ مُسْتَحَقَّ الْقِصَاصِ قَدْ يَعْفُو عَلَى مَالٍ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَتَعَلُّقُهُ بِهَا ضَارٌّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ بِغُضْوِهِ جَزْمًا كَمَا ذَكَرَ فِي بَابِ الْخِيَارِ، فَيَتَبَيَّنُ بِهِ الرَّدُّ كَمَا سَيَأْتِي فِيهِ.

(٣٦) (الصواب بالباء، فيقال: الكرياس وهو الثوب).

(٣٧) (القياس طرده: يعني جواز بيع نصف السيف والإناء إذا كان ذلك لا ينقص قيمته على الأصح).

(٣٨) (خلاصة ما تقدم من بيع جزء من السيف أو الإناء أو الثوب أن المنع إذا كان البيع يترتب عليه الكسر أو القطع؛ لنقصان قيمته، ونقصان القيمة هدر للمال، فيمنع منه شرعاً، وأما إذا باع الجزء بالمشاع فصار شريكاً فيصح، أو أن البائع فصل الجزء قبل البيع ثم باعه لحاله فيصح، ويسري الحكم على الأرض إن كان في بيع جزء معين منها ما يؤثر على قيمتها أولاً يؤثر كما في الثياب والسيف).

(٣٩) (للهي عن ذلك في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه».

(الرَّابِعُ) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ (الْمَلِكُ) فِيهِ (لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ) الْوَاقِعُ، وَهُوَ الْعَاقِدُ أَوْ مُوَكَّلُهُ أَوْ مُوَلَّيْهِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ. (فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ. (وَفِي الْقَدِيمِ) هُوَ (مَوْفُوفٌ إِنْ أَجَازَ مَالِكُهُ) أَوْ وَلِيُّهُ (نَقَذَ) بِالْمُعْجَمَةِ (وَالَّا فَلَا) يَنْقُذُ^(٤٠) (وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ) فِيمَا لَوْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِلَا إِذْنٍ بَعِيْنٍ مَالِهِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ^(٤١)، وَفِيمَا لَوْ رَوَّجَ أَمَةً غَيْرَهُ أَوْ بَنْتَهُ، أَوْ طَلَّقَ مَنكُوحَتَهُ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، أَوْ آجَرَ دَابَّتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. (وَلَوْ بَاعَ مَالُ مُورَثِهِ ظَانًّا حِيلَتَهُ وَكَانَ مَيِّتًا) بِسُكُونِ الْيَاءِ (صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ) تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكُهُ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَنْ رَوَّجَ أَمَةً مُورَثَهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَيٌّ فَبَانَ مَيِّتًا هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ.

(الخَامِسُ) مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ (الْعِلْمُ بِهِ) عَيْنًا وَقَدْرًا وَصِفَةً^(٤٢) عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ حَدَرًا مِنَ الْغَرَرِ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»^(٤٣) (فَبَيْعُ أَحَدِ التَّوْبِنِ) أَوْ الْبُعْدَيْنِ مَثَلًا (بَاطِلٌ) وَإِنْ تَسَاوَتْ قِيَمَتُهُمَا لِلْجَهْلِ بَعِيْنٍ الْمَبِيعِ (وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ تُعْلَمُ صِيعَانُهَا) لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ، فَإِذَا عَلِمَا أَنَّهَا عَشْرَةُ آصِعٍ فَالْمَبِيعُ عَشْرُهَا، فَلَوْ تَلَفَ بَعْضُهَا تَلَفَ بِقَدْرِهِ مِنَ الْمَبِيعِ، وَقِيلَ الْمَبِيعُ صَاعٌ مِنْهَا، أَيْ صَاعٌ كَانَ، فَيَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ. (وَكَذَا إِنْ جُهِلَتْ) صِيعَانُهَا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ يَصِحُّ الْبَيْعُ (فِي الْأَصَحِّ) الْمَنْصُوصُ وَالْمَبِيعُ صَاعٌ مِنْهَا، أَيْ صَاعٌ كَانَ وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْتَبًا لِأَنَّ رُؤْيَا ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ كَرُؤْيَا كُلِّهَا.

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ فَرَّقَ صِيعَانُهَا، وَقَالَ بَعْتُكَ صَاعًا مِنْهَا، وَلَوْ بَاعَهُ ذُرَاعًا مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذُرْعَانَ ذَلِكَ كَعَشْرَةِ صَحٍّ وَكَأَنَّهُ بَاعَهُ الْعَشْرَ. وَإِنْ جَهِلَ أَحَدُهُمَا الذُّرْعَانَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ فِي الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا لَا تَتَقَاوُثُ بِخِلَافِ أَجْزَاءِ مَا ذَكَرَ.

(وَلَوْ بَاعَ بِمِلءٍ ذَا الْبَيْتِ حِنْطَةً أَوْ بَزْنَةً هَذِهِ الْحَصَاةَ ذَهَبًا أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ) أَيْ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَأَحَدُهُمَا لَا يَعْلَمُهُ (أَوْ بِأَلْفِ دِرَاهِمٍ وَدَنَانِيرٍ لَمْ يَصِحَّ) الْبَيْعُ؛ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مِلءٌ مَنْصُوبًا وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا. (وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ) دِرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ فُلُوسٍ (وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ) مِنْ ذَلِكَ وَنَقْدٌ غَيْرُ غَالِبٍ مِنْهُ (تَعَيَّنَ) الْغَالِبُ لِيُظْهِرَ أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَرَادَاهُ. (أَوْ نَقْدَانِ) مِنْ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ (لَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا)

(٤٠) محل الخلاف فغي القولين إذا كان المالك غائباً، فإن كان حاضراً وسكت لم يصح من غير خلاف.

(٤١) مراده ما لو اشترى الفضولي بماله هو أو جعل الثمن في ذمته لغيره بغير إذن.

(٤٢) أي بالمعقود عليه معاً (السلعة والثمن)، وكل ما ذكره بعد ذلك في هذا الشرط أمثلة.

(٤٣) أخرجه مسلم [كتاب البيوع - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر] رقم (١٥١٣).

أَشْرَطَ التَّعْيِينَ) لِأَحَدِهِمَا فِي الْعَقْدِ لِيُعْلَمَ، وَهَذَا كَمَا قَالَ فِي الْبَيَانِ إِذَا تَقَاوَتَتْ قِيَمَتُهُمَا، فَإِنْ اسْتَوَتْ صَحَّ الْبَيْعُ بِدُونِ التَّعْيِينِ وَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي مَا شَاءَ مِنْهُمَا (وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ الصِّيْعَانِ) لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ (كُلُّ صَاعٍ بِدَرَاهِمٍ) بِنَضَبٍ كُلِّ كَأَنَّ يَقُولُ: بَعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدَرَاهِمٍ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ، وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْتَفْصِيلِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: بَعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ الدَّارَ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدَرَاهِمٍ، أَوْ هَذِهِ الْأَغْنَامَ كُلَّ شَاةٍ بِدَرَاهِمٍ وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ^(٤٤)، وَلَوْ عَلِمَا عَدَدَ الصِّيْعَانِ وَالذُّرْعَانِ وَالْأَغْنَامِ صَحَّ الْبَيْعُ جَزْمًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَكَرَ مِنْهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَسْأَلَةُ الدَّارِ. (وَلَوْ بَاعَهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعٍ بِدَرَاهِمٍ صَحَّ إِنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ وَإِلَّا) أَيَّ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِائَةٌ بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلُّ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرُ (فَلَا) يَصِحُّ الْبَيْعُ (عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِتَعَدُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي النَّاقِصَةِ، فَإِنْ أَجَازَ فَجَمِيعِ الثَّمَنِ لِمُقَابَلَةِ الصُّبْرَةِ بِهِ أَوْ بِالْفِسْطِ لِمُقَابَلَةِ كُلِّ صَاعٍ بِدَرَاهِمٍ وَجِهَانِ، وَالزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي، وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ، وَقِيلَ: هِيَ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ قَالَ بَعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدَرَاهِمٍ، وَقَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ تَبَعَ فِي الْمَحَرَّرِ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ وَجْهَيْنِ، وَحَكَاهُ فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا قَوْلَيْنِ^(٤٥).

(وَمَتَى كَانَ الْعَوَضُ مُعَيَّنًا) أَيَّ مُشَاهِدًا (كَفَتْ مُعَايِنَتُهُ) مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِقَدْرِهِ^(٤٦)، وَكَذَا الْمَعْوَضُ، فَلَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِهِذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَلَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهَا صَحَّ الْبَيْعُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَقَّعُ فِي النَّدَمِ، وَفِي التَّيَمُّنَةِ أَنَّ شِرَاءَ مَجْهُولِ الذَّرْعِ لَا يُكْرَهُ.

^(٤٧) (وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا. (وَالثَّانِي: يَصِحُّ) اعْتِمَادًا عَلَى الْوَصْفِ بِذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ كَأَنَّ يَقُولُ: بَعْتُكَ عَبْدِي التُّرْكِيَّ وَفَرَسِي الْعَرَبِيَّ، وَلَا يَفْتَقِرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى ذِكْرِ صِفَاتٍ أُخَرَ^(٤٨) نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ مِنْ نَوْعٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ يَقَعُ بِهَا التَّمْيِيزُ كَالْتَعَرُّضِ لِلسِّنِّ أَوْ غَيْرِهِ.

(٤٤) لأنه لا يعلم جملة وقدر الثمن وقت العقد.

(٤٥) وخلاصة ما تقدم من هذه الأمثلة جميعها أنه إذا علم العاقدان بالمعقود عليه علماً ينتفي معه الجهالة صح البيع؛ لعدم الغرر، ومع عدم التحقق منه يوجد الغرر فلا يصح؛ لاختلال شرط العلم في البيع.

(٤٦) يعني أن المشاهدة وحدها كافية في العلم بالمعقود عليه (سلعة كانت أو ثمناً)، فالمشاهدة أقوى الحواس في العلم بالمعقود عليه، ومن ثم تكلم بعد ذلك عن بيع الغائب.

(٤٧) حكم بيع الغائب.

(٤٨) يفهم منه أنه إذا لم يذكر شيئاً من الصفات فلا يصح البيع بلا خلاف؛ لأنه مجهول.

(وَيُثَبِّتُ الْخِيَارَ) لِلْمُشْتَرِي (عِنْدَ الرُّؤْيَةِ) وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ^(٤٩)؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْمُعَايَنَةِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ «مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ»^(٥٠) لَكِنْ قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ إِنَّهُ ضَعِيفٌ، وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفُسْخُ دُونَ الْإِجَازَةِ^(٥١)، وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ، وَقِيلَ: لَهُ الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَأَى الْمَبِيعَ.

(٥٢) وَحَيْثُ ثَبَّتَ فَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْقَوْرِ، وَالْأَصَحُّ: يَمْتَدُّ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ، وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي رَهْنِ الْغَائِبِ وَهَبْتِهِ، وَعَلَى صِحَّتِهِمَا لَا خِيَارَ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ.

(٥٣) (و) عَلَى الْأَظْهَرِ فِي اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ (تَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ) كَالْأَرَاضِيِّ وَالْأَوَانِيِّ وَالْحَدِيدِ وَالنَّحَاسِ (دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا) كَالْأَطْعِمَةِ الَّتِي يُسْرِعُ فَسَادُهَا نَظَرًا لِلْغَالِبِ فِيهِمَا^(٥٤)، وَفِيمَا يُحْتَمَلُ مِنْهَا التَّغْيِيرُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً كَالْحَيَوَانِ وَجَهَانِ:

أَصَحُّهُمَا: صِحَّةُ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَرْثِيِّ فِيهَا بِحَالِهِ^(٥٥)، فَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ،^(٥٦) فَإِنْ نَارَعَهُ الْبَائِعُ فِي تَغْيِيرِهِ فَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغْيِيرِ، وَالْأَصَحُّ: قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِبَيْعِهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَهُوَ يُنْكِرُهَا^(٥٧)، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنِ الْمَآوَرِدِيِّ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْإِكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ أَنْ يَكُونَ حَالَ الْبَيْعِ مُتَذَكِّرًا

(٤٩) ثبوت الخيار مبني على القول الثاني مقابل الأظهر، ويثبت إن وجده بالصفات التي ذكرها، فإن كان على غير الصفة فلا بيع ولا خيار.

(٥٠) أخرجه الدارقطني في السنن [كتاب البيوع] رقم (٢٨٠٥)، والبيهقي في الكبرى [كتاب البيوع - باب من قال يجوز بيع العين الغائبة] رقم (١٠٤٢٥)، وقال: هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.

(٥١) أي يحق للمشتري فسخ البيع قبل رؤية المبيع، وأما بعد الرؤية فيحق له الفسخ أو الإمضاء.

(٥٢) وقت خيار الرؤية، وهو مبني على مقابل الأظهر في صحة بيع الغائب المعتمد على الوصف.

(٥٣) سوف يبني على الأظهر في اشتراط رؤية المبيع احتمالات، منها ما بدأ به وهو الوقت المعبر في الرؤية، ومنها بيان أنه يختلف باختلاف المبيع، ومنها رؤية بعض المبيع هل تدل على باقيه أم؟ وهذا أيضاً يختلف باختلاف المبيع، ومنها أن رؤية كل مبيع بحسب حاله، والعادة محكمة في ذلك، ومنها ما لو وصف الشيء المراد بيعه بصفة السلم هل تكفي عن الرؤية؟.

(٥٤) كالتفاح والطماطم والخضروات بصفة عامة.

(٥٥) هذا مبني على قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان".

(٥٦) الصورة هنا أن يدعي المشتري تغير المبيع عن وقت ما رآه قبل العقد، ويدعي البائع عدم التغير، ولا توجد بينة.

(٥٧) هذا الوجه نظر إلى أن البائع هو المدعى للعلم، والمشتري ينكر العلم بصفات المبيع، والقول قول المنكر؛ لأن الأصل العدم.

الأوصاف^(٥٨)، فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب^(٥٩)، قال: وهذا غريب لم يتعرض له الجمهور.

(وتكفي رؤيته بغض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من الحنطة والشعير والجوز واللوز وغيرها مما الغالب أن لا تختلف أجزاؤه، ولا خيار له إذا رأى الباطن إلا إذا خالف الظاهر بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل؛ لأنها تختلف اختلافاً بيناً، وتباع عدداً، فلا بد فيها من رؤية واحد واحد (و) مثل (أنموذج المتماثل) أي المتساوي الأجزاء كالحبوب، فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع، فلا بد من إدخاله في البيع، وهو بضم الهمزة والميم وفتح الدال المعجمة (أو كان صواناً^(٦٠)) بكسر الصاد (للباقى خلة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز) أي تكفي رؤيته القشر المذكور؛ لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل هو عليه، فقوله أو كان إلى آخره قسيم^(٦١) قوله: إن دل إلى آخره، وقوله كالمحزر خلة مزيد على الروضة وأصلها وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها، وقد اختار به عن جلد الكتاب ونحوه^(٦٢) واختاروا بوصف القشرة بالسفلى لما ذكر وهي التي تكسر حالة الأكل عن العليا فلا تكفي رؤيتها، فلا يصح بيعه فيها كما سيأتي في باب بيع الأصول والثمار لاستتاره بما ليس من مصلحته، والخشكان^(٦٣) تكفي رؤيته ظاهره كما ذكره في شرح المهدب مع أمثلة الصوان المذكورة والفقاع، قال العبادي: يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان، وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به قال في الروضة وغيرها: الأصح قول الغزالي لأن بقاءه في الكوز من مصلحته.

(وتعتبر رؤية كل شيء) غير ما ذكر (على ما يليق به)^(٦٤) فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسفوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وفي البستان رؤية الأشجار والجدران ومسائل الماء، وفي العبد رؤية الوجه والأطراف، وكذا باقي البدن غير العورة في الأصح، والأمة كالعبد،

(٥٨) هذا تحرير لمحل النزاع في المسألة.

(٥٩) يعني أن البيع لا يصح.

(٦٠) الصوان: بضم الصاد وكسرهما والصيان بالياء مع الكسر لغة، وهو ما يسان فيه الشيء وصننته حفظته في صوانه. ينظر: المصباح المنير ص ٣٥٢.

(٦١) قسيم الشيء: هو ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر، كالاسم؛ فإنه مقابل للفعل ومندرجان تحت شيء آخر، وهي الكلمة التي هي أعم منهما.

(٦٢) فإن رؤيته لا تكفي للدلالة على ورقه وخطة الكتابة وغيره.

(٦٣) الخشكان: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق وتقلي. ينظر: المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٣٦.

(٦٤) هذا يصلح أن يكون ضابطاً لرؤية للمبيع.

وَقِيلَ: يَكْفِي فِيهَا رُؤْيَا مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْخِدْمَةِ، وَفِي الدَّابَّةِ رُؤْيَا مُقَدَّمَهَا وَمُؤَخَّرَهَا وَقَوَائِمَهَا وَظَهْرَهَا، وَفِي الثَّوْبِ الدِّيْبَاجِ الْمُنْقَشِ رُؤْيَا وَجْهِهِ، وَكَذَا السَّبَاطُ، وَفِي الْكَرْبَاسِ رُؤْيَا أَحَدِ وَجْهَيْهِ، وَقِيلَ رُؤْيَاهُمَا، وَفِي الْكُتُبِ وَالْوَرَقِ الْبَيَاضِ وَالْمُصْحَفِ رُؤْيَا جَمِيعِ الْأَوْرَاقِ.

(٦٥) (وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَصْفَهُ) أَيِ الشَّيْءِ الَّذِي يُرَادُ بَبَيْعِهِ (بِصِفَةِ السَّلَامِ لَا يَكْفِي) عَنْ رُؤْيَيْهِ (٦٦)، وَالثَّانِي يَكْفِي، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الرُّؤْيَا لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْمَعْرِفَةَ كَالرُّؤْيَا وَدُفِعَ بِأَنَّ الرُّؤْيَا تُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُ الْعِبَارَةُ. (٦٧) (وَيَصِحُّ سَلَمُ الْأَعْمَى) أَيِ أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِ بِعَوَضٍ فِي الذِّمَّةِ يُعَيِّنُ فِي الْمَجْلِسِ، وَيُوكِّلُ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ أَوْ يَقْبِضُ لَهُ رَأْسَ مَالِ السَّلَامِ أَوْ الْمُسَلِّمِ فِيهِ، لِأَنَّ السَّلَامَ يَعْتَمِدُ الْوَصْفَ لَا الرُّؤْيَا. (وَقِيلَ: إِنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ) بَيْنَ الْأَشْيَاءِ أَوْ خُلِقَ أَعْمَى (فَلَا) يَصِحُّ سَلَمُهُ لِانْتِقَاءِ مَعْرِفَتِهِ بِالْأَشْيَاءِ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ يَعْرِفُهَا بِالسَّمَاعِ وَيَتَخَيَّلُ فَرْقًا بَيْنَهَا. أَمَّا غَيْرُ السَّلَامِ مِمَّا يَعْتَمِدُ الرُّؤْيَا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ، وَإِنْ قُلْنَا يَصِحُّ بَبَيْعِ الْغَائِبِ وَسَبِيلُهُ أَنْ يُوكِّلَ فِيهَا، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ وَيُؤْجِرَهَا لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُهَا، وَلَوْ كَانَ رَأَى قَبْلَ الْعَمَى شَيْئًا مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ صَحُّ بَبَيْعِهِ وَشِرَاؤُهُ إِيَّاهُ كَالْبَصِيرِ وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ.

بَابُ الرِّبَا

بَابُ الرِّبَا بِالْقَصْرِ، وَالْقَصْدُ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ (٦٨)، وَالْقَصْدُ بِهِذَا النَّبَابِ بَبَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ، وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (٦٩) (وَإِذَا بَاعَ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِنْ كَانَ) أَيِ الطَّعَامِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ (جِنْسًا) (٧٠) وَاحِدًا كَحِنْطَةٍ وَحِنْطَةٍ (أُشْتَرِطَ) فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ (الْحُلُولُ وَالْمُمَاتَلَةُ وَالْتَقَابُضُ قَبْلَ النَّفْقِ أَوْ

(٦٥) لما انتهى من الكلام عن الرؤية للمبيع؛ لتحقيق العلم به ورد في الذهن ما لو وصف المبيع وصفاً كما في السلم هل يجوز به البيع أم لا؟

(٦٦) لأن الرؤية تفيد أموراً تقصر عنها العبارة، فليس الخبر كالمعاينة.

(٦٧) حكم سلم الأعشى وشراؤه للغائب ونكاحه.

(٦٨) الربا لغة: الزيادة، وشرعاً: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، وهو من أكبر الكبائر، ولم يحل في شريعة قط.

(٦٩) مراده ما تقدم من شروط المبيع الخمسة.

(٧٠) الجنس: هو أعم من النوع يقال الحيوان جنس والإنسان نوع لأنه أخص من قولنا حيوان وإن كان جنساً بالنسبة إلى ما تحته. المغرب ج ١ ص ٩٣، وعليه فلا ينظر إلى النوع في المماثلة، ولا الجودة من عدمها ولا إلى الثمن بل يقال الكل جنس، فالتمر جنس، وأنواعه كثيرة متعددة، وكل ما يجري فيه الربا كذلك.

جَنْسَيْنِ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ جَارَ النَّقَاضِ، وَاشْتَرَطَ الْحُلُولَ وَالنَّقَابُضَ) قَبْلَ التَّفْرِقِ^(٧١) قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»^(٧٢) أَيْ مُقَابَضَةً، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الْحُلُولُ، فَإِذَا بَاعَ الطَّعَامُ بغيرِهِ كَنَقْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِ الطَّعَامِ بِغَيْرِ الطَّعَامِ، وَلَيْسَ نَقْدَيْنِ كَحَيَوَانٍ بِحَيَوَانٍ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَالنَّقْدَانِ كَالطَّعَامَيْنِ^(٧٣) كَمَا سَيَأْتِي.

^(٧٤) (وَالطَّعَامُ مَا قُصِدَ لِلطَّعْمِ) بِضَمِّ الطَّاءِ مَصْدَرُ طَعِمَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ أَكَلَ (اِفْتِيَاتًا أَوْ تَقْكُهَا أَوْ تَدَاوِيًا) وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ مَأْخُودَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، فَإِنْ نَصَّ فِيهِ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا النَّقُوتُ فَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا يُشَارِكُهُمَا فِي ذَلِكَ كَالْأُرْزِ وَالذُّرَّةِ، وَعَلَى النَّمْرِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّادُّمُ وَالنَّقْكُ فَأُلْحِقَ بِهِ مَا يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ كَالرَّيْبِ وَالتَّيْنِ، وَعَلَى الْمِلْحِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِصْلَاحُ فَأُلْحِقَ بِهِ مَا يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ كَالْمُضْطَكِّي وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ قُصِدَ مَا لَا يُقْصَدُ تَنَاوُلُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ كَالْجُلُودِ فَلَا رِبَا فِيهِ بِخِلَافِ مَا يُؤْكَلُ نَادِرًا كَالْبُلْبُلِ، وَقَوْلُهُ لِلطَّعْمِ إِلَى آخِرِهِ ظَاهِرٌ فِي إِرَادَةِ مَطْعُومِ الْأَدَمِيِّينَ وَإِنْ شَارَكَهُمْ فِيهِ الْبَهَائِمُ قَلِيلًا أَوْ عَلَى السَّوَاءِ، فَخَرَجَ مَا اخْتَصَّ بِهِ الْحِجُّ كَالْعَظْمِ أَوْ الْبَهَائِمِ كَالْحَشِيشِ وَالتَّيْنِ^(٧٥) أَوْ غَلَبَ تَنَاوُلُ الْبَهَائِمِ لَهُ فَلَا رِبَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، قَوْلُهُ: تَقْكُهَا يَشْمَلُ التَّادُّمَ وَالتَّحْلِيَّ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا فِي الْأَيْمَانِ فَقَالَ: وَالطَّعَامُ يَتَنَاوَلُ قُوَّتًا وَفَاكِهَةً وَأُدْمًا وَحَلْوًى، وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّوَاءَ لِأَنَّ الطَّعَامَ لَا يَتَنَاوَلُهُ عُرْفًا، وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ^(٧٦). تَدَاوِيًا يَشْمَلُ

(٧١) تنبيه: اختلال جميع الشروط يؤدي إلى وجود (ربا الفضل وربا النسيئة) معاً، واختلال (المماثلة) يؤدي إلى وجود ربا الفضل وحده، واختلال (الحلول أو تأخير القبض عن المجلس) يؤدي إلى ربا النسيئة وحده.

(٧٢) أخرجه مسلم [كتاب المساقاة - باب الربا] رقم (١٥٨٤).

(٧٣) قوله "إذا باع الطعام بغيره لم يشترط شيء من الثلاثة والنقدان كالطعامين": يعني أن ما عدا الطعام والنقدين لا يجري فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره مع الزيادة في أحدهما على الآخر، ويجوز التأخير في القبض، ويجوز التأجيل يعني لا يشترط الحلول.

(٧٤) شرع (رحمه الله) في بيان علة الربا في الطعام، وهي "الطعم"، وكذلك بيان ما يسمى طعاماً ربوياً بالنص في الحديث أو القياس عليه؛ لاشتراكه في العلة.

(٧٥) [ولتين] هكذا وجدتها، والصواب (ولتين)، فهو طعام البهائم، والتصحيح مذکور في مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٦٥.

(٧٦) كلامه يصلح أن يكون جواباً عن اعتراض مفاده: أنه في كتاب الأيمان لو حلف على الطعام لم يدخل فيه الدواء، فلم يدخل الدواء في الطعام هنا في الربا ولم يدخل في الأيمان؟

التَّدَاوِي بِالْمَاءِ الْعَذْبِ^(٧٧)، وَهُوَ رَبَوِيٌّ مَطْعُومٌ، قَالَ تَعَالَى: [وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي] [البقرة: ٢٤٩].

(٧٨) (وَأَدِقَّةُ الْأُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وَخُلُولُهَا وَأَذْهَانُهَا أَجْنَأَسُ) كَأُصُولِهَا فَيَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الشَّعِيرِ مُتَقَاضِلًا، وَخَلِّ التَّمْرِ بِخَلِّ الْعِنَبِ كَذَلِكَ، وَدُهْنُ الْبَنْفَسَجِ بِدُهْنِ الْوَرْدِ كَذَلِكَ، وَاخْتَرَزَ بِالْمُخْتَلَفَةِ عَنِ الْمُتَّحِدَةِ كَأَدِقَّةِ أَنْوَاعِ الْحِنْطَةِ فَهِيَ جِنْسٌ. (وَاللُّحُومُ وَاللَّبَنُ) أَيُّ كُلِّ مِنْهُمَا (كَذَلِكَ) أَيُّ أَجْنَأَسٍ (فِي الْأَظْهَرِ) كَأُصُولِهَا، فَيَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ الْبَقَرِ بِلَحْمِ الضَّأْنِ مُتَقَاضِلًا، وَلَبَنِ الْبَقَرِ بِلَبَنِ الضَّأْنِ مُتَقَاضِلًا، وَالثَّانِي: هِيَ جِنْسٌ^(٧٩) فَلَا يَجُوزُ التَّقَاضُلُ فِيمَا ذَكَرَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لُحُومُ الْبَقَرِ وَالْجَوَامِيسِ جِنْسٌ، وَلُحُومُ الضَّأْنِ وَالْمَعَزِ جِنْسٌ، وَاللَّبَنُ الْبَقَرِ وَالْجَوَامِيسِ جِنْسٌ، وَاللَّبَنُ الضَّأْنِ وَالْمَعَزِ جِنْسٌ. (٨٠) (وَالْمُمَائِلَةُ تُعْتَبَرُ فِي الْمَكِيلِ كَيْلًا وَالْمُوزُونِ وَزْنًا) فَالْمَكِيلُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضِ وَزْنًا، وَلَا يَضُرُّ مَعَ الْإِسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ التَّفَاوُتُ وَزْنًا، وَالْمُوزُونُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضِ كَيْلًا، وَلَا يَضُرُّ مَعَ الْإِسْتِوَاءِ فِي الْوُزْنِ التَّفَاوُتُ كَيْلًا (وَالْمُعْتَبَرُ) فِي كَوْنِ الشَّيْءِ مَكِيلًا أَوْ مُوزُونًا. (غَالِبٌ عَادَةً أَهْلُ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) لِيُظْهِرَ أَنَّهُ أَطْلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ، فَلَوْ أَخَذَتِ النَّاسُ خِلَافَ ذَلِكَ فَلَا اعْتِبَارَ بِإِحْدَاثِهِمْ.

(٨١) (وَمَا جُهِلَ) أَيُّ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ كَانَ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يُوزَنُ فِي عَهْدِهِ مَرَّةً وَيُكَالُ أُخْرَى وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ عَادَةٌ بِلَدِّ الْبَيْعِ. وَقِيلَ: الْكَيْلُ، لِأَنَّ أَكْثَرَ الْمَطْعُومَاتِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكِيلٌ. (وَقِيلَ: الْوُزْنُ) لِأَنَّهُ أَحْصَرَ وَأَقْلَّ تَفَاوُتًا. (وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ) بَيْنَ الْكَيْلِ وَالْوُزْنِ لِيَتَعَادَلَ وَجْهِيهِمَا. (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لَهُ أَضْلٌ أُعْتَبِرَ) أَضْلُهُ فِي الْكَيْلِ وَالْوُزْنِ فِيهِ، فَعَلَى هَذَا دُهْنُ السِّمْسِمِ مَكِيلٌ، وَدُهْنُ اللَّوزِ مُوزُونٌ، وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَ جُزْمًا مِنَ التَّمْرِ، فَإِنْ كَانَ

(٧٧) تقييده للماء بالعذب أفاد أن الماء المالح لا يجري فيه الربا؛ لأنه ليس بطعام.

(٧٨) شرع في بيان ما يستخلص من الطعام الربوي من دقيق أو خلٍ أو دهن ونحو ذلك، فهل ترجع إلى أصولها، فيكون حكم دقيق الحنطة كالحنطة يعني من جنسها أم أن الدقيق ونحوه أصبح جنساً مستقلاً عن أصولها؟ والمسألة فيها خلاف في المذهب على قولين.

(٧٩) أي أن اللحم جنس وكونه من البقر نوع أو الغنم نوع ، والدقيق جنس والخل جنس وكونه من الشعير نوع أو من الحنطة نوع، ومن ثم فلا بد من التماثل ويحرم التفاضل.

(٨٠) في صحة بيع الربوي بربوي من جنسه لابد من العلم بالتماثل في العوضين، وهو معتبر في المكيل بالكيل والموزون بالوزن

(٨١) عدم العلم بكيفية ضبط المبيع الربوي كَيْلاً أَوْ وَزناً لم يكن مبرراً في جواز التفاضل بل لابد من تحقق التماثل في العوضين، وفي كيفية التحقق خلاف على وجوه.

كَالْبَيْضِ فَلَا عِتْبَارُ فِيهِ بِالْوِزْنِ جَزْماً^(٨٢)، وَسَوَاءُ الْمَكْيَالِ الْمُعْتَادُ فِي عَصْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَكْيَالِ الْمُحْدَثَةُ بَعْدَهُ، وَيَجُوزُ الْكَيْلُ بِقِصْعَةٍ مَثَلًا فِي الْأَصَحِّ، وَالْوِزْنُ بِالْقَبَّانِ. (وَالنَّقْدُ) أَيِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ^(٨٣) (بِالنَّقْدِ كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ) فَإِنْ بَاعَ بِجِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَشْطَرَطَ الْمُمَائِلَةَ وَالْحُلُولُ وَالنَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ جَازَ النَّقَاضُ، وَأَشْطَرَطَ الْحُلُولُ وَالنَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَلَا رَبَا فِي الْفُلُوسِ^(٨٤) الرَّائِجَةِ فِي الْأَصَحِّ، فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَقَاضِلًا وَإِلَى أَجَلٍ^(٨٥). (وَلَوْ بَاعَ) طَعَامًا أَوْ نَقْدًا بِجِنْسِهِ (جِزَافًا) بِكُسْرِ الْجِيمِ (تَخْمِينًا) أَيِ حِزْرًا لِلتَّسَاوِي (لَمْ يَصِحَّ) الْبَيْعُ (وَإِنْ حَرَجَا سَوَاءً) لِلْجَهْلِ بِالْمُمَائِلَةِ حَالَ الْبَيْعِ^(٨٦)، وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ جِزَافًا يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا، وَلَوْ بَاعَهُ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِتِلْكَ مُكَائِلَةً أَوْ كَيْلًا بِكَيْلٍ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِتِلْكَ مُوَازَنَةً فَإِنْ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا وَخَرَجْنَا سَوَاءً صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأُظْهَرِ^(٨٧)، وَعَلَى الثَّانِي: يَصِحُّ فِي الْكَبِيرَةِ بِقَدَرٍ مَا يُقَابَلُ الصَّغِيرَةِ، وَلِمُشْتَرِي الْكَبِيرَةِ الْخِيَارُ.. (وَتُعْتَبَرُ الْمُمَائِلَةُ) فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ. (وَقَتَّ الْجَفَافِ)^(٨٨) أَيِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْكَمَالُ (وَقَدْ يُعْتَبَرُ الْكَمَالُ) بِالْجَفَافِ (أَوَّلًا) وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَرَايَا^(٨٩) الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ. (فَلَا يُبَاعُ رُطْبٌ) بِضَمِّ الرَّاءِ (بِرُطْبٍ وَلَا بِتَمْرٍ وَلَا عِنَبٍ بِعِنَبٍ وَلَا بِزَيْبٍ) لِلْجَهْلِ الْآنَ بِالْمُمَائِلَةِ وَقَتَّ الْجَفَافِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «أَنَّهُ» - صَلَّى اللَّهُ

(٨٢) هذا تحرير محل الخلاف عند عدم العلم في المبيع ببيع كيلاً أو وزناً.

(٨٣) أي يراعى فيها أن الذهب جنس والفضة جنس، وكل منهما له أنواع، وصحيح ومكسور وسبيكة ومضروب، وقديم وجديد، فكلها أنواع تدخل تحت جنس الذهب أو تحت جنس الفضة.

(٨٤) الفلوس: عملة مضروبة من غير الذهب والفضة كانت تقدر في الماضي بسدس الدرهم ، وهي اليوم ١/١٠٠٠ من الدينار في الدول التي تعتمد الدينار وحدتها النقدية كالعراق والأردن، وتعادل القرش السوري، والهلاله السعوديه، فهي أصغر وحدات النقد ، ويعادل ثلاثة مليمات مصريه. ينظر: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي. مجلة البحوث الإسلامية العدد (٣٩) ج-١ ص ٢٩٨-٣٠٨

(٨٥) لأن علة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالباً، ويعبر عنها بجوهرية الأثمان غالباً، وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض وليست قيماً للأشياء.

(٨٦) أي بدون كيل ولا وزن إذا كان المبيع من جنس المباع به، كأن يقول بعتك هذه الصبرة من القمح بهذه الصبرة من القمح، أو بعتك هذه الإسورة من الذهب بهذا الخاتم من الذهب بدون وزن، فالبيع ربا حتى وإن وزنا البدين بعد ذلك فبان أنهما متساويين؛ لأن العبرة بتحقيق التساوي وقت العقد لا بعده.

(٨٧) نعم لم يعلم قدر المبيع والمباع به، وإنما صح البيع هنا؛ لأنه لم يكن تخميناً بل بما يظهر مقدره، فلما كال الصبرة وجدها خمسة فأخذ من الثانية ما يساويها.

(٨٨) شرع في بيان ما تتحقق به المماثلة في الثمار والحبوب، وهذا شرط لتحقيق التساوي، وليس شرطاً لتحقيق الكمال.

(٨٩) وهي التي رخص فيها بأن يباع الرطب منها باليابس من التمر بمقدار خمسة أوسق لا يزداد عليها؛ لحاجة الناس، وتفصيل المسألة في باب الأصول والثمار.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا نَعَمْ، فَتَهَى عَنْ ذَلِكَ» ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُمَاتِلَةَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْجَفَافِ وَالْحَقِّ بِالرُّطْبِ فِيمَا دُكِرَ طَرِيَّ اللَّحْمِ فَلَا يُبَاعُ بِطَرِيَّهِ وَلَا بِقَدِيدِهِ^(٩٠) مِنْ جِنْسِهِ، وَيُبَاعُ بِقَدِيدِهِ^(٩١) بِلَا عَظْمٍ وَلَا مِلْحٍ يَظْهَرُ فِي الْوِزْنِ.

(وَمَا لَا جَفَافَ لَهُ كَالْقَتَاءِ) بِكُسْرِ الْقَافِ وَبِالْمُتَلَثَّةِ وَالْمَدِّ^(٩٢) (وَالْعَنْبِ الَّذِي لَا يَتَرَبَّبُ لَا يُبَاعُ) بَعْضُهُ بِبَعْضٍ (أَصْلًا) كَالرُّطْبِ بِالرُّطْبِ (وَفِي قَوْلٍ: تَكْفِي مُمَاتِلَتُهُ رَطْبًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ كَاللَّبَنِ بِاللَّبَنِ فَيُبَاعُ وَزَنًا وَإِنْ أَمَكْنَ كَيْلُهُ^(٩٣)، وَقِيلَ مَا يُمَكَّنُ كَيْلُهُ كَالنَّقَّاحِ وَالَّتَيْنِ يُبَاعُ كَيْلًا، وَلَا بَأْسَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ بِتَقَاوُتِ الْعَدَدِ، وَمِمَّا لَا جَفَافَ فِيهِ الزَّيْتُونُ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ وَارْتِضَاهُ جَوَازَ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَسِيطِ.

(وَلَا تَكْفِي مُمَاتِلَتُهُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ^(٩٤)) أَيْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ. (وَالْخُبْزِ) فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضٍ كُلِّ مِنْهَا بِبَعْضِهِ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاتِلَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِتَقَاوُتِ الدَّقِيقِ فِي النُّعُومَةِ وَالْخُبْزِ فِي تَأْثِيرِ النَّارِ. (بَلْ تُعْتَبَرُ الْمُمَاتِلَةُ فِي الْخُبُوبِ حَبًّا) لِتَحَقُّقِهَا فِيهَا وَقْتُ الْجَفَافِ^(٩٥) (و) تُعْتَبَرُ (فِي خُبُوبِ الدُّهْنِ كَالسِّمْسِمِ) بِكُسْرِ السِّينَيْنِ (حَبًّا أَوْ دُهْنًا وَفِي الْعَنْبِ زَبِيًّا أَوْ خَلًّا عَنْبٍ، وَكَذَا الْعَصِيرُ) أَيْ عَصِيرُ الْعَنْبِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مَا دُكِرَ حَالَاتُ كَمَالٍ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ السِّمْسِمِ أَوْ دُهْنِهِ بِبَعْضٍ وَبَيْعُ بَعْضِ الزَّيْبِ أَوْ خَلِّ الْعَنْبِ بِبَعْضٍ وَبَيْعُ بَعْضِ عَصِيرِ الْعَنْبِ بِبَعْضٍ^(٩٦). وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِيهِ يُمْنَعُ كَمَالُهُ^(٩٧) وَمِثْلُهُ عَصِيرُ الرُّطْبِ وَالزَّمَانِ وَقَصْبُ السُّكَّرِ^(٩٨)، وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ خَلِّ الرُّطْبِ بِبَعْضٍ بِخِلَافِ خَلِّ الزَّيْبِ أَوْ التَّمْرِ لِأَنَّ فِيهِ مَاءً، فَيَمْتَنِعُ الْعِلْمُ بِالْمُمَاتِلَةِ وَالْمُعْيَارُ فِي الدُّهْنِ وَالْخَلِّ وَالْعَصِيرِ الْكَئِيلُ.

(٩٠) القديد من اللحم: هو المشرح والمجفف في الشمس.

(٩١) أي يبيع قديد اللحم بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن.

(٩٢) القتاء: هو اسم لما يسميه الناس بالخيار، والمقصود منه ومما يشبهه أن لا ييبس بل لا يعرف إلا رطباً.

(٩٣) قوله " كَاللَّبَنِ " وجه القياس فيه أنه إذا جاز بيع اللبن بعضه ببعض من نفس الجنس، وهو مائع، فكذلك ما لا ييبس كالقتاء يجوز بيع بعضه ببعض وإن كان رطباً.

(٩٤) طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير سمي بذلك لانسياقه في الحلق. المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٦٥.

(٩٥) كالحنطة والشعير والذرة ونحوها يعتبر كمالها بالجفاف فحسب فلا يمكن الاستفادة منها ولا أخذ ما يشتق منها كالدقيق إلا بالجفاف.

(٩٦) الكمال فيها يتحقق بأكثر من صورة (الحب والدهن والعصير والخل)، وعليه فيجوز بيع بعض السمسم ببعض، وبيع الدهن منه بعضه ببعض، وهكذا

(٩٧) يمنع بيع بعض العصير بعضه ببعض، فالعصير ليس على هيئة كمال المنفعة.

(٩٨) أي يجري فيها الخلاف على الوجهين.

(و) تُعْتَبَرُ الْمُمَائِلَةُ (فِي اللَّبَنِ لَبَنًا) بِحَالِهِ (أَوْ سَمَنًا أَوْ مَخِيضًا صَافِيًا) أَيَّ خَالِصًا مِنْ الْمَاءِ، فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ اللَّبَنِ بِبَعْضٍ كَثِيرًا سَوَاءً فِيهِ الْحَلِيبُ وَالْحَامِضُ وَالرَّائِبُ وَالْخَائِرُ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلِيًّا بِالنَّارِ وَلَا مُبَالَاةً بِكَوْنِ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ مِنَ الْخَائِرِ أَكْثَرَ وَزَنًا، وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ السَّمَنِ بِبَعْضٍ وَزَنًا عَلَى النَّصِّ، وَقِيلَ كَثِيرًا، وَقِيلَ وَزَنًا إِنْ كَانَ جَامِدًا وَكَثِيرًا إِنْ كَانَ مَائِعًا، وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ الْمَخِيضِ الصَّافِي بِبَعْضٍ. أَمَّا الْمَشُوبُ بِالْمَاءِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ، وَلَا بِخَالِصٍ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَائِلَةِ (وَلَا تَكْفِي الْمُمَائِلَةُ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ) أَيَّ بَاقِيهَا (كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ) وَالْمَصْلِ وَالزُّبْدِ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ مُخَالَطَةِ شَيْءٍ، فَالْجُبْنُ تَخَالِطُهُ الْإِنْفَحَةُ وَالْأَقِطُ يُخَالِطُهُ الْمِلْحُ، وَالْمَصْلُ يُخَالِطُهُ الدَّقِيقُ، وَالزُّبْدُ لَا يَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ مَخِيضٍ، فَلَا تَتَحَقَّقُ فِيهَا الْمُمَائِلَةُ الْمُعْتَبَرَةُ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضٍ كُلِّ مِنْهَا بِبَعْضِهِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزُّبْدِ بِالسَّمَنِ، وَلَا بَيْعُ اللَّبَنِ بِمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَالسَّمَنِ وَالْمَخِيضِ (٩٩).

(وَلَا تَكْفِي مُمَائِلَةُ مَا أَثَرَتْ فِيهِ النَّارُ بِالطَّبَخِ أَوْ الْقَلْيِ أَوْ الشَّيِّ) فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ حَبًّا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ كَالسَّمْسِمِ وَاللَّحْمِ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَائِلَةِ بِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ قُوَّةً وَضَعْفًا، وَفِيمَا أَثَرَتْ فِيهِ بِالْعَقْدِ كَالدَّبْسِ وَالسُّكَّرِ وَجَهَانِ أَصْحُهُمَا لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. (وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ تَمْيِيزِ) بِالنَّارِ (كَالْعَسَلِ وَالسَّمَنِ) يُمَيِّزَانِ بِالنَّارِ عَنِ الشَّمْعِ وَاللَّبَنِ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضٍ كُلِّ مِنْهُمَا بِبَعْضِهِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَائِلَةِ (١٠٠)

(١٠١) (وَإِذَا جَمَعْتَ الصَّفَقَةَ) أَيَّ عَقْدَ الْبَيْعِ سَمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَحَدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ يُصَفِّقُ يَدَهُ عَلَى يَدِ الْآخَرِ فِي عَادَةِ الْعَرَبِ (رَبَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ) أَيَّ جِنْسُ الرَّبَوِيِّ (مِنْهُمَا) جَمِيعُهُمَا أَوْ مَجْمُوعُهُمَا بِأَنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جِنْسَيْنِ اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطُّ. (كَمَدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمَدِّ وَدِرْهَمٍ وَكَمَدِّ وَدِرْهَمٍ بِمَدِّينِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ) اخْتَلَفَ (النَّوْعُ) أَيَّ نَوْعُ الرَّبَوِيِّ بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ مَثَلًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعُهُمَا أَوْ مَجْمُوعُهُمَا بِأَنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ

(٩٩) خلاصة القول فيما تقدم من اللبن وما يتحول عنه إذا كان صافياً ولم يضاف إليه شيء من ملح أو نحوه جاز بيع بعضه ببعض متماثلاً وأن يكون وزناً، وفي تحقق المماثلة في بيع السمن الخلف المذكور، وأما إذا خاطه شيء كالجبين والأقط فلا يجوز بيع بعضه ببعض؛ لعدم تحقيق التماثل، واللبن المشوب بالماء لا يباع بمثله مشوباً، ولا باللبن الخاصة؛ لأنه من قاعدة "مد عجوة ودرهم".

(١٠٠) نفس الكلام المتقدم بأن الطعام الربوي إذا خالطه شيء أو وضع على النار لم تتحقق المماثلة، فظهر الفرق بين جواز بيع السمسم حباً بمثله وزناً، ولم يجز بيع بعضه ببعض إذا وضع على النار بالطبخ والقلي ونحوه؛ لانتفاء التماثل.

(١٠١) بعد ما انتهى (رحمه الله) من الكلام عن الربويات وذكر أجناسها وما يشتق منها وأنواعها، وما يعتبر في تحقيق التماثل شرع في بيان قاعدة فقهية معروفة بـ "مد عجوة ودرهم"

الدَّائِرِ عَلَى مَوْصُوفَيْنِ بِصِفَتَيْنِ اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ. (كَصَاحٍ وَمُكْسَرَةٍ بِهِمَا) أَيْ بِصَاحٍ وَمُكْسَرَةٍ (أَوْ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ بِصَاحٍ فَقَطْ أَوْ بِمُكْسَرَةٍ فَقَطْ، وَقِيَمَةُ الْمُكْسَرَةِ دُونَ قِيَمَةِ الصَّاحِ فِي الْجَمِيعِ. (فَبَاطِلَةٌ) (١٠٢)؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اشْتِمَالِ أَحَدِ طَرَفَيْ الْعَقْدِ عَلَى مَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَنْ يُورَعَ مَا فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيَمَةِ (١٠٣) مِثَالُهُ بَاعَ شَقْصًا مِنْ دَارٍ وَسَيِّفًا بِالْأَلْفِ، وَقِيَمَةُ الشَّقْصِ مِائَةٌ وَالسَّيْفِ خَمْسُونَ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشَّقْصَ بِثُلَاثِي الْأَلْفِ، وَالتَّوْزِيعُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ يُؤَدِّي إِلَى الْمُقَاضَلَةِ أَوْ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاتَلَةِ، فَعِي بَيْعٍ مَدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمَدٍّ وَدِرْهَمٍ إِنْ اخْتَلَفَتْ قِيَمَةُ الْمَدِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ كَدِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمٍ فَمَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ ثُلَاثًا طَرَفِهِ فَيُقَابَلُهُ ثُلَاثًا مَدٍّ وَثُلَاثًا دِرْهَمٍ مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ يَبْقَى مِنْهُ ثُلُثٌ مَدٍّ وَثُلُثٌ دِرْهَمٍ فِي مُقَابَلَةِ الدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ الطَّرَفِ بِالسَّوِيَّةِ، فَتَتَحَقَّقُ الْمُقَاضَلَةُ فِي مُقَابَلَةِ ثُلُثِ دِرْهَمٍ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيَمَةُ الْمَدِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَالْمُمَاتَلَةُ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ التَّقْوِيمَ، وَهُوَ تَحْمِينٌ قَدْ يُخْطِئُ، وَفِي بَيْعٍ مَدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمَدِّينِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ إِنْ كَانَتْ قِيَمَةُ الْمَدِّ الَّذِي مَعَ الدِّرْهَمِ دِرْهَمًا فَالْمُمَاتَلَةُ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ لِمَا ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَتْ قِيَمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ كَدِرْهَمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ كَنِصْفِ دِرْهَمٍ تَحَقَّقَتْ الْمُقَاضَلَةُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مُقَابَلَةُ مَدٍّ بِمَدٍّ وَثُلُثٍ أَوْ بِثُلَاثِي مَدٍّ وَفِي الثَّانِيَةِ مُقَابَلَةُ دِرْهَمٍ بِثُلَاثِي دِرْهَمٍ أَوْ بِدِرْهَمٍ وَثُلُثِ دِرْهَمٍ وَفِي بَيْعِ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّائِرِ الصَّاحِ أَوْ الْمُكْسَرَةِ بِهِمَا إِنْ اسْتَوَتْ قِيَمَةُ الْمُكْسَرَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَمْ تَتَحَقَّقِ الْمُمَاتَلَةُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ تَحَقَّقَتْ الْمُقَاضَلَةُ عَلَى وَزَانٍ مَا تَقَدَّمَ كَمَا هِيَ مُحَقَّقَةٌ فِي الْبَيْعِ بِصَاحٍ فَقَطْ أَوْ مُكْسَرَةٍ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ فِي فَرْضِ الْمُسَائَلَةِ أَنَّ قِيَمَةَ الْمُكْسَرَةِ دُونَ قِيَمَةِ الصَّاحِ، فَلَوْ تَسَاوَتْ قِيَمَتُهُمَا فَلَا بُطْلَانَ، (١٠٤) وَلَوْ فَصَلَ فِي الْعَقْدِ فَجَعَلَ الْمَدُّ فِي مُقَابَلَةِ الْمَدِّ أَوْ الدِّرْهَمُ وَاللِّدْرَاهِمُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّرَاهِمِ أَوْ الْمَدِّ صَحَّ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَمَلْ أَحَدُ جَانِبَيْ الْعَقْدِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْآخَرُ كَبَيْعِ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ بِصَاعٍ حِنْطَةٍ وَصَاعٍ شَعِيرٍ أَوْ بِصَاعَيْنِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَبَيْعِ دِينَارٍ صَحِيحٍ وَآخَرَ مُكْسَرٍ بِصَاعٍ ثَمَرٍ بَرْنِيٍّ وَصَاعٍ مَغْقَلِيٍّ أَوْ بِصَاعَيْنِ بَرْنِيٍّ أَوْ مَغْقَلِيٍّ جَارَ.

-
- (١٠٢) ما ذكره من بيع (مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم) أو (مد عجوة ودرهمين) أو (مد عجوة ودرهم بمدين) وما بعده من أمثلة جمع فيها بين ربويين مختلفين في الصفة (صحيحة ومكسورة) إنما على سبيل التمثيل ويطبق في كل ما هو ربوي، ويطبق عليه قاعدة (مد عجوة ودرهم) والحكم فيها أنها ربا.
- (١٠٣) معنى اعتبار القيمة يعني أن المقابل يقدَّر فيه بالتقويم وهو تخمين، يحتمل التساوي ويحتمل غيره فلا يتحقق التماثل، وقد شرع في توضيح ذلك بالتوزيع.
- (١٠٤) شرع رحمه الله في بيان تصحيح هذا البيع وأنه يكون بالتفريق بينهما وذكر كل منهما على حدة ومعرفة مقابله، فلو قال المد بالمد والدرهم بالدرهم فقد فصل فلا توجد القاعدة

(١٠٥) (وَيَحْرُمُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ) كَبَيْعِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ (وَكَذَا بَيْعُ جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ) كَبَيْعِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالشَّاةِ وَبَيْعِهِ بِالْجَمَارِ (فِي الْأَطْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ ρ «نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ»، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (١٠٦)، «وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا (١٠٧) وَأَسَنَدُهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَمَةَ السَّاعِدِيِّ (١٠٨). وَمُقَابِلُ الْأَطْهَرِ: الْجَوَازُ، وَأَمَّا فِي الْمَأْكُولِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ أَجْنَاسٌ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَوُجَّهَ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ بَيْعُ مَالِ الرَّبَا بِأَصْلِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا (١٠٩).

بَابُ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (١١٠)

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ (١١١). وَعَسَبٌ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهِمْلَتَيْنِ (وَهُوَ ضِرَابُهُ) أَيْ طُرُقُهُ لِلْأُنْثَى (وَيُقَالُ مَاؤُهُ، وَيُقَالُ: أُجْرَةُ ضِرَابِهِ) وَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ (١١٢) يُقَدَّرُ فِي الْحَدِيثِ مُضَافٌ لِيَصِحَّ النَّهْيُ أَيْ نَهَى عَنْ بَدَلِ عَسَبِ الْفَحْلِ مِنْ أُجْرَةِ ضِرَابِهِ أَوْ ثَمَنِ مَائِهِ أَيْ بَدَلِ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ (فَيَحْرُمُ ثَمَنُ مَائِهِ) (١١٣) وَكَذَا أُجْرَتُهُ) لِلضَّرَابِ (فِي الْأَصَحِّ) عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي النَّهْيِ مِنَ التَّحْرِيمِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَاءَ

(١٠٥) (حكم بيع اللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه، والخلاف فيه).

(١٠٦) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [كتاب البيوع - باب بيع اللحم بالحيوان] رقم (١٠٥٦٩)، والحاكم في المستدرک [كتاب البيوع] رقم (٢٢٥١)).

(١٠٧) (أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (١٧٨)).

(١٠٨) (لم أجده عند الترمذي في سننه وإنما وجدته في سنن الدارقطني عن سهل بن سعد [كتاب البيوع] رقم (٣٠٥٦) وقال: "تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا".

(١٠٩) (قوله "وأما في المأكول...." إلى آخره دليل على مقابل الأظهر بالجواز، وبيانه أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه (لحم بقر ببقر) بناءً على ما تقدم - في مقابل الأظهر عند الكلام عن بيع الدقيق بالدقيق - اعتبار اللحوم جنس بنفسها، فاختلف الجنس فلا ربا وجاز التفاضل، وأما جواز بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه مأكولاً كان أو غير مأكول بأن سبب المنع كان لبيع مال بجنسه وهو غير متحقق هنا فجاز البيع.

(١١٠) (شرح في الكلام عن البيوع المنهي عنها، وأثر النهي فيها فساد العقد، وهذه البيوع فسدت لاختلال شروط عقد البيع فيها، ونص في كل منها على ما خالف شروط العقد المتقدمة.

(١١١) (أخرجه البخاري [كتاب الإجارة - باب عسب الفحل] رقم (٢٢٨٤)).

(١١٢) (على التفسير بأن معناه طروقه للأُنْثَى أو معناه: ماؤه.

(١١٣) (هذا من غير خلاف في التحريم، وأما على التفسير: بأجرة ضرابه خلاف على وجهين: الأصح ومقابله.

الْفَحْلُ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَضَرَابُهُ؛ لِتَعْلُقِهِ بِاخْتِيَارِهِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ^(١١٤).

وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: جَوَّازُ اسْتِئْجَارِهِ لِلضَّرَابِ كَالِاسْتِئْجَارِ لِتَلْقِيحِ النَّخْلِ^(١١٥)، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبُ الْأُنْثَى صَاحِبَ الْفَحْلِ شَيْئًا هَدِيَّةً^(١١٦)، وَالْإِعَارَةُ لِلضَّرَابِ مَحْبُوبَةٌ (وَعَنْ حَبْلِ الْحَبْلَةِ)^(١١٧) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوجَدَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بَلْفِظَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ^(١١٨) (وَهُوَ نِتَاجُ النَّتَاجِ بِأَنْ يَبِيعَ نِتَاجُ النَّتَاجِ أَوْ يَنْمَنَ إِلَى نِتَاجِ النَّتَاجِ)^(١١٩)

أَيُّ إِلَى أَنْ تَلِدَ هَذِهِ الدَّابَّةُ وَيَلِدَ وَلَدُهَا، فَوَلَدَ وَلَدُهَا نِتَاجُ النَّتَاجِ، وَهُوَ بِكُسْرِ النُّونِ بِضَبِّ الْمُصْتَفِ كَالْجَوْهَرِيِّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمُفْعُولِ بِالْمَصْدَرِ، يُقَالُ نُبِجَتْ النَّاقَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ نِتَاجًا بِكُسْرِ النُّونِ أَيُّ وَلَدَتْ، وَبُطْلَانُ الْبَيْعِ الْمُسْتَقَادِ مِنَ النَّهْيِ عَلَى التَّقْسِيرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَعَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ إِلَى أَجْلِ مَجْهُولٍ^(١٢٠). (وَعَنْ الْمَلَقِيحِ) وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ مِنَ الْأَجْنَةِ (وَالْمَضَامِينِ وَهِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ) مِنَ الْمَاءِ^(١٢١) رَوَى النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِمَا مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا^(١٢٢) وَالْبَزَّازُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدًا^(١٢٣) وَبُطْلَانُ الْبَيْعِ فِيهِمَا لِمَا عَلِمَ مِمَّا ذُكِرَ^(١٢٤)، (وَالْمَلَامَسَةُ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(١١٤) قوله: "وَالْمَعْنَى فِيهِ" إلى آخره ... بيان لما لم يتوافر من شروط عقد البيع، والتي أدت إلى البطلان.
(١١٥) جواز الاستئجار لتلقيح النخل جائز؛ لأن المستأجر عليه هو فعل الأجير، وإنما لو شرط عليه ما يلحق به فسدت الإجارة.

(١١٦) هذا تطبيق عملي لمُخْرِجٍ مِنْ مُخْرَجَاتِ التَّعْلِيمِ، وهو البحث عن الحل الشرعي عند وجود المانع.
(١١٧) معطوف على نهى رسول الله ﷺ عن عصب الفحل وما يأتي بعد كذلك وعن الملاقيح والمضامين إلى آخره

(١١٨) أخرجه البخاري [كتاب البيوع - باب بيع الغرر وحبل الحبله] رقم (٢١٤٣)، ومسلم [كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبله] رقم (١٥١٤).

(١١٩) هذان تفسيران لبيع نتاج النتاج.
(١٢٠) قوله: "وبطلان البيع إلى آخره" إنما هو بيان للشرط المفقود من شروط البيع المتقدم ذكرها، سواء على التفسير الأول لمعنى نتاج النتاج أو على التفسير الثاني.

(١٢١) وهذا يفعلونه غالباً عند التنافس على الانتاج لقلته وكثرة الطلب عليه أو لنوع النتاج ونفاسته، وعلى أي مبرر لهذا البيع فهو منهى عنه.

(١٢٢) أخرجه مالك في الموطأ [كتاب البيوع - ما لا يجوز من بيع الحيوان] رقم (٢٤١١).

(١٢٣) أخرجه البزار في مسنده رقم (٧٧٨٥).

(١٢٤) وهو عدم القدرة على تسليم المبيع، وللجهالة بالمبيع، فأدى إلى بطلان البيع فيهما.

وَقَالَ: وَالْمُنَابَذَةُ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ بَلْفُظٌ: «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُنَابَذَةُ وَالْمَلَامَسَةُ»^(١٢٥)، (بِأَنْ يَلْمَسَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكُسْرِهَا (تُؤَبَّأُ مَطْوِيًّا) أَوْ فِي ظُلْمَةٍ (ثُمَّ يَشْتَرِيهِ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ إِذَا رَأَهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيِيهِ (أَوْ يَقُولُ: إِذَا لَمَسْتَهُ فَقَدْ بَعَثْتَهُ) اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ الصَّيْغَةِ أَوْ يَبِيعُهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَانْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَغَيْرُهُ.

(وَالْمُنَابَذَةُ) بِالْمُعْجَمَةِ (بِأَنْ يَجْعَلَ النَّبَذَ بَيْعًا) اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصَّيْغَةِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: أَنْبِذْ إِلَيْكَ تَوْبِي بِعَشْرَةٍ، فَيَأْخُذُهُ الْآخَرُ أَوْ يَقُولُ: بَعْتُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِّي إِذَا نَبَذْتَهُ إِلَيْكَ لَزِمَ الْبَيْعُ وَانْقَطَعَ الْخِيَارُ، وَالْبُطْلَانُ فِيهِمَا لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ أَوْ عَدَمِ الصَّيْغَةِ أَوْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ^(١٢٦). «وَبَيْعُ الْحَصَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ^(١٢٧) (بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: بَعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا تَقَعُ هَذِهِ الْحَصَاةُ عَلَيْهِ أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ) لَهَا (بَيْعًا) اكْتِفَاءً بِهِ عَنْ الصَّيْغَةِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: إِذَا رَمَيْتَ هَذِهِ الْحَصَاةَ فَهَذَا التَّوْبُ مَبِيعٌ مِنْكَ بِعَشْرَةٍ. (أَوْ يَقُولُ (بَعْتُكَ وَلَكَ الْخِيَارُ إِلَى رَمِيهَا) وَالْبُطْلَانُ فِي ذَلِكَ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ أَوْ بِزَمَنِ الْخِيَارِ أَوْ لِعَدَمِ الصَّيْغَةِ^(١٢٨)) (وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ^(١٢٩)، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (بِأَنْ يَقُولَ بَعْتُكَ) هَذَا (بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، أَوْ شِئْتُ أَنَا (أَوْ بَعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَكَ بِكَذَا) أَوْ تَشْتَرِي مِنِّي دَارِي بِكَذَا، وَالْبُطْلَانُ فِي ذَلِكَ لِلْجَهْلِ بِالْعَوَضِ فِي الْأَوَّلِ وَلِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ فِي الثَّانِي^(١٣٠)

كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ (وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ) رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ^(١٣١)، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِهِذَا الطَّرِيقِ: «لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطٌ وَبَيْعٌ»^(١٣٢) (كَبَيْعٍ بِشَرْطٍ بَيْعٍ) كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ قَرْضٍ) كَانَ يَبِيعُهُ عَبْدُهُ بِأَلْفٍ بِشَرْطٍ أَنْ يُفْرِضَهُ مِائَةً،

(١٢٥) أخرجه البخاري [كتاب البيوع - باب بيع الملامسة] رقم (٢١٤٤)، ومسلم [كتاب البيوع - باب إبطال بيع الملامسة والمناذة] رقم (١٥١١).

(١٢٦) قوله "والبطالان فيهما....." إلى آخره بيان لشرط البيع وهو العلم بالمعقود عليه أو عدم الصيغة أحد أركان العقد.

(١٢٧) أخرجه مسلم [كتاب البيوع - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر] رقم (١٥١٣).

(١٢٨) قوله: "والبطلان في ذلك للجهل" بيان لما فقدته عقد البيع من الشروط.

(١٢٩) أخرجه الترمذي رقم [أبواب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة] (١٢٣١).

(١٣٠) قوله: "والبطلان..." إلى آخره بيان لما فقدته عقد البيع من الشروط.

(١٣١) أخرجه عبد الحق في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى [البيوع - باب ذكر بيع نهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا].

(١٣٢) أخرجه أبو داود [كتاب البيوع - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده] رقم (٣٥٠٤).

وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ وَرَفَقَ الْعَقْدَ (١٣٣) الثَّانِي ثَمَنًا. وَاشْتَرَا طُ الْعَقْدَ الثَّانِي فَاسِدٌ فَبَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ قِيَمَةٌ مَعْلُومَةٌ حَتَّى يَفْرِضَ التَّوْزِيعَ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْبَاقِي فَبَطَلَ الْعَقْدُ (١٣٤) (وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَخْصُدَهُ الْبَائِعُ) بِضَمِّ الصَّادِ وَكُسْرِهَا (أَوْ ثَوْبًا وَيَخِيطُهُ) الْبَائِعُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَخِيطَهُ (فَالْأَصَحُّ بَطْلَانُهُ) أَيِ الشِّرَاءِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ، وَذَلِكَ فَاسِدٌ.

وَالثَّانِي: يَصِحُّ، وَيَلْزَمُ الشَّرْطُ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ يُوزَعُ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيَمَةِ. وَالثَّلَاثُ: يَبْطُلُ الشَّرْطُ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِمَا يُقَابِلُ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُسَمَّى. وَهَذَا حَاصِلُ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَصَحُّهَا بَطْلَانُ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ، وَالثَّانِيَةُ فِيهِمَا الْقَوْلَانِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، وَالثَّلَاثَةُ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَفِي الْبَيْعِ قَوْلُ تَفْرِيقِ الصِّفَةِ (١٣٥). (١٣٦) (وَيُسْتَنْتَى) مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ (صُورٌ) نَصَحٌ لِمَا سَيَأْتِي (كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِ الثَّمَرِ) وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَالِهِ (وَالْأَجَلِ) (١٣٧) وَالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ الْمُعَيَّنَاتِ الثَّمَنِ فِي الدِّمَةِ) أَمَّا الْأَجَلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: [إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى] [البقرة: ٢٨٢]. أَيِ مُعَيَّنٍ. [فَاكْتُبُوهُ] [البقرة: ٢٨٢]، وَأَمَّا الرَّهْنُ وَالْكَفِيلُ؛ فَلِلْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا فِي مُعَامَلَةٍ مَنْ لَا يَرْضَى إِلَّا بِهِمَا، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الرَّهْنِ غَيْرَ الْمَبِيعِ (١٣٨)، فَإِنْ شَرَطَ رَهْنُهُ بِالْثَّمَنِ بَطَلَ الْبَيْعُ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ رَهْنٍ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ، وَالتَّعْيِينُ فِي الرَّهْنِ (١٣٩) بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ، وَفِي الْكَفِيلِ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ، وَلَا يَكْفِي الْوَصْفُ كَمُوسِرٍ ثَقَةٍ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا هُوَ النُّقْلُ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: الْإِكْتِفَاءُ بِالْوَصْفِ أَوَّلَى مِنَ الْإِكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةٍ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يَكُنْ مُبْعَدًا، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الرُّوْضَةِ. وَتَقْيِيدُ الثَّمَنِ بِكَوْنِهِ فِي الدِّمَةِ لِلِاخْتِرَازِ عَنْ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَهَا لِي فِي وَقْتٍ كَذَا أَوْ تَرَهَّنَ بِهَا كَذَا أَوْ يَضْمَنَكَ بِهَا فَلَا نَّ فَإِنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ، ذَكَرَهُ فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْأَجَلِ لِأَنَّهُ رَفُقَ أُثْبِتَ

(١٣٣) يقصد به القرض، فهو عقد إرفاق

(١٣٤) بطلان العقد للجهالة بضمن المبيع.

(١٣٥) معنى تفريق الصفة: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه، أو يتناوله ثم ينحسر عنه . فتكون الصفة الواحدة المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو تجزأت وبكل هذه المترادفات يعبر الفقهاء فيسمونه (تفرق الصفة) أو (تبعضها) أو (تجزؤها).

(١٣٦) النهي عن بيع وشرط ليس على إطلاقه بل يستثني منه صوراً يجوز فيها البيع والشرط، ترجع جميعها لمصلحة العقد وإتمامه.

(١٣٧) وذلك في عقود لا يشترط فيها الحلول والتقابض في مجلس العقد كالرؤيات وعقد السلم.

(١٣٨) يشترط لصحة الرهن.

(١٣٩) معطوف على ولا بد، أي يشترط لصحة الرهن التعيين

لِتَحْصِيلِ الْحَقِّ فِي الْمَدَّةِ وَالْمَعِينِ حَاصِلًا. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّافِعِي فِي التَّكَلُّمِ عَنِ الْفَاطِ الْوَجِيزِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ، وَيُقَالُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا إِنَّهُ رَفِقَ شُرْعَ لِتَحْصِيلِ الْحَقِّ، وَالْمَعِينُ حَاصِلٌ. فَشَرَطُ كُلِّ مِنْ الثَّلَاثَةِ^(١٤٠) مَعَهُ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ لَهُ.

(وَالْإِشْهَادُ)^(١٤١)؛ لِلأَمْرِ بِهِ فِي الْآيَةِ قَالَ تَعَالَى: [وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ] [البقرة: ٢٨٢] (وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الشُّهُودِ فِي الْأَصَحِّ).

وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ كَالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِتَقَاوُتِ الْأَعْرَاضِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الشُّهُودِ فَإِنَّ الْحَقَّ يَنْبُتُ بِأَيِّ عُدُولٍ كَانُوا، وَقَطَعَ الْإِمَامُ بِالْأَوَّلِ وَرَدَّ الْخِلَافَ إِلَى أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَهُمْ هَلْ يَتَعَيَّنُونَ. (فَإِنْ لَمْ يَرَهْنِ) الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْهَدْ كَمَا فِي أَصْلِ الرُّوَضَةِ (أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمِ الْمُعِينُ فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ) لِقَوَاتِ مَا شَرَطَهُ، وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدَيْنِ فَاِمْتَنَعَ مِنَ التَّحَمُّلِ ثَبَتَ الْخِيَارُ إِنْ أُشْتَرِطَ التَّعْيِينُ وَإِلَّا فَلَا^(١٤٢)).

(وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا بِشَرَطِ إِعْتَاقِهِ فَالْمَشْهُورُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَالشَّرْطُ) لِنَشُوءِ الشَّارِعِ إِلَى الْعِتْقِ^(١٤٣)، وَالثَّانِي: بَطْلَانُهُمَا كَمَا لَوْ شَرَطَ بَيْعُهُ أَوْ هِبَتُهُ، وَالثَّلَاثُ: صِحَّةُ الْبَيْعِ وَبَطْلَانُ الشَّرْطِ كَمَا فِي النِّكَاحِ. (وَالْأَصَحُّ) عَلَى الْأَوَّلِ (أَنَّ لِلْبَائِعِ مَطَالِبَةَ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ) وَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْأَصَحُّ كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِاشْتِرَاطِهِ، وَالثَّانِي لَيْسَ لَهُ مَطَالِبَتُهُ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ لَهُ فَلَهُ مَطَالِبَتُهُ وَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ، فَإِنْ اِمْتَنَعَ مِنَ الْإِعْتَاقِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ لِلْبَائِعِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي فسخِ الْبَيْعِ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَالْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ فِيهِ لِلْبَائِعِ (و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ مَعَ الْعِتْقِ الْوَلَاءَ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (أَوْ شَرَطَ تَدْبِيرَهُ أَوْ كِتَابَتَهُ أَوْ إِعْتَاقَهُ بَعْدَ شَهْرٍ) مَثَلًا (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) أَمَّا فِي شَرَطِ الْوَلَاءِ فَلَمُخَالَفَتِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي وَاحِدٍ مِمَّا مَا تَشَوَّفَ إِلَيْهِ الشَّارِعُ مِنَ الْعِتْقِ النَّاجِزِ، وَالثَّانِي يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلَاءِ قَوْلٌ مَنْصُوصٌ أَوْ مُحَرَّجٌ. ^(١٤٤) (وَلَوْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَالْقَبْضِ وَالرَّدِّ بَعِيْبٍ أَوْ مَا لَا

(١٤٠) يقصد بها قوله في الشرح "عَلَى أَنْ تُسَلِّمَهَا لِي فِي وَقْتٍ كَذَا أَوْ تَرَهَّنَ بِهَا كَذَا أَوْ يَضْمَنَكَ بِهَا فَلَنْ".

(١٤١) ويجوز اشتراط الإِشهاد في عقد البيع.

(١٤٢) قوله: "فإن لم يرهن المشتري" إلى آخره بيان للأثر المترتب على الخلف في الشرط، وهو ثبوت الخيار للمشتري، وليس بطلان العقد؛ لأن الخلل في شرط خارج عن العقد.

(١٤٣) هذه من الصور المستثناة من النهي عن بيع وشرط، ووقع الخلاف في جوازها على وجهين ذكرهما.

(١٤٤) أي يطمح إلى العتق، وهذا من محاسن التشريع، فهو إحياء للعبد وإحاقه بالإنسان لتكريمه بدلاً من إحاقه بالجمادات.

(١٤٥) ما زال الكلام موصولاً بالحديث عن البيع والشرط معاً، وهنا يتكلم عن نوع جديد من الشروط يتوافق مع مقتضى العقد ولا ينافيه وكذلك إذا كان الشرط لوصف مقصود.

غَرَضَ فِيهِ كَشْرَطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا كَذَا صَحَّ) الْعَقْدُ فِيهِمَا^(١٤٦) وَلَعَا الشَّرْطُ فِي الثَّانِي^(١٤٧). وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِ التَّيَمَّةِ، وَنَصَّ فِي الْأُمِّ فَسَادَ الْعَقْدِ فِي الثَّانِي. . (وَلَوْ شَرَطَ وَضْعًا يُقْصَدُ كَكُونِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ الدَّابَّةِ حَامِلًا أَوْ لَبُونًا صَحَّ) الشَّرْطُ مَعَ الْعَقْدِ، (وَلَوْ الْخِيَارُ إِنْ أَخْلَفَ) الشَّرْطُ.

(وَفِي قَوْلٍ: يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِي الدَّابَّةِ) بِصُورَتَيْهَا لِلْجَهْلِ بِمَا شَرِطَ فِيهَا، بِخِلَافِ شَرِطِ الْكِتَابَةِ لِإِمْكَانِ الْعِلْمِ بِهَا بِالِاخْتِبَارِ فِي الْحَالِ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْعِلْمَ بِمَا شَرِطَ فِي الدَّابَّةِ فِي ثَانِي الْحَالِ كَافٍ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ بِشَرْطِ أَنَّهَا حَامِلٌ^(١٤٨)، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ فِيهَا بِالصَّحَّةِ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهَا عَيْبٌ فَاشْتَرَاؤُهُ إِعْلَامٌ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا آبِقَةً أَوْ سَارِقَةً.

(وَلَوْ قَالَ: بَعَثْتُهَا) أَيُّ الدَّابَّةِ (وَحَمَلَهَا بَطَلَ) الْبَيْعُ (فِي الْأَصَحِّ) لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا بِخِلَافِ بَيْعِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا فَفِيهِ جَعْلُ الْحَامِلِيَّةِ وَضْعًا تَابِعًا، وَالثَّانِي يَقُولُ: لَوْ سَكَتَ عَنِ الْحَمْلِ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَضُرُّ التَّنْصِيبُ عَلَيْهِ.

(١٤٩) (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَمْلِ وَحْدَهُ)؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَيْهِ (وَلَا الْحَامِلِ دُونَهُ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ، (وَلَا الْحَامِلِ بِحَرٍّ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، فَكَأَنَّهُ اسْتِثْنَى، وَقِيلَ: يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَكُونُ الْحَمْلُ مُسْتَثْنَى شَرْعًا (وَلَوْ بَاعَ حَامِلًا مُطْلَقًا) عَنْ ذِكْرِ الْحَمْلِ مَعَهَا وَنَفْيِهِ (دَخَلَ الْحَمْلُ فِي الْبَيْعِ) تَبَعًا لَهَا^(١٥٠).

(١٥١) (فَضَلَ وَمِنْ الْمُنْهَيِّ عَنْهُ مَا لَا يَبْطُلُ بِضَمِّ الْإِيَاءِ بِضَبِّ الْمُصَنِّفِ أَيُّ النَّهْيِ فِيهِ الْبَيْعُ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَبَفَتْحِهَا أَيْضًا (لِرُجُوعِهِ) أَيُّ النَّهْيِ فِي ذَلِكَ (إِلَى مَعْنَى يَقْتَرِنُ بِهِ) لَا إِلَى ذَاتِهِ.

(١٥٢) (كَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ: بِأَنْ يَقْدَمَ غَرِيبٌ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَيَقُولُ) لَهُ (بَلَدِي أَتْرُكُهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ) لَكَ (عَلَى التَّذْرِيجِ) أَيُّ شَيْئًا فَشَيْئًا (بِأَعْلَى) فَيُؤَافِقُهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ -

(١٤٦) "فيهما" في شرط القبض للثمن أو القبض للمبيع، أو شرط الرد بوجود عيب في المبيع أو وجود عيب في الثمن، فهما من مقتضيات العقد.

(١٤٧) قصده إذا شرط ما لا غرض فيه.

(١٤٨) على القول الأول يصح البيع وشرط الحمل معاً، وفي قول: لا يصح للجهل بما شرط.

(١٤٩) حالات بيع الحمل، ما يجوز منها وما لا يجوز.

(١٥٠) وهذا الفرع يدخل تحت قاعدة: "التابع تابع".

(١٥١) شرع في بيان النوع الثاني من البيوع المنهي عنها، وهي ما لا يترتب عليها فساد العقد؛ لأنها الخلل ليس لذات العقد وإنما لأمر خارج عنه.

(١٥٢) شرع في بيان النوع الأول من البيوع المنهي عنها، والنهي خارج عن حقيقة العقد "بيع الحاضر للباد".

p- «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ، زَادَ مُسْلِمٌ «دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»^(١٥٣) وَالْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنَ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ^(١٥٤) بِأَنْ يَكُونَ بِالشَّرْطَيْنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِمَا التَّفْسِيرُ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ نَادِرًا لَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ.

ثَانِيهِمَا: قَصْدُ الْقَادِمِ الْبَيْعِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، فَلَوْ قَصَدَ الْبَيْعَ عَلَى التَّدْرِيجِ، فَسَأَلَهُ الْبَلَدِيُّ تَقْوِيضَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضُرَّ بِالنَّاسِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَنَعِ الْمَالِكِ مِنْهُ، وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، فَيَأْتِي بِإِزْكَارِهِ الْعَالَمَ بِهِ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ، قَالَ فِي الرُّوضَةِ: قَالَ الْقَفَّالُ الْإِثْمُ عَلَى الْبَلَدِيِّ دُونَ الْبَدَوِيِّ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي اهـ.

وَالْبَادِي سَاكِنُ الْبَادِيَةِ. وَالْحَاضِرُ سَاكِنُ الْحَاضِرَةِ، وَهِيَ الْمَدُنُ وَالْقُرَى وَالرِّيْفُ، وَهُوَ أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ وَخَصْبٌ وَذَلِكَ خِلَافُ الْبَادِيَةِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا بَدَوِيٌّ وَإِلَى الْحَاضِرَةِ حَضَرِيٌّ.

^(١٥٥) (وَتَلْقَى الرُّكْبَانَ: بِأَنْ يَتَلَقَّى طَائِفَةٌ يَحْمِلُونَ مَتَاعًا إِلَى الْبَلَدِ فَيَشْتَرِيهِ) مِنْهُمْ (قَبْلَ قُدُومِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّعْرِ، وَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا عَرَفُوا الْغُبْنَ) قَالَ p: «لَا تَتَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»^(١٥٦)، وَالْمَعْنَى فِي النَّهْيِ غَبْنُهُمْ، وَهُوَ نَهْيُ تَحْرِيمِ فَيَأْتِي مُزْكَابُهُ الْعَالَمَ بِهِ، ^(١٥٧) وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ التَّلْقِي، بَلْ خَرَجَ لِاصْطِيَادٍ أَوْ غَيْرِهِ فَرَأَاهُمْ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ فَلَا أَصَحَّ عَصِيَانُهُ لِمُشْمُولِ الْمَعْنَى، وَعَلَى مُقَابِلِهِ: لَا خِيَارَ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَغْبُوتِينَ، وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِسِعْرِ الْبَلَدِ أَوْ بِدُونِ سِعْرِهِ وَهُمْ غَالِمُونَ بِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى الصُّورَتَيْنِ، وَحَيْثُ ثَبَتَ لَهُمُ الْخِيَارُ فَهُوَ عَلَى الْقَوْرِ، وَلَوْ تَلَقَّى الرُّكْبَانَ وَبَاعَهُمْ مَا يَقْصِدُونَ شِرَاءَهُ مِنَ الْبَلَدِ، فَهَلْ هُوَ كَالْتَّلْقَى لِلشِّرَاءِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَالْتَّلْقَى، وَالرُّكْبَانُ جَمْعُ رَاكِبٍ .

(١٥٣) أخرجه البخاري [كتاب البيوع - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر] رقم (٢١٥٩)، ومسلم [كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي] رقم (١٥٢٠).

(١٥٤) وهذا المعنى خارج عن أركان وشروط عقد البيع، فكان البيع صحيحاً، ولكنه حرام للنهي عنه، والنهي للتحريم كما ذكر (رحمه الله).

(١٥٥) ثم شرع في بيان النوع الثاني من البيوع المنهي عنها لوصف خارج عنها "تلقى الركبان".

(١٥٦) أخرجه البخاري [كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان....] رقم (٢١٦٢)، ومسلم [كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب] رقم (١٥١٩).

(١٥٧) يذكر هنا فروعاً تترتب على عدم توافر الشروط في تلقي الركبان وأثر ذلك في عدم التحريم وعدم الخيار، وتفصيل القول في ذلك كما بينه (رحمه الله).

(١٥٨) (وَالسَّوْمُ) (١٥٩) عَلَى سَوْمٍ غَيْرِهِ) قَالَ P: «لَا يَسَوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٦٠) وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، فَيَأْتِي مُرْتَكِبُهُ الْعَالَمُ بِهِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْإِيذَاءُ، (وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ) وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ لِمَنْ أَخَذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ بِكَذَا رُدَّهُ حَتَّى أُبَيْعَكَ خَيْرًا مِنْهُ بِهَذَا الثَّمَنِ أَوْ مِثْلَهُ بِأَقَلٍّ أَوْ يَقُولَ لِمَالِكِهِ اسْتَرِدَّهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِأَكْثَرٍ، وَلَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى صَحَّ وَاسْتِقْرَارُ الثَّمَنِ بِالتَّرَاضِي بِهِ صَرِيحًا (١٦١) فِي السُّكُوتِ وَغَيْرِ الصَّرِيحِ لَا يَحْرُمُ السَّوْمُ، وَقِيلَ يَحْرُمُ، وَمَا يُطَافُ بِهِ عَلَى مَنْ يَزِيدُ لِعَیْرِ مَنْ طَلَبَهُ الدُّخُولَ عَلَيْهِ وَالزِّيَادَةَ فِي الثَّمَنِ (١٦٢).

(١٦٣) (وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعٍ غَيْرِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ) بِانْقِضَاءِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ (بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُشْتَرِي بِالْفَسْخِ لِيَبِيعَهُ مِثْلَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ بِأَقَلٍّ مِنْ ثَمَنِهِ (وَالشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ) قَبْلَ لُزُومِهِ (بِأَنْ يَأْمُرَ الْبَائِعُ بِالْفَسْخِ لِيَشْتَرِيَهُ) بِأَكْثَرٍ قَالَ P: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١٦٤) زَادَ النَّسَائِيُّ «حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» (١٦٥)، وَفِي مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» (١٦٦)، وَالْمَعْنَى فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ الْإِيذَاءُ، وَهُوَ لِلْعَالَمِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَلَوْ أَذِنَ الْبَائِعُ فِي الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِهِ ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ، وَكَذَا الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ (١٦٧)، وَلَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى دُونَ إِذْنِ صَحَّ.

-
- (١٥٨) وشرع في بيان النوع الثالث من البيوع المنهي عنها، والنهي خارج عن حقيقة العقد "السوم على السوم"
- (١٥٩) سوم البائع معناه عرض السلعة وذكر ثمنها، وسوم المشتري طلب بيعها.
- (١٦٠) أخرجه البخاري [كتاب الشروط - باب الشروط في الطلاق] رقم (٢٧٢٧)، ومسلم [كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه] رقم (١٥١٥).
- (١٦١) هذه الصورة يتضح منها محل التحريم في هذا البيع، وأنه حاصل من سوم على المشتري أو السوم على البائع، فالنهي يشملهما.
- (١٦٢) لم يحرم هذا البيع؛ لأنه لم يستقر الثمن ولم يتراضيا عليه.
- (١٦٣) وشرع في بيان النوع الرابع والخامس من البيوع المنهي عنها، والنهي خارج عن حقيقة العقد "البيع على البيع والشراء على الشراء"
- (١٦٤) أخرجه البخاري [كتاب النكاح - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع] رقم (٥١٤٢)، ومسلم [كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه] رقم (١٤١٢).
- (١٦٥) أخرجه النسائي في الكبرى [كتاب البيوع - بيع الرجل على بيع أخيه] رقم (٦٠٥١).
- (١٦٦) أخرجه مسلم [كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك] رقم (١٤١٤).
- (١٦٧) لأن الحق لهما وقد أسقطاه، وهو مفهوم الحديث.

(^{١٦٨}) (وَالنَّجْشُ: بَأْنٌ يَزِيدُ فِي الثَّمَنِ) لِلسَّلْعَةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ (لَا لِرَغْبَةٍ) فِي شِرَائِهَا (بَلْ لِيُخَدَعَ غَيْرُهُ) فَيَشْتَرِيهَا، رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ P: «نَهَى عَنِ النَّجْشِ» (^{١٦٩})، وَالْمَعْنَى فِي تَحْرِيمِهِ الْإِيذَاءُ وَهُوَ لِلْعَالِمِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ فِي الْمُخْتَصَرِ. (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ) لِلْمُشْتَرِي؛ لِتَقْرِيطِهِ.

وَالثَّانِي: لَهُ الْخِيَارُ إِنْ كَانَ النَّجْشُ بِمُوَاطَأَةٍ مِنَ الْبَائِعِ؛ لِتَدْلِيلِهِ أَيْ لَا خِيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ الْوَطْأَةِ جَزْماً، وَلَا فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِيُخَدَعَ غَيْرُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّ يَزِيدَ عَمَّا تُسَاوِيهِ الْعَيْنُ.

(^{١٧٠}) (وَبَيْعُ الرُّطْبِ وَالْعَنْبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ) وَالنَّبِيذِ أَيْ مَا يُؤْوَلُهُ إِلَيْهِمَا، فَإِنْ تَوَهَّمَ اتِّخَاذُهُ إِيَّاهُمَا مِنْ الْمُبِيعِ فَالْبَيْعُ لَهُ مَكْرُوهٌ أَوْ تَحَقُّقُ فَحَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَجْهَانِ، قَالَ فِي الرُّوْضَةِ الْأَصَحِّ التَّحْرِيمُ وَالْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ، وَبِالنَّوْهِمِ الْحُصُولُ فِي الْوَهْمِ أَيْ الذَّهْنِ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَحُرْمَتُهُ أَوْ كِرَاهَتُهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِمَعْصِيَةٍ مُتَحَقِّقَةٍ أَوْ مُتَوَهَّمَةٍ (^{١٧١}).

(^{١٧٢}) (وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأُمِّ) الرَّقِيقَةِ (وَالْوَلَدِ) الرَّقِيقِ الصَّغِيرِ (حَتَّى يُمَيَّرَ) (^{١٧٣}) لِسَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ تَقْرِيباً (وَفِي قَوْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ) قَالَ P: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (^{١٧٤})، وَسَوَاءُ التَّفْرِيقُ بِالْبَيْعِ وَالْهَبَةِ وَالْقِسْمَةِ وَنَحْوِهَا. وَلَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ فِي الْعَنْقِ وَلَا فِي الْوَصِيَّةِ فَلَعَلَّ الْمَوْتَ يَكُونُ بَعْدَ

(١٦٨) وشرع في بيان النوع السادس من البيوع المنهي عنها، والنهي خارج عن حقيقة العقد "النجش".

(١٦٩) أخرجه البخاري [كتاب البيوع - باب النجش، ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»] رقم (٢١٤٢)، ومسلم [كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش ...] رقم (١٥١٦).

(١٧٠) النوع السابع من البيوع المنهي عنها، والنهي خارج عن حقيقة العقد (بيع الرطب والعنب لعاصر الخمر)، وهذا تطبيق عملي لما هو معلوم من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فبيع العنب في ذاته لا يحرم.

(١٧١) وخلاصة القول أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ومن هنا يختلف الحكم فتارة يكون حرام قطعاً إذا كان يتخذ منها خمراً بيقين، وهذا يفهم من كلامه، وأما إذا كان الظن قوياً وهو دون اليقين برتبة فالأصح التحريم كما في الروضة، ومقابله الكراهة، وإذا كان العلم باتخاذ العنب خمراً مبني على الوهم وهو أدنى من الظن فمكروه؛ لأن الحرمة لا تثبت إلا باليقين أو غالب الظن.

(١٧٢) هذا النوع من البيوع وهو (التفريق بين الأم وولدها) وما يليه (بيع العربون) النهي خارج عن حقيقة البيع شروطه وأركانها، ولكن العقد فيهما باطل، ونبه الشارح (رحمه الله) على ذلك في آخر الكلام عن بيع العربون.

(١٧٣) يفهم منه أن حرمة التفريق بين الأم وولدها من الأدمةين (الرقيق)، وأما البهائم فيجوز إن استغني عن اللبن، وهو المذهب.

(١٧٤) أخرجه الترمذي [أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع] رقم (١٢٨٣)، والحاكم في المستدرک [كتاب البيوع] رقم (٢٣٣٤).

انْقِصَاءِ زَمَانِ التَّخْرِيمِ، وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ رَقِيقَةً وَالْوَلَدُ حُرًّا أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا مَنَعَ مِنْ بَيْعِ الرَّقِيقِ مِنْهُمَا (وَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُ أَوْ هَبَهُ بَطْلًا فِي الْأُظْهَرِ)؛ لِعَجْزِ عَنِ التَّسْلِيمِ شَرْعًا بِالْمَنَعِ مِنَ التَّفْرِيقِ.

وَالثَّانِي: يَقُولُ الْمَنَعُ مِنَ التَّفْرِيقِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِضْرَارِ لَا لِخَلَلٍ فِي الْبَيْعِ.

وَلَوْ فَرَّقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ بَيْنَهُ أَوْ هَبَهُ صَحَّ قَطْعًا لَكِنْ يُكْرَهُ، وَقَوْلُهُ وَفِي قَوْلِ (١٧٥) مُوَافِقٍ لِمَا فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِي الْمُحَرَّرِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.

(١٧٦) (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَبِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ (بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لِيَتَكُونَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ وَالْأَقْبَحَ) بِالنَّصْبِ. رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ ر «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» (١٧٧) أَيْ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ لَعَنَ ثَالِثَةً وَعَدَمَ صِحَّتِهِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ الرَّدِّ وَالْهَبَةِ إِنْ لَمْ يَرْضَ السِّلْعَةَ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ هُنَا، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْمَنَاهِي الْأَوَّلِ وَقَدَّمَهُ فِي الرُّوضَةِ إِلَى مَحَلِّهِ، فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ هُنَا أَيْضًا وَتَقْدِيمُ مَسْأَلَةِ التَّفْرِيقِ لِلْبَطْلَانِ فِيهَا.

فَصَلَّ: بَاعَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (١٧٨) (حَلًّا وَخَمْرًا أَوْ عَبْدَهُ وَحُرًّا أَوْ عَبْدَهُ غَيْرَهُ أَوْ مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخِرِ) أَيْ الشَّرِيكَ (صَحَّ) الْبَيْعُ (فِي مِلْكِهِ) مِنَ الْخَلِّ وَالْعَبْدِ وَحِصَّتُهُ مِنَ الْمُشْتَرَكِ وَبَطَلَ فِي غَيْرِهِ (فِي الْأُظْهَرِ) إِعْطَاءً لِكُلِّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ (١٧٩)، وَالثَّانِي: يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ تَغْلِيْبًا لِلْحَرَامِ عَلَى الْحَلَالِ. قَالَ الرَّبِيعُ: وَإِلَيْهِ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ آخِرًا وَالْقَوْلَانِ بِالْأَصَالَةِ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَطَرْدًا فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ، وَالصِّحَّةُ فِي الْأَوَّلَى دُونَهَا فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَهَا فِي الثَّالِثَةِ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَهَا فِي الرَّابِعَةِ لِمَا سَيَأْتِي مِنَ التَّقْدِيرِ فِي الْأَوَّلَيْنِ مَعَ فَرْضِ تَغْيِيرِ الْخِلْقَةِ فِي الْأَوَّلَى وَلِمَا فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ عَبْدَ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْمُشْتَرَكِ فِي الرَّابِعَةِ (١٨٠)، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الشَّرِيكَ فِي الْبَيْعِ صَحَّ بَيْعُهُ جَزْمًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ مَالِكُ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ

(١٧٥) يعني وفي قول حتى يبلغ.

(١٧٦) وشرع في بيان النوع الأخير من البيوع المنهي عنها، والنهي خارج عن حقيقة العقد "بيع العربون".

(١٧٧) أخرجه أبو داود [كتاب البيوع باب في العربان] (٣٥٠٢).

(١٧٨) بمعنى أن العقد اشتمل على متعدد يختلف في أفرادها، وهو ثلاثة أنواع، بدأ بالنوع الأول منها، وهو ما اجتمع فيه جائز وممنوع، وذكر الأمثلة على ذلك.

(١٧٩) الأظهر بني على عدم تأثير الصفقة في الحكم، فصح بيع الخل؛ لأنه حلال، ولا أثر لكون الخمر معه في نفس العقد، وكذلك بطل بيع الخمر؛ لأنه حرام.

(١٨٠) أي الأمثلة الأربعة يختلف التعليل في الأوليين عن الثالث عن الرابع.

في الأظهر في شرح المذهب للجهل بما يخصُّ كلاً منهما عند العقد، والثاني يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر قيمتهما، وسكت في الروضة كأصلها عن الترجيح في ذلك.

(^{١٨١}) (فَيَتَحَيَّرُ الْمُشْتَرِي) بِنَاءً عَلَى الصِّحَّةِ (إِنْ جَهَلَ) كَوْنِ بَعْضِ الْمَبِيعِ خَمْراً أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا ذُكِرَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ لِنَبْعِضِ الصَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَخِيَارُهُ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ، فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيباً يَغْلُمُ عَيْبَهُ (^{١٨٢})، وَفِيمَا يُلْزِمُهُ الْخِلَافُ الْآتِي مِنَ الْحِصَّةِ أَوْ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَقَبْلَ يُلْزِمُهُ الْجَمِيعُ قَطْعاً؛ لِأَنَّهُ التَّرَمُّهُ عَالِماً بِأَنَّ بَعْضَ الْمَذْكُورِ لَا يَقْبَلُ الْعَقْدَ (^{١٨٣}).

(^{١٨٤}) (فَإِنْ أَجَارَ) الْبَيْعَ (فَبِحِصَّتِهِ) أَيِ الْمَمْلُوكِ لَهُ (مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ قِيمَتَيْهِمَا)، وَيُقَدَّرُ الْخَمْرُ خَلاً، وَقِيلَ: عَصِيراً، وَالْحُرُّ رَقِيقاً، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا ثَلَاثِمِائَةً وَالْمُسَمَّى مِائَةً وَخَمْسِينَ، وَقِيمَةُ الْمَمْلُوكِ مِائَةً فَحِصَّتُهُ مِنَ الْمُسَمَّى خَمْسُونَ (وَفِي قَوْلٍ: بِجَمِيعِهِ) وَكَأَنَّهُ بِالْإِجَارَةِ رَضِيَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَمْلُوكِ لِلْبَائِعِ (^{١٨٥}) (وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ) وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لَهُ إِلَّا الْحِصَّةُ [لِتَعْدِيدٍ] حَيْثُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَطَمَعَ فِي ثَمَنِهِ.

(^{١٨٦}) (وَلَوْ بَاعَ عَبْدِيهِ فَتَلَفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ) انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (^{١٨٧}) (وَلَمْ يَنْفَسَخْ فِي الْآخَرِ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ لَمْ يَقْبُضْهُ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: يَنْفَسَخُ فِيهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُخْرَجَيْنِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَعَبْدُ غَيْرِهِ مَعاً (بَلْ يَتَحَيَّرُ) الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ (فَإِنْ أَجَارَ فَبِالْحِصَّةِ) مِنَ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ قِيمَتَيْهِمَا (قَطْعاً) وَطَرَدَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُرُوزِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا: بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَضَعَفَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَا اقْتَرَنَ بِالْعَقْدِ وَبَيْنَ مَا حَدَثَ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ تَوَزُّعِ الثَّمَنِ فِيهِ عَلَيْهِمَا ابْتِدَاءً.

(١٨١) ثبوت الخيار للمشتري في تفريق الصفقة وعدم ووقت الخيار.

(١٨٢) بجامع الرضا في كل منهما المبني على العلم.

(١٨٣) قوله "وفيما يلزمه" إلى آخره مبني على إذا كان يعلم بحال المبيع

(١٨٤) كيفية توزيع الثمن على المبيع عند تعدد الصفقة إذا جمعت بين جائز وممنوع، وهي التقدير بالقيمة، فيحتسب ما كان ممنوعاً على أنه جائز تقديراً ويخصم من الثمن المسمى على الراجح.

(١٨٥) حكم خيار البائع في تعدد الصفقة التي جمعت بين جائز وممنوع.

(١٨٦) شرع في بيان النوع الثاني من تعدد الصفقة، وهو إذا جمع بين شيئين جائزين من جنس واحد (صفة المعقود عليه واحدة)، وذكر المثال على العبدین، ويقاس عليه ما يشابهه.

(١٨٧) انفسخ البيع في الجميع على المذهب؛ لفوات جزء من المعقود عليه فأشبهه فوات الجميع، وللجهل بالثمن.

(^{١٨٨}) (وَلَوْ جَمَعَ فِي صَفَقَةٍ مُخْتَلَفِي الْحُكْمِ كَالْإِجَارَةِ وَبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ (وَسَلَمَ) كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ عَبْدِي وَاجْزَيْتُكَ دَارِي سَنَةً بِكَذَا، وَكَقَوْلِهِ: آجِزْتُكَ دَارِي شَهْرًا وَبِعْتُكَ صَاعَ قَمْحٍ فِي ذِمَّتِي سَلَمًا بِكَذَا (صَحًّا فِي الْأَظْهَرِ وَيُوزَعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيَمَتَيْهِمَا) أَيْ قِيَمَةِ الْمُوجَّرِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْرَةُ وَقِيَمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الْمُسَلَّمِ فِيهِ.

وَالثَّانِي: يَبْطُلَانِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْرَضُ لِاخْتِلَافِ حُكْمَيْهِمَا بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ وَالْإِنْفِسَاخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا يَقْتَضِي فَسْخَ أَحَدِهِمَا فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّوْزِيعِ، وَيَلْزَمُ الْجَهْلُ عِنْدَ الْعَقْدِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْعَوَضِ، وَذَلِكَ مَحْذُورٌ (^{١٨٩}).

وَأُجِيبُ: بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ وَشِقْصٍ مِنْ دَارٍ صَفَقَةً وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي الشُّفْعَةِ وَاحْتِيجَ إِلَى التَّوْزِيعِ اللَّازِمِ لَهُ مَا ذَكَرَهُ (أَوْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ) كَقَوْلِهِ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَبِعْتُكَ عَبْدَهَا وَهِيَ فِي حِجْرِهِ (صَحَّ النِّكَاحُ، وَفِي الْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ أُظْهَرُ هُمَا: صِحَّتُهُمَا، وَيُوزَعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيَمَةِ الْمَبِيعِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ.

وَالثَّانِي: بَطْلَانُهُمَا وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ بِأَبْسَطِ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا.

(^{١٩٠}) (وَتَتَعَدَّدُ الصَّفَقَةُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَبِعْتُكَ ذَا بَكْذَا وَذَا بَكْذَا) فَيُقْبَلُ فِيهِمَا وَلَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ، (وَيَتَعَدَّدُ الْبَائِعُ) نَحْوُ بَعْتُكَ هَذَا بَكْذَا فَيُقْبَلُ مِنْهُمَا وَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ، (وَكَذَا يَتَعَدَّدُ الْمُشْتَرِي) نَحْوُ بَعْتُكُمَا هَذَا بَكْذَا فَيُقْبَلَانِ (فِي الْأَظْهَرِ) كَالْبَائِعِ.

وَالثَّانِي: لَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي بَانَ عَلَى الْإِيجَابِ السَّابِقِ، فَالْنَّظَرُ إِلَى مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْإِيجَابُ، وَلَوْ فِي أَحَدِ الْمُشْتَرَيْنِ نَصِيبُهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُسَلِّمَهُ قِسْطَهُ مِنَ الْمَبِيعِ كَمَا يُسَلِّمُ الْمُشَاعَ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يَجِبُ حَتَّى يُؤْفَى الْآخَرَ نَصِيبُهُ كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الْمُشْتَرِي لِثُبُوتِ

(١٨٨) شرع في بيان حكم النوع الثالث من تعدد الصفقة: إذا جمع بين مختلف الصفقة في عقد واحد.

(١٨٩) يقصد الجهل بالعوض، فاختلف شرط من شرط العقد وهو العلم بالمعقود عليه السلعة والثمن معاً، علماً ينتقي معه الجهالة.

(١٩٠) بعد ما انتهى من الكلام عن تعدد الصفقة دون تفصيل في العقد بالثمن على المعقود عليه، وذكر الخلاف فيه شرع في بيان تعدد الصفقة مع بيان ما يخص كل مبيع منها بالثمن، وهذا لا خلاف فيه للعلم وعدم الجهالة، وشرع في بيان جواز تعدد البائع وكذلك بتعدد المشتري أصالة أو نيابة، وبيان حكم كل.

حَقَّ الْحَبْسِ، (وَلَوْ وَكَلَاهُ) ^(١٩١) أَوْ وَكَلَهُمَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ) فِي اتِّحَادِ الصَّفَقَةِ وَتَعَدُّدِهَا؛ لِتَعَلُّقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ كَرُؤْيَا الْمُبِيعِ، وَتُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالثَّانِي اعْتِبَارُ الْمُوَكَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ لَهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ فِي أَكْثَرِ نُسخِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ: تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الْوَجِيزِ وَنُقِلَ فِي الشَّرْحَيْنِ تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ عَنِ الْأَكْثَرَيْنِ. ^(١٩٢) وَلَوْ خَرَجَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ وَكِيلٍ عَنْ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ وَكِيلَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ مَعِيْبًا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ رَدُّ نِصْفِهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَعَلَى الثَّانِي يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ. وَلَوْ خَرَجَ مَا اشْتَرَاهُ وَكِيلٌ عَنْ اثْنَيْنِ أَوْ وَكِيلَانِ عَنْ وَاحِدٍ مَعِيْبًا فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوَكَّلِ الْوَاحِدِ رَدُّ نِصْفِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُوَكَّلَيْنِ رَدُّ نِصْفِهِ. وَعَلَى الثَّانِي يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ هُوَ شَامِلٌ لِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَسِتَاتِي الثَّلَاثَةِ ^(١٩٣).

كتاب الرهن ^(١٩٤)

كتاب الرهن ^(١٩٥) (أركان الرهن)

يَتَحَقَّقُ بِعَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَصِيغَةً ^(١٩٦)، وَبَدَأَ بِهَا فَقَالَ: (لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ)، أَيْ بِشَرْطِهِمَا الْمُعْتَبَرِ فِي الْبَيْعِ، وَفِي الْمُعَاطَاةِ وَالِاسْتِجَابِ ^(١٩٧) مَعَ الْإِيجَابِ كَقَوْلِهِ: ارْهَنُ عِنْدِي، فَقَالَ: رَهْنْتُ عِنْدَكَ الْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ.

(١٩١) التعدد هنا في الوكالة، فو وكيل عن البائع، وهو نفسه وكيل عن المشتري، وهنا يتولى طرفي العقد بنفسه.

(١٩٢) رتب على تعدد العاقد صوراً، كما لو اشترى الوكيل من اثنين أو وكيلان عن واحد، وبين الحكم في الكل.

(١٩٣) هذا آخر ما علق عليه، والحمد لله رب العالمين.

(١٩٤) علق على هذا الجزء من الدراسة النصية (دكتور) علي منصور عثمان حبيب، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة).

(١٩٥) الرهن لغة: الثبوت، وشرعاً: جعل عين مال وثيقةً بدينٍ يُستوفى منها. والأصل فيه قبل الإجماع: من القرآن: قول الله تعالى: ﴿فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ومن السنة: "رَهْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ"، أخرجه البخاري في صحيحه ٢ / ٧٢٩، رقم: (١٩٦٣).

(١٩٦) هذه أركان الرهن، وهي ثلاثة إجمالاً: (عاقد، ومعقود عليه، وصيغة)، وستة تفصيلاً (راهن، ومرتهن، ومرهون، ومرهون به، وإيجاب، وقبول).

(١٩٧) المعاطاة: عدم التلفظ بالقبول والاكتفاء بالإعطاء، وصورة المعاطاة في الرهن (أن يقول له أقرضني لأعطيك ثوبي هذا رهناً، فيعطى العشرة ويقبضه الثوب)، والاستيجاب: عدم القبول باللفظ، كأن يقول

(الشروط المقتترنة بعقد الرهن)

(فَإِنْ شَرَطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُّمِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ) أَيِّ بِالْمُرْهُونِ عِنْدَ تَرَاحُمِ الْغَرَمَاءِ، (أَوْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَالْإِشْهَادِ) بِهِ (أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ) كَأَنْ لَا يَأْكُلَ الْعَبْدُ الْمُرْهُونُ إِلَّا كَذَا (صَحَّ الْعَقْدُ) وَلَغَا الشَّرْطُ الْأَخِيرُ، (وَإِنْ شَرَطَ مَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ) وَيَنْفَعُ الرَّاهِنَ كَأَنْ لَا يُبَاعَ عِنْدَ الْمَحَلِّ (بَطُلَ الرَّهْنُ) لِإِخْلَافِ الشَّرْطِ بِالْغَرَضِ مِنْهُ (وَإِنْ نَفَعَ) الشَّرْطُ (الْمُرْتَهِنَ وَضَرَ الرَّاهِنَ) كَشَرَطِ مَنْفَعَتِهِ) أَيِّ الْمُرْهُونِ أَوْ زَوَائِدِهِ (لِلْمُرْتَهِنِ بَطُلَ الشَّرْطُ)^(١٩٨)، وَكَذَا الرَّهْنُ فِي الْأَظْهَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ، وَالثَّانِي: يَقُولُ الرَّهْنُ تَبَرُّعٌ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ، (وَلَوْ شَرَطَ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ) كَثَمَارِ الشَّجَرِ وَنَتَاجِ الشِّيَاهِ (مَرْهُونَةً) فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ، لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ مَعْدُومَةٌ، وَالثَّانِي يَتَسَمَّحُ فِي ذَلِكَ، (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ مَتَى فَسَدَ) الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ (فَسَدَ الْعَقْدُ) يَعْنِي أَنَّهُ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ لِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ.

(شروط أركان الرهن)

(وَشَرَطُ الْعَاقِدِ) مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ (كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ)، فَلَا يَرَهُنُ الْوَلِيُّ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَلَا يَرْتَهِنُ لَهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ^(١٩٩) فَيَجُوزُ لَهُ الرَّهْنُ وَالْإِزْتِهَانُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا، سَوَاءً كَانَ أَبَا أَمْ جَدًّا أَمْ وَصِيًّا أَمْ حَاكِمًا أَمْ أَمِينَةً، مِثَالُهُمَا لِلضَّرُورَةِ: أَنْ يَرَهُنَ عَلَى مَا يُفْتَرَضُ لِحَاجَةِ النِّقَقَةِ أَوْ الْكِسْفَةِ لِيُوقِيَ مَا يَنْتَظَرُ مِنْ حُلُولِ دَيْنٍ أَوْ نِفَاقِ مَتَاعٍ كَاسِدٍ^(٢٠٠)، وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَى مَا يُفْرَضُ أَوْ يَبِيعُهُ مُوجِبًا لِضَرُورَةِ نَهْبٍ، وَمِثَالُهُمَا لِلْغِبْطَةِ أَنْ يَرَهُنَ مَا يُسَاوِي مِائَةً عَلَى ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ نَسِيئَةً وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ، وَأَنْ يَرَهُنَ عَلَى ثَمَنِ مَا يَبِيعُهُ نَسِيئَةً بِغِبْطَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَجْرِ.

(وَشَرَطُ الرَّهْنِ) أَيِّ الْمُرْهُونِ (كَوْنُهُ عَيْنًا)^(٢٠١) (فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ رَهْنُهُ تَنْزِيلًا لَهُ مِنْزِلَةَ الْعَيْنِ، وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ، كَأَنْ يَرَهُنَ سُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَتَلَفُ، فَلَا يَحْصُلُ بِهَا اسْتِثْنَاءٌ.

(حكم رهن المشاع)(٢٠٢)

-
- المرتتهن للراهن (ارهن بيتك عندي)، فيقول له الراهن (رهنت بيتي عندك) ولا يقول المرتتهن بعده (قبلت)، وفي صحة الرهن بالمعاطاة والاستيجاب وجهان: أحدهما يصح، والثاني لا يصح.
- (١٩٨) بطل الشرط: لحديث: "كُلُّ شَرَطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ"، (متفق عليه).
- (١٩٩) غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ: أي مصلحة واضحة للصبي أو المجنون.
- (٢٠٠) المتاع الكاسد: الذي لا يرغب أحد في شرائه.
- (٢٠١) العين: المال الحاضر، كالبيت، والذهب، والسيارة.
- (٢٠٢) المشاع: المال المشترك.

(وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمَشَاعِ) مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ، وَيُقْبَضُ بِتَسْلِيمِ كُلِّهِ، قَالَ فِي الرُّوضَةِ: فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ خَلَّى الرَّاهُنُ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَبَيْنَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُنْقَلُ لَمْ يَحْصُلْ قَبْضُهُ إِلَّا بِالنَّقْلِ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ، فَإِنْ أَذِنَ قَبْضُ، وَإِنْ امْتَنَعَ، فَإِنْ رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ، وَإِنْ تَنَازَعَا^(٢٠٣) نَصَبَ الْحَاكِمُ غَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا.

(رهن الأمة وولدها)

(و) يَصِحُّ رَهْنُ (الْأُمِّ) مِنَ الْإِمَاءِ (دُونَ وَلَدِهَا) الصَّغِيرِ، (وَعَكْسُهُ) أَيَّ رَهْنُهُ دُونَهَا (وَعِنْدَ الْحَاجَةِ) إِلَى تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ (يُبَاعَانِ) مَعًا حَذَرًا مِنَ التَّقْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ (وَيُوزَعُ الثَّمَنُ) عَلَيْهِمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ (وَالْأَصَحُّ) أَيَّ فِي صُورَةِ رَهْنِ الْأُمِّ (أَنْ) تَقُومَ الْأُمُّ وَحْدَهَا ثُمَّ مَعَ الْوَلَدِ فَالزَّائِدُ عَلَى قِيَمَتِهَا (قِيَمَتُهُ) وَالثَّانِي: يَقُومُ الْوَلَدُ وَحْدَهُ أَيْضًا وَتُجْمَعُ الْقِيَمَتَانِ ثُمَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ تُنْسَبُ قِيَمَةُ الْأُمِّ إِلَى الْمَجْمُوعِ وَيُوزَعُ الثَّمَنُ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَإِذَا قِيلَ قِيَمَةُ الْأُمِّ مِائَةٌ دِرْهَمٍ، وَقِيَمَتُهَا مَعَ الْوَلَدِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَوْ قِيَمَةُ الْوَلَدِ خَمْسُونَ، فَالنِّسْبَةُ بِالْأَثْلَاثِ، فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِثُلثِي الثَّمَنِ وَإِذَا قِيلَ قِيَمَتُهُمَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، أَوْ قِيَمَةُ الْوَلَدِ عِشْرُونَ، فَالنِّسْبَةُ بِالْأَسَدَاسِ، فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِخَمْسَةِ أَسَدَاسِ الثَّمَنِ وَيُقَاسَ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُهُ صُورَةُ رَهْنِ الْوَلَدِ فَيَقَالُ: يَقُومُ وَحْدَهُ ثُمَّ مَعَ الْأُمِّ أَوْ تَقُومُ الْأُمُّ وَحْدَهَا أَيْضًا وَتُجْمَعُ الْقِيَمَتَانِ، ثُمَّ تُنْسَبُ قِيَمَةُ الْوَلَدِ إِلَى الْمَجْمُوعِ، وَيُوزَعُ الثَّمَنُ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَفِي الْمَثَالِ الْمَذْكُورِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِثُلْثِ الثَّمَنِ أَوْ بِسُدُسِهِ.

(حكم رهن الجاني والمرتد والمدبر)

(وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرْتَدِّ كَبَيْعِهِمَا) وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالًا، بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ فِي الْأَطْهَرِ فِيهِمَا^(٢٠٤)، وَبَيْعُ الْمُرْتَدِّ يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَتَقَدَّمَ مَا هُوَ مُفَرَّغٌ عَلَيْهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَعَلَى الصَّحَّةِ فِي الْجَانِي الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ بِالرَّهْنِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، عَلَى خِلَافِ الْأَصَحِّ فِي الْبَيْعِ الْمُتَقَدِّمِ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجَنَايَةِ بَاقٍ فِي الرَّهْنِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.

(٢٠٣) أي تنازع المرتهن والشريك في كون المال المرهون في يد أحدهما، فالمرتهن يريد أن يكون المال المرهون في يده ليضمن حقه، والشريك يرفض ذلك، لأنه لا علاقة له بالرهن.

(٢٠٤) أي الأظهر أن الجاني المتعلق برقبته مال لا يصح رهنه، كما لو قتل خطأ أو شبه عمد ووجبت عليه الدية، فإذا رهن هذا الجاني مالا له لا يصح رهنه، لأنه ربما يحتاج إلى هذا المال في دفع الدية، أما الجاني المتعلق برقبته قصاص، كما لو قتل عمدا ووجب عليه القصاص، فالأظهر أنه إذا رهن ماله صح الرهن، لأنه لا يجب عليه مال يمنع الرهن من استحقاقه.

(وَرَهْنُ الْمُدَبَّرِ) (٢٠٥) أَيُّ الْمُعْلَقِ حُرَيْتُهُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ (وَمُعْلَقُ الْعَتَقِ بِصِفَةِ يُمَكِّنُ سَبْقَهَا حُلُولَ الدَّيْنِ بَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الرِّقِّ. وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ فِي كُلِّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَلَا تَتَقَيَّدُ الْأُولَى بِكَوْنِ الدَّيْنِ مُؤَجَّلًا كَمَا أَطْلَقُوهَا، فَإِنَّهَا لَا تَسْلَمُ مَعَ كَوْنِهِ حَالًا مِنَ الْغَرَرِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَجَاءَ وَلَوْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ الدَّيْنُ حَالًا أَوْ يَتَيَقَّنُ حُلُولَهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ صَحَّ الرَّهْنُ جَزْمًا، وَلَوْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الصِّفَةِ قَبْلَ الْحُلُولِ بَطَلَ الرَّهْنُ جَزْمًا.

(رهن ما يسرع إليه الفساد من الطعام)

(وَلَوْ رَهَنَ مَا يَسْرَعُ فَسَادُهُ فَإِنْ أَمَكْنَ تَجْفِيفُهُ كَرُطِبٍ) وَعَنْبٍ (فَعَلَن) وَصَحَّ الرَّهْنُ، وَقَاعِلُهُ الْمَالِكُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُؤَنَّتُهُ، قَالَهُ ابْنُ الرَّفْعَةِ، (وَالْأَلَا) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يُمَكَّنْ تَجْفِيفُهُ (فَإِنْ رَهْنَهُ بِدَيْنٍ حَالٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ، أَوْ) بَعْدَ فَسَادِهِ، لَكِنْ (شَرَطَ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (بِنِعْيَةٍ) عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْفَسَادِ، (وَجَعَلَ الثَّمَنَ رَهْنًا صَحَّ) الرَّهْنُ فِي الصُّورِ الثَّلَاثِ (٢٠٦)، (وَيُبَاعُ) الْمَرْهُونُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ وَجُوبًا (عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا) كَمَا شَرَطَ، وَيُبَاعُ أَيْضًا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا.

(وَإِنْ شَرَطَ مَنَعَ بِنِعْيَةٍ) (٢٠٧) قَبْلَ الْحُلُولِ (لَمْ يَصِحَّ) الرَّهْنُ لِمُنَافَاةِ الشَّرْطِ لِمَقْصُودِ التَّوْثِيقِ (٢٠٨)، (وَإِنْ أَطْلَقَ) فَلَمْ يَشْرُطْ الْبَيْعَ وَلَا عَدَمَهُ (فَسَدَ) الرَّهْنُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، وَالْبَيْعُ قَبْلَهُ لَيْسَ مِنْ مُقَنْصَيَاتِ الرَّهْنِ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيُبَاعُ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ إِفْسَادَ مَالِهِ، وَفِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَمَالَ مَنْ سِوَاهُمْ إِلَى الثَّانِي، وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الرَّافِعِيَّ رَجَّحَ فِي الْمَحَرَّرِ الْأَوَّلَ.

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) (٢٠٩) هَلْ يَفْسُدُ الْمَرْهُونُ (قَبْلَ) حُلُولِ (الْأَجَلِ صَحَّ) الرَّهْنُ الْمُطْلَقِ (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فَسَادِهِ إِلَى الْحُلُولِ، وَالثَّانِي: يَجْعَلُ جَهْلَ الْفَسَادِ كَعِلْمِهِ. (وَإِنْ رَهَنَ مَا لَا يَسْرَعُ فَسَادُهُ فَطَرًا مَا عَرَضَهُ لِلْفَسَادِ) قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ (كَحِطَّةٍ ابْتَلَثَ) وَتَعَدَّرَ تَجْفِيفُهَا (لَمْ

(٢٠٥) المدبّر: هو العبد المعلق عتقه بموت سيده، كما لو قال السيد لعبده: (إذا مت فأنت حر).

(٢٠٦) الصور الثلاث: ١- رهن الطعام بدین حال، ٢- رهن الطعام بدین مؤجل ويحل الأجل قبل فساد الطعام،

٣- رهن الطعام بدین مؤجل، ويحل أجل الدين بعد فساد الطعام.

(٢٠٧) أي الطعام.

(٢٠٨) لأن المقصود من الرهن ضمان المرتهن لدينه بحيث إذا لم يردده الراهن يبيع المرتهن المال المرهون

ليستوفي دينه، وشرط منع البيع ينافي كل ذلك، فلا يصح.

(٢٠٩) أي الراهن.

يُنْفَسَخُ الرَّهْنُ بِحَالٍ)، وَلَوْ طَرَأَ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَرْهُونِ فَفِي انْفِسَاخِ الرَّهْنِ وَجْهَانِ، أَرْجَحُهُمَا فِي الرُّوْضَةِ: أَنَّهُ لَا يَنْفَسَخُ، وَإِذَا لَمْ يَنْفَسَخْ فِي الصُّورَتَيْنِ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ، وَفِي الرُّوْضَةِ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى بَيْعِهِ حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ.

(حكم رهن العارية)

(وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ) بِدَيْنِهِ، (وَهُوَ) أَيُّ عَقْدٍ الاسْتِعَارَةِ بَعْدَ الرَّهْنِ (فِي قَوْلِ عَارِيَةٍ) أَيُّ بَاقٍ عَلَيْهَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا مِنْ جِهَةِ الْمُعِيرِ إِلَى ضَمَانِ الدَّيْنِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ إِنْ كَانَ يُبَاعُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي، (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ ضَمَانُ دَيْنٍ فِي رَقَبَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَيُشْتَرَطُ) عَلَى هَذَا^(٢١٠) (ذَكَرَ جِنْسَ الدَّيْنِ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ)، وَمِنْهَا الْخُلُولُ وَالتَّاجِيلُ، (وَكَذَا الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ فِي الْأَصَحِّ)، لِاخْتِلَافِ الْأَعْرَاضِ بِذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ وَاحِدٌ مِمَّا ذَكَرَ^(٢١١) عَلَى قَوْلِ الْعَارِيَةِ، وَإِذَا عَيَّنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَجْزِ مُخَالَفَتُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَرهَنَ بِمَا دُونَهُ جَازَ قَالَ فِي الرُّوْضَةِ، وَإِذَا قُلْنَا عَارِيَةً فَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِأَيِّ جِنْسٍ شَاءَ وَبِالْحَالِ وَالْمَوْجَلِ، قَالَ فِي النَّتْمَةِ: لَكِنْ لَا يَرْهَنُهُ بِأَكْثَرٍ مِنْ قِيَمَتِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا فَإِنَّهُ لَا يُمَكِّنُهُ فَكُّهُ إِلَّا بِقَضَاءِ جَمِيعِ الدَّيْنِ.

(تلف المال المرهون)

(فَلَوْ تَلَفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ) عَلَى الرَّاهِنِ لَمْ يَسْقُطِ الْحَقُّ عَنْ ذِمَّتِهِ^(٢١٢). وَعَلَى قَوْلِ الْعَارِيَةِ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِحَالٍ، (وَلَا رُجُوعَ لِلْمَالِكِ)^(٢١٣) بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ، وَعَلَى قَوْلِ الْعَارِيَةِ لَهُ الرُّجُوعُ فِي وَجْهِهِ، وَالْأَصَحُّ لَا رُجُوعَ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الرَّهْنِ مَعْنَى، وَلَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، (فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ أَوْ كَانَ حَالًا رُوجِعَ الْمَالِكُ لِلْبَيْعِ، وَيُبَاعُ إِنْ لَمْ يَقْضِ الدَّيْنُ) مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمَالِكِ، أَيُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ عَلَى قَوْلِ الْعَارِيَةِ يَتَوَقَّفُ الْبَيْعُ عَلَى الْإِذْنِ، (ثُمَّ يَرْجَعُ الْمَالِكُ) عَلَى الرَّاهِنِ (بِمَا بَيْعَ بِهِ) عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ، سَوَاءً بَيْعَ بِقِيَمَتِهِ أَمْ بِأَكْثَرٍ أَمْ بِأَقَلٍّ، بِقَدْرِ يَتَغَابُنُ النَّاسَ بِمِثْلِهِ^(٢١٤)، وَعَلَى قَوْلِ الْعَارِيَةِ يَرْجَعُ بِقِيَمَتِهِ إِنْ بَيْعَ بِهَا أَوْ بِأَقَلٍّ وَكَذَا بِأَكْثَرٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، لِأَنَّ الْعَارِيَةَ بِهَا تَضْمَنُ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَجَمَاعَةٌ رَجَعَ وَبَيْعَ بِهِ، لِأَنَّهُ ثَمَنٌ مِلْكِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا أَحْسَنُ، زَادَ فِي الرُّوْضَةِ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ.

(٢١٠) أي: على أن العارية بعد الرهن تحولت من عارية إلى ضمان دين .

(٢١١) أي: ذكر جنس الدين وقدره وصفته.

(٢١٢) أي: لو تلف المال المرهون في يد المرتهن فلا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة، ولا ضمان على الراهن أيضا، لأنه لم يسقط الدين عن ذمته.

(٢١٣) أي: مالك المال المعار الذي رهنه المستعير .

(٢١٤) ما يتغابن الناس بمثله، يقصد به الزيادة اليسيرة أو النقص اليسير في ثمن الشيء، والذي جرت العادة أن يرضى به البائع والمشتري .

(شروط المرهون به)

(فَصْلٌ: شَرْطُ الْمَرْهُونِ بِهِ) (٢١٥) لِيَصِحَّ الرَّهْنُ (كَوْنُهُ دَيْنًا ثَابِتًا لَازِمًا، فَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ (بِالْعَيْنِ الْمَغْضُوبَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ) وَالْمَأْخُودَةِ بِالسُّومِ (٢١٦) (فِي الْأَصَحِّ)، لِأَنَّهَا لَا تُسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِ الْمَرْهُونِ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِعَرَضِ الرَّهْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَالثَّانِي: لَا يَلْتَزِمُ هَذَا الْعَرَضُ، وَقَاسَ الرَّهْنُ بِهَا عَلَى ضَمَانِهَا لِتَرَدِّ، بِجَامِعِ التَّوَثُّقِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَأَنَّ ضَمَانَهَا لَا يَجُزُّ لَوْ لَمْ تَتَلَفْ إِلَى ضَرَرٍ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهَا فَيَجُزُّ إِلَى ضَرَرٍ دَوَامِ الْحَجْرِ فِي الْمَرْهُونِ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ خَرَجَتْ عَنْ الصِّحَّةِ بِقَوْلِهِ دَيْنًا، (وَلَا) يَصِحُّ الرَّهْنُ (بِمَا سَيَقْرُضُهُ) وَلَا بِثَمَنِ مَا يَشْتَرِيهِ، لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ حَقٌّ، فَلَا يَفْدُمُ عَلَى الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ، وَعَنْ ذَلِكَ الدَّخَلِ فِي الدَّيْنِ بِيَجُوزُ اخْتِرَارُ بِقَوْلِهِ ثَابِتًا، (وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضْتُكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَارْتَهَنْتُ بِهَا عَبْدَكَ، فَقَالَ: اقْتَرَضْتُ وَرَهَنْتُ، أَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِكَذَا أَوْ ارْتَهَنْتُ النَّوْبَ بِهِ، فَقَالَ اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ لِتَقْدُمِ أَحَدِ شِقَيْهِ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ، وَالْأَوَّلُ اغْتَفَرَ ذَلِكَ لِحَاجَةِ الْوَثِيقَةِ.

(وَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ (بِجُورِ الْكِتَابَةِ) (٢١٧) لِأَنَّ الرَّهْنَ لِلتَّوَثُّقِ وَالْمَكَاتِبِ بِسَبِيلٍ مِنْ إِسْقَاطِ النُّجُومِ مَتَى شَاءَ فَلَا مَعْنَى لِتَوْثِيقِهَا، (وَلَا يَجْعَلُ الْجَعَالَةَ قَبْلَ الْفَرَاغِ) مِنَ الْعَمَلِ وَإِنْ شَرَعَ فِيهِ، لِأَنَّ لَهُمَا فُسْخَهَا فَيَسْقُطُ بِهِ الْجُعْلُ، وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلُ بِفُسْخِهِ وَحَدَهُ أَجْرَهُ مِثْلَ الْعَمَلِ وَعَنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ اخْتِرَارُ بِقَوْلِهِ لَازِمًا (٢١٨)، (وَقِيلَ يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ) فِي الْعَمَلِ لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ فِيهِ إِلَى اللُّزُومِ، وَيَصِحُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ قَطْعًا لِلزُّومِ الْجُعْلِ بِهِ.

(وَيَجُوزُ) الرَّهْنُ (بِالْتَّمَنِ فِي مَدَّةِ الْخِيَارِ) لِأَنَّهُ آيَلٌ إِلَى اللُّزُومِ، وَالْأَصْلُ فِي وَضْعِهِ اللُّزُومُ، بِخِلَافِ جُعْلِ الْجَعَالَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ حَيْثُ قُلْنَا مَلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِمَلَكَ الْبَائِعِ التَّمَنُّ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ فِي التَّمَنِ مَا لَمْ تَمُضِ مَدَّةُ الْخِيَارِ، وَدَخَلَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي قَوْلِهِ لَازِمًا بِيَجُوزُ، وَلَا فَرْقَ فِي اللَّازِمِ الْمُسْتَقَرِّ كَدَيْنِ الْقَرْضِ وَتَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُقْبُوضِ، وَغَيْرِ الْمُسْتَقَرِّ كَتَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَالْأَجْرَةُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ الْمُنْفَعَةِ، وَيَصِحُّ الرَّهْنُ

(٢١٥) المرهون به: هو الدين الذي أخذه الراهن من المرتهن، ومن أجله تم الرهن.

(٢١٦) المأخوذ بالسوم: هو السلعة التي اشتراها شخص بعد اتفاق شخص آخر مع صاحب السلعة على شرائها، بأن زاد الشخص الثاني في الثمن ليغري بذلك البائع، وهو منهى عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سوم المسلم على سوم أخيه.

(٢١٧) نجوم الكتابة: هي الأقساط التي يدفعها العبد المكاتب لسيده حتى ينال حريته، كما لو قال السيد لعبده: (إذا دفعت لي ألفا كل شهر لمدة سنة فأنت حر).

(٢١٨) أي من شروط المرهون به أن يكون دينا لازما، أي لا يمكن الرجوع فيه، وعلى ذلك لا يصح الرهن بأقساط الكتابة على العبد وكذلك الجعل الذي يستحقه العامل في الجعالة قبل الشروع في العمل، لأن العبد والجاعل يجوز لهما الرجوع.

بِالْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَيُبَاغُ الْمَرْهُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَتَحْصُلُ الْمَنْفَعَةُ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَا يَصِحُّ بِالْمَنْفَعَةِ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ^(٢١٩).

(تَنْبِيْهٌ): سَكَتَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ مَعْلُومًا مَعَ ذِكْرِهِمْ اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْمَضْمُونِ مَعْلُومًا فِي الْجَدِيدِ كَمَا سَيَأْتِي، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ، وَفِي الْكِفَايَةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لَهُمَا، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِسْتِصَاءِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَفِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ عَبْدِانَ وَفِي الْمُعِينِ لِأَبِي خَلْفٍ الطَّبْرِيِّ

(و) يَجُوزُ (بِالدَّيْنِ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ)، وَهُوَ كَمَا لَوْ رَهْنُهُمَا بِهِ مَعًا (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرَهْنَهُ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ فِي الْجَدِيدِ)، وَيَجُوزُ فِي الْقَدِيمِ بَزِيَادَةِ الرَّهْنِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَيَانَ الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ شَغْلُ فَارِغٍ وَفِي الدَّيْنِ شَغْلُ مَشْغُولٍ، وَقَوْلُهُ الْمَرْهُونَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ ثَانٍ.

(لزوم الرهن بالقبض)

(وَلَا يَلْزَمُ) الرَّهْنُ (إِلَّا بِقَبْضِهِ) أَيُّ الْمَرْهُونِ كَانَتْ (مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ) أَيُّ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ الرَّهْنِ يَصِحُّ مِنْهُ الْقَبْضُ، (وَتَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ) كَالْعَقْدِ (لَكِنْ لَا يَسْتَنْبِطُ رَاهِنًا)، لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْقَبْضِ^(٢٢٠)، وَلَا (عِنْدَهُ)^(٢٢١) لِأَنَّ يَدَهُ كَيْدُهُ، وَيُصَدَّقُ بِالْمَادُونِ لَهُ وَالْمُدَبِّرِ، وَمِثْلُهُ أُمُّ الْوَلَدِ، (وَفِي الْمَادُونِ لَهُ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ لِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ وَالنَّصْرِفِ، وَدُفِعَ بِأَنَّ السَّيِّدَ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، (وَيَسْتَنْبِطُ مَكَاتِبَهُ) لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ وَالنَّصْرِفِ كَالْأَجَنْبِيِّ، وَصَفَةُ الْقَبْضِ هُنَا فِي الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

(وَلَوْ رَهْنٌ وَدِيعَةٌ عِنْدَ مُودِعٍ أَوْ مَغْضُوبًا عِنْدَ غَاصِبٍ لَمْ يَلْزَمْ) هَذَا الرَّهْنُ (مَا لَمْ يَمُضِ زَمَنٌ إِمَّا كَانَ قَبْضُهُ) أَيُّ الْمَرْهُونِ (وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ إِذْنِهِ) أَيُّ الرَّاهِنِ (فِي قَبْضِهِ) لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ، وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ، وَالتَّانِي: يَقُولُ الْعَقْدُ مَعَ ذِي الْيَدِ يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ فِي الْقَبْضِ، (وَلَا يُبْرئُهُ اِرْتِهَانُهُ عَنِ الْغُصْبِ) وَإِنْ لَزِمَ، (وَيُبْرئُهُ الْإِيْدَاعُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ ائْتِمَانٌ يُنَافِي الضَّمَانَ، وَالْإِرْتِهَانُ تَوَثُّقٌ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ، فَإِنَّهُ لَوْ تَعَدَّى فِيهِ الْمَرْهُونُ صَارَ

(٢١٩) خلاصة هذه المسألة: أنه يجوز الرهن بضمن المبيع على أن ثمن المبيع هو الدين، حتى لو كان البيع لم يلزم الآن لكونه في زمن الخيار، ولا يعد ذلك مخالفا لاشتراط المصنف أن يكون المرهون به ديناً ثابتاً لازماً، وذلك لأن البيع في زمن الخيار في طريقه إلى اللزوم بانتهاء مدة الخيار.

(٢٢٠) يقصد أن عقد الرهن لا يصير عقداً لازماً إلا إذا قبض المرتهن المال المرهون، سواء قبضه بنفسه، أو وكل من يقبضه نيابة عنه، لكن لا يجوز للمرتهن أن يوكل الراهن في قبض الرهن، حتى لا يكون الراهن قابلاً وموجباً في وقت واحد.

(٢٢١) أي عبد الراهن.

ضَامِنًا مَعَ بَقَاءِ الرَّهْنِ بِحَالِهِ، وَلَوْ تَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ ارْتَفَعَ كَوْنُهَا وَدِيعَةً، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ قَاسِ
الْإِيْدَاعِ عَلَى الْإِرْتِهَانِ^(٢٢٢).

(الرجوع عن الرهن قبل القبض)

(وَيَحْصُلُ الرَّجُوعُ عَنِ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِتَصَرُّفٍ يُزِيلُ الْمَلِكَ، كَهَبَةِ مَقْبُوضَةٍ) وَإِعْتَاقِ
وَبَيْعِ (وَبِرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَكِتَابَةٍ، وَكَذَا تَدْبِيرُهُ فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّ التَّدْبِيرَ تَغْلِيْقُ عِثْقِ
بِصِفَةٍ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لَا يَحْصُلُ الرَّجُوعُ بِهِ، (وَبِإِحْبَالِهَا)^(٢٢٣) لَا الْوُطْءِ مِنْ غَيْرِ
إِحْبَالٍ، (وَالْتَرْوِيجِ) إِذْ لَا تَعْلُقُ لَهُ بِمُورِدِ الرَّهْنِ، بَلْ رَهْنُ الْمُرُوجَةِ ابْتِدَاءً جَائِزٌ.

(بطلان الهبة بالموت أو الجنون)

(وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ (قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ جُنَّ أَوْ تَحَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ
الْعَبْدُ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الثَّلَاثِ أَيْضًا (لَمْ يَبْطُلِ الرَّهْنُ فِي الْأَصَحِّ)، أَمَّا بُطْلَانُهُ بِالمَوْتِ
وَالْجُنُونِ فَلِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ فَيَرْتَفِعُ بِهِمَا كَالْوَكَالَةِ، وَأَجَابَ الْآخَرُ بِأَنَّ مَصِيرَهُ إِلَى اللُّزُومِ فَلَا يَرْتَفِعُ
بِهِمَا كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَعَلَى هَذَا تَقُومُ وَرَثَةُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مَقَامَهُمَا فِي الْإِقْبَاضِ
وَالْقَبْضِ، وَيَفْعَلُهُمَا مَنْ يَنْظُرُ فِي مَالِ الْمَجْنُونِ بِرِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ لَهُ، وَأَمَّا بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِالتَّحَمُّرِ
فَلِخُرُوجِ الْمَرْهُونِ عَنِ الْمَالِيَّةِ، وَالنَّافِي لِلْبُطْلَانِ يَقُولُ ارْتَفَعَ حُكْمُ الرَّهْنِ بِالتَّحَمُّرِ وَبِإِنْقِلَابِ الْحَمْرِ
خَلًّا يَعُودُ الرَّهْنُ، وَإِبَاقُ الْعَبْدِ مُلْحَقٌ بِالتَّحَمُّرِ لِأَنَّهُ انْتَهَى إِلَى حَالَةٍ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ، وَمَسْأَلَةُ
الْمَوْتِ نَصٌّ فِيهَا فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِمَوْتِ الْمُرْتَهِنِ، وَنَقَلَ نَصٌّ آخَرُ أَنَّهُ يَبْطُلُ
بِمَوْتِ الرَّاهِنِ، وَخَرَجَ مِنْ كُلِّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلٌ إِلَى الْآخَرَى، وَقَرَّرَ بَعْضُهُمُ النَّصَّ فِيهِمَا وَقَطَعَ
بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا، وَالتَّخْرِيجُ أَصَحُّ، فَإِنْ قُلْنَا لَا يَبْطُلُ بِالمَوْتِ فَالْجُنُونُ أَوْلَى، أَوْ يَبْطُلُ
بِهِ فِي الْجُنُونِ وَجْهَانِ، وَالْإِغْمَاءُ كَالْجُنُونِ، وَلَوْ تَحَمَّرَ الْعَصِيرُ بَعْدَ الْقَبْضِ بَطُلَ الرَّهْنُ بِمَعْنَى

(٢٢٢) معنى هذه المسألة: أن الراهن إذا كان له وديعة عند شخص أو مالا مغصوبا بيد الغاصب، فيجوز له أن
يحول هذه الوديعة إلى رهن عند المودع والمال المغصوب إلى رهن عند الغاصب بدين يأخذه منهما، لكن لا
يلزم الرهن في هاتين الحالتين حتى يقبض المودع والغاصب الوديعة والمال المغصوب على أساس كونهما
رهنًا، ويشترط أن يأذن الراهن صاحب المال بهذا القبض، والغاصب لا تبرأ ذمته بتحويل المال المغصوب
إلى مرهون في يده لأن الغاصب معتدي ولا تبرأ ذمته إلا برد المغصوب لصاحبه، وتبرأ ذمة المودع بتحويل
الوديعة إلى رهن، لأن يده على الوديعة يد أمانة.

(٢٢٣) أي الأمة.

ارْتَفَعَ حُكْمُهُ، فَإِنْ عَادَ خَلَا عَادَ الرَّهْنُ، وَلَا بُطْلَانٌ قَطْعًا فِي الْمَوْتِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْإِبَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ^(٢٢٤).

(تصرف الراهن في المال المرهون بعد الرهن)

(وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُقْبِضِ تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمَلَكَ) كَالْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ^(٢٢٥)، (لَكِنَّ فِي إِعْتَاقِهِ أَقْوَالًا، أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ بِالْمُعْجَمَةِ (مِنْ الْمُؤَسِّرِ وَيَغْرُمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عِتْقِهِ) وَتَكُونُ (رَهْنًا) مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، قَالَهُ الْإِمَامُ، وَلَا يَنْفُذُ مِنَ الْمُعْسِرِ، وَالثَّانِي: يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَيَغْرُمُ الْمُعْسِرُ إِذَا أَيْسَرَ الْقِيَمَةَ وَتَكُونُ رَهْنًا، وَالثَّلَاثُ: لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا، (وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ فَأَنْفَكَ) الرَّهْنُ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَمْ يَنْفُذْ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يَنْفُذُ لِرَوَالِ الْمَانِعِ، (وَلَوْ عَقَّه) أَيَّ عَلَّقَ عِتْقَ الْمَرْهُونِ (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ، وَهُوَ رَهْنٌ فَكَالْإِعْتَاقِ) فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنَ الْمُؤَسِّرِ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ، (أَوْ) وَجِدَتْ (بَعْدَهُ) أَيَّ بَعْدَ فَكَاكِ الرَّهْنِ (نَفَذَ) الْعِتْقُ (عَلَى الصَّحِيحِ)، وَالثَّانِي: يَقُولُ التَّغْلِيْقُ بَاطِلٌ كَالْتَنْجِيزِ فِي قَوْلِ (وَلَا رَهْنُهُ لغيرِهِ) أَيَّ غَيْرِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ، (وَلَا التَّرْوِيجِ)^(٢٢٦) فَإِنَّهُ يُنْقَضُ الْمَرْهُونُ وَيَقْلَلُ الرَّغْبَةُ فِيهِ، قَالَ فِي الرُّوْضَةِ فَلَوْ خَالَفَ فَرَوَّجَ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ الْمَرْهُونَيْنِ فَالْنِّكَاحُ بَاطِلٌ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ.

(وَلَا الْإِجَارَةُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا أَوْ يَحِلُّ قَبْلَهَا)^(٢٢٧) أَيَّ قَبْلَ مُدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَقْلَلُ الرَّغْبَةَ فَتَبْطُلُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ بَعْدَ مُدَّتِهَا أَوْ مَعَ قَرَاغِهَا، فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ، وَتَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ مُطْلَقًا، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ، (وَلَا الْوَطْءُ)^(٢٢٨) لِحَوْفِ الْحَبْلِ فِيمَنْ تَحَبَّلُ، وَحَسْمًا لِلْبَابِ فِي غَيْرِهَا (فَإِنْ وَطِئَ) فَأَحْبَلَ (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) نَسِيبٌ^(٢٢٩)، وَلَا قِيَمَةٌ عَلَيْهِ وَلَا حَدٌّ وَلَا مَهْرٌ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ

(٢٢٤) الأصح في المذهب أن الرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن، وتنتقل المعاملة بعد موتهما لورثتهما، فيحل ورثة الراهن محل الراهن في وجوب سداد الدين، ويحل ورثة المرتهن محل المرتهن في الاستحواذ على المال المرهون لحين سداد الدين.

(٢٢٥) الراهن إذا رهن ماله بدين، فلا يجوز له بعد الرهن أن يتصرف في المال المرهون بما يزيل ملكه عنه، لأن ذلك يخالف مقصود الرهن، وهو أن يستوفى الدين من المال المرهون إذا لم يلتزم الراهن بالسداد، لكن تصرف الراهن في المرهون بالعتق إذا كان المرهون عبداً، فهو محل خلاف.

(٢٢٦) لا يجوز للسيد إذا رهن عبداً أو أمة أن يزوجهما أثناء الرهن، لأنه ممنوع من التصرف في المرهون بما يزيل الملك أو يقلل الرغبة في المملوك، وزواج العبد والأمة يقلل الرغبة فيهما، فإن زوجهما السيد فالزواج باطل.

(٢٢٧) أي لا يجوز كذلك لمالك العين المرهونة إجارتها أثناء الرهن إذا كان الدين حالاً، أو مؤجلاً لكن يحل أجله قبل انتهاء مدة الإجارة، إلا إذا المستأجر هو المرتهن، فتصح الإجارة قطعاً، لأن العين المؤجرة تحت يده بالرهن والإجارة.

(٢٢٨) أي لا يجوز للسيد أن يطأ الأمة المرهونة، لأنه ربما تحمل، وإذا حملت صارت أم ولد، وأم الولد لا تباع ولا توهب، وتعتق بموت سيدها.

(٢٢٩) أي ينسب ولد الأمة المرهونة التي وطئها لأبيه.

الْبَكَارَةِ^(٢٣٠) إِنْ افْتَضَّهَا، فَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ رَهْنًا، وَإِنْ شَاءَ قَصَّاهُ مِنَ الدَّيْنِ (وَفِي نُفُودِ
الِاسْتِيلَادِ^(٢٣١)) أَقْوَالُ الْإِعْتَاقِ أَظْهَرُهَا نُفُودُهُ مِنَ الْمَوْسِرِ، فَيَلْزِمُهُ قِيمَتُهَا وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهَا، فَإِنْ
لَمْ يَنْفُذْ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ وَلَا تَبَاعُ حَامِلًا لِخَرِيَّةِ حَمْلِهَا (فَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ فَأَنْفَكَ) الرَّهْنُ مِنْ غَيْرِ
بَيْعٍ (نَفَذَ) الْإِسْتِيلَادُ، (فِي الْأَصَحِّ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ قَوْلٌ يَفْتَضِي الْعِتْقَ فِي
الْحَالِ، فَإِذَا رُدَّ لَعَا وَالِاسْتِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رُدُّهُ وَإِنَّمَا يُمنَعُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِ لِحَقِّ الْغَيْرِ، فَإِذَا زَالَ
حَقُّ الْغَيْرِ ثَبَتَ حُكْمُهُ، (فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ) وَالنَّقْرِيعُ عَلَى عَدَمِ التَّنْفِيزِ (غَرِمَ قِيمَتُهَا)
وَتَكُونُ (رَهْنًا) مَكَانَهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي هَلَاكِهَا بِالْإِحْبَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، وَالثَّانِي:
لَا يَغْرَمُ وَإِضَافَةُ الْهَلَاكِ إِلَى عِلَلٍ تَفْتَضِي شِدَّةَ الطَّلْقِ أَقْرَبُ مِنْ إِضَافَتِهِ إِلَى الْوُطْءِ.

(انتفاع المرتهن والراهن بالمرهون)

(وَلَهُ كُلُّ انْتِفَاعٍ لَا يُنْقِصُهُ) أَيُّ الْمَرْهُونِ (كَالرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى) وَفِي ذَلِكَ حَدِيثُ
الْبَخَارِيِّ: {الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا}^(٢٣٢)، (لَا الْبَنَاءُ وَالْغِرَاسُ) فَإِنَّهُمَا يُنْقِصَانِ قِيَمَةَ
الْأَرْضِ (فَإِنْ فَعَلَ) ذَلِكَ (لَمْ يُفْلَعْ قَبْلَ) حُلُولِ (الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ يُفْلَعْ إِنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ) أَيُّ
قِيمَتِهَا (بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ) أَيُّ بِالْقَلْعِ (ثُمَّ إِنْ أَمَكَنَ الْإِنْتِفَاعُ) بِالْمَرْهُونِ (بِغَيْرِ اسْتِزْدَادٍ لَمْ
يُسْتَرَدَّ) كَأَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ حِرْفَةً يَعْمَلُهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يُسْتَرَدُّ لِعَمَلِهَا وَيُسْتَرَدُّ
لِلْخِدْمَةِ (وَالْأَيُّ) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ بِغَيْرِ اسْتِزْدَادٍ (فَيُسْتَرَدُّ) كَأَنْ تَكُونَ دَارًا فَتُسْكَنَ أَوْ دَابَّةً
فَتُرْكَبَ وَيُرَدَّهَا وَعَبْدُ الْخِدْمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ لَيْلًا، (وَيُشْهِدُ) الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِالِاسْتِزْدَادِ لِلْإِنْتِفَاعِ
شَاهِدَيْنِ (إِنْ اتَّهَمَهُ) فَإِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِشْهَادِ (وَلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ مَا مَنَعَاهُ) مِنْ
التَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ فَيَحِلُّ الْوُطْءُ، فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ، وَإِنْ أَحْبَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ نَفَذَتْ
وَبَطَلَ الرَّهْنُ^(٢٣٣).

(وَلَهُ) أَيُّ لِلْمُرْتَهِنِ (الرُّجُوعُ) عَنِ الْإِذْنِ (قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ، فَإِنْ تَصَرَّفَ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ
فَكَتَصَرَّفَ وَكَيْلٍ جَهْلٍ عَزَلَهُ) مِنْ مُوَكَّلِهِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي الْأَصَحِّ (وَلَوْ أَدْنِ فِي بَيْعِهِ لِيَجْعَلَ
الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيُّ لِهَذَا الْغَرَضِ بِأَنْ شَرَطَهُ كَمَا فِي الْمَحَرَّرِ وَغَيْرِهِ (لَمْ يَصِحَّ

(٢٣٠) أُرِشَ الْبَكَارَةُ: أَيُّ الْفَرْقُ بَيْنَ قِيَمَةِ الْأَمَةِ بَكْرًا، وَقِيمَتِهَا بَعْدَ أَنْ صَارَتْ ثِيَابًا بَوَاطِنًا.

(٢٣١) الْإِسْتِيلَادُ: وَطْءُ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ طَلْبًا لِلْوَلَدِ مِنْهَا.

(٢٣٢) رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ٢ / ٨٨٨، رَقْمٌ: (٢٣٧٧).

(٢٣٣) يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِأَمَالِ الْمَرْهُونِ بِمَا لَا يَنْقُصُ قِيَمَتَهُ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُونِ أَثْنَاءَ
مُدَّةِ الرَّهْنِ، إِذَا كَانَ الْمَرْهُونُ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِرْدَادُهُ، مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوْ السَّيَّارَةِ، حَيْثُ يُمْكِنُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا نَهَارًا
بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَيُرَدُّهَا لَهُ لَيْلًا، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى أَخْذِ الرَّاهِنِ لِلْمَرْهُونِ وَرَدِّهِ إِذَا خَافَ أَحَدُهُمَا إِنْكَارَ الْآخَرِ،
فَإِذَا تَوَفَّرَتِ الثَّقَةُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ مَنَعَ مِنْهُ الرَّاهِنُ بِحُكْمِ عَقْدِ الرَّهْنِ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ
بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَيَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ عَنِ الْإِذْنِ الَّذِي مَنَحَهُ لِلرَّاهِنِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ.

الْبَيْعِ) لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ^(٢٣٤)، (وَكَذًا لَوْ شَرَطَ) فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ (رَهْنُ الثَّمَنِ) مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذَكَرَ، وَفَسَادُ الشَّرْطِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ^(٢٣٥)، وَالثَّانِي: يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الرَّاهِنَ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ فِي الْبَدَلِ، فَكَمَا انْتَقَلَ الرَّهْنُ إِلَيْهِ فِي الْإِتْلَافِ شَرْعًا، جَازَ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِ شَرْطًا، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا أَمْ مُؤَجَّلًا.

(المرهون يبقى في يد المرتهن أو في يد عدل)

(فَصْلٌ: إِذَا لَزِمَ الرَّهْنُ فَالْيَدُ فِيهِ) أَيُّ الْمَرْهُونِ (لِلْمُرْتَهِنِ، وَلَا تُزَالُ إِلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ) ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ لَيْلًا كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ يَعْمَلُ لَيْلًا كَالْحَارِسِ رُدَّ إِلَيْهِ نَهَارًا، وَقَدْ لَا تَكُونُ الْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا فِي رَهْنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ كَافِرٍ، وَالْجَارِيَةِ الْحَسَنَاءِ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ بِالصِّفَةِ الْآتِيَةِ، فَيَصِحُّ الرَّهْنُ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ، وَيُجْعَلُ الْعَبْدُ فِي يَدِ عَدْلٍ، وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَقَّةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ زَوْجَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ أَوْ نِسْوَةٌ يُؤْمَنُ مَعَهُنَّ الْإِلْمَامُ بِالْمَرْهُونَةِ.

(وَلَوْ شَرَطًا) أَيُّ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (وَضَعَهُ) أَيُّ الْمَرْهُونِ (عِنْدَ عَدْلٍ جَازٍ)، وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي يَدِ ثَالِثٍ، وَهُوَ صَادِقٌ بَعِيرٍ عَدْلٍ، وَسَيَأْتِي عَنْهُمَا^(٢٣٦) مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْوَضْعِ عِنْدَهُ (أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ وَنَصًّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظِهِ أَوْ الْإِنْفِرَادِ بِهِ) أَيُّ أَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا الْإِنْفِرَادَ بِحِفْظِهِ (فَذَلِكَ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَتَّبَعُ الشَّرْطَ فِيهِ، (وَإِنْ أَطْلَقَا)^(٢٣٧) فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْإِنْفِرَادُ بِحِفْظِهِ (فِي الْأَصَحِّ)، فَيَجْعَلَانِهِ فِي حِزْزٍ^(٢٣٨) لَهُمَا كَمَا فِي النَّصِّ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا، وَالثَّانِي: يَجُوزُ الْإِنْفِرَادُ لِمَشَقَّةِ الْاجْتِمَاعِ، وَعَلَى هَذَا إِنْ اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِهِ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَذَلِكَ، وَإِنْ تَنَازَعَا وَهُوَ مِمَّا يَنْقَسِمُ قُسَمَ وَحَفِظَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمِ حِفْظُهُ هَذِهِ مُدَّةً وَهَذَا مُدَّةً، (وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ) الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ (أَوْ فَسَقَ جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ) أَيُّ عِنْدَ عَدْلٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ،

(٢٣٤) فساد الشرط سببه أن الدين الذي أخذه الراهن من المرتهن دين مؤجل، وقد اتفقا على ذلك، وإذن المرتهن للراهن ببيع المرهون بشرط أن يسدد الدين من ثمن بيع المرهون إخلال بما اتفقا عليه من تأجيل الدين، ولذلك لا يصح بيع المرهون لأنه مرتبط بشرط فاسد وهو تعجيل الدين المؤجل، ولا يصح البيع كذلك إذا كان شرط المرتهن على الراهن رهن الثمن، لفساد الشرط.

(٢٣٥) لا يصح البيع إذا شرط المرتهن على الراهن رهن الثمن، لفساد الشرط، وسبب فساد الشرط هنا جهالة الثمن، لأن المرتهن لا يعلم بكم يبيع الراهن المال المرهون، ومن شروط المرهون أن يكون معلوما عينا وقدرًا وصفة.

(٢٣٦) أي عن الروضة وأصلها، وأصل الروضة هو كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي، حيث إن كتاب روضة الطالبين للإمام النووي اختصار لكتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي.

(٢٣٧) أي وضع الراهن والمرتهن المرهون عند عدلين، ولم يشترط حفظهما للمرهون معا أو أحدهما منفردا.

(٢٣٨) الحرز: المكان المخصص لحفظ المال.

(وَإِنْ تَشَاحَا) (٢٣٩) فِيهِ (وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ) يَرَاهُ وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ كَانَ الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ فَاسِقًا فِي الْإِبْتِدَاءِ فَرَادَ فِسْقُهُ نُقِلَ إِلَى آخِرٍ يَتَّقَانِ عَلَيْهِ.

(بيع المرهون لاستيفاء الدين)

(وَيَسْتَحَقُّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ) بَأْنِ حَلِّ الدَّيْنِ وَلَمْ يُوفِ (وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهَنُ بِثَمَنِهِ) عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ (وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهَنِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ: تَأْذُنْ أَوْ ثَبْرِي) هُوَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ انْذَنْ فِي بَيْعِهِ أَوْ أَثْبَرْتُهُ. كَمَا فِي الرُّوْضَةِ وَأَصْلُهَا (وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْتَهَنُ بَيْعَهُ فَأَبَى الرَّاهِنُ أَلَزَمَهُ الْقَاضِي قَضَاءَ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعَهُ، فَإِنْ أَصَرَ بِاعَهُ الْحَاكِمُ) وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ (وَلَوْ بَاعَهُ الْمُرْتَهَنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ فَأَلْصَحُّ أَنَّهُ إِنْ بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ) الْبَيْعُ (وَالْأَوَّلُ) يَصِحُّ بَيْعُهُ، لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِعَرَضِ نَفْسِهِ فَيُتَّهَمُ فِي الْإِسْتِعْجَالِ وَتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْغَيْبَةِ دُونَ الْحُضُورِ (٢٤٠)، وَالثَّانِي: يَصِحُّ مُطْلَقًا (٢٤١) كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ مَالٍ آخَرَ، وَالثَّلَاثُ: لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِيهِ تَوَكُّلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ، وَلَوْ قَالَ: بَعُهُ بِكَذَا انْتَفَتِ التَّهْمَةُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى غَيْرِ الثَّلَاثِ، وَلَوْ قَالَ: بَعُهُ وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ مِنْ ثَمَنِهِ، جَاءَتْ التَّهْمَةُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى غَيْرِ الثَّلَاثِي، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُوجِبًا، وَقَالَ: بَعُهُ صَحَّ الْبَيْعُ جَزْمًا (وَلَوْ شَرِطَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ) عِنْدَ الْمَحَلِّ (جَازَ) هَذَا الشَّرْطُ (وَلَا تُشْتَرِطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ) فِي الْبَيْعِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْإِذْنِ وَالثَّانِي يُشْتَرِطُ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا الْمُرْتَهَنُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ يُشْتَرِطُ مُرَاجَعَتُهُ قَطْعًا فَرَبَّمَا أَمَهَلْ أَوْ أَثْبَرًا وَقَالَ الْإِمَامُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُرَاجَعُ لِأَنَّ غَرَضَهُ تَوْفِيَةَ الْحَقِّ، وَلَوْ عَزَلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ قَبْلَ الْبَيْعِ انْعَزَلَ وَلَوْ عَزَلَهُ الْمُرْتَهَنُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَقِيلَ يَنْعَزِلُ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لَهَا وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ لَمْ يَبِعْ (فَإِذَا بَاعَ) الْعَدْلُ وَقَبِضَ الثَّمَنَ (فَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهَنُ) وَهُوَ أَمِينٌ فِيهِ، فَإِنْ ادَّعَى تَلْفَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ بِبَيْعِهِ أَوْ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُرْتَهَنِ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِبَيْعِهِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ حَقَّهُ مِنَ الرَّاهِنِ وَرَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ.

(وَلَوْ تَلَفَ ثَمَنُهُ) (٢٤٢) فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ الْمَبِيعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ)، فَيَرْجِعُ الْعَدْلُ الْغَارِمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَأَمَرَ الْحَاكِمُ الْعَدْلَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ وَتَلَفَ الثَّمَنُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي مَالِ الرَّاهِنِ، وَلَا يَكُونُ

(٢٣٩) تشاحا: أي اختلف الراهن والمرتهن في من يحفظ عنده المال المرهون.

(٢٤٠) أي لا يجوز للمرتهن بيع المرهون في غيبة الراهن، ويصح بيعه في حضوره، لأنه إذا باعه في غيبته ربما يبيعه بأقل من ثمنه، أو يبيعه قبل حلول أجل الدين.

(٢٤١) أي يجوز للمرتهن بيع المرهون في غيبة الراهن وحضوره.

(٢٤٢) أي ثمن المرهون الذي تم بيعه.

الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَضْمَنُ، وَقِيلَ يَكُونُ طَرِيقًا^(٢٤٣) كَالْوَكِيلِ، وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلُ الْمَرْهُونَ (إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًا مِنْ نَقْدٍ بَلَدِهِ) كَالْوَكِيلِ، فَإِنْ أَخْلَى بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ^(٢٤٤) لَمْ يَصَحَّ الْبَيْعُ، وَالْمُرَادُ بِالنَّقْصِ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ النَّقْصُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ، فَالنَّقْصُ بِمَا يَتَغَابَنُونَ بِهِ لَا يَضُرُّ لِتَسَامُحِهِمْ فِيهِ (فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ انْقِصَاءِ الْخِيَارِ فَلْيُفَسَخْ وَلْيَبْعُهُ) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ انْفَسَخَ فِي الْأَصَحِّ، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ كَالشَّرْطِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ لِيُعْمَ خِيَارِي الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِيهَا: وَلَوْ زَادَ الرَّاعِبُ^(٢٤٥) بَعْدَ انْقِصَاءِ الْخِيَارِ فَلَا أَثَرَ لِلزِّيَادَةِ.

(تكلفة حفظ المرهون على الراهن)

(وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ) الَّتِي بَهَا يَبْقَى كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ وَكِسْوَتِهِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ، وَفِي مَعْنَاهَا سَقْيُ الْأَشْجَارِ وَجِدَادُ الشِّمَارِ وَتَجْفِيفُهَا وَرَدُّ الْأَبْقِ^(٢٤٦)، وَأُجْرَةُ مَكَانِ الْحِفْظِ (عَلَى الرَّاهِنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ)، وَالثَّانِي: لَا يُجْبَرُ عِنْدَ الْإِمْتِنَاعِ، وَلَكِنْ يَبِيعُ الْقَاضِي جُزْءًا مِنْهُ فِيهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ (وَلَا يُنْعَى الرَّاهِنُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ كَقَضْدِ وَحِجَامَةِ) وَمُعَالَجَةِ بِالْأَدْوِيَةِ وَالْمَرَاهِمِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا.

(يد المرتهن على المرهون يد أمانة)

(وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ) لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ إِلَّا إِذَا تَعَدَّى فِيهِ أَوْ ائْتَمَعَ مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ، (وَلَا يَنْسَقُطُ بِتَلْفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ) كَمَوْتِ الْكَفِيلِ بِجَامِعِ التَّوَثُّقِ^(٢٤٧) (وَحُكْمُ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ) وَعَدَمُهُ، فَالْمَقْبُوضُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ، وَبِهَيْبَةٍ فَاسِدَةٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ^(٢٤٨)، (وَلَوْ شَرِطَ^(٢٤٩)) كَوْنُ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ فَسَدَا) أَيْ الرَّهْنُ وَالْبَيْعُ لِتَأْقِيتِ الرَّهْنِ وَتَعْلِيقِ الْبَيْعِ، (وَهُوَ) أَيْ الْمَرْهُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (قَبْلَ الْمَحَلِّ) بِكُسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتُ الْحُلُولِ (أَمَانَةٌ) وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ، (وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلْفِ بِبَيِّنَةٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكَرَ سَبَبُ التَّلْفِ، فَإِنْ ذَكَرَهُ فَقَبِيهِ النَّقْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ

(٢٤٣) أي إذا تلف الثمن يرجع المشتري على العدل الذي قام ببيع المرهون، ثم يرجع العدل على الراهن.

(٢٤٤) أي البيع بثمان المثل، حالا غير مؤجل، ومن نقد البلد، فهذه شروط ثلاثة.

(٢٤٥) أي الراغب في شراء المرهون.

(٢٤٦) أي تكلفة رد العبد الهارب إذا احتاج رده لتكلفة.

(٢٤٧) أي لا ينقص شيء من الدين إذا تلف المرهون، قياسا على موت الكفيل، فإنه موته لا يؤثر في الدين

الذي كان كافلا له، بجامع أن الرهن والكفالة واحد في أن القصد منهما توثيق الديون وضمانها.

(٢٤٨) لأن الأصل في البيع الضمان، والأصل في الهبة عدم الضمان.

(٢٤٩) أي المرتهن.

مِنْ الرُّوْضَةِ (وَلَا يُصَدَّقُ فِي) دَعَا (الرَّدِّ) إِلَى الرَّاهِنِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) وَقَالَ غَيْرُهُمْ: يُصَدَّقُ بِبَيْمِينِهِ.

(وَلَوْ وَطِئَ الْمُزْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ) مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ (بِلَا شُبْهَةٍ فَرَانِ) ^(٢٥٠) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَيَجِبُ الْمَهْرُ إِنْ أَكْرَهَهَا بِخِلَافِ الْمُطَاوَعَةِ ^(٢٥١)، (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهْلْتُ تَحْرِيمَهُ) أَيْ الْوُطْءَ (إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ إِسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ) فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْحَدِّ وَيَجِبُ الْمَهْرُ، وَقَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ أُحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إِذَا ظَنَّنَهَا رَوْجَتَهُ أَوْ أَمْتَهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ الْمَهْرُ، وَقَوْلُهُ: فَرَانِ، أَيْ فَهُوَ زَانٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ جَوَابُ لَوْ بِمَعْنَى أَنَّ مُجَرَّدَةَ عَنْ زَمَانٍ، وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ أَوَّلَ النَّبَابِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ (وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قَبْلَ دَعْوَاهُ جَهْلُ التَّحْرِيمِ) مُطْلَقًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى، وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ وَعَلَى الْقَبُولِ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ (وَيَجِبُ الْمَهْرُ إِنْ أَكْرَهَهَا) وَفِي قَوْلِ حَكَاهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَجْهًا لَا يَجِبُ لِإِذْنِ مُسْتَحِقِّهِ ^(٢٥٢)، وَدُفِعَ بَأَنَّ وَجُوبَهُ حَقُّ الشَّرْعِ فَلَا يُؤْثِرُ فِيهِ الْإِذْنُ، كَمَا أَنَّ الْمُفَوَّضَةَ ^(٢٥٣) تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ بِالدُّخُولِ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ جَزْمًا (وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ) وَكَذَا حُكْمُهُ فِي صُورَتَيْ انْتِقَاءِ الْحَدِّ السَّابِقَتَيْنِ.

(وَلَوْ أَتْلَفَ) ^(٢٥٤) الْمَرْهُونَ وَقَبِضَ بَدْلَهُ صَارَ رَهْنًا) مَكَانَهُ، وَجُعِلَ فِي يَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ مِنَ الْمُزْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ، وَقَبْلَ قَبْضِهِ قِيلَ: لَا يَحْكُمُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ لِأَنَّهُ دَيْنٌ، وَقِيلَ يَحْكُمُ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ رَهْنُ الدَّيْنِ ابْتِدَاءً، قَالَ فِي الرُّوْضَةِ: الثَّانِي أَرْجَحُ، وَبِالْأَوَّلِ قَطَعَ الْمَرَاوِزَةُ ^(٢٥٥)، (وَالْخَصْمُ فِي الْبَدْلِ الرَّاهِنُ، فَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ) فِيهِ (لَمْ يُخَاصِمِ الْمُزْتَهِنُ فِي الْأَصَحِّ) وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ، وَإِذَا خَاصَمَ الرَّاهِنُ فَلِلْمُزْتَهِنِ حُضُورُ خُصُومَتِهِ لِيَتَعَلَّقَ حَقُّهُ بِالْمَأْخُودِ، (فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ) فِي الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ كَالْعَبْدِ (اِفْتَصَّ الرَّاهِنُ) أَيْ لَهُ ذَلِكَ (وَفَاتِ الرَّهْنُ) لِقَوَاتِ مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ (فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ) عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ (أَوْ بِجَنَائَةٍ خَطِئَ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ) لِحَقِّ الْمُزْتَهِنِ.

(٢٥٠) أي حكمه حكم الزاني في وجوب الحد والمهر.

(٢٥١) أي إذا طاوَعته الأمة في الزنا وجب عليه الحد دون المهر.

(٢٥٢) أي إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الأمة لا يجب المهر؛ لأن الراهن هو سيد الأمة وهو من يستحق

المهر، وهذا وجه ضعيف لأن المهر حق الشرع.

(٢٥٣) المفوضة: المرأة إذا قالت لوليها زوجني بلا مهر.

(٢٥٤) أي المرتهن.

(٢٥٥) أي فقهاء الشافعية في بلدة مرو.

(وَلَا يَصِحُّ لَهُ^(٢٥٦)) (إِبْرَاءُ الْمُرْتَهَنِ الْجَانِي) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ، وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنْ
الْوَثِيقَةِ فِي الْأَصَحِّ.

(حُكْمُ زِيَادَاتِ الْمَرْهُونِ)

(وَلَا يَسْرِي الرِّهْنُ إِلَى زِيَادَتِهِ) أَيُّ الْمَرْهُونِ (الْمُنْفَصِلَةَ كَثْمَرٍ وَوَلَدٍ) وَبَيْضٍ^(٢٥٧)، بِخِلَافِ
الْمُتَّصِلَةَ كَسِمَنِ الْعَبْدِ وَكَبَرِ الشَّجَرَةِ فَيَسْرِي الرِّهْنُ إِلَيْهَا (فَلَوْ رَهَنَ حَامِلًا وَحَلَّ الْأَجَلَ وَهِيَ حَامِلٌ
بِيعَتْ) كَذَلِكَ، لِأَنَّا إِن قُلْنَا: إِنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَكَانَتْ رَهْنَهُمَا، وَإِلَّا فَقَدْ رَهْنَهَا، وَالْحَمْلُ مَحْضٌ
صِفَةٍ (وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَيْعٌ مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَهُوَ رَهْنٌ، وَالثَّانِي: لَا يُبَاعُ
مَعَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ، فَهُوَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ (فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ
الرَّهْنِ فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ
مُتَعَذِّرٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا حَامِلًا وَتَوَزُّعِ الثَّمَنِ عَلَى الْأُمِّ وَالْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيَمَتُهُ،
وَالثَّانِي: يَقُولُ تَبَاعُ حَامِلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ، فَهُوَ كَزِيَادَةِ مُتَّصِلَةٍ.

(أَحْكَامُ جَنَايَةِ الْمَرْهُونِ)

(فَصْلٌ: إِذَا جَنَى الْمَرْهُونُ) عَلَى أَجَنْبِيٍّ بِالْقَتْلِ (قَدَّمَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ)^(٢٥٨)؛ لِأَنَّ حَقَّهُ
مُتَعَيِّنٌ فِي الرِّقْبَةِ بِخِلَافِ حَقِّ الْمُرْتَهَنِ لَتَعْلُقِهِ بِالذِّمَّةِ وَالرِّقْبَةِ، (فَإِنْ اقْتَصَصَ) وَارِثُ الْمَجْنِي عَلَيْهِ (أَوْ
بَيْعَ) الْمَرْهُونُ (لَهُ) أَيُّ لِحَقِّهِ، بِأَنْ أُوجِبَتْ الْجَنَايَةُ مَالًا، أَوْ عَقَا عَلَى مَالٍ (بَطَلَ الرِّهْنُ)، فَلَوْ عَادَ
الْمَبِيعُ إِلَى مَلِكِ الرَّاهِنِ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا، (وَإِنْ جَنَى) الْمَرْهُونُ (عَلَى سَيِّدِهِ) بِالْقَتْلِ (فَاقْتَصَصَ) بِضَمِّ
التَّاءِ مِنْهُ (بَطَلَ) الرِّهْنُ، (وَإِنْ عَقَا عَلَى مَالٍ) أَوْ كَانَتْ الْجَنَايَةُ خَطَأً (لَمْ يَثْبُتْ عَلَى
الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ (فَيَبْقَى رَهْنًا) كَمَا كَانَ، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ الْمَالُ
وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى فَكِّ الرِّهْنِ، وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ، وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ
بِالْأَصَحِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَنَايَةَ عَلَى السَّيِّدِ أَوْ الْأَجَنْبِيِّ بغيرِ الْقَتْلِ لَا تُبْطِلُ الرِّهْنَ.

(وَإِنْ قَتَلَ) الْمَرْهُونُ (مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرٍ فَاقْتَصَصَ) السَّيِّدُ (بَطَلَ الرِّهْنَانِ) جَمِيعًا، (وَإِنْ
وَجَبَ مَالٌ) بِأَنْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ عَمَى عَلَى مَالٍ (تَعْلَقَ بِهِ عَنْ مُرْتَهَنِ الْقَتِيلِ)، وَالْمَالُ مُتَعَلِّقٌ بِرِقْبَةِ
الْقَاتِلِ، (فَيُبَاعُ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ وَقِيلَ يَصِيرُ) نَفْسُهُ (رَهْنًا) وَدُفِعَ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهَنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي
عَيْنِهِ، وَعَلَى الثَّانِي: يَنْتَقِلُ إِلَى يَدِهِ، هَذَا إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيَمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ مِثْلَهَا، فَإِنْ كَانَ
أَقَلَّ مِنْهَا بَيْعَ مِنَ الْقَاتِلِ جُزْءٌ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا، أَوْ صَارَ الْجُزْءُ رَهْنًا عَلَى الْخِلَافِ،
وَمَحَلُّهُ^(٢٥٩) إِذَا طَلَبَ مُرْتَهَنُ الْقَتِيلِ الْبَيْعَ وَأَبَى الرَّاهِنُ، وَفِي الْعَكْسِ يُبَاعُ جُزْمًا، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى

(٢٥٦) أي الراهن.

(٢٥٧) أي لا تصير هذه الزيادات المنفصلة مرهونة مع الأصل.

(٢٥٨) أي قدم حق المجني عليه على حق المرتهن.

(٢٥٩) أي محل الخلاف.

عَدَمِ الْبَيْعِ، قَالَ الْإِمَامُ: لَيْسَ لِمُرْتَبِعِ الْقَاتِلِ طَلَبُ الْبَيْعِ، أَيْ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَشَارَ الرَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ لِتَوَقُّعِ رَاغِبٍ بِالزِّيَادَةِ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الرُّوْضَةِ، (فَإِنْ كَانَا) أَيْ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ (مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ بَدَيْنٍ وَاحِدٍ نَقَصَتْ الْوَثِيقَةُ) وَلَا جَابِرٌ (٢٦٠)، (أَوْ بَدَيْنَيْنِ) وَوَجَبَ الْمَالُ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ، (وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ) بِهِ إِلَى دَيْنِ الْقَتِيلِ (غَرَضٌ) أَيْ فَائِدَةٌ (نُقِلَتْ) بِأَنْ يُبَاعَ الْقَاتِلُ وَيُقَامَ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَقَامَ الْقَتِيلِ أَوْ يُقَامَ نَفْسُهُ مَقَامَهُ رَهْنًا عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ فِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ لَمْ تُنْقَلْ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًا وَالْآخَرُ مُوَجَّلًا لِلْمُرْتَبِعِ التَّوَقُّعُ الْقَاتِلِ لِدَيْنِ الْقَتِيلِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْحَالُّ فَالْفَائِدَةُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ثَمَنِ الْقَاتِلِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمُوَجَّلِ فَقَدْ تَوَقَّعَ وَيُطَالِبُ بِالْحَالِ، وَإِنْ اتَّقَى الدَّيْنَانِ فِي الْقَدْرِ وَالْحُلُولِ أَوْ التَّأْجِيلِ، وَقِيَمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرُ مِنْ قِيَمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ مُسَاوِيَةٌ لَهَا لَمْ تُنْقَلِ الْوَثِيقَةُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيَمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ نَقِلَ مِنْهُ قَدْرُ قِيَمَةِ الْقَتِيلِ.

(ما ينفك به الرهن)

(وَلَوْ تَلَفَ الْمَرْهُونُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) (٢٦١) (بَطَلَ) الرَّهْنُ، (وَيَنْفَكُ) الرَّهْنُ (بِفَسْخِ الْمُرْتَبِعِ) وَخَدَهُ أَوْ مَعَ الرَّاهِنِ، (وَبِالْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ) بِقَضَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ أَوْ حَوَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، (فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ) (٢٦٢) (لَمْ يَنْفَكْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ) أَيْ الْمَرْهُونُ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الدَّيْنِ، (وَلَوْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ بَدَيْنٍ وَنِصْفَهُ بِآخَرِ فَبَرِيٍّ مِنْ أَحَدِهِمَا انْفَكَّ قِسْطُهُ) لِتَعَدُّ الْعَقْدِ، (وَلَوْ رَهَنَاهُ) بَدَيْنٍ (فَبَرِيٍّ أَحَدُهُمَا) مِمَّا عَلَيْهِ (انْفَكَّ نَصِيبُهُ) لِتَعَدُّ مِنْ عَلَيْهِ الدَّيْنِ، وَلَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَبَرِيٍّ مِنْ دَيْنٍ أَحَدِهِمَا انْفَكَّ قِسْطُهُ لِتَعَدُّ مُسْتَحَقِّ الدَّيْنِ

(الاختلاف في الرهن)

(فَصَلَ): إِذَا (اخْتَلَفَا) (٢٦٣) (فِي الرَّهْنِ) أَيْ أَضْلِهِ كَأَنْ قَالَ: رَهَنْتَنِي كَذَا فَأَنْكَرَ، (أَوْ قَدَّرَهُ) أَيْ الرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ، كَأَنْ قَالَ: رَهَنْتَنِي الْأَرْضَ بِأَشْجَارِهَا، فَقَالَ: بَلْ وَخَدَهَا أَوْ تَغْيِينُهُ كَهَذَا الْعَبْدِ، فَقَالَ: بَلْ هَذَا الثَّوْبُ، أَوْ قَدَّرَ الْمَرْهُونَ بِهِ، كِبَالَتَيْنِ فَقَالَ بَلْ بِأَلْفٍ، (صَدَّقَ الرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ) (٢٦٤)، (وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْمُنْكَرِ بِالنَّظَرِ لِلْمُدَّعِي، وَقَوْلُهُ (إِنْ كَانَ رَهْنٌ تَبَرُّعٌ) قِيَدٌ فِي التَّصَدِيقِ، (وَإِنْ شَرَطَ) الرَّهْنُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ بِوَجْهِ مِمَّا ذَكَرَ (فِي بَيْعٍ تَحَالُفًا) كَسَائِرِ صُورِ الْبَيْعِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهَا، (وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُمَا رَهْنَاهُ عَبْدُهُمَا بِمِائَةٍ) وَأَقْبَضَاهُ (وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا، فَنَصِيبُ

(٢٦٠) أي نقص كون الرهن وثيقة أو ضمان يستوفى منه الدين عند الحاجة.

(٢٦١) أي تلف بدون جناية عليه من أحد.

(٢٦٢) أي الدين.

(٢٦٣) أي الراهن والمرتهن.

(٢٦٤) يصدق الراهن بيمينه هنا إذا لم تكن بينة للمرتهن، لأن البينة على المدعي وهو المرتهن، واليمين على

المدعي عليه وهو الراهن.

الْمُصَدِّقِ رَهْنٍ بِخَمْسِينَ، وَالْقَوْلُ فِي نَصِيبِ الثَّانِي قَوْلُهُ بِبَيْمِينِهِ، وَتَقْبُلُ شَهَادَةُ الْمُصَدِّقِ عَلَيْهِ) فَإِنْ شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ، أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ رَهْنُ الْجَمِيعِ.

(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِهِ) أَيِ الْمَرْهُونِ، (فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقَالَ الرَّاهِنُ: غَصَبْتَهُ صَدَّقَ بِبَيْمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِ الرَّهْنِ وَعَدَمُ إِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ (وَكَذَا إِنْ قَالَ: أَقْبَضْتُهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى) كَالِإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِيدَاعِ يُصَدَّقُ بِبَيْمِينِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ عَنِ الرَّهْنِ، وَالثَّانِي: يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى قَبْضِ مَأْذُونٍ فِيهِ، (وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ (بِقَبْضِهِ)، أَيِ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونِ، (ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ إِقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ، فَلَهُ تَحْلِفُهُ) أَيِ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ قَبَضَ الْمَرْهُونَ (وَقِيلَ: لَا يُحْلِفُهُ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا، كَقَوْلِهِ: أَشْهَدْتُ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ)^(٢٦٥)، قَبْلَ حَقِيقَةِ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا يَكُونُ مُنَاقِضًا بِقَوْلِهِ لِإِقْرَارِهِ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْوَثَائِقَ فِي الْغَالِبِ يُشْهَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ تَحْقِيقِ مَا فِيهَا فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَى تَلْفُظِهِ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ إِقْرَارُهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بَعْدَ تَوَجُّهِ الدَّعْوَى فَقِيلَ لَا يُحْلِفُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ تَأْوِيلًا لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يُعْرَى عِنْدَ الْقَاضِي إِلَّا عِنْدَ تَحْقِيقٍ، وَقِيلَ: لَا فَرْقَ لِمُشْمُولِ الْإِمْكَانِ.

(وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا) أَيِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (جَنَى الْمَرْهُونَ)^(٢٦٦)، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ صَدَّقَ الْمُنْكَرُ بِبَيْمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْجَنَائَةِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ، وَإِذَا بَاعَ فِي الدِّينِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرَّرِ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ بِإِقْرَارِهِ، وَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ الْمُقَرَّرِ لِإِقْرَارِهِ، (وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ: جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ)، وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ (فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِبَيْمِينِهِ فِي إِنْكَارِهِ) الْجَنَائَةَ صِيَانَةً لِحَقِّهِ، وَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا، وَالثَّانِي: يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ، (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ) الْمُرْتَهِنُ (غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ حَالٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ، وَالثَّانِي لَا يَغْرَمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ إِقْرَارَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَرَّ، (و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَغْرَمُ الْأَقْلَ مِنْ قِيَمَةِ الْعَبْدِ وَأَرْشِ الْجَنَائَةِ)^(٢٦٧)، وَالثَّانِي يَغْرَمُ الْأَرْشَ بِالْعَا مَا بَلَغَ (و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (لَا عَلَى الرَّاهِنِ) لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ شَيْئًا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي تُرَدُّ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ، وَالْخُصُومَةُ تَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ (فَإِذَا حَلَفَ) الْمُرْدُودُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا (بِيعَ) الْعَبْدُ (فِي الْجَنَائَةِ) إِنْ اسْتَعْرِقَتْ قِيَمَتَهُ وَإِلَّا بَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِهَا، وَلَا يَكُونُ الْبَاقِي رَهْنًا لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمُرْدُودَةَ كَالْبَيْتَةِ أَوْ كَالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ كَانَ جَانِيًا فِي الْإِبْتِدَاءِ، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ شَيْءٍ مِنْهُ،

(٢٦٥) رسم القبالة: هي الوثيقة التي تم فيها كتابة عقد الرهن بين الراهن والمرتهن.

(٢٦٦) يعني إذا كان المرهون عبداً، وادعى الراهن أو المرتهن أنه ارتكب جنائية توجب القصاص مثلاً، مما يعني تلف المرهون وهو العبد.

(٢٦٧) المقصود بأرش الجنائية: النقص الذي طرأ على قيمة العبد بعد ارتكابه للجنائية، فإذا كانت قيمة العبد قبل الجنائية ألفاً، وبعد الجنائية خمسمائة، فأرش الجنائية خمسمائة.

وَفِي الرُّوْضَةِ كَاصِلَهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَوْلَيْنِ، وَتَضْعِيفُ أَنَّهُ وَجْهَانِ فِي الثَّالِثَةِ، وَتَرْجِيحُ الْقَطْعِ بِالْأَوَّلِ فِي الثَّانِيَةِ.

(وَلَوْ أَذِنَ) الْمُرْتَهِنُ (فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ، فَبَيْعَ وَرَجَعَ عَنِ الْإِذْنِ وَقَالَ: رَجَعْتُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَقَالَ: الرَّاهِنُ بَعْدَهُ فَأَلْصَحُّ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ) بِبَيْعِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجُوعِهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ بَيْعِ الرَّهْنِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدَّعِيهِ فَيَتَعَارِضَانِ، وَيَبْقَى أَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الرَّهْنِ، وَالثَّانِي: يُصَدِّقُ الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِوَقْتِ بَيْعِهِ، وَقَدْ سَلَّمَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ الْإِذْنَ. (وَمَنْ عَلَيْهِ أَلْفَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ، فَأَدَّى أَلْفًا وَقَالَ: أَدَيْتُهُ عَنْ أَلْفِ الرَّهْنِ صَدِّقَ بِبَيْعِهِ) عَلَى الْمُسْتَحَقِّ الْقَائِلِ: إِنَّهُ أَدَّى عَنِ الْأَلْفِ الْآخَرِ، سَوَاءً اخْتَلَفَا فِي نِيَّةِ ذَلِكَ أَمْ فِي لَفْظِهِ، لِأَنَّ الْمُؤَدِّيَّ أَعْرَفَ بِقَصْدِهِ وَكَيْفِيَّةِ أَدَائِهِ، (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا جَعَلَهُ عَمَّا شَاءَ) مِنْهُمَا أَوْ عَنْهُمَا (وَقِيلَ: يُقَسِّطُ) عَلَيْهَا^(٢٦٨).

(حُكْمُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ)

(فَصْلٌ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِتَرَكَّتِهِ) قَطْعًا مُنْتَقِلَةً إِلَى الْوَارِثِ عَلَى الصَّحِيحِ الْآتِي^(٢٦٩)، (تَعَلَّقَهُ بِالْمَرْهُونِ)^(٢٧٠)، وَفِي قَوْلِ كَتَعَلَّقَ الْأَرْضَ بِالْجَانِي^(٢٧١)، لِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ (فَعَلَى الْأَظْهَرِ) الْأَوَّلُ (يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَعْرِقُ)^(٢٧٢) (وَاخْتِلَافُهَا فِي رَهْنِ التَّرَكَّةِ بِهِ، فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا (فِي الْأَصَحِّ) عَلَى قِيَاسِ الدُّيُونِ وَالرُّهُونِ، وَالثَّانِي قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنَ التَّرَكَّةِ نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى إِلَّا قَدْرُ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَجَرَ فِي مَالٍ كَثِيرٍ بِشَيْءٍ حَقِيرٍ بَعِيدٌ، قَالَ فِي الرُّوْضَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ: وَسَوَاءٌ أَعْلِمَ الْوَارِثُ بِالْدَّيْنِ أَمْ لَا، لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الْأَدْمِيَّةِ لَا يُخْتَلَفُ بِهِ، وَحَكَى فِي الْمَطْلَبِ الْخِلَافَ عَلَى قَوْلِ تَعَلَّقِ الْأَرْضِ، وَذَكَرُوا

(٢٦٨) أَيِ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّاهِنِ أَلْفَانِ، وَرَهْنُ شَيْئًا يُقَابِلُ أَلْفًا وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ فِي الْأَلْفِ الَّتِي يَدَّعِي أَنَّ الرَّهْنَ تَمَّ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ أَدَّى بَنِيَّتَهُ وَقَصْدَهُ عِنْدَ الرَّهْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا عِنْدَ الرَّهْنِ، فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى أَيِّ أَلْفٍ يَشَاءُ، وَقِيلَ يَقْسِمُ الرَّهْنَ عَلَى الْأَلْفَيْنِ، بَحِثْ يَكُونُ لِلأَوَّلِ نِصْفُ الرَّهْنِ، وَلِلْأَلْفِ الثَّانِي النِّصْفُ الْآخَرُ.

(٢٦٩) يَقْصِدُ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ عِنْدَمَا يَتَحَدَّثُ عَنْ انْتِقَالِ التَّرَكَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْوَارِثِ.

(٢٧٠) تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِالتَّرَكَّةِ تَعَلَّقَ الْمَرْهُونُ أَفْضَلُ وَأَحْوَطُ لِلْمَيْتِ، لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُمْكِنُ لِلْوَرِثَةِ التَّصَرُّفُ فِي التَّرَكَّةِ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ دِيُونِ الْمَيْتِ، وَبِذَلِكَ تَبَرُّأَ ذِمَّتُهُ مِنَ الدَّيْنِ وَلَا يَحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَةِ بِسَبَبِهِ.

(٢٧١) مَعْنَى تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِالتَّرَكَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ تَعَلَّقَ الْأَرْضُ بِالْجَانِي: أَنَّ الْوَرِثَةَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِي التَّرَكَّةِ قَبْلَ سَدَادِ دَيْنِ الْمَيْتِ، ثُمَّ إِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَطَالِبُ بَدْيَتِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ تَصَرُّفَ الْوَرِثَةِ فِي التَّرَكَّةِ لِيَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْهَا.

(٢٧٢) الدَّيْنُ الْمُسْتَعْرِقُ: هُوَ الَّذِي يَسْتَحُوزُ عَلَى جَمِيعِ تَرَكَّةِ الْمَيْتِ، كَمَا لَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَعَلَيْهِ عَشْرَةُ آلَافٍ، وَالتَّرَكَّةُ خَمْسَةُ آلَافٍ، فَالَّذِينَ هُنَا قَدْ اسْتَعْرِقُوا كُلَّ التَّرَكَّةِ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ لِلْوَرِثَةِ.

مِثْلَهُ فِي تَعْلُقِ الرِّكَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَ تَرْجِيحِ التَّعْلُقِ بِقَدْرِهَا فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا فَيُخَالِفُ الْمُرَجَّحَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُرَجَّحَ عَلَى الرَّهْنِ، فَقَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلخَ صَحِيحٌ.

(وَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ وَلَا دَيْنَ ظَاهِرٍ، فَظَهَرَ دَيْنٌ بَرْدٌ مَبِيعٍ بَعِيْبٍ) أَكَلَ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ، (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ تَصَرُّفِهِ) لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرًا^(٢٧٣)، (لَكِنْ إِنْ لَمْ يَقْضِ^(٢٧٤) الدَّيْنَ فُسِخَ) التَّصَرُّفُ لِيَصِلَ الْمُسْتَحَقُّ إِلَى حَقِّهِ، وَقِيلَ: لَا يَنْقَسِخُ بَلْ يُطَالِبُ الْوَارِثُ بِالْأَيْنِ وَيَجْعَلُ كَالضَّامِنِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَتَبَيَّنُ فَسَادُ التَّصَرُّفِ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ مِنَ الدَّيْنِ بِالْأَيْنِ الْمُقَارِنِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ، (وَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلْوَارِثِ إِمْسَاكَ عَيْنِ التَّرَكَةِ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ)، نَعَمْ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنَ التَّرَكَةِ، فَقَالَ الْوَارِثُ: أَخَذْتُهَا بِقِيَمَتِهَا، وَأَرَادَ الْغُرْمَاءُ بَيْعَهَا لِتَوْفُّعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ، أُجِيبَ الْوَارِثُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْقِيَمَةِ، (وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَعْلُقَ الدَّيْنِ بِالتَّرَكَةِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ)، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِرْثِ الْمُفِيدِ لِلْمَلِكِ أَكْثَرُ مِنْ تَعْلُقِ الدَّيْنِ بِالْمَوْرُوثِ تَعْلُقَ رَهْنٍ أَوْ أَزْشٍ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمَلِكَ فِي الْمَرْهُونِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي، وَالثَّانِي اسْتِنْدَادَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: سَمَحَ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ سَجَى [النساء: ١١]، فَقَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ لِقِسْمَتِهِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْهُ، وَعَلَى الثَّانِي هَلْ الْمَنْعُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ أَوْ فِي الْجَمِيعِ؟، قَالَ فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا فِي أَوَاخِرِ الشُّفْعَةِ فِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ هُنَا فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي الْجَمِيعِ، أَوْ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الْمُبْنِيِّ عَلَى أَنَّ تَعْلُقَ الدَّيْنِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ، وَلَمْ يُذَكَّرْ ذَلِكَ الْخِلَافُ هُنَا.

وَعَلَى الْأَوَّلِ^(٢٧٥) وَهُوَ أَنَّ تَعْلُقَ الدَّيْنِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ قَالَ (فَلَا يَتَعْلَقُ) أَيُّ الدَّيْنِ (بِزَوَائِدِ التَّرَكَةِ كَالْكَسْبِ وَالنِّتَاجِ)، لِأَنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ، وَعَلَى الثَّانِي يَتَعْلَقُ بِهَا نَبْعًا لِأَصْلِهَا. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ)

(٢٧٣) أي إذا تصرف الوارث في نصيبه من تركة مورثه وهو لا يعلم أن ما تصرف فيه مستحق للغير ، فتصرف الوارث صحيح، لأنه تصرف فيما ظهر له أنه ملكه.

(٢٧٤) أي الوارث.

(٢٧٥) أي على القول الأول.

كتاب التفليس (٢٧٦)

قَالَ فِي الصَّاحِ: فَلَسَهُ الْقَاضِي تَقْلِيصًا نَادَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَفْلَسَ، وَقَدْ أَفْلَسَ الرَّجُلُ صَارَ مُفْلِسًا ١ هـ، وَالْمُفْلِسُ فِي الْعُرْفِ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَفِي الشَّرْعِ مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ، كَمَا قَالَ ذَاكِرًا حُكْمَهُ (مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ حَالَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَالِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ) فِي مَالِهِ (بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ) وَفِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَفِي أَصْلِ الرُّوضَةِ يَحْجَرُ عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَزَادَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَأَصْحَابُ الْحَاوِي وَالشَّامِلِ وَالْبَسِيطِ وَآخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَنَّ قَوْلَ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ فَلِلْقَاضِي الْحَجْرُ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُحَيَّرٌ فِيهِ أَيْ بَلْ إِنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوَجِبِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ فِي مَالِهِ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ} (٢٧٧)، وَفِي النَّهْيَةِ أَنَّهُ كَانَ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ (وَلَا حَجْرَ بِالْمُؤَجَّلِ) (٢٧٨) لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ فِي الْحَالِ.

(أحكام الحجر على المفلس)

(وَإِذَا حَجَرَ بِحَالٍ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ فِي الْأُظْهَرِ)، وَالثَّانِي: يَحِلُّ بِالْحَجْرِ كَالْمَوْتِ بِجَمَاعٍ تَعْلُقُ الدَّيْنَ بِالْمَالِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِخَرَابِ الدِّمَّةِ بِالْمَوْتِ دُونَ الْحَجْرِ، (وَلَوْ كَانَتْ الدُّيُونُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يَنْفِقُ مَنْ كَسَبَهُ فَلَا حَجْرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا) لَا حَجْرَ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يُحْجَرُ عَلَيْهِ كَيْ لَا يُضَيِّعَ مَالَهُ فِي النَّفَقَةِ وَدَفَعَ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ (وَلَا يُحْجَرُ بِغَيْرِ طَلَبٍ) مِنَ الْغُرَمَاءِ (فَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ) الْحَجْرَ (وَدَيْنُهُ قَدْرٌ يُحْجَرُ بِهِ) بَأَنْ زَادَ عَلَى مَالِهِ (حَجْرَ وَإِلَّا)، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ الدَّيْنُ عَلَى مَالِهِ (فَلَا) حَجْرَ كَمَا نَقَدَّمْ، ثُمَّ لَا يَخْتَصُّ أَثَرُ الْحَجْرِ بِالطَّلَبِ بَلْ يَعْمُهُمْ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الدُّيُونُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِمْ بِصَبَا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِمَصْلَحَتِهِمْ، وَلَا يُحْجَرُ لِدَيْنِ الْغَائِبِينَ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَوْفَى مَا لَهُمْ فِي الدِّمَمِ، (وَيُحْجَرُ بِطَلَبِ الْمُفْلِسِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَهُ فِيهِ غَرَضًا ظَاهِرًا، وَالثَّانِي يَقُولُ الْحَقُّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: رُوِيَ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى مُعَاذٍ كَانَ بِالنِّمَاسِ مِنْهُ، (فَإِذَا حُجِرَ) عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ دُونَهُ (تَعْلُقُ حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) حَتَّى لَا يَنْقُذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ، وَلَا تَرَاخُمُهُمْ فِيهِ الدُّيُونُ الْحَادِثَةُ، (وَأَشْهَدُ) الْحَاكِمُ اسْتِحْبَابًا (عَلَى حَجْرِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ (لِيُخَذَرَ) أَيْ لِيُخَذَرَ النَّاسُ مُعَامَلَتَهُ.

(٢٧٦) التفليس لغة: النداء على المفلس بصفة الإفلاس.

وشرعا: الحجر على من عليه ديون حالة لا يفي بها ماله.

(٢٧٧) أخرجه الحاكم في المستدرک ٢ / ٦٧، رقم: (٢٣٤٨)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه".

(٢٧٨) أي لا حجر بسبب الدين المؤجل، لأنه لم يحل سداداه.

(حكم تصرف المفلس)

(وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ) ^(٢٧٩) فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ الْمَذْكُورُ (فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ) لِازْتِمَاعِ الْقِيَمَةِ أَوْ إِزَاءٍ (نَقْدًا وَإِلَّا لَعَا) أَيُّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا أَوْ لَاغِيًا، (وَالْأَظْهَرُ بَطْلَانُهُ) ^(٢٨٠) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرْمَاءِ بِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ، (فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لَغُرْمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ) مِنْ غَيْرِ إِذَنْ الْقَاضِي (بَطَلَ) الْبَيْعَ (فِي الْأَصَحِّ)، لِأَنَّ الْحَجَرَ يَنْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ، وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ، وَالثَّانِي: قَالَ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ^(٢٨١)، وَهُمَا ^(٢٨٢) مُفَرَّعَانِ عَلَى بَطْلَانِ الْبَيْعِ لِلْأَجْنَبِيِّ السَّابِقِ كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ، وَالْكَلَامُ حَيْثُ يَصِحُّ الْبَيْعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَجَرٌ وَبِإِذْنِ الْقَاضِي يَصِحُّ، (فَلَوْ بَاعَ سَلَمًا) ^(٢٨٣) طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ، (أَوْ اشْتَرَى) شَيْئًا بِثَمَنِ (فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صَحَّتْهُ وَيُثْبِتُ) الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ (فِي ذِمَّتِهِ) وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ لِلْحَجَرِ عَلَيْهِ كَالسَّفِيهِ، وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الثَّانِي قَوْلًا شَاذًا.

(وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ وَطَلَّاقُهُ وَخُلْعُهُ) ^(٢٨٤) زَوْجَتَهُ (وَاقْتِصَاصُهُ وَإِسْقَاطُهُ) أَيُّ الْقِصَاصِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِهِ، (وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجَرِ) بِمُعَامَلَةٍ أَوْ إِتْلَافٍ (فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْغُرْمَاءِ) كَمَا يُقْبَلُ فِي حَقِّهِ جَزْمًا، وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّهِمْ لِاحْتِمَالِ الْمَوَاطَاةِ، وَدُفِعَ بِأَنَّهَا ^(٢٨٥) خِلَافُ الظَّاهِرِ.

(وَإِنْ أَسْنَدَ وَجُوبَهُ) ^(٢٨٦) إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجَرِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ مُطْلَقًا) أَيُّ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهِمْ)، فَلَا يُزَاحِمُهُمُ الْمُقَرَّرُ لَهُ (وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ) ^(٢٨٧) قَبْلَ فِي الْأَصَحِّ (فَيُزَاحِمُهُمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ كَمَا لَوْ قَالَ عَنْ مُعَامَلَةٍ وَإِنْ أَطْلَقَ وَجُوبَهُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ التَّنْزِيلُ عَلَى الْأَقْلَرِ وَجَعَلَهُ كَمَا لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجَرِ، زَادَ فِي الرُّوْضَةِ هَذَا ظَاهِرٌ إِنْ تَعَدَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقَرَّرِ، وَإِنْ أَمَكَّنَتْ) ^(٢٨٨) فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ

(٢٧٩) أي المفلس.

(٢٨٠) أي بطلان تصرف المفلس.

(٢٨١) أي الأصل عدم وجود غرماء آخرين.

(٢٨٢) أي القولان.

(٢٨٣) بيع السلم: هو بيع شيء موصوف في الذمة.

(٢٨٤) أي المفلس.

(٢٨٥) أي المواطأة.

(٢٨٦) يقصد وجوب العين أو الدين الذي أقر به المفلس.

(٢٨٧) أي أقر المفلس بجناية.

(٢٨٨) مراجعة المقر.

إِقْرَارُهُ، (وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ إِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ^(٢٨٩)) فِي الرَّدِّ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي إِبْقَائِهِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْوِيَةِ مَالٍ بِغَيْرِ عَوَضٍ.

(وَالْأَصَحُّ تَعْدِي الْحَجْرِ إِلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ^(٢٩٠)) بِالْإِضْطِيَادِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ (إِنْ صَحَّحْنَاهُ)^(٢٩١) وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالثَّانِي: لَا يَتَعَدَّى إِلَى مَا ذَكَرَ^(٢٩٢) (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ) أَيِ الْمُفْلِسِ فِي الذِّمَّةِ (أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إِنْ عَلِمَ الْحَالَ^(٢٩٣))، وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ)، وَالثَّانِي: لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا. وَالثَّلَاثُ: لَا مُطْلَقًا، وَهُوَ مُقَصِّرٌ فِي الْجَهْلِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ، (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمَكِّنِ التَّعَلُّقَ بِهَا) بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ كَمَا تَقَدَّمَ (لَا يُرَاجِعُ الْغُرْمَاءَ بِالثَّمَنِ) لِأَنَّهُ حَدَثَ بِرِضَاهُ، وَالثَّانِي يُرَاجِعُهُمْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَلِكٍ جَدِيدٍ زَادَ بِهِ الْمَالُ.

(بيع مال المفلس وقسمته)

(فَصْلٌ: يُبَادِرُ الْقَاضِي) اسْتِحْبَابًا (بَعْدَ الْحَجْرِ) عَلَى الْمُفْلِسِ (بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَسْمِهِ) أَيِ قَسْمِ ثَمَنِهِ (بَيْنَ الْغُرْمَاءِ) لِنَلَا يَطُولُ زَمَنُ الْحَجْرِ، وَلَا يُفْرِطُ فِي الْإِسْتِعْجَالِ لِنَلَا يُطْمَعُ فِيهِ بِثَمَنِ بَخْسٍ^(٢٩٤) (وَيُقَدَّمُ) فِي الْبَيْعِ (مَا يَخَافُ فُسَادَهُ) لِنَلَا يَضِيعُ، (ثُمَّ الْحَيَوَانُ) لِحَاجَتِهِ إِلَى النِّفْقَةِ وَكَوْنُهُ عُرْضَةً لِلْهَلَاكِ، (ثُمَّ الْمَنْقُولُ ثُمَّ الْعَقَارُ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ^(٢٩٥) يُخْشَى عَلَيْهِ السَّرِقَةُ بِخِلَافِ الثَّانِي (وَلِيَبِيعَ بِحَضْرَةِ الْمُفْلِسِ) أَوْ وَكِيلِهِ (وَعُرْمَائِهِ)؛ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ (كُلَّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ) لِأَنَّ طَالِبِيهِ فِيهِ أَكْثَرُ وَيُشْهَرُ بَيْعُ الْعَقَارِ^(٢٩٦)، وَالْأَمْرُ فِي هَذَيْنِ لِلْإِسْتِحْبَابِ (بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًا مِنْ نَقْدِ النَّبْلِ) الْأَمْرُ فِيهِ لِلْوُجُوبِ، (ثُمَّ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ جِنْسِ النَّقْدِ وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إِلَّا بِجِنْسٍ حَقَّهُ اشْتَرَى) لَهُ، (وَإِنْ رَضِيَ جَارَ صَرْفِ النَّقْدِ إِلَيْهِ إِلَّا فِي السَّلَمِ) فَلَا يَجُوزُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ الْإِعْتِيَاظِ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَازُ السَّلَمِ فِي النَّقْدِ فِي كِتَابِهِ.

(٢٨٩) الغبطة: حسن الحال، والمراد بها هنا المعاملة الأفضل.

(٢٩٠) أي بعد الإقرار.

(٢٩١) أي بعد الإقرار.

(٢٩٢) أي إلى ما حدث بعد الإقرار.

(٢٩٣) أي علم بكونه مفلسا.

(٢٩٤) أي لا يستعجل القاضي جدا في بيع مال المفلس، لأن ذلك ربما يؤدي إلى البيع بأقل من الثمن الحقيقي.

(٢٩٥) أي المنقول.

(٢٩٦) أي يعلن بيع العقار على العامة ليكثر من يرغب في شرائه فيرتفع ثمنه لمصلحة المفلس والغرماء.

(وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) اخْتِيَاظًا لِمَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ (وَمَا قَبْضُ) يَفْتَحُ الْقَافَ (قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يُعْصِرَ) قَسَمَهُ (بِقَلْبِهِ فَيُؤَخِّرُ لِيَجْتَمَعَ) فَإِنْ أَبَوْا التَّأخيرَ فِي النِّهَايَةِ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجِيبُهُمْ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ^(٢٩٧) وَسَكَتَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (وَلَا يُكَلِّفُونَ) عِنْدَ الْقِسْمَةِ (بَيِّنَةٌ بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ) لِأَنَّ الْحَجَرَ يَشْتَهَرُ، وَلَوْ كَانَ نَمَّ غَرِيمٌ لَطَهَرَ وَطَلَبَ حَقَّهُ (فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ شَارَكَ بِالْحِصَّةِ) لِحُصُولِ الْمُقْصُودِ (وَقِيلَ: تَنْقُصُ الْقِسْمَةُ) وَتُسْتَأْنَفُ فَعَلَى الْأَوَّلِ^(٢٩٨) لَوْ قَسَمَ مَالَهُ، وَهُوَ خَمْسَةُ عَشَرَ عَلَى غَرِيمَيْنِ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ، وَلِلْآخِرِ عَشْرَةٌ فَأَخَذَ الْأَوَّلُ عَشْرَةً وَالْآخِرُ خَمْسَةً فَظَهَرَ غَرِيمٌ لَهُ ثَلَاثُونَ اسْتَرَدَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ، وَعَلَى الثَّانِي^(٢٩٩) يَسْتَرَدُّ مِنْهُمَا الْقَاضِي مَا أَخَذَهُ وَيَسْتَأْنَفُ الْقِسْمَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ، (وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحِقًّا وَالثَّمَنُ) الْمُقْبُوضُ (تَالِفٌ فَكَذَيْنِ) أَيِ فَمَثَلِ الثَّمَنِ اللَّازِمِ كَذَيْنِ (ظَهَرَ) مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ فَيُشَارِكُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ أَوْ مَعَ نَقْضِهَا (وَإِنْ أُسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ) وَالثَّمَنُ الْمُقْبُوضُ تَالِفٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا (قَدِمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ) أَيِ بِمِثْلِهِ (وَفِي قَوْلِ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ) بِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَدَفَعَ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ النَّاسِ عَنْ شِرَاءِ مَالِ الْمُفْلِسِ، فَكَانَ التَّقْدِيمُ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ.

(نفقة المفلس وأهله)

(وَيُنْفِقُ) الْحَاكِمُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَ (عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ (حَتَّى يُقَسِّمَ مَالَهُ) مِنْهُ^(٣٠٠) لِأَنَّهُ مُوسِرٌ مَا لَمْ يَزَلْ مَلِكُهُ، وَكَذَلِكَ يَكْسُوهُمْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَفِي مَعْنَى الزَّوْجَاتِ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ^(٣٠١) (إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ) فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكْسُوهُمْ وَيَصْرِفُ كَسْبَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفِ بِهِ كَمَلٌ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجَاتِ، قَالَ الْإِمَامُ: نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ^(٣٠٢) وَالزَّوْجَانِي نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا قِيَاسُ النَّبَابِ، وَإِلَّا لَمَا أَنْفَقَ عَلَى الْأَقَارِبِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يُرْجَحُ قَوْلُ الْإِمَامِ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ كُلِّ يَوْمٍ أَقَلَّ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ، ثُمَّ قَالَ فِيهَا عَنْ الْبَيَانِ وَتُسَلَّمُ إِلَيْهِ النَّفَقَةُ يَوْمًا بِيَوْمٍ، (وَيُبَاعُ مَسْكَنُهُ

(٢٩٧) أي لا يجيب الغرماء لطلبهم إذا رفضوا تأخير القسمة لقلة الثمن المقبوض من بيع مال المفلس.

(٢٩٨) أي المشاركة بالحصة.

(٢٩٩) أي نقض القسمة.

(٣٠٠) أي ينفق القاضي على المفلس وأهله من ماله قبل قسمته على الغرماء.

(٣٠١) أم الولد: هي الأمة التي وطأها سيدها وأنجبت ولدا (نكرا أو أنثى)، فتصير الأمة أم ولد لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتعتق بموت سيدها.

(٣٠٢) نفقة المعسرين: أقل ما يكفي من النفقة من غير توسع فيها، وعكسها في المعنى نفقة الموسرين.

وَحَادِمُهُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ اخْتَجَّ إِلَى خَادِمٍ لَزِمَاتِهِ^(٣٠٣) وَمَنْصِبِهِ) أَيُّ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالثَّانِي: يَنْقِيَانِ لَهُ لِحَاجَتِهِ إِذَا كَانَا لَا يَتَقَيَّنُ بِهِ دُونَ النَّفِيسَيْنِ، وَالثَّالِثُ: يَنْقَى الْمُسْكَنُ فَقَطُّ (وَيُتْرَكُ لَهُ دُسْتُ نَوْبٍ يَلِيْقُ بِهِ، وَهُوَ قَمِيصٌ وَسِرَاوِيلٌ وَعِمَامَةٌ وَمَكْعَبٌ) أَيُّ مَدَاسٍ^(٣٠٤) (وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً) وَيُتْرَكُ لِعِيَالِهِ مِنَ النَّوْبِ كَمَا يُتْرَكُ لَهُ، وَيُسَامَحُ بِالْبِدِّ^(٣٠٥) وَالْحَصِيرِ الْقَلِيلِ الْقِيَمَةِ، وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ فَوْقَ مَا يَلِيْقُ بِهِ رَدَدْنَاهُ إِلَى اللَّائِقِ، وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ دُونَ اللَّائِقِ تَقْتِيرًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مَا قُلْنَا يُتْرَكُ لَهُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي مَالِهِ اشْتَرَى بِهِ (وَيُتْرَكُ لَهُ قُوْتُ يَوْمِ الْقِسْمَةِ) لَهُ وَ (لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) لِأَنَّهُ مُوسِرٌ فِي أَوَّلِهِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ وَسُكِنَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ غَيْرُهُ.

(عمل المفلس لسداد ما عليه من الديون)

(وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُوجِرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ) قَالَ تَعَالَى: سَمَحَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۖ سَجَى [البقرة: ٢٨٠]، حَكَمَ بِإِنْظَارِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْكُسْبِ (وَالْأَصَحُّ وَجُوبُ إِجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ) لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ فَيَصْرِفُ بِذَلِكَ لِلدَّيْنِ، وَالثَّانِي: يَقُولُ الْمَنْفَعَةُ لَا تُعَدُّ مَالًا حَاصِلًا، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُوجِرُ مَا ذَكَرَ^(٣٠٦) مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَضِيَّتُهُ هَذَا إِدَامَةُ الْحَجَرِ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَهُوَ كَالْمُسْتَبْعَدِ، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْفَتَاوَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إِجَارَةِ الْوَقْفِ مَا لَمْ يَظْهَرْ تَقَاوُتٌ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ فِي غَرَضِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَالنَّخْلُصِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ.

(ادعى المدين أنه معسر ولا مال له)

(وَإِذَا ادَّعى) الْمَدِينُ (أَنَّهُ مُعْسِرٌ أَوْ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ غُرْمَائِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَنْكَرُوا، فَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُعَامَلَةٍ مَالٍ كَشْرَاءٍ أَوْ قَرْضٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ) كَمَا لَوْ ادَّعى هَلَكَ الْمَالُ (وَالْأَيُّ) وَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي غَيْرِ مُعَامَلَةٍ (فَيُصَدَّقُ بِبَيِّنِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ^(٣٠٧)، وَالثَّانِي: لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْحَرِّ أَنَّهُ يَمْلِكُ شَيْئًا، وَالثَّالِثُ: إِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ بِاخْتِيَارِهِ كَالصَّدَاقِ وَالضَّمَانِ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ لَزِمَهُ لَا بِاخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ الْجَنَايَةِ وَغَرَامَةِ الْمُتْلَفِ صَدَّقَ بِبَيِّنِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَشْغُلُ ذِمَّتَهُ بِاخْتِيَارِهِ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

(٣٠٣) أي مرضه المزمع.

(٣٠٤) حذاء.

(٣٠٥) اللبد: الثياب الثقيل من الصوف ونحوه.

(٣٠٦) أي أم ولده والأرض الموقوفة عليه.

(٣٠٧) أي الأصل عدم قسمة ماله بين الغرماء.

(وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ فِي الْحَالِ) بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ (وَشَرْطُ شَاهِدِهِ) وَهُوَ اثْنَانِ وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ (خَبْرُهُ بَاطِنُهُ) (٣٠٨) أَيِ الْمُعْسِرِ بِطُولِ الْجَوَارِ وَكَثْرَةِ الْمُجَالَسَةِ وَالْمُخَالَطَةِ، فَإِنَّ الْأَمْوَالَ تُخْفَى، فَإِنْ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّ الشَّاهِدَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ أَنَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، قَالَهُ فِي النَّهَائِيَّةِ، (وَلْيُقْلَ) (٣٠٩) هُوَ مُعْسِرٌ وَلَا يُمَحِّضُ النَّفْيَ كَقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا) بَلْ يُعَيِّدُهُ كَقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ إِلَّا قُوَّتُ يَوْمِهِ وَثِيَابُ بَدَنِهِ.

(وَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ) عِنْدَ الْقَاضِي (لَمْ يَجْزُ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازِمَتُهُ، بَلْ يُمَهِّلُ حَتَّى يُوسِرَ) لِلْآيَةِ (٣١٠) نَعَمْ لِلْغَرِيمِ تَخْلِيفُهُ وَيَجِبُ بِطَلَبِهِ، قِيلَ: وَمَعَ سُكُوتِهِ أَيْضًا فَيَكُونُ مِنْ آدَابِ الْقَاضِي، (وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ يُؤَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِعْسَارُهُ شَهِدَ بِهِ) لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ، وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَصْدِيرُ الْكَلَامِ بِلَفْظٍ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَكَّلَ، قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَهَذَا أَبَدَاهُ الْإِمَامُ تَفَقُّهُا لِنَفْسِهِ.

(فسخ البيع لعدم قبض الثمن إذا أفلس المشتري)

(فَصَلَّ: مَنْ بَاعَ وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلْسِ) أَيِ بِسَبَبِ إِفْلَاسِهِ وَالْمَبِيعُ بَاقٍ عِنْدَهُ (فَلَهُ) أَيِ لِلْبَائِعِ (فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بَعَيْنَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ (٣١١)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ نَحْوُهُ، وَلَا فسخ قبل الحجر، (وَالْأَصَحُّ أَنَّ خِيَارَهُ) أَيِ الْفَسْخِ (عَلَى الْفُورِ) كَخِيَارِ الْعَيْبِ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ، وَالثَّانِي: عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ الرَّجُوعِ فِي الْهَبَةِ لِلْوَلَدِ، وَعَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ لَا يَمْتَنِعُ تَأْقِيَّتُهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، (و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفَسْخُ بِالْوَطْءِ) لِلْأَمَةِ (وَالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ) كَمَا لَا يَحْصُلُ بِهَا فِي الْهَبَةِ لِلْوَلَدِ، وَالثَّانِي: يَحْصُلُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا يَحْصُلُ بِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مِنَ الْبَائِعِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِفَسْخِ الْبَيْعِ أَوْ رَفْعَتِهِ أَوْ نَقْضَتِهِ وَلَا يَفْتَقِرُ (٣١٢) إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ فِي الْأَصَحِّ.

(الرجوع في المعاملات التي عقدها المفلس إذا تم الحجر عليه)

(وَلَهُ) أَيِ لِلشَّخْصِ (الرَّجُوعُ) فِي عَيْنِ مَالِهِ بِالْفَسْخِ (فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ) الَّتِي (كَالْبَيْعِ) وَهِيَ الْمَخْصُةُ (٣١٣)، مِنْهَا الْقَرْضُ وَالسَّلَامُ وَالْإِجَارَةُ، فَإِذَا سَلَّمَهُ دَرَاهِمَ قَرْضًا أَوْ رَأْسَ مَالٍ سَلَمَ حَالًا أَوْ مُوجَّلاً فَحَلَّ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ وَالدَّرَاهِمُ بَاقِيَةٌ فَلَهُ الرَّجُوعُ فِيهَا بِالصِّلَحِ، فَإِذَا أَجَرَهُ دَارًا

(٣٠٨) أي يعرف الشهود أموره المالية التي قد تخفى على عوام الناس.

(٣٠٩) أي الشاهد.

(٣١٠) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: □ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ □ [البقرة: ٢٨٠].

(٣١١) صحيح مسلم ٥ / ٣١، رقم (١٥٥٩).

(٣١٢) أي الفسخ.

(٣١٣) المعاوضات المحضة: أي المعاوضات الخالصة التي لا تبرع فيها من أحد الطرفين.

بِأَجْرَةٍ حَالَةٍ لَمْ يَقْبِضْهَا عَلَى حَجَرٍ عَلَيْهِ فَلَهُ الرَّجُوعُ فِي الدَّارِ بِالْفَسْخِ، تَنْزِيلًا لِلْمَنْفَعَةِ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ فِي النَّبْعِ، وَفِي قَوْلٍ لَا إِذْ لَا وَجُودَ لِلْمَنْفَعَةِ وَلَا رُجُوعَ فِي مُعَاوَضَةٍ غَيْرِ مَحْضَةٍ، فَإِذَا خَالَعَهَا أَوْ صَالَحَهُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى عَوْضٍ حَالٍ لَمْ يَقْبِضْ حَتَّى وَجَدَ الْحَجَرَ فَلَيْسَ لَهُ الرَّجُوعُ إِلَى النَّبْعِ أَوْ الدَّمِ.

وَدَلِيلُ الشَّقِّ الْأَوَّلِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ {مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ} (٣١٤).

(شروط الرجوع في البيع الذي عقده المفلس)

(وَلَهُ) أَيُّ لِلرَّجُوعِ فِي الْمَبِيعِ (شُرُوطٌ مِنْهَا: يَكُونُ الثَّمَنُ حَالًا) فِي الْأَصْلِ أَوْ حَلَّ قَبْلَ الْحَجَرِ، وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَى وَجْهِ صَحْحِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْكَبِيرِ تَصْحِيحٌ (وَأَنْ يَتَعَدَّرَ حُصُولُهُ) أَيُّ الثَّمَنُ (بِالْإِفْلَاسِ) أَيُّ بِسَبَبِهِ (فَلَوْ) انْتَقَى الْإِفْلَاسُ بِأَنْ (امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ مَعَ يَسَارِهِ أَوْ هَرَبٍ) عُطِفَ عَلَى امْتَنَعَ (فَلَا فُسْخٌ فِي الْأَصَحِّ) لِإِمْكَانِ الْإِسْتِيفَاءِ بِالسُّلْطَانِ، فَإِنْ فُرِضَ عَجَزٌ (٣١٥) فَتَأْدِرُ لَا عِبْرَةَ بِهِ، وَالثَّانِي: لَهُ الْفُسْخُ كَمَا فِي الْمَفْلَسِ بِجَامِعِ تَعَدُّرِ الْوُصُولِ إِلَى حَقِّهِ حَالًا مَعَ تَوَقُّعِهِ مَالًا، (وَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ) لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْفُسْخِ (لَا تَفْسُخُ وَتَقْدَمُكَ بِالثَّمَنِ فَلَهُ الْفُسْخُ) لِمَا فِي النَّقْدِيمِ مِنَ الْمَنَّةِ، وَقَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ فَيُرَاجِعُهُ فِيمَا أَخَذَهُ.

(و) مِنَ الشُّرُوطِ (٣١٦) (كَوْنُ الْمَبِيعِ بَاقِيًا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، فَلَوْ فَاتَ) مِلْكُهُ بِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ وَتَحْوِهِ أَوْ إِعْتَاقٍ أَوْ وَقْفٍ (أَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ) أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ (فَلَا رُجُوعَ)، وَلَوْ زَالَ الْمَلِكُ ثُمَّ عَادَ قَبْلَ الْحَجَرِ فَوَجَّهَانِ: أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ لَا رُجُوعَ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الزَّوَالِ (٣١٧) (وَلَا يَمْنَعُ) الرَّجُوعُ (التَّرْوِيجَ) وَالتَّذْبِيرَ وَتَغْلِيْقَ الْعَتَقِ وَالْإِجَارَةَ فَيَأْخُذُهُ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ أَوْ يُضَارِبُ.

وَمِنْ الشُّرُوطِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ (٣١٨) حَقٌّ كَجِنَايَةٍ أَوْ رَهْنٍ، وَأَنْ لَا يُحَرِّمَ النَّبَاعُ وَالْمَبِيعُ صَيْدًا، (وَلَوْ تَعَيَّبَ بِأَفَةٍ) كَسُقُوطِ عَضْوٍ (أَخَذَهُ نَاقِصًا أَوْ ضَارَبَ بِالثَّمَنِ، أَوْ بِجِنَايَةٍ أَجْنَبِيٍّ أَوْ النَّبَاعِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيَمَةِ) الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي، مِثَالُهُ قِيَمَتُهُ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا تَسْعُونَ فَيَرْجِعُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ، (وَجِنَايَةُ الْمُشْتَرِي كَافَّةٌ فِي الْأَصَحِّ) (٣١٩)، وَالثَّانِي وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ.

(٣١٤) رواه البخاري ٢ / ٨٤٦، رقم: (٢٢٧٢)، ومسلم في صحيحه ٥ / ٣١، رقم: (١٥٥٩).

(٣١٥) أي عن استيفاء الثمن مع قدرة المفلس على دفعه .

(٣١٦) أي شروط فسخ البيع الذي عقده المفلس.

(٣١٧) أي زوال الملك.

(٣١٨) أي بالمبيع في البيع الذي عقده المفلس.

(٣١٩) أي أن جنابة المشتري على المبيع لها حكم التعيب بالآفة، وهو أن يأخذ المشتري المبيع ناقصا أو يضارب بثمانه.

(وَلَوْ تَلَفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ) أَوْ التَّوْبَيْنِ (ثُمَّ أَفْلَسَ) وَحَجَرَ عَلَيْهِ (أَخَذَ الْبَاقِي وَضَارِبَ بِحِصَّةِ التَّالِفِ)، بَلْ لَوْ بَقِيَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِي بَعْضِهِ مُكِّنَ مِنْهُ، (فَلَوْ كَانَ قَبْضُ بَعْضِ الثَّمَنِ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ، (فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا^(٣٢٠)) وَقَبْضُ نِصْفِ الثَّمَنِ أَخَذَ الْبَاقِي بِبَاقِي الثَّمَنِ) وَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ فِي مُقَابَلَةِ التَّالِفِ، (وَفِي قَوْلٍ يَأْخُذُ نِصْفَهُ) أَيُّ نِصْفِ الْبَاقِي (بِنِصْفِ بَاقِي الثَّمَنِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ) وَهُوَ رُبُعُ الثَّمَنِ، وَيَكُونُ الْمُقْبُوضُ فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِ التَّالِفِ، وَنِصْفُ الْبَاقِي، وَالْقَدِيمُ لَا يَرْجِعُ بَلْ يُضَارِبُ بِبَاقِي الثَّمَنِ لِحَدِيثِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَلَوْ لَمْ يَتَلَفْ شَيْءٌ مِنَ الْمَبِيعِ وَكَانَ قَبْضُ بَعْضِ الثَّمَنِ رَجَعَ عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْمَبِيعِ بِقِسْطِ الْبَاقِي مِنَ الثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ قَبْضُ نِصْفِهِ رَجَعَ فِي النِّصْفِ وَيُضَارِبُ عَلَى الْقَدِيمِ.

(زيادة المبيع قبل فسخ البيع بالإفلاس)

(وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسَمَنِ وَتَعَلَّمَ صَنْعَةً فَازَ الْبَائِعُ بِهَا) فَيَرْجِعُ فِيهَا مَعَ الْأَصْلِ، (وَالْمُنْفَصِلَةُ^(٣٢١)) كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الْبَيْعِ (لِلْمُشْتَرِي، وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْأَصْلِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا وَبَذَلَ بِالْمُعْجَمَةِ (الْبَائِعُ قِيمَتَهُ أَخَذَهُ مَعَ أُمِّهِ وَإِلَّا) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يَبْذُلْهَا (فَيُبَاعَانِ وَتُضْرَفُ إِلَيْهِ حِصَّةُ الْأُمِّ) مِنَ الثَّمَنِ، (وَقِيلَ: لَا رُجُوعَ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيُضَارِبُ، (وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ أَوْ عَكْسِهِ) بِالنَّصْبِ أَيُّ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ بِأَنْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ قَبْلَهُ (فَالْأَصْحُ تَعْدِي الرُّجُوعِ إِلَى الْوَلَدِ) وَجَهٌ فِي الْأَوَّلَى بِأَنَّ الْحَمْلَ تَابِعٌ فِي الْبَيْعِ. فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ وَمُقَابَلُهُ قَالَ: إِنَّمَا يَرْجِعُ فِيمَا كَانَ عِنْدَ الْبَيْعِ فَيَرْجِعُ فِي الْأُمِّ فَقَطَّ. قَالَ الْجَوْنِيُّ: قَبْلَ الْوَضْعِ وَالصِّدْلَانِي وَغَيْرُهُ: بَعْدَ الْوَضْعِ.

قَالَ فِي الرُّوْضَةِ الْأَوَّلِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ إِلَى آخِرِهِ وَيَلِي التَّعْدِي فِي الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَمُقَابَلُهُ عَلَى مُقَابَلِهِ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا^(٣٢٢) عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ رَجَعَ فِيهَا حَامِلًا، وَلَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ الرُّجُوعِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَاسْتِتَارَ الثَّمَرُ بِكَمَامِهِ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَهُوَ أَوْعِيَةُ الطَّلَعِ (وُظْهُورُهُ بِالتَّابِيرِ) أَيُّ تَشَقُّقِ الطَّلَعِ (قَرِيبٌ مِنْ اسْتِتَارِ الْجَنِينِ وَانْفِصَالِهِ)^(٣٢٣)، فَإِذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ عَلَى النَّخِيلِ الْمَبِيعِ عِنْدَ الْبَيْعِ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ وَعِنْدَ الرُّجُوعِ مُؤَبَّرَةٌ فَهِيَ كَالْحَمْلِ عِنْدَ الْبَيْعِ الْمُنْفَصِلِ قَبْلَ الرُّجُوعِ، فَيَتَعَدَّى الرُّجُوعُ إِلَيْهَا عَلَى الرَّاجِحِ، (وَ) هِيَ^(٣٢٤) (أَوَّلَى بِتَعْدِي الرُّجُوعِ) إِلَيْهَا مِنَ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهَا مُشَاهِدَةٌ مُوثِقَةٌ بِهَا بِخِلَافِهِ، وَلِذَلِكَ قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالرُّجُوعِ فِيهَا، وَلَوْ حَدَثَتْ الثَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ

(٣٢٠) أي العبدین أو التوبین.

(٣٢١) أي زيادة المبيع المنفصلة عنه.

(٣٢٢) أي الأمة التي اشتراها المفلس ثم أعسر بثمانها.

(٣٢٣) أي له حكم الزيادة المنفصلة عن المبيع من حيث الرجوع والاستحقاق.

(٣٢٤) أي الثمرة التي على النخيل.

الرُّجُوعِ رَجَعَ فِيهَا عَلَى الرَّاجِحِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَمْلِ، وَقِيلَ: لَا يَرْجَعُ فِيهَا قَطْعًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا تَتَنَاوَلُهَا عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ كَانَتْ الشَّمْرَةُ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ رَجَعَ فِيهَا جَزْمًا، وَلَوْ حَدَّثَتْ الشَّمْرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرُّجُوعِ مُؤَبَّرَةٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي.

(حكم الأرض التي اشتراها المفلس وغرسها أو بنى عليها)

(وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ) الْمُشْتَرَاةَ (أَوْ بَنَى) فِيهَا ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَأَرَادَ الْبَائِعُ الرُّجُوعَ فِيهَا (فَإِنْ اتَّفَقَ الْغَرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى تَفْرِيعِهَا) مِنَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ (فَعَلُوا وَأَخَذَهَا الْبَائِعُ) بِرُجُوعِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُمْ^(٣٢٥) أَخَذَ قِيَمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ لِيَتَمَلَّكَهَا مَعَ الْأَرْضِ، وَإِذَا قَلَعُوا وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ، وَإِنْ حَدَّثَ فِي الْأَرْضِ نَقْصٌ بِالْقَلْعِ وَجَبَ أَرْشُهُ^(٣٢٦) مِنْ مَالِهِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ، وَفِي الْمُهَذَّبِ^(٣٢٧) وَالتَّهْذِيبِ^(٣٢٨) أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ لِأَنَّهُ لِيَتَخْلَصَ مَالِهِ، (وَإِنْ امْتَنَعُوا) مِنَ الْقَلْعِ (لَمْ يُجْبَرُوا) عَلَيْهِ (بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ) فِي الْأَرْضِ (وَيَتَمَلَّكَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ بِقِيَمَتِهِ) أَيُّ لَهُ مَجْمُوعُ الْأُمْرَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي، (وَلَهُ)^(٣٢٩) بَدَلُ تَمَلُّكِ مَا ذَكَرَ (أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَغْرِمَ أَرْضَ نَقْصِهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ فِيهَا وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ) لِنَقْصِ قِيَمَتِهِمَا بِلاَ أَرْضٍ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ الرُّجُوعُ إِنَّمَا يَنْتَبِثُ لِذَفْعِ الضَّرَرِ وَلَا يَزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ، وَالثَّانِي: لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ صَبَعَ الْمُشْتَرِي الثُّوبَ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ يَرْجَعُ الْبَائِعُ فِي الثُّوبِ فَقَطْ، وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا مَعَهُ بِالصَّبْغِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّبْغِ كَالصِّفَةِ التَّابِعَةِ لِلثُّوبِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ أَوْ يَعُودُ إِلَى بَدَلِ قِيَمَتِهِمَا أَوْ قَلْعِهِمَا مَعَ غَرَامَةِ أَرْضِ النِّقْصِ.

(حكم خلط المفلس المبيع الذي اشتراه بغيره)

(وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ) لَهُ (حِنْطَةً فَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا) ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ (فَلَهُ) أَيُّ لِلْبَائِعِ بَعْدَ الْفَسْخِ (أَخْذَ قَدْرِ الْمَبِيعِ مِنَ الْمَخْلُوطِ) وَيَكُونُ فِي الدُّونِ^(٣٣٠) مُسَامِحًا بِنَقْصِهِ كَنَقْصِ

(٣٢٥) أي الغرماء.

(٣٢٦) أي قيمة ما نقص منها.

(٣٢٧) للإمام أبي إسحاق الشيرازي.

(٣٢٨) للإمام البغوي.

(٣٢٩) أي البائع.

(٣٣٠) أي خلط المفلس الحنطة التي اشتراها بحنطة أقل منها في الجودة.

الْعَيْبِ (أَوْ) خَلَطَهَا (بِأَجُودَ فَلَا رُجُوعَ فِي الْمَخْلُوطِ فِي الْأَظْهَرِ) حَدَرًا مِنْ ضَرَرِ الْمُفْلِسِ^(٣٣١) وَيُضَارِبُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ، وَالثَّانِي: لَهُ الرُّجُوعُ، وَيُبَاعَانِ^(٣٣٢) وَيُوزَعُ الثَّمَنُ عَلَى نِسْبَةِ الْقِيَمَةِ.

(الحكم لو اشترى المفلس حنطة وطحنها أو ثوبا وقصره)

(وَلَوْ طَحَنَهَا) أَيِ الْحِنْطَةِ الْمَبِيعَةِ لَهُ (أَوْ قَصَرَ الثَّوْبَ) الْمَبِيعَ لَهُ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيَمَةَ) بِالطَّحْنِ أَوْ الْقِصَارَةِ (رَجَعَ) الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ (وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ) فِيهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ زَادَتْ فَلَا أَظْهَرُ أَنْ يُبَاعَ، وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ، وَلَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ فَإِنْ زَادَتْ الْقِيَمَةُ قَدَّرَ قِيَمَةَ الصَّبْغِ رَجَعَ، وَالْمُفْلِسُ شَرِيكَ بِالصَّبْغِ أَوْ أَقَلَّ، فَالْثَّقُصُ عَلَى الصَّبْغِ أَوْ أَكْثَرَ، فَالْأَصَحُّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ، وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ الصَّبْغَ وَالثَّوْبَ رَجَعَ فِيهِمَا، إِلَّا أَنْ لَا تَزِيدَ قِيَمَتُهُمَا عَلَى قِيَمَةِ الثَّوْبِ فَيَكُونُ فَاقِدًا لِلصَّبْغِ، وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ لِلْبَائِعِ مَعَهُ (وَإِنْ زَادَتْ)^(٣٣٣) فَلَا أَظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ)، مِثَالُهُ: الْقِيَمَةُ خَمْسَةٌ، وَبَلَغَتْ بِمَا فَعَلَ سِتَّةً فَلِلْمُفْلِسِ سُدُسُ الثَّمَنِ، وَالثَّانِي: لَا شَرَكَةَ لِلْمُفْلِسِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي سِمَنِ الدَّابَّةِ بَعْلَفِهِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَأَنَّ الطَّحْنَ أَوْ الْقِصَارَةَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ^(٣٣٤) بِخِلَافِ السِّمَنِ فَهُوَ مُحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ الْعَلْفَ يُوجَدُ كَثِيرًا وَلَا يَحْصُلُ السِّمَنُ.

(الحكم لو صبغ المفلس الثوب الذي اشتراه)

(وَلَوْ صَبَغَهُ) أَيِ الثَّوْبِ الْمُشْتَرَى (بِصِبْغِهِ) ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ (فَإِنْ زَادَتْ الْقِيَمَةُ قَدَّرَ قِيَمَةَ الصَّبْغِ) كَأَنْ تَكُونَ قِيَمَةُ الثَّوْبِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَالصَّبْغُ دَرَاهِمَيْنِ فَصَارَتْ قِيَمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوعًا سِتَّةَ دَرَاهِمَ (رَجَعَ) الْبَائِعُ فِي الثَّوْبِ، (وَالْمُفْلِسُ شَرِيكَ بِالصَّبْغِ) فَيُبَاعُ الثَّوْبُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَهَلْ نَقُولُ كُلُّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ، وَكُلُّ الصَّبْغِ لِلْمُفْلِسِ أَوْ نَقُولُ يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا بِالْأَثْلَاثِ لَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ؟ وَجَهَانٍ، (أَوْ) زَادَتْ الْقِيَمَةُ (أَقَلَّ) مِنْ قِيَمَةِ الصَّبْغِ، كَأَنْ صَارَتْ خَمْسَةٌ (فَالنَّقْصُ عَلَى الصَّبْغِ) لِأَنَّهُ هَالِكٌ فِي الثَّوْبِ، وَالثَّوْبُ قَائِمٌ بِحَالِهِ فَيُبَاعُ، وَلِلْبَائِعِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ خَمْسَةٌ، (أَوْ) زَادَتْ الْقِيَمَةُ (أَكْثَرَ) مِنْ قِيَمَةِ الصَّبْغِ، كَأَنْ صَارَتْ ثَمَانِيَّةً، (فَالْأَصَحُّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ) فَيُبَاعُ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ^(٣٣٥)، وَالثَّانِي: أَنَّهَا لِلْبَائِعِ كَالسِّمَنِ، فَيَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ رُبْعُهُ، وَالثَّلَاثُ: أَنَّهَا تَقْصُ عَلَيْهِمَا^(٣٣٦)، فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ ثُلَاثَا الثَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ

(٣٣١) وجه ضرر المفلس هنا أنا الحنطة التي خلط بها الحنطة التي اشتراها أجود وأعلى ثمنًا، فلو أخذها صاحب الحنطة التي باعها له مخلوطة فقد أخذ أكثر من حقه، وفي ذلك ظلم للمفلس.

(٣٣٢) أي الحنطة التي اشتراها المفلس، والحنطة الأخرى التي تم الخلط بها.

(٣٣٣) أي زادت قيمة الحنطة بالطحن والثوب بالتقصير.

(٣٣٤) أي للمفلس.

(٣٣٥) أي بين المفلس والبائع.

(٣٣٦) أي توزع على المفلس والبائع.

تُلْتُهُ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيَمَةَ بِالصَّبْغِ شَيْئًا رَجَعَ الْبَائِعُ فِي الثَّوْبِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ فِيهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ مَعَهُ.

(وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ الصَّبْغَ وَالثَّوْبَ) وَصَبَّغَهُ بِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ (رَجَعَ) أَيُّ الْبَائِعِ (فِيهِمَا) أَيُّ فِي الثَّوْبِ بِصَبْغِهِ، (إِلَّا أَنْ لَا تَزِيدَ قِيَمَتُهُمَا عَلَى قِيَمَةِ الثَّوْبِ) قَبْلَ الصَّبْغِ بِأَنْ سَاوَتْهَا أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا (فَيَكُونُ فَاقِدًا لِلصَّبْغِ) فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ مَعَ الرَّجُوعِ فِي الثَّوْبِ مِنْ جِهَتِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا زَادَتْ (٣٣٧) وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الْإِسْتِثْنَاءِ فَهُوَ مَحَلُّ الرَّجُوعِ فِيهِمَا، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيَمَةِ الصَّبْغِ فَالْمُفْلِسُ شَرِيكَ بِالزَّائِدِ عَلَيْهَا، وَقِيلَ لَا شَيْءَ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ لَمْ يُضَارِبْ بِالْبَاقِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْقِصَاصَةِ.

(وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ) الثَّوْبَ مِنْ وَاحِدٍ وَالصَّبْغَ مِنْ آخَرَ وَصَبَّغَهُ بِهِ، ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ وَأَرَادَ الْبَائِعَانِ الرَّجُوعَ (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيَمَتُهُ مَصْبُوعًا عَلَى قِيَمَةِ الثَّوْبِ) قَبْلَ الصَّبْغِ (فَصَاحِبُ الصَّبْغِ فَاقِدٌ) لَهُ، فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ، وَصَاحِبُ الثَّوْبِ وَاحِدٌ لَهُ (٣٣٨) فَيَرْجِعُ فِيهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إِنْ نَقَصَتْ قِيَمَتُهُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْقِصَاصَةِ، (وَإِنْ زَادَتْ بِقَدْرِ قِيَمَةِ الصَّبْغِ اشْتَرَاكَ) فِي الرَّجُوعِ وَالثَّوْبِ، وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ فَلَهُمَا الرَّجُوعُ وَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ، (وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيَمَتَيْهِمَا) (٣٣٩) فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكَ لِهُمَا) أَيُّ لِلْبَائِعَيْنِ (بِالزِّيَادَةِ)، فَإِذَا كَانَتْ قِيَمَةُ الثَّوْبِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَالصَّبْغُ دَرَاهِمَيْنِ، وَصَارَتْ قِيَمَتُهُ مَصْبُوعًا ثَمَانِيَةً فَالْمُفْلِسُ شَرِيكَ بِالرُّبْعِ، وَالثَّانِي: لَا شَيْءَ لَهُ، وَالزِّيَادَةُ لَهُمَا بِنِسْبَةِ مَالِيَّتِهِمَا، وَلَوْ اشْتَرَى صَبْغًا وَصَبَّغَ بِهِ ثَوْبًا لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ، فَلِلْبَائِعِ الرَّجُوعُ إِنْ زَادَتْ قِيَمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوعًا عَلَى مَا كَانَتْ قَبْلَ الصَّبْغِ فَيَكُونُ شَرِيكًا فِيهِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَإِذَا شَارَكَ (٣٤٠) وَنَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَنْ ثَمَنِ الصَّبْغِ فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ قَنَعَ بِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَارَبَ بِالْجَمِيعِ، وَالثَّانِي لَهُ أَخْذُهُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالْبَاقِي اه، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ (٣٤١) حُكْمُ قَسَمٍ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، وَهُوَ أَنَّ تَكُونَ الزِّيَادَةُ أَقَلَّ مِنْ قِيَمَةِ الصَّبْغِ، فَيَتَخَيَّرُ بَائِعُهُ بَيْنَ أَخْذِ الزِّيَادَةِ وَالْمُضَارَبَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى الْأَصَحِّ.

(٣٣٧) أي قيمة الصبغ والثوب.

(٣٣٨) أي الصبغ.

(٣٣٩) أي زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمة الثوب والصبغ منفردين.

(٣٤٠) أي المفلس.

(٣٤١) أي مما قاله الإمام النووي في الروضة.

باب الحجر (٣٤٢)

(مِنْهُ حَجَرُ الْمُفْلِسِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ) أَيِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ (وَالرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ) فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ (وَالْمَرِيضِ لِلْوَرَثَةِ) فِي غَيْرِ الثَّلَاثِ (وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ وَالْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ) أَيِ لِحَقِّهِمْ (وَلَهَا أَبْوَابٌ) تَقْدَمُ بَعْضُهَا، وَيَأْتِي بَاقِيهَا (وَمَقْصُودُ الْبَابِ حَجَرُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ) وَالْمُبَدَّرِ بِالْمُعْجَمَةِ. وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ.

(فَبِالْمَجْنُونِ تَنْسَلِبُ الْوَلَايَاتُ وَاعْتِبَارُ الْأَقْوَالِ) كَوَلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْإِيصَاءِ وَالْإِيْتَامِ، وَأَقْوَالِ الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا. أَمَّا الْأَفْعَالُ فَيُعْتَبَرُ الْإِثْلَافُ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ كَالْهَدْيَةِ، (وَيَرْتَفَعُ) أَيِ حَجَرُ الْمَجْنُونِ (بِالْإِفَاقَةِ) التَّامَّةِ مِنَ الْجُنُونِ.

(علامات بلوغ الصبي)

(وَحَجَرُ الصَّبِيِّ يَرْتَفَعُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا، وَبِالْبُلُوغِ) يَحْصُلُ (بِاسْتِكْمَالِ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةً) قَمَرِيَّةً (أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَوُفَتْ إِمْكَانُهُ اسْتِكْمَالُ تِسْعِ سِنِينَ) (٣٤٣) لِلْإِسْتِقْرَاءِ (٣٤٤)، وَفِي الْأَوَّلِ (٣٤٥) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: {عَرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةِ سَنَةٍ فَلَمْ يُجِرْنِي، وَعَرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةٍ فَأَجَارَنِي وَرَأَنِي بَلَغْتُ} (٣٤٦)، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي الثَّانِي (٣٤٧) قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: ٥٩]، وَالْحُلُمُ وَالْإِسْحَاتِلَامُ وَهُوَ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ، (وَنَبَاتُ الْعَانَةِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِبُلُوغِ وَلَدِ الْكَافِرِ) أَيِ أَنَّهُ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ (لَا الْمُسْلِمَ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: قَاسَهُ عَلَى الْكَافِرِ وَفِيهِ حَدِيثُ {عَطِيَّةُ الْقُرْطَيْيِّ قَالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ مَنْ أَتَيْتُ الشَّعَرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ} (٣٤٨). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَالتِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٣٤٢) الحجر في اللغة: المنع والحظر والتضييق، وشرعا: من الشخص من التصرف بماله. والمحجور عليهم ثمانية: خمسة حجر عليهم لحق غيرهم، وثلاثة حجر عليهم لحق أنفسهم: فأما الخمسة المحجور عليهم لحق غيرهم: فالمفلس حجر عليه لحق الغرماء، والمريض لحق الورثة، والعبد والمكاتب لحق السيد، والمرتد لحق المسلمين.

وأما الثلاثة المحجور عليهم لحق أنفسهم: فالصبي، والمجنون، والسفيه، وهو موضع هذا الباب. (٣٤٣) أي أقل وقت يمكن أن يحكم فيه ببلوغ الصغير بلوغه تسع سنوات، فلا يمكن أن يحكم ببلوغه قبل تسع سنوات حتى لو ظهرت علاماته.

(٣٤٤) الاستقراء تتبع أحوال الناس في العصور السابقة.

(٣٤٥) أي استكمال الصبي خمس عشرة سنة.

(٣٤٦) أخرجه ابن ماجة في سننه، ص ٥٤٦، رقم: (٢٥٤٤).

(٣٤٧) حصول البلوغ بخروج المني من الصبي.

(٣٤٨) أخرجه أبو داود في سننه ٦ / ٤٥٦، رقم: (٤٤٠٤).

وَالْمُعْتَبَرُ^(٣٤٩) شَعْرٌ خَشِنٌ يَحْتَاجُ فِي إِزَالَتِهِ إِلَى حَلْقٍ، وَدَفَعَ قِيَاسَ الْمُسْلِمِ بِأَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَعَجَلَ نَبَاتِ الْعَانَةِ بِالْمُعَالَجَةِ دَفْعًا لِلْحَجْرِ، وَتَشَوُّفًا لِلْوَلَايَاتِ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُفْضِي بِهِ إِلَى الْقَتْلِ أَوْ ضَرْبِ الْجُزْيَةِ، قَالَ فِي الرُّوْضَةِ: وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مَنْبَتِ عَانَةٍ مَنْ اخْتَجْنَا إِلَى مَعْرِفَةِ بُلُوغِهِ بِهَا لِلضَّرُورَةِ.

(وَتَزِيدُ الْمَرْأَةُ) عَلَى مَا ذَكَرَ مِنَ السِّنِّ وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَنَبَاتِ الْعَانَةِ الشَّامِلِ لَهَا، (حَيْضًا) بِالْإِجْمَاعِ (وَحَبَلًا) لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِنْزَالِ، لَكِنْ لَا يَتَيَقَّنُ الْوَلَدُ إِلَّا بِالْوَضْعِ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَكَمْنَا بِحُصُولِ الْبُلُوغِ قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَشَيْءٍ.

(علامات الرشد)

(وَالرُّشْدُ صِلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ) كَمَا فُسِّرَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: سَمَحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا سَجَى [النساء: ٦]، (فَلَا يَفْعَلُ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ الْعِدَالَةَ) مِنْ كَبِيرَةٍ أَوْ إِصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ، (وَلَا يُبَذِّرُ بَأَنْ يُضَيِّعَ الْمَالَ بِاحْتِمَالِ غَيْبٍ فَاحِشٍ فِي الْمُعَامَلَةِ) وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ، وَالْيَسِيرِ^(٣٥٠) كَبَيْعٍ مَا يُسَاوِي عَشْرَةَ بَتْسَعَةٍ (أَوْ رَمِيهِ فِي بَحْرٍ أَوْ إِنْفَاقِهِ فِي مُحَرَّمٍ)، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسَ الْمَالِ، (وَالْأَصَحُّ أَنَّ صَرْفَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ الَّتِي لَا تَلِيْقُ بِحَالِهِ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ)؛ لِأَنَّ الْمَالَ يُتَّخَذُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذَّ، وَالثَّانِي: فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ قَالَ: إِنَّهُ تَبْذِيرٌ عَادَةٌ، وَالثَّانِي فِي وَجُوهِ الْخَيْرِ قَالَ: إِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ مُعَرِّطًا فِي الْإِنْفَاقِ فِيهَا فَهُوَ مُبَذِّرٌ وَإِنْ عُرِضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مُقْتَصِدًا فَلَا.

(اختبار الصبي لمعرفة رشده)

(وَيُخْتَبَرُ رُشْدُ الصَّبِيِّ) فِي الْمَالِ (وَيُخْتَلَفُ بِالْمَرَاتِبِ فَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِيهِمَا، (وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا) أَيِ النَّقْصِ عَمَّا طَلَبَ الْبَائِعُ وَالزِّيَادَةَ عَلَى مَا أُعْطِيَ الْمُشْتَرِي أَيِ طَلَبِهَا^(٣٥١)، (وَوَلَدُ الزَّارِعِ بِالزَّرَاعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْقَوَامِ بِهَا)^(٣٥٢)، (وَالْمُحْتَرِفِ)^(٣٥٣) بِالرَّفْعِ (بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ وَالْقَطْنِ وَصَوْنِ الْأَطْعِمَةِ عَنْ الْهَرَّةِ وَنَحْوِهَا) كَالْقَارَةِ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ.

(وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ الْإِخْتِبَارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ) بِحَيْثُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرُشْدِهِ، (وَوَقْتُهُ) أَيِ وَقْتُ الْإِخْتِبَارِ (قَبْلَ الْبُلُوغِ وَقِيلَ: بَعْدَهُ) لِيَصِحَّ تَصَرُّفُهُ، (فَعَلَى الْأَوَّلِ)^(٣٥٤) (الْأَصَحُّ) بِالرَّفْعِ (أَنَّهُ لَا

(٣٤٩) أي في إنبات العانة.

(٣٥٠) أي الغبن اليسير.

(٣٥١) وهو ما يسمى المساومة والفصال في البيع والشراء.

(٣٥٢) أي المزارعين، وهم القائمون بأعمال الزراعة.

(٣٥٣) أي صاحب الحرفة.

(٣٥٤) أي اختباره قبل البلوغ.

يَصِحُّ عَقْدُهُ بَلْ يُنْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ^(٣٥٥)، فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ عَقْدَ الْوَلِيِّ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ عَقْدُهُ لِلْحَاجَةِ.

(فَلَوْ بَلَغَ غَيْرُ رَشِيدٍ) لِاخْتِلَالِ صَلَاحِ الدِّينِ أَوْ الْمَالِ (دَامَ الْحَجَرُ) عَلَيْهِ وَيَنْصَرِفُ فِي مَالِهِ مَنْ كَانَ يَنْصَرِفُ فِيهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ، (وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَّ) الْحَجَرُ عَنْهُ (بِنَفْسِ الْبُلُوغِ وَأُعْطِيَ مَالُهُ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فَكُّ الْقَاضِي)؛ لِأَنَّ الرُّشْدَ مُحْتَاجٌ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَيَنْفَكُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا بِفَكِّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ، وَفِي الْوَصِيِّ وَالْقِيمِ وَجْهَانِ.

(فَلَوْ بَدَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ^(٣٥٦) حُجْرَ عَلَيْهِ) أَيَّ حَجَرَ الْقَاضِي فَقَطُّ، قِيلَ: وَالْأَبُ وَالْجَدُّ أَيْضًا، وَفِي الْمَطْلَبِ وَالْوَصِيِّ، (وَقِيلَ يَعُودُ الْحَجَرُ بِلا إِعَادَةٍ) مِنْ أَحَدٍ أَيْ يَعُودُ بِنَفْسِ التَّبْذِيرِ، (وَلَوْ فَسَقَ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَحْجُرُوا عَلَى الْفَسَقَةِ، وَالثَّانِي يَحْجُرُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ بَدَّرَ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَأَنَّ التَّبْذِيرَ يَتَحَقَّقُ بِهِ تَضْيِيعُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْفُسْقِ، فَقَدْ يُصَانُ مَعَهُ الْمَالُ، وَلَا يَجِيءُ عَلَى الثَّانِي^(٣٥٧) الْوَجْهُ الذَّاهِبُ إِلَى عَوْدِ الْحَجَرِ بِنَفْسِ التَّبْذِيرِ، قَالَهُ الْإِمَامُ.

(الحجر على السفية)

(وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَاهِهِ) أَيَّ سُوءِ تَصَرُّفٍ (طَرَأَ فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي، وَقِيلَ: وَلِيُّهُ فِي الصَّغَرِ) أَيَّ الْأَبِ وَالْجَدِّ، وَالْخِلَافُ وَالتَّصْحِيحُ فِي الرُّوْضَةِ وَأَصْلُهَا عَلَى الْوَجْهِ الذَّاهِبِ إِلَى عَوْدِ الْحَجَرِ بِنَفْسِ التَّبْذِيرِ، وَفِيهِمَا^(٣٥٨) عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَجْرِ الْقَاضِي الْجَزْمُ بِأَنَّهُ وَلِيُّهُ. (وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصَّغَرِ وَقِيلَ الْقَاضِي)، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّصْحِيحَيْنِ أَنَّ السَّفَهَ مُجْتَنَدٌ فِيهِ فَاحْتَاجَ إِلَى نَظَرِ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْجُنُونِ.

(حكم تصرف المحجور عليه)

(وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمُحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَاهِهِ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا إِعْتَاقٌ وَهَبَةٌ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ) هُوَ قَيَّدَ فِي الْجَمِيعِ، وَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ (فَلَوْ اشْتَرَى أَوْ اقْتَرَضَ وَقَبَضَ وَتَلَفَ الْمَأْخُودُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ) فِي الْحَالِ، (وَلَوْ بَعْدَ فَكِّ الْحَجَرِ سَوَاءً عَلِمَ حَالَهُ مِنْ غَامِلِهِ أَوْ جَهْلًا) لِتَقْصِيرِهِ فِي النَّبَحِ عَنْ حَالِهِ.

(وَيَصِحُّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ نِكَاحُهُ) عَلَى مَا سَيَأْتِي بِسَطْهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ (لَا التَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يَصِحُّ إِذَا قَدَّرَ الْوَلِيُّ الْعَوَضَ، فَمَا لَا عَوَضَ فِيهِ كَالْإِعْتَاقِ وَالْهَبَةِ لَا يَصِحُّ جَزْمًا (وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ^(٣٥٩) بِدَيْنٍ) عَنْ مُعَامَلَةٍ أَسْنَدَهُ إِلَى مَا (قَبْلَ الْحَجَرِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَا بِاتِّلَافِ

(٣٥٥) أي المساومة في البيع والشراء.

(٣٥٦) أي بعد فك الحجر عنه.

(٣٥٧) أي الوجه الثاني في المسألة.

(٣٥٨) أي في الروضة وأصلها.

(٣٥٩) أي السفية المحجور عليه.

الْمَالِ) أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ (فِي الْأَظْهَرِ)، وَالثَّانِي اسْتَدَّ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ الْإِثْلَافَ (٣٦٠) ضَمِنَ، فَإِذَا أَقْرَبَ بِهِ يُقْبَلُ، ثُمَّ مَا رُدَّ مِنْ إِفْرَارِهِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجَرِ.

(وَيَصِحُّ) إِفْرَارُهُ (بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ) فَيَقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ، وَفِي الْمَالِ قَوْلَانِ كَالْعَبْدِ إِذَا أَقْرَبَ بِهَا، وَهُمَا مُبْنِيَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِفْرَارُهُ بِالْإِثْلَافِ، فَإِنْ قَبِلَ فَهَذَا أَوْلَى، وَالرَّاجِحُ فِي الْعَبْدِ أَنَّهُ لَا يَنْبُتُ الْمَالُ وَلَوْ عَقَا مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى الصَّحِيحِ. (و) يَصِحُّ (طَلَاغُهُ) وَخُلْعُهُ، وَيَجِبُ دَفْعُ الْعَوَضِ إِلَى وَلِيِّهِ (وِظَاهَرُهُ) وَإِبِلَاؤُهُ (وَنَفْيُهُ النَّسَبِ) لِمَا وَلَدَتْهُ زَوْجَتُهُ (بِلَعَانٍ) وَاسْتِلْحَاقُهُ النَّسَبِ، وَيُنْفِقُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(حُكْمُ عِبَادَةِ الْمُحْجُورِ عَلَيْهِ)

(وَحُكْمُهُ فِي الْعِبَادَةِ كَالرَّشِيدِ) فَيَفْعَلُهَا (لَكِنْ لَا يَفَرِّقُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ مَالِيٍّ، (وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجٍّ فَرَضٍ) أَضْلَى أَوْ مَذْهَبٍ قَبْلَ الْحَجْرِ (أَعْطِيَ الْوَلِيَّ كِفَايَتَهُ لِنَفَقَةٍ يَنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ)، أَوْ يَخْرُجُ الْوَلِيُّ مَعَهُ لِيَنْفِقَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ (٣٦١) إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لِلْإِحْرَامِ، وَأَنَّ الْعُمَرَةَ كَالْحَجِّ فِيمَا ذَكَرَ.

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَزَادَتْ مُؤْنَتُهُ سَفَرَهُ) لِإِتِمَامِ الشُّكِّ (عَلَى نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ لِلْوَلِيِّ مِنْهُ) مِنَ الْإِتِمَامِ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَمُحْصِرٍ) (٣٦٢) (فَيَتَحَلَّلُ)، وَثَانِي الْوَجْهَيْنِ مِنَ الطَّرِيقِ الثَّانِي أَنَّهُ كَالْفَاقِدِ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِلِقَاءِ الْبَيْتِ، (قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ (وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ) إِنْ قُلْنَا لِدَمِ الْإِحْصَارِ بَدَلًا، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرَ زِيَادَةِ الْمُؤْنَةِ لَمْ يَجْزِ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَتَقَدَّمَ تَرْجِيحُ أَنَّ لِدَمِ الْإِحْصَارِ بَدَلًا وَنِيَابَةَ الصَّوْمِ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الطَّعَامِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ يَبْقَى فِي الذِّمَّةِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَيُظْهَرُ أَنَّ يَبْقَى فِي ذِمَّةِ السَّفِيهِ أَيْضًا.

(مَنْ لَهُ حَقُّ الْوَلَايَةِ عَلَى الصَّبِيِّ)

(فَصْلٌ: وَلِيُّ الصَّبِيِّ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ. وَلِيُّ الصَّبِيِّ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ لِأَبِيهِ (ثُمَّ وَصِيَّهِمَا) أَيْ وَصِيِّ الْأَبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ وَوَصِيِّ الْجَدِّ (ثُمَّ الْقَاضِي) أَوْ مَنْ يُنْصَبُ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَصَايَا أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوَصِيِّ الْعَدَالَةَ، وَفِي الرُّوَصَةِ هُنَا وَهَلْ يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ إِلَى ثُبُوتِ عَدَالَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِثُبُوتِ وَلَا يَتِيهِمَا وَجْهَانِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ الْإِكْتِفَاءُ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ (٣٦٣) ١ هـ. وَلَا تَلِي الْأُمُّ (٣٦٤) فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: تَلِي بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدِّ، وَتَقَدَّمَ عَلَى وَصِيَّهِمَا.

(٣٦٠) أي أُلْفَ الْمَالِ بَعْدَ الْحَجَرِ.

(٣٦١) أي إعطاء الولي نفقته لثقة ينفق منها عليه في سفره.

(٣٦٢) الإحصار للمحرم: هو المنع من بلوغ المناسك وإتمام النسك.

(٣٦٣) العدالة الظاهرة: أن لا يعرف بالفسق، ولا يصدر منه ما يحكم به بفسقه.

(٣٦٤) أي لا تثبت لها الولاية على الصبي.

(تصرف الولي في مال الصبي)

(وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ فَيَشْتَرِي لَهُ الْعَقَارَ) وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّجَارَةِ، (وَيَبْنِي دُورَهُ بِالطِّينِ وَالْأَجْرِ) أَيِ الطُّوبِ الْمُحَرَّقِ (لَا اللَّيْنِ) أَيِ الطُّوبِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّقْ بَدَلَ الْأَجْرِ لِقَلَّةِ بَقَائِهِ (وَالْحَصَى) أَيِ الْحِجْسِ بَدَلَ الطِّينِ لِكَثْرَةِ مُؤْنَتِهِ، (وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَنَفَقَةٍ وَكِسْفَةٍ، بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّتُهُ بِهِمَا (أَوْ غِنَاطَةً ظَاهِرَةً) (٣٦٥) بِأَنْ يَرْغَبَ فِيهِ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ.

(وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرَضٍ وَنَسِيئَةٍ) (٣٦٦) لِلْمَصْلَحَةِ الَّتِي رَأَاهَا (وَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً) وَظَاهَرَ أَنَّهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى النَّقْدِ (أَشْهَدَ) عَلَيْهِ (وَارْتَهَنَ بِهِ) رَهْنًا وَافِيًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَحَكَى الْإِمَامُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَرْتَهِنْ وَالْمُشْتَرِي مَلِيءٌ (٣٦٧) وَجْهَيْنِ، وَقَالَ الْأَصْحُ الصِّحَّةُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشَبِّهُ أَنْ يَذْهَبَ الْقَائِلُ بِالصِّحَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ، وَبِجَوَازِهِ اعْتِمَادًا عَلَى ذِمَّةِ الْمَلِيءِ، وَإِذَا بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ نَسِيئَةً لَا يَخْتِاجُ إِلَى رَهْنٍ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي حَقِّ وَلَدِهِ.

(وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ) الَّتِي رَأَاهَا فِي ذَلِكَ، (وَيُزَكِّي مَالَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ) وَيَكْسُوهُ (بِالْمَعْرُوفِ) وَيُنْفِقُ عَلَى قَرِيبِهِ بِالطَّلَبِ (فَإِنْ ادَّعَى) (٣٦٨) بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ بَيْعًا) لِمَالِهِ (بِلَا مَصْلَحَةٍ صَدَقًا بِالْيَمِينِ)؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ لَوْفُورِ شَفَقَتِهِمَا (وَإِنْ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ) أَيِ مَنْصُوبِ الْقَاضِي (صَدَقَ هُوَ بِيَمِينِهِ) لِلتُّهْمَةِ فِي حَقِّهِمَا، وَقِيلَ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ هُمَا الْمُصَدَّقَانِ، وَالْفَرْقُ عُسْرُ الْإِشْهَادِ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ يُبَاعُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ وَلِيِّ وَوَلِيِّ، وَلَا بَيْنَ الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ، وَدَعَاوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْوَلِيِّ كَهَيِّ عَلَى الْوَلِيِّ.

(٣٦٥) أي مصلحة واضحة وربح ظاهر.

(٣٦٦) النسيئة: تأخير الثمن في البيع.

(٣٦٧) أي موسر قادر على دفع الثمن.

(٣٦٨) أي الصبي.

باب الحوالة^(٣٦٩)

هِيَ أَنْ تُحِيلَ مَنْ لَهُ عَلَيْكَ دَيْنٌ عَلَى مَنْ لَكَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، فَتَقُولُ: أَحْلَيْتُكَ بِعَشْرَتِكَ عَلَيَّ عَلَى فُلَانٍ بِعَشْرَتِي عَلَيْهِ فَيَقُولُ اخْتَلْتُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: {مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ}^(٣٧٠)، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ: {وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُحْتَلْ}^(٣٧١)، وَأَتَّبَعَ بِسُكُونِ التَّاءِ أُحِيلَ، فَلْيَتَّبِعْ بِسُكُونِهَا فَلْيُحْتَلْ.

(شروط الحوالة)

(يَشْتَرِطُ لَهَا) لِتَصِحَّ (رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ)^(٣٧٢)؛ لِأَنَّهُمَا عَاقِدَاهَا فَهِيَ بِنِعْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فِي الْأَصَحِّ جَوْرَهَا الشَّارِعُ لِلْحَاجَةِ (لَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ)، لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَقِّ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بغيره، وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَوَالََةَ اسْتِيفَاءُ حَقٍّ كَأَنَّ الْمُحْتَالَ اسْتَوْفَى مَا كَانَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ وَأَقْرَضَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، وَيَتَعَذَّرُ إِفْرَاضُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.

(وَلَا تَصِحُّ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ تَصِحُّ بِرِضَاهُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ إِلَى آخِرِهِ، فَقَبُولُهُ ضَمَانٌ لَا يَبْرَأُ بِهِ الْمُحِيلُ، وَقِيلَ: يَبْرَأُ (وَتَصِحُّ بِالذَّيْنِ اللَّازِمِ وَعَلَيْهِ) وَإِنْ اخْتَلَفَ الدَّيْنَانِ فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ كَالثَّمَنِ وَالْقَرْضِ وَالْأُجْرَةِ وَبَدَلِ الْمُتَلَفِ، وَيُسْتَنْتَضَى دَيْنُ السَّلَمِ فَإِنَّهُ لَازِمٌ، وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالََةُ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمَقَابِلُهُ^(٣٧٣) مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ ذَكَرَ هَذَا الْإِسْتِذْرَاكُ فِي الرُّوْضَةِ (الْمِثْلِيُّ) مِنَ الدَّيْنِ كَالثَّمَرِ وَالْحَبِّ، (وَكَذَا الْمُتَقَوِّمُ) مِنْهُ كَالنُّوبِ وَالْعَبْدِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي يُشْتَرِطُ كَوْنُهُ^(٣٧٤) مِثْلِيًّا لِيَتَحَقَّقَ مَقْصُودُ الْحَوَالََةِ مِنْ إِيصَالِ الْمُسْتَحَقِّ إِلَى الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ تَقَاوُتٍ.

(و) تَصِحُّ^(٣٧٥) (بِالْتَّمَنِ فِي مَدَّةِ الْخِيَارِ وَعَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ آيِلٌ إِلَى الزُّرْمِ، وَالثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ الْآنَ (وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ حَوَالََةِ الْمُكَاتِبِ سَيِّدُهُ بِالنُّجُومِ)^(٣٧٦) دُونَ

(٣٦٩) الحوالة بفتح الحاء وكسرهما مشتقة من التحويل والانتقال، ويقال فيها: إحالة، وهي لغة: الانتقال والتغيير، وشرعا: نقل الحق من ذمة إلى ذمة.

(٣٧٠) أخرجه البخاري في صحيحه ٢ / ٧٩٩، رقم: (٢١٦٧)، ومسلم في صحيحه ٥ / ٣٤، رقم: (١٥٦٤).

(٣٧١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٦ / ٤٨، رقم: (٩٩٧٤).

(٣٧٢) المحيل: صاحب الدين، المحتال: هو من يستوفي الحق من المدين (المحال عليه)، مقابل إسقاط دينه عن من أحاله (المحيل).

(٣٧٣) أي مقابل الصحيح.

(٣٧٤) الدين.

(٣٧٥) أي الحوالة.

(٣٧٦) أي أقساط الكتابة الواجبة على العبد لسيده مقابل تحرره.

حَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ)، وَالثَّانِي: صِحَّتُهُمَا، وَالثَّلَاثُ: عَدَمُ صِحَّتَيْهِمَا، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَأَنَّ لِلْمَكَاتِبِ إِسْقَاطَ النُّجُومِ مَتَى شَاءَ فَلَمْ تَصِحَّ حَوَالَةُ السَّيِّدِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ حَوَالَةِ السَّيِّدِ.

(وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمَا يُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَفِي قَوْلٍ: تَصِحُّ بِإِبِلِ الدِّيَةِ وَعَلَيْهَا) وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهَا.

(وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا) أَيُّ الْمَحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ (جِنْسًا وَقَدْرًا وَكَدًّا حُلُولًا وَأَجَلًا وَصِحَّةً وَكَسْرًا فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي تَصِحُّ بِالْمَوْجَلِ عَلَى الْحَالِ؛ لِأَنَّ لِلْمُحِيلِ أَنْ يُعْجَلَ مَا عَلَيْهِ، وَبِالْمُكْسَرِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ الْمُحِيلُ مُتَبَرِّعًا بِصِفَةِ الصِّحَّةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِيهِمَا^(٣٧٧)؛ لِأَنَّ تَأْجِيلَ الْحَالِ لَا يَصِحُّ، وَتَرَكَ صِفَةَ الصِّحَّةِ لِجَحِيلِهِ رَشُوءًا.

(ما يترتب على الحوالة)

(وَيَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ الْمُحِيلُ عَنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ، وَالْمَحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ، وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحْتَالِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَحَالِ عَلَيْهِ) أَيُّ يَصِيرُ فِي ذِمَّتِهِ سَوَاءً قُلْنَا الْحَوَالَةَ بِنَيْعٍ أَمْ اسْتِيفَاءً، (فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَخَذَهُ^(٣٧٨) (بِقُلُسٍ أَوْ جَدِّ وَحَلَفَ وَنَحْوَهُمَا) كَمَوْتٍ (لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ) كَمَا لَوْ أَخَذَ عَوَضًا عَنِ الدَّيْنِ، وَتَلَفَ فِي يَدِهِ.

(فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا)^(٣٧٩) عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجَهْلُهُ الْمُحْتَالِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ)، كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا هُوَ مَعْبُودٌ فِيهِ^(٣٨٠) (وَقِيلَ: لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ شَرَطَ يَسَارُهُ) لَا خِلَافَ الشَّرْطِ، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ: هَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَهُوَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْفَحْصِ.

(وَلَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ (بِالْتَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ) لَارْتِفَاعِ التَّمَنِ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ، وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ كَمَنْ اسْتَبَدَلَ عَنِ التَّمَنِ ثَوْبًا، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ، وَيَرْجِعُ بِمِثْلِ التَّمَنِ، وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافَةِ كَأَنَّ رَدَّ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِهِ أَمْ قَبْلَهُ، وَبَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ التَّمَنِ أَمْ قَبْلَهُ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الرَّدُّ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ بَطَلَتْ قَطْعًا، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا، (أَوْ) أَحَالَ (الْبَائِعُ) عَلَى الْمُشْتَرِي (بِالْتَّمَنِ، فَوُجِدَ الرَّدُّ) لِلْمَبِيعِ بِعَيْبٍ (لَمْ تَبْطُلْ عَلَى الْمَذْهَبِ)، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طَرُدُ الْقَوْلَيْنِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِتَعَلُّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِ قَبْضُ الْمُحْتَالِ الْمَالِ أَمْ لَا، فَإِنْ كَانَ قَبْضُهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، وَإِلَّا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَوْ لَا يَرْجِعُ إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَجَهَانِ أَصْحُهُمَا الثَّانِي.

(٣٧٧) أي الحوالة بالدين الحال على الدين المؤجل، والحوالة بالدين بدراهم صحيحة على الدين بدراهم مكسرة.

(٣٧٨) أي حق المحتال الذي في ذمة المحال عليه.

(٣٧٩) أي المحال عليه.

(٣٨٠) أي مخدوع فيه.

(وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ) عَلَى الْمُشْتَرِي (ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايعَانِ، وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ أَوْ ثَبَّتَتْ بَيِّنَةٌ) تَشْهَدُ حِسْبَةً أَوْ يُقِيمُهَا الْعَبْدُ (بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ) لِطُلَانِ الْبَيْعِ، فَيَرُدُّ الْمُحْتَالُ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَبْقَى حَقُّهُ، كَمَا كَانَ (وَإِنْ كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ) فِي الْحُرِّيَّةِ (وَلَا بَيِّنَةٌ) بِهَا (حَلْفَاهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) بِهَا، (ثُمَّ) بَعْدَ حَلْفِهِ (يَأْخُذُ الْمَالَ مِنَ الْمُشْتَرِي)، وَهَلْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الْمُحِيلِ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ يَقُولُ ظَلَمَنِي الْمُحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ، وَالْمُظْلُومُ لَا يُطَالِبُ غَيْرَ ظَالِمِهِ، قَالَ الْبَغَوِيُّ بِالثَّانِي (٣٨١) وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ كَجَّ وَأَبُو عَلِيٍّ بِالْأَوَّلِ (٣٨٢)، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى هَذَا هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الدَّفْعِ إِلَى الْمُحْتَالِ، فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ.

(الاختلاف في الحوالة)

(وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ) لِلْمُسْتَحَقِّ (وَكُلْتُكَ لِتَقْبِضَ لِي وَقَالَ الْمُسْتَحَقُّ: أَحْلَلْتَنِي أَوْ قَالَ) الْأَوَّلُ (أَرَدْتُ بِقَوْلِي أَحْلَلْتُكَ الْوَكَالَةَ، وَقَالَ الْمُسْتَحَقُّ: بَلْ أَرَدْتُ الْحَوَالَةَ صَدَّقَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ)؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفَ بِقَضْدِهِ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَقِّينِ (وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَجْهٌ) بِتَضَدِّقِ الْمُسْتَحَقِّ بِيَمِينِهِ لِشَهَادَةِ لَفْظِ الْحَوَالَةِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا قَالَ: أَحْلَلْتُكَ بِمَائَةٍ مَثَلًا عَلَى عَمْرٍو، فَإِنْ قَالَ بِالْمَائَةِ الَّتِي لَكَ عَلَيَّ عَلَى عَمْرٍو، فَالْمُصَدِّقُ الْمُسْتَحَقُّ (٣٨٣) قَطْعًا، لِأَنَّ هَذَا لَا يُحْتَمَلُ إِلَّا حَقِيقَةَ الْحَوَالَةِ، وَإِذَا حَلَفَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ انْدَفَعَتْ الْحَوَالَةُ، وَبِانْكَارِ الْآخَرِ (٣٨٤) الْوَكَالَةَ انْعَزَلَ فَلَيْسَ لَهُ قَبْضٌ، وَإِنْ كَانَ قَبِضَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَلْفِ بَرَأَ الدَّافِعُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَكَيْلٌ أَوْ مُحْتَالٌ، وَوَجِبَ تَسْلِيمُهُ لِلْحَالِفِ وَحَقُّهُ عَلَيْهِ بَاقٍ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ: (أَحْلَلْتُكَ فَقَالَ) الْمُسْتَحَقُّ: (وَكُلْتُكَ الثَّانِي بِيَمِينِهِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ، وَكَذَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إِذَا قَالَ عَنْ الْآخَرِ: إِنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَحْلَلْتُكَ الْوَكَالَةَ، وَقِيلَ الْمُصَدِّقُ الْآخَرُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَيُظْهَرُ أَنَّ النَّزَاعَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عِنْدَ إِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَلَفَ الْمُسْتَحَقُّ فِيهِمَا انْدَفَعَتْ الْحَوَالَةُ، وَيَأْخُذُ حَقُّهُ مِنَ الْآخَرِ، وَيَرْجِعُ بِهِ الْآخَرُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي أَحَدٍ وَجْهَيْنِ اخْتَارَهُ ابْنُ كَجَّ.

(٣٨١) أي لا يرجع المشتري على البائع المحيل.

(٣٨٢) أي يرجع المشتري على البائع المحيل.

(٣٨٣) قصد بالمستحق هنا المحيل، وسماه مستحقاً لوجود التنازع بين المحيل والمحال في كون المعاملة وكالة

أو حوالة.

(٣٨٤) أي المستحق.

باب الضمان^(٣٨٥)

[المراد بالضمان^(٣٨٦) ^(٣٨٧) وأركانه]

وَيُذَكَّرُ مَعَهُ الْكَفَالَةُ: هُوَ التَّزَامُ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ مِنَ الْمَالِ، وَيَتَحَقَّقُ بِالضَّامِنِ وَالْمُضْمُونِ لَهُ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا سَيَأْتِي.

[شَرَطُ الضَّامِنِ]

(شَرَطُ الضَّامِنِ^(٣٨٨)) لِيَصِحَّ ضَمَانُهُ (الرُّشْدُ) وَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ: صَلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ بِدُونِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ، وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ الْعِبَارَةِ رَشِيدًا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهَةِ^(٣٨٩) ١ هـ.

[ضَمَانُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ]

(وَضَمَانُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ كَثِيرًا^(٣٩٠)) أَي: بِتَمَنٍّ فِي الذِّمَّةِ وَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ^(٣٩١) كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ.

(٣٨٥) تعليق على شرح (كنز الراغبين) لجلال الدين المحلي، وهو شرح على متن (منهاج الطالبين) للإمام محيي الدين النووي، الدكتور / محمد جمعة / بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة..

(٣٨٦) الضمان لغة: الالتزام.

وشرعا: بالمعنى الشامل للكفالة، يقال: على التزام دين أو إحضار عين أو بدن، ويقال: على العقد المحصل لذلك.

(٣٨٧) وسمي بذلك؛ لأن من التزم مال غيره فقد جعله في ذمته، وكل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه، فهو من الضمن.

(٣٨٨) ويقال له الضمين والزعيم والحميل والكفيل، والصبير والقبيل.

(٣٨٩) لا يصح منهم ولو بإذن أوليائهم.

(وَضَمَانُ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ بَاطِلٌ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ كَانَ مَادُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ وَيُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَقِ (وَيَصِحُّ بِإِذْنِهِ^(٣٩١)) فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ كَسْبَهُ (أَوْ غَيْرَهُ) كَالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْمَادُونِ (قَضَى مِنْهُ وَإِلَّا) أَيُّ: وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْأَدَاءَ كَمَا قَالَ فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.

وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَادُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ) أَيُّ: غَرِمَ الضَّمَانُ (بِمَا فِي يَدِهِ) وَقَتَّ الْإِذْنُ فِيهِ مِنْ رَأْسِ مَالٍ وَرَبْحٍ (وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ) فِيهِ كَاخْتِطَابِهِ (وَإِلَّا) أَيُّ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَادُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ (فِيمَا) أَيُّ: فَيَتَعَلَّقُ غُرْمُ الضَّمَانِ بِمَا (يَكْسِبُهُ) بَعْدَ الْإِذْنِ فَقَطْ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فِي الْقِسْمَيْنِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَقِ، وَالثَّلَاثُ فِي الْأَوَّلِ يَتَعَلَّقُ بِمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فَقَطْ، وَالرَّابِعُ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَبِالرَّابِحِ الْحَاصِلِ فِي يَدِهِ فَقَطْ، وَالثَّلَاثُ فِي الثَّانِي: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، (وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ الْمَضْمُونِ لَهُ) أَيُّ: إِنَّ مَعْرِفَةَ الضَّامِنِ وَهُوَ مُسْتَحَقُّ الدِّينِ لِنَقَاوَتِ النَّاسِ فِي اسْتِيفَائِهِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى أَنَّ الضَّامِنَ يُؤْفَى فَلَا يُبَالِي بِذَلِكَ، (وَ) الْأَصَحُّ عَلَى الْأَوَّلِ (أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَرِضَاُهُ) أَيُّ: وَاحِدٌ مِنْهُمَا^(٣٩٢)، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطَانِ أَيُّ: الرِّضَا ثُمَّ الْقَبُولُ لَفْظًا وَالثَّلَاثُ يُشْتَرَطُ الرِّضَا دُونَ الْقَبُولِ لَفْظًا، وَعَلَى اشْتِرَاطِهِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّمَانِ مَا بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.

[مسائل المضمون عنه]

(٣٩٠) فيصح كضمان مريض.

(٣٩١) أي: السيد وإن تعدد.

(٣٩٢) لظاهر حديث أبي قتادة؛ حيث لم يسأل النبي المضمون له عن رضاه بذلك، بل قبل منه الضمان مطلقًا، والحديث هو ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنزة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتى بجنزة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال هل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنائير فصلى عليها ثم أتى بثلاثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنائير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه فصلى عليه. أخرجه البخاري.

(وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَطْعًا) وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ^(٣٩٣) (وَلَا مَعْرِفَتُهُ فِي الْأَصَحِّ)
وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ لِيُعْرِفَ حَالَهُ وَأَنَّهُ هَلْ يَسْتَحِقُّ اضْطِنَاعَ الْمَعْرُوفِ إِلَيْهِ.

[شروط المضمون (الدين)]

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ (كَوْنُهُ ثَابِتًا) فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ قَبْلَ ثُبُوتِهِ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ
لَهُ فَلَا يَسْبِقُهُ كَالشَّهَادَةِ وَهَذَا فِي الْجَدِيدِ،

[ضمان ما سيجب]

(وَصَحَّحَهُ فِي الْقَدِيمِ ضَمَانُ مَا سَيَجِبُ) كَأَن يَضْمَنَ الْمَائِتَةَ الَّتِي سَتَجِبُ بِبَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ؛ لِأَنَّ
الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

[المراد بضمان الدرك] و[ضمان العيب]

(وَالْمَذْهَبُ صَحَّهُ ضَمَانُ الدَّرَكِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَهُوَ أَنَّ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إِنْ خَرَجَ
الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا) وَرُدَّ

[ضمان النقصان]

(أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ الصَّنَجَةِ) الَّتِي وُزِنَ بِهَا وَرُدَّ، وَهِيَ بَفَتْحِ الصَّادِ وَوَجْهُ صِحَّتِهِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ،
وَفِي قَوْلٍ هُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ كَمَا ذُكِرَ تَبَيَّنَ وَجُوبُ
رَدِّ الثَّمَنِ وَقَطْعَ بَعْضِهِمْ بِالْأَوَّلِ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ مَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ
الْبَائِعِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ بِأَن لَا يُسَلِّمَ الثَّمَنَ إِلَّا بَعْدَهُ، **(وَكَوْنُهُ)**
أَيُّ: الْمَضْمُونُ **(لَا زِمًا، لَا كُنْجُومًا^(٣٩٤) كِتَابَةً)** إِذْ لِلْمَكَاتِبِ إِسْقَاطُهَا بِالْفُسْخِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا
وَسِوَاءَ فِي اللَّازِمِ الْمُسْتَقَرُّ وَغَيْرُهُ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَقَبْلَهُ.

[ضمان الثمن في مدة الخيار]

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ آيِلٌ إِلَى اللُّزُومِ،

(٣٩٣) لجواز أداء دين الغير بغير إذنه فالتزامه أولى، وكذا لظاهر حديث أبي قتادة السابق.

(٣٩٤) أي: دفعات سداد.

وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ الْآنَ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى أَنَّ تَصْحِيحَ الضَّمَانِ مُفَرَّغٌ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمَلِكِ فِي التَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ، أَمَّا إِذَا مَنَعَهُ فَهُوَ ضَمَانٌ مَا لَمْ يَجِبْ.

[ضَمَانُ الْجُعْلِ]

(وَضَمَانُ الْجُعْلِ) فِي الْجَعَالَةِ (كَالرَّهْنِ بِهِ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ وَقِيلَ: يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِهِ فَيَجُوزُ قَطْعًا.

(وَكَوْنُهُ) أَيُّ: الْمَضْمُونِ (مَعْلُومًا فِي الْجَدِيدِ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ، وَصَحَّحَهُ الْقَدِيمُ بِشَرْطِ أَنْ تَأْتِيَ الْإِحَاطَةُ بِهِ كَضَمَانِ مَا لَكَ عَلَى فُلَانٍ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ مُتَبَيِّرَةٌ بِخِلَافِ ضَمِنْتَ شَيْئًا مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ قَطْعًا.

[الْإِبْرَاءُ مِنَ الْمَجْهُولِ]

(وَالْإِبْرَاءُ مِنَ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ فِي الْجَدِيدِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكُ الْمَدِينِ مَا فِي ذِمَّتِهِ، فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهِ، وَفِي الْقَدِيمِ يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِسْقَاطُ كَالْإِعْتَاقِ وَعَلَى التَّمْلِيكِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِسْقَاطُ، وَقِيلَ: يَحْتَاجُ إِلَيْهِ

[الاستثناء من الإبراء من المجهول]

(إِلَّا مِنْ إِبْلِ الذِّمَّةِ) فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا؛ لِأَنَّهُ أُغْتَرِ ذَلِكَ فِي إِثْبَاتِهَا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي فَيُغْتَرُ فِي الْإِبْرَاءِ تَبَعًا لَهُ.

(وَيَصِحُّ ضَمَانُهَا فِي الْأَصَحِّ) عَلَى الْجَدِيدِ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ السِّنِّ وَالْعَدَدِ وَيَرْجِعُ فِي صِفَتِهَا إِلَى غَالِبِ إِبْلِ الْبَلَدِ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى جَهْلِ صِفَتِهَا.

(وَلَوْ قَالَ: ضَمِنْتَ مِمَّا لَكَ عَلَى زَيْدٍ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشْرَةٍ فَأَلْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) وَالثَّانِي: بَطْلَانُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَدُفِعَتْ بِذِكْرِ الْغَايَةِ (و) الْأَصَحُّ عَلَى الْأَوَّلِ (أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِعَشْرَةٍ قُلْتُ: الْأَصَحُّ لِتِسْعَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرُّوضَةِ وَقِيلَ: لِثَمَانِيَةٍ إِخْرَاجًا لِلطَّرَفَيْنِ وَالْأَوَّلِ أَدْخَلَهُمَا، وَالثَّانِي: أَدْخَلَ الْأَوَّلَ فَقَطْ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَحَرَّرِ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْإِقْرَارِ، وَنَقَلَ فِي الشَّرْحِ تَصْحِيحَ الْأَوَّلِ عَنِ الْبَغَوِيِّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.

فَرْعٌ: يَجُوزُ صَمَانُ الْمَنَافِعِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ كَالْأَمْوَالِ.

[فصل في كفالة البدن^(٣٩٥)]

[حكم كفالة البدن وعلتها]

(فصل: المذهب: صحة كفالة البدن^(٣٩٦)) في الجملة؛ للحاجة إليها^(٣٩٧)، وفي قول: لا تصح وقطع بعضهم بالأول، (فإن كفل^(٣٩٨) بدن من عليه مال.. لم يشترط العلم بقدره) لعدم لزومه للكفيل، (و) لكن (يشترط كونه مما يصح ضمانه^(٣٩٩)) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم^(٤٠٠).

(والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى^(٤٠١)) كحد الحمر والزنا والسرقعة؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن^(٤٠٢)، وفي قول في المسألة الأولى إنها لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فنقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها، أو قطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني: نظرا إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة، وفي المسألة الثانية طريقة حاكية للقولين.

(٣٩٥) أي بدن من يستحق حضوره مجلس الحكم.

(٣٩٦) الكفالة: هي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها. مغني المحتاج (دار الكتب العلمية -

الطبعة الأولى - ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م) ج ٣ ص ٢٠٧.

(٣٩٧) ولإطباق الناس عليه، ودليلهم في ذلك قول الله تعالى في أمر يعقوب - عليه السلام -: {قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} [يوسف: ٦٦] وهو شرع لنا كذلك لترك الإنكار عليه.

(٣٩٨) بفتح الفاء أفصح من كسرهما وعدها بنفسه؛ لأنه بمعنى ضمن وعدم استعمال أئمة اللغة له بغير الباء، لعله للأفصح وأما كفل بمعنى عال كما في الآية فيتعدى بنفسه دائما.

(٣٩٩) ومنه الزكاة والكفارة.

(٤٠٠) وكذا دين السيد غير النجوم.

(٤٠١) وإن تحتمت ومثلها عقوبة الله كالتعزير، ولو عبر بالعقوبة كالذي قبله لشمليهما.

(٤٠٢) لأننا مأمورون بستورها والسعي في إسقاطها ما أمكن.

[الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ]

(وَتَصَحُّ) الْكَفَالَةُ (بِبَدَنِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) بِإِذْنِ وَلِيَّهِمَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ إِحْضَارُهُمَا لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى صُورَتِهِمَا فِي الْإِتْلَافِ وَغَيْرِهِ^(٤٠٣)، وَإِذْنُ وَلِيَّهِمَا قَائِمٌ مَقَامَ رِضَا الْمَكْفُولِ الْمُشْتَرَطِ كَمَا سَيَأْتِي، وَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ وَلِيَّهُمَا بِإِحْضَارِهِمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

[كفالة مَحْبُوسٍ وَغَائِبٍ]

(و) بِبَدَنِ (مَحْبُوسٍ وَغَائِبٍ)^(٤٠٤) وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ الْغَرَضِ فِي الْحَالِ، كَمَا يَجُوزُ لِلْمُعْسِرِ صَمَانُ الْمَالِ **(و) بِبَدَنِ (مَيِّتٍ)** قَبْلَ دَفْنِهِ^(٤٠٥) **(لِيُحْضِرَهُ فَيَشْهَدَ)** بَفَتْحِ الْهَاءِ **(عَلَى صُورَتِهِ)** إِذَا تَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَعْرِفُوا اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: اشْتَرَا إِذْنُ الْوَارِثِ^(٤٠٦) إِذَا شَرَطْنَا إِذْنَ الْمَكْفُولِ.

(ثُمَّ إِنْ عَيَّنَ مَكَانَ التَّسْلِيمِ) فِي الْكَفَالَةِ (تَعَيَّنَ وَإِلَّا) أَيُّ: وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ (فَمَكَائِهَا) يَتَعَيَّنُ^(٤٠٧).

[مَا يَبْرَأُ بِهِ الْكَفِيلُ]

(وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ) الْمَذْكُورِ (بِلَا حَائِلٍ كَمُتَغَلِّبٍ) يَمْنَعُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَنْهُ فَمَعَ وَجُودِ الْحَائِلِ لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ^(٤٠٨) (وَبِأَنْ يَحْضُرَ الْمَكْفُولُ وَيَقُولَ) لِلْمَكْفُولِ لَهُ (سَلَّمْتُ نَفْسِي عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ حُضُورِهِ) عَنِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ (فَإِنْ غَابَ لَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلُ إِحْضَارُهُ إِنْ جَهِلَ مَكَانُهُ وَإِلَّا) أَيُّ: وَإِنْ عَرَفَ مَكَانَهُ (فَيَلْزِمُهُ) إِحْضَارُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَمَا دُونَهَا (وَيُمْهَلُ مُدَّةُ ذَهَابٍ وَإِيَابٍ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حُبْسٌ، وَقِيلَ: إِنْ غَابَ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ

(٤٠٣) أشار به إلى قاعدة هي أن كل دين لو ادعى به على شخص عند حاكم، لزمه الحضور له تصح الكفالة ببدن من هو عليه، لا أن كل شخص يلزمه الحضور تصح كفالته.

(٤٠٤) ولو فوق مسافة القصر.

(٤٠٥) لا بعده، مع الأمن من التغير.

(٤٠٦) وإن تعدد أو كان عاما كالإمام، فإن لم يكن الوارث أهلا اعتبر إذن وليه، ولو عاما نعم لو كان للميت ولي خاص قبل موته اعتبر إذنه فقط، ولو لم يكن وارث كذمي مات بلا وارث لم تصح الكفالة.

(٤٠٧) قياساً على السلم، ولأنه هو المتبادر عند الإطلاق.

(٤٠٨) لعدم حصول المقصود.

يَلْزِمُهُ إِحْضَارُهُ)، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا حِينَ الْكَفَالَةِ بِرِضَاهُ، فَالْحُكْمُ فِي إِحْضَارِهِ كَمَا لَوْ غَابَ بَعْدَ الْكَفَالَةِ بِمَسَافَةِ الْإِحْضَارِ تَتَقَيَّدُ غَيْبَتُهُ فِي صِحَّةِ كِفَالَتِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْعَزَالِيُّ. وَقَوْلُهُ: حُبْسَ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إِلَى أَنْ يَتَعَذَّرَ إِحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ.

[هَلْ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ إِذَا مَاتَ وَدُفِنَ الْمَكْفُولُ]

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَدُفِنَ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزِمْهُ، وَالثَّانِي يَقُولُ: الْكَفَالَةُ وَثِيقَةٌ فَيَسْتَوْفِي الدَّيْنَ مِنْهَا إِذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ كَالرَّهْنِ، وَقَبْلَ الدَّفْنِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى صُورَتِهِ

[اشتراط الغرم في الكفالة]

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَنَّهُ يَغْرُمُ الْمَالُ إِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ بَطَلَتْ) وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْمَالِ،

[رِضَا الْمَكْفُولِ]

(و) الْأَصَحُّ: (أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ) وَإِلَّا لَفَاتَ مَقْصُودُهَا مِنْ إِحْضَارِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزِمُهُ الْحُضُورُ مَعَ الْكَفِيلِ حِينَئِذٍ، وَالثَّانِي: تَصِحُّ وَيَغْرُمُ الْكَفِيلُ الْمَالُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إِحْضَارِهِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ أَيْضًا.

[ضَمَانِ الْأَعْيَانِ]

(تِمَّةٌ) فِي ضَمَانِ الْأَعْيَانِ: إِذَا ضَمِنَ عَيْنًا لِمَالِكِهَا أَنْ يَرُدَّهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ^(٤٠٩) مَضمُونَةٌ عَلَيْهِ كَالْمَعْصُوبَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ وَالْمُسْتَأْمَةِ^(٤١٠)، فَفِيهِ الطَّرِيقَانِ فِي كِفَالَةِ الْبَدَنِ، وَعَلَى الصَّحَّةِ إِذَا رَدَّهَا بَرِيءٌ مِنَ الضَّمَانِ وَإِنْ تَلَفَتْ فَهَلْ عَلَيْهِ قِيَمَتُهَا؟ وَجِهَانِ كَمَا لَوْ مَاتَ

(٤٠٩) أي بإذنه أو لقدرة على انتزاعها منه.

(٤١٠) المستأمة: هي المطلوب شراؤها، يقال: سام الشيء، استامه: طلب ابتياعه. المطلع على ألفاظ المقنع

(ص: ٣٨٧) .

الْمَكْفُولُ^(٤١١)، وَعَلَى وُجُوبِهَا هَلْ يَجِبُ فِي الْمَغْصُوبَةِ أَكْثَرُ الْقِيَمِ أَوْ قِيَمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ وَجْهَانِ أَفْوَهِمَا الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَالُ فِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا التَّخْلِيَةُ دُونَ الرَّدِّ.

(٤١١) يفيد أن الأصح عدم لزوم قيمتها، بل لا تصح الكفالة على أن يغرم قيمتها لو تلفت كما مر في الكفيل؛ لأنه ضمان ما لم يجب وبذلك فارق لزوم قيمتها في ضمان الدرك.

(فصل): [في بقية أركان الضمان والكفالة]

[بيان صيغة الكفالة]

(يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ لَفْظُ^(٤١٢) يُشْعِرُ^(٤١٣) بِالِاتِّزَامِ كَضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ) أَي: فَلَانَ (أَوْ تَحَمَّلْتُهُ أَوْ تَقَلَّدْتُهُ أَوْ تَكَفَّلْتُ بِدَيْنِهِ^(٤١٤) أَوْ أَنَا بِالْمَالِ) الْمَغْهُودِ، (أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ) الْمَغْهُودِ^(٤١٥)، (ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ أَوْ زَعِيمٌ أَوْ حَمِيلٌ) وَكُلُّهَا صَرَائِحُ^(٤١٦).

(وَلَوْ قَالَ: أُوَدِّي الْمَالَ أَوْ أَخْضِرُ الشَّخْصَ فَهُوَ وَغْدٌ^(٤١٧)) لَا التَّزَامَ،

[تعليق الكفالة والضمان بشرط]

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْلِيْقُهُمَا بِشَرْطٍ) نَحْوُ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ ضَمِنْتُ أَوْ كَفَّلْتُ، (وَلَا تَوْقِيْتُ الْكَفَالَةَ^(٤١٨)) نَحْوُ: أَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ إِلَى شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى بَرِئْتُ، وَلَا يَجُوزُ تَوْقِيْتُ الضَّمَانِ قَطْعًا، نَحْوُ: أَنَا ضَامِنٌ بِالْمَالِ إِلَى شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى وَلَمْ أَغْرَمْ فَأَنَا بَرِيءٌ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِي التَّغْلِيْقِ نَظَرٌ إِلَى عَدَمِ اسْتِزَاطِ الْقُبُولِ، وَفِي تَوْقِيْتِ الْكَفَالَةِ نَظَرٌ إِلَى أَنَّهَا تَبَرُّعٌ بِعَمَلٍ، وَبِهَذَا يُوجَّهُ الثَّلَاثُ الْمَجُوزُ لِتَغْلِيْقِ الْكَفَالَةِ دُونَ الضَّمَانِ.

[تأجيل الكفالة]

(٤١٢) وهو الصيغة، فالشرطية في كلامه متوجهة إلى إشعار اللفظ بما ذكره لا إليه، فتأمل. وفي معنى اللفظ: إشارة الأخرس المفهومة وهي صريحة إن فهمها كل واحد، فإن اختص بفهمها الفطن فكناية، وإلا فلغو، والكتابة ولو من ناطق كناية .

(٤١٣) أولى من قول غيره يدل؛ لأن الكتابة مشعرة لا دالة.

(٤١٤) أو بجزئه الشائع أو بما لا يبقى بدونه.

(٤١٥) ليس من لفظ الضامن بل مراده الإشارة إلى أن اللام عهدية لما يصح ضمانه، أو كفالاته لا مطلق المال أو الشخص، فلا بد أن يقول المال الذي على فلان أو الشخص الذي هو فلان، وهكذا بدليل أنها كلها صرائح كما يأتي.

(٤١٦) ومنها الذي عند فلان علي بخلاف عندي فهو كناية، وكذا ضمنت فلانا أو ضمان فلان علي أو دين فلان إلي أو عندي، فإن نوى في ذلك المال لزماً، أو البدن لزماً وإلا لغا.

(٤١٧) أي: لا يلزم الوفاء به ما لم يرد به الالتزام فالمراد بالقرينة عند من عبر بها: النية.

(٤١٨) وتقييد المصنف عدم صحة التوقيت بالكفالة ؛ لأنه لا يصح توقيت الضمان بلا خلاف، فالمقصود الأداء والإحضار.

(وَلَوْ نَجَّزَهَا وَشَرَطْنَا خَيْرَ الْإِخْضَارِ شَهْرًا جَازًا) لِلْحَاجَةِ نَحْوُ: أَنَا كَفَيْلٌ بِرَيْدٍ أُحْضِرُهُ بَعْدَ شَهْرٍ،
وَلَوْ شَرَطَ التَّأْخِيرَ بِمَجْهُولٍ كَالْحَصَادِ لَمْ تَصِحَّ الْكِفَالَةُ فِي الْأَصَحِّ.

[ضمان الحال مؤجلًا]

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِ مُؤَجَّلًا^(٤١٩) أَجَلًا مَعْلُومًا) لِلْحَاجَةِ، وَيَتَّبْتُ الْأَجَلَ فِي
حَقِّ الضَّامِنِ^(٤٢٠)، وَقِيلَ: لَا يَتَّبْتُ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ لِلْمُخَالَفَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي بَعْضِ
نُسَخِ الْمُحَرَّرِ كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ. قَالَ: وَفِي بَعْضِهَا تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ وَهُوَ الصَّوَابُ، أَيْ: الْمُوَافَقُ
لِمَا فِي الشَّرْحِ، وَلَوْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلُ إِلَى شَهْرٍ مُؤَجَّلًا إِلَى شَهْرَيْنِ فَهُوَ كَضَمَانِ الْحَالِ مُؤَجَّلًا.

[ضمان المؤجل حالًا]

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُؤَجَّلِ حَالًا)، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ لِلْمُخَالَفَةِ (و) الْأَصَحُّ عَلَى
الأَوَّلِ (أَنَّهُ لَا يُلْزَمُهُ التَّغْيِيلُ) كَمَا لَوْ التَزَمَهُ الْأَصِيلُ، وَعَلَى هَذَا يَتَّبْتُ الْأَجَلَ فِي حَقِّهِ مَقْصُودًا أَوْ
تَبَعًا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ وَجَهَانِ وَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ قَالَ: الضَّمَانُ تَبَرُّعٌ لَزِمَ فِتْلَرُ صِفَتُهُ، وَلَوْ ضَمِنَ
الْمُؤَجَّلُ إِلَى شَهْرَيْنِ مُؤَجَّلًا إِلَى شَهْرٍ فَهُوَ كَضَمَانِ الْمُؤَجَّلِ حَالًا^(٤٢١).

[مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ]

(وَلَمْ يُسْتَحَقَّ) أَيْ: الْمَضْمُونُ لَهُ (مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ^(٤٢٢) وَالْأَصِيلِ^(٤٢٣)) بِالَّذَيْنِ^(٤٢٤)

(٤١٩) لم يقيده بالمال فيشمل الكفالة.

(٤٢٠) أي أصالة بمعنى أنه لا يطالبه قبل فراغه، وهذا هو الأصح من وجهين أشار إلى ثانيهما بقوله: وقيل: لا يثبت.

(٤٢١) أي في الخلاف والحكم وفي الشهر الثاني.

(٤٢٢) وإن تعدد عن الأصيل أو عن ضامن آخر.

(٤٢٣) أما الضامن فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم" رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي وحسنه الترمذي، وأما الأصيل فلبقاء الدين عليه.

[الضمان بشرط براءة الأصل]

(وَالْأَصْلَحُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) الضَّامَنُ^(٤٢٥) (بِشْرَاطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ) لِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ لِمُقْتَضَى الضَّامَنِ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ الضَّامَنُ وَالشَّرْطُ. وَالثَّلَاثُ: يَصِحُّ الضَّامَنُ فَقَطْ، فَإِنْ صَحَّحْنَاهُمَا بَرَى الْأَصِيلُ وَرَجَعَ الضَّامَنُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ إِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بَرَاءَتُهُ كَمَا لَوْ أَدَّى، (وَلَوْ أَبْرَأَ) الْمُسْتَحِقُّ (الْأَصِيلِ) مِنَ الدَّيْنِ (بِرَى الضَّامِنِ) مِنْهُ^(٤٢٦) (وَلَا عَكْسَ) أَي: لَوْ أَبْرَأَ الضَّامِنُ لَمْ يَبْرَأِ الْأَصِيلُ.

(وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) وَالَّذِينَ مُوَجَّلَ (حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ)، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْأَصِيلُ فَلِلضَّامِنِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُسْتَحِقَّ بِأَخْذِ الدَّيْنِ مِنْ تَرْكِتِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ هُوَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَهْلَكَ التَّرِكَةُ فَلَا يَجْدُ مَرْجِعًا إِذَا غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الضَّامِنُ وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ الدَّيْنَ مِنْ تَرْكِتِهِ لَمْ يَكُنْ لَوَرَثَتِهِ الرَّجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ الْأَذِنِ فِي الضَّامَنِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجْلِ.

(وَإِذَا طَالَبَ الْمُسْتَحِقُّ الضَّامِنَ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ)^(٤٢٧) بِتَخْلِيصِهِ بِالْأَدَاءِ إِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ^(٤٢٨) قَبْلَ أَنْ يُطَالَبَ، وَالثَّانِي: (يُطَالَبُ) بِتَخْلِيصِهِ (وَلِلضَّامِنِ) الْغَارِمِ (الرَّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ إِنْ وَجَدَ إِذْنُهُ فِي الضَّامَنِ وَالْأَدَاءِ)^(٤٢٩) (وَإِنْ انْتَفَى فِيهِمَا فَلَا) رُجُوعَ (وَإِنْ

(٤٢٤) أي بجميعه أو بعضه. نعم إن قال: ضمنا مالك على زيد فكل ضامن للنصف فقط، وإن صح أن الدين لا يتعدد بتعدد الضامن، بل هو واحد تعدد محله كفرض الكفاية، وقال الإمام مالك: لا يطالب الضامن إلا إن عجز الأصل، ولو طالب المستحق الضامن، ف قيل له: اذهب إلى الأصل فطالبه. فقال: لا حق لي عنده فإن جهل إسقاط حقه بذلك، وخفي عليه ولم يرد الإقرار فحقه باق، وإلا سقط مطالبة له على أحد منهما.

(٤٢٥) ومثله الكفالة.

(٤٢٦) أي: أبرأ صاحب الدين الأصل من الدين، وكذا لو أدى الأصل إليه دينه، وإن أقال به أو اعتاض عنه، أو نحو ذلك، برئ الضمان وإن تعدد عن الأصل أو عن بعضهم؛ لأنهم كلهم فروع الأصل، وقد حصلت براءته.

(٤٢٧) أو وليه إن كان محجورا وفائدة المطالبة إحضاره مجلس الحكم، وتقسيقه لو امتنع، وليس له حبسه ولا ملازمته.

(٤٢٨) أي إن الضامن لا يطالب الأصل بتخليصه، ولا يطالب المضمون له بأن يطالب الأصل أو يبرئه من الضمان.

(٤٢٩) أي إن لم يقصد غير جهة الضمان، ولم يؤد من سهم الغارمين، ولم يكن عبدا عن سيده، وإن عتق بعده أو سيدا أدى عن عبده، ولو مكاتبا قبل تعجيزه ولم يكن ما أداه خمر الذمي عن دين ضمنه له عن مسلم،

أَذِنَ فِي الضَّمَانِ فَقَطْ أي: وَلَمْ يَأْذَنْ فِي الْأَدَاءِ **(رَجَعَ فِي الْأَصَحِّ)**؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي سَبَبِ الْغُرْمِ، وَالثَّانِي: يَقُولُ: الْغُرْمُ حَصَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ **(وَلَا عَكْسَ)**، أي: لَا رُجُوعَ فِي الْعَكْسِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ فَقَطْ **(فِي الْأَصَحِّ)**؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ^(٤٣٠)، وَالثَّانِي: يَقُولُ: أَسْقَطَ الدَّيْنَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ **(وَلَوْ أَدَّى مُكْسَرًا عَنْ صِحَاحٍ أَوْ صَالِحٍ عَنْ مِائَةِ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَّا بِمَا غَرِمَ)** وَالثَّانِي: يَرْجِعُ بِالصَّحَاحِ وَالْمِائَةِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ الْبَرَاءَةُ مِنْهُمَا بِمَا فَعَلَ وَالْمُسَامَحَةُ جَرَتْ مَعَهُ. **(وَمَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِلا ضَمَانٍ وَلَا إِذْنٍ فَلَا رُجُوعَ)** لَهُ عَلَيْهِ، **(وَإِنْ أَذِنَ)** لَهُ فِي الْأَدَاءِ **(بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ)** عَلَيْهِ، **(وَكَذَا إِنْ أَذِنَ مُطْلَقًا)** عَنْ شَرْطِ الرُّجُوعِ يَرْجِعُ^(٤٣١) **(فِي الْأَصَحِّ)** لِلْعُرْفِ، وَالثَّانِي قَالَ: لَيْسَ مِنْ صُرُورَةِ الْأَدَاءِ الرُّجُوعُ.

(وَالْأَصَحُّ أَنَّ مُصَالَحَتَهُ) أي: الْمَأْذُونَ **(عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ)**؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْأَذْنِ أَنْ يُبْرَى ذِمَّتُهُ وَقَدْ فَعَلَ، وَالثَّانِي: تَمْنَعُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ دُونَ الْمُصَالَحَةِ، وَعَلَى الرُّجُوعِ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ^(٤٣٢) كَالضَّامِنِ.

(ثُمَّ إِنَّمَا يَرْجِعُ الضَّامِنُ وَالْمُؤَدِّي إِذَا أَشْهَدَ بِالْأَدَاءِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَكَذَا رَجُلٌ) أَشْهَدَهُ كُلُّ مِثْلِهِمَا **(لِيُخْلَفَ مَعَهُ)** فَيَكْفِي **(فِي الْأَصَحِّ)**؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ، وَالثَّانِي يَقُولُ: قَدْ يَتَرَفَعَانِ إِلَى حَنْفِيٍّ لَا يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، **(فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ)** أي: الضَّامِنُ بِالْأَدَاءِ أَوْ أَنْكَرَهُ رَبُّ الدَّيْنِ^(٤٣٣) **(فَلَا رُجُوعَ)** لَهُ **(وَإِنْ أَدَّى فِي غَيْبَةِ الْأَصِيلِ وَكَذَبَهُ، وَكَذَا إِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأَصَحِّ)**؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى تَصَدِيقِهِ **(فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ)** مَعَ تَكْذِيبِ الْأَصِيلِ **(أَوْ أَدَّى)**

وقلنا بالمرجوح من سقوط لدين فلا رجوع في شيء من ذلك، كما لا رجوع له لو لم يغرم المفهوم من تقييده بالغارم، بأن أبراه المحتال خلافا للبلقيني، ولو نذر عدم الرجوع لم يرجع أيضا، كذا قالوا وفي صحة النذر نظر وكذا لا رجوع لو أنكر الضمان، وقامت عليه بينة به وغرم؛ لأنه مظلوم بزعمه ولا يرجع على غير ظالمه.

(٤٣٠) شامل لما لو نهاه عنه، أو عن الأداء بعد الإذن فيه، وقيل في النهي: لا يرجع قطعا ولا عبرة بنية الرجوع إلا من ولي أدى عن محجوره، ولو أذن له في الأداء بعد الضمان بغير إذن بشرط الرجوع، رجع إن قصد الأداء عن الإذن.

(٤٣١) إن لم يقع من المؤدي ضمان بعد الإذن، وإلا فلا رجوع.

(٤٣٢) إن كان أقل من الدين، وإلا رجع بالدين؛ لأن الرجوع بالأقل منهما.

(٤٣٣) أو كذبه الشهود أو قالوا: لا ندري وكذا لو ادعى غيبة الشهود أو فسقهم أو موتهم، وكذبه الأصيل وحلف فإن صدقه رجع عليه، ولو أدى مرة بلا إشهاد ومرة بإشهاد رجع بالأقل منهما.

بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ) مَعَ تَكْذِيبِ الْمَضْمُونِ لَهُ (رَجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ) أَي: الرَّاجِعِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي
الْمَسْأَلَتَيْنِ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ فِي الْأُولَى وَعِلْمِ الْأَصِيلِ بِالْأَدَاءِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّانِي: فِي الْأُولَى يَقُولُ:
تَصَدِّقُ رَبِّ الدِّينِ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى الْأَصِيلِ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقُولُ: لَمْ يَنْتَفِعِ الْأَصِيلُ بِالْأَدَاءِ لِتَرْكِ
الْإِشْهَادِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ بَتَرَكَ الْإِشْهَادَ وَيُقَاسُ بِمَا ذُكِرَ فِي الضَّامِنِ الْمُؤَدِّي فِي الْأَحْوَالِ
الْمَذْكُورَةِ.

كتاب الشركة

[ضبط كلمة الشركة]

كِتَابُ الشَّرْكَةِ ^(٤٣٤) (٤٣٥) بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَحُكِيِّ فَتْحِ الشَّيْنِ وَكَسْرِ الرَّاءِ .

[أنواع الشركة]

(هِيَ أَنْوَاعٌ: شَرَكَةُ الْأَبْدَانِ ^(٤٣٦) كَشَرَكَةِ الْحَمَالَيْنِ وَسَائِرِ الْمُخْتَرِفَةِ) كَالذَّلَالَيْنِ وَالنَّجَارَيْنِ وَالْحَيَّاطَيْنِ (لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا) بِحَرْفَتِهِمَا (مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ) كَمَا ذُكِرَ، (أَوْ اخْتِلَافُهَا) كَالْحَيَّاطِ وَالرَّفَاءِ وَالنَّجَّارِ وَالْخَرَّاطِ.

[شركة المفاوضة]

(وَشَرَكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ^(٤٣٧)) يَفْتَحُ الْوَاوُ: بِأَنْ يَشْتَرِكَا (لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا) قَالَ الشَّيْخُ فِي التَّنْبِيهِ: بِأَمْوَالِهِمَا ^(٤٣٨) وَأَبْدَانِهِمَا ^(٤٣٩)، (وَعَلَيْهِمَا مَا يَغْرِضُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (مِنْ غَرَمٍ ^(٤٤٠)) وَسُمِّيَتْ مُفَاوَضَةً مِنْ تَفَاوُضًا فِي الْحَدِيثِ شَرَعًا فِيهِ جَمِيعًا.

[شركة الوجوه]

(٤٣٤) وهي في اللغة: الاختلاط والامتزاج.

وفي الشرع: ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنتين فصاعدًا على جهة الشبوع. النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/٧)

(٤٣٥) هي اسم مصدر لأشرك، ومصدره الإشراك، ويقال لمن أثبتتها مشرك وشريك، لكن العرف خصص الإشراك والمشارك بمن جعل لله شريكا.

(٤٣٦) جوزها أبو حنيفة مطلقا ومالك وأحمد مع اتحاد الحرفة قال بعضهم: والوجه أنه ليس من الشركة وإنما له حكمها وهو ظاهر حيث انفرد كل لواحد، وكذا يقال: فيما بعدها ثم على البطلان، فما انفرد أحدهما بكسبه، فهو له وما اشتركا فيه يوزع عليهما بنسبة أجرة المثل.

(٤٣٧) جوزها أبو حنيفة.

(٤٣٨) أي من غير خلطهما.

(٤٣٩) عبارة غيره أو أبدانها وهي تفيد أنها تكون بالأبدان فقط، أو الأموال فقط أو بهما معا يجعلها مانعة خلق.

(٤٤٠) أي ولو بغير الشركة كغصب ونحوه.

(وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ^(٤٤١)) بِأَنْ يَشْتَرِكَ الْوَجِيهَانِ لِيَنْتَاعَ كُلُّ مِنْهُمَا بِمُؤَجَّلٍ^(٤٤٢)، وَيَكُونُ الْمُتَبَاعُ (لَهُمَا فَإِذَا بَاعَا كَانَ الْفَاضِلُ عَنِ الْأَثْمَانِ) الْمُتَبَاعِ بِهَا (بَيْنَهُمَا، وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ) الثَّلَاثَةُ (بَاطِلَةٌ) وَيَخْتَصُّ كُلُّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بِمَا يَكْسِبُهُ بِيَدَيْهِ، أَوْ مَالِهِ أَوْ يَشْتَرِيهِ.

[المراد بشِرْكَةُ الْعِنَانِ وحكمها]

(وَشِرْكَةُ الْعِنَانِ صَحِيحَةٌ^(٤٤٣)) وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي مَالٍ لَهُمَا لِيَنْتَجِرَا فِيهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَالْعِنَانُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ^(٤٤٤) مِنْ عَنِ الشَّيْءِ ظَهَرَ^(٤٤٥)، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ.

[بيان الصيغة والإذن بالتصرف]

(وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظُ^(٤٤٦) يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ) مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا لِلْآخِرِ^(٤٤٧)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّصَرُّفَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي التِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ، (فَلَوْ اقْتَصَرَا

(٤٤١) من الوجاهة أي العظمة والصدقة لا من الوجه.

(٤٤٢) هذا أشهر ما فسرت به وفسرت بأن يشترك وجيه، وخامل إما بأن الوجيه يشتري، والخامل يبيع، أو بأن يعمل الوجيه والمال للخامل في يده، أو يدفعه إلى الوجيه ليبيعه بزيادة، وعلى كل يكون الربح بينهما.

(٤٤٣) لخبر السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مرحباً بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري". قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٩٤ / ١): "رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح" ففي ذكره صلى الله عليه وسلم للشركة دليل على جوازها؛ لأنه تقرير لما وقع قبله، وللإجماع على ذلك، ولسلامتها من كل أنواع الغرر.

(٤٤٤) وقيل بفتحها والأصح في فتحها أنه من عنان السماء أي سحابها؛ لأنها علت كالسمااء بصحتها وشهرتها للاتفاق عليها.

(٤٤٥) لأنها أظهر الأنواع أو؛ لأن مال كل ظهر للآخر. وقال السبكي: أو من عنان الدابة لاستواء الشريكين في التصرف والفسخ والربح بقدر المالين، كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل من الشريكين، الآخر من التصرف كمنع العنان للدابة أو لمنع الشريك نفسه من التصرف مع أنه لا حجر عليه، كمنع أخذ عنان الدابة يده التي فيها العنان من التصرف كيف شاء دون الأخرى.

(٤٤٦) المراد بالشرط ما لا بد منه أو الشرطية متوجهة إلى دلالة اللفظ، لا إليه؛ لأنه صيغة العقد وهي ركن كالعاقدين والمعقود عليه فأركانها أربعة، وأما العمل فأمر خارج عنها يترتب عليها بعد، وجودها فجعله من الأركان كما في المنهج فيه نظر.

(٤٤٧) أي مع عدم رد الآخر كأن يقول كل منهما للآخر: اتجر أو بع واشتر أو تصرف بيعة وشراء، لا تصرف فقط خلافاً لابن حجر إلا إن حمل على ما يأتي، فإن قال أحدهما للآخر ذلك تصرف القائل في نصيبه فقط والآخر في الجميع.

عَلَى اشْتَرَكْنَا لَمْ يَكْفِ فِي الْإِذْنِ الْمَذْكُورِ ^(٤٤٨) **(فِي الْأَصَحِّ)** لِقُصُورِ اللَّفْظِ عَنْهُ، وَالثَّانِي يَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْهُ عُرْفاً **(و)** يُشْتَرَطُ **(فِيهِمَا أَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ وَالتَّوَكُّلِ)**، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَكَيْلٌ فِي مَالِهِ عَنْ الْآخَرِ.

[الشركة في المثلي]

(وَتَصِحُّ) الشَّرَكَةُ (فِي كُلِّ مِثْلِي) نَقْدٍ وَغَيْرِهِ كَالْحِنْطَةِ (دُونَ الْمُتَقَوِّمِ) بِكُسْرِ الْوَاوِ كَالثِّيَابِ، (وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ) مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ، وَفِي جَوَازِهَا فِي الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَجِهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرُّوْضَةِ: الْجَوَازُ إِنْ اسْتَمَرَ فِي الْبَلَدِ رَوَاجُهَا، وَلَا يَجُوزُ فِي التَّبَرِّ وَفِيهِ وَجْهٌ فِي النَّتْمَةِ.

[شروط مال الشركة]

(وَيُشْتَرَطُ خَلْطُ الْمَالَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ) وَيَكُونُ الْخَلْطُ قَبْلَ الْعَقْدِ، فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ فِي مَجْلِسِهِ فَوَجْهَانِ فِي النَّتْمَةِ أَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ، أَيْ: فَيَعَادُ الْعَقْدُ، (وَلَا يَكْفِي الْخَلْطُ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسِ) كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ (أَوْ صِفَةِ كَصِحَاحٍ وَمُكْسَرَةٍ) وَحِنْطَةٍ حَمْرَاءَ وَحِنْطَةٍ بَيْضَاءَ، فَلَا تَصِحُّ الشَّرَكَةُ فِي ذَلِكَ (هَذَا) أَيْ: اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ ^(٤٤٩) (إِذَا أَخْرَجَا مَالَيْنِ وَعَقَدَا فَإِنْ مَلَكَا مُشْتَرَكًا) مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرَكَةُ (بِإِزِثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا وَأَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ تَمَثَّ الشَّرَكَةُ)؛ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ بِالْخَلْطِ حَاصِلًا، (وَالْحِيلَةُ فِي الشَّرَكَةِ فِي الْعُرُوضِ ^(٤٥٠)) مِنْ الْمُتَقَوِّمِ ^(٤٥١) كَالثِّيَابِ (أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (بِبَعْضٍ عَرْضِهِ بَعْضَ عَرْضِ الْآخَرِ وَيَأْذَنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ) بَعْدَ التَّقَابُضِ ^(٤٥٢)، وَالبَعْضُ كَالنِّصْفِ بِالنِّصْفِ، وَالثَّلْثُ بِالثَّلْثَيْنِ. وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِقِيمَةِ الْعَرْضَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ فِي الرُّوْضَةِ، وَسَوَاءٌ تَجَانَسَا أَمْ اخْتَلَفَا. وَقَوْلُهُ: كُلُّ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ فِي الْإِذْنِ وَنِسْبَةِ الْبَيْعِ إِلَيْهِ

(٤٤٨) أي فلا شركة. نعم إن نويًا به الإذن في التصرف كما فيها كفى قاله السبكي.

(٤٤٩) أفاد أن كلامه في المثلي، وهو المراد بقوله مما تصح فيه الشركة، وإنما قصر عليه لأجل العلة المذكورة، ولذكره المتقوم بعده، لا للاحتراز عن المتقوم من حيث صحة الشركة.

(٤٥٠) أي وكذا النقود إذا اختلفت جنسًا أو صفة.

(٤٥١) بيان المراد من العروض ليخرج العروض المثالية.

(٤٥٢) متعلق بالإذن فهو بعد العقد، وهذا الإذن كافٍ عن عقد الشركة، فلو شرط الشركة حالة العقد لم يصح العقد.

بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُشْتَرِي بِتَأْوِيلِ أَنَّهُ بَائِعٌ لِلثَّمَنِ، **(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّرْكَةِ تَسَاوِي قَدْرِ الْمَالَيْنِ)** أَي: تَسَاوِيهِمَا فِي الْقَدْرِ كَمَا فِي الْمَحَرَّرِ وَغَيْرِهِ^(٤٥٣)، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ لِلتَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ) أَي: بِقَدْرِ كُلِّ مِّنَ الْمَالَيْنِ أَهْوِ النَّصْفِ أَمْ غَيْرُهُ إِذَا أُمِكنَ مَعْرِفَتُهُ مِنْ بَعْدُ، وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَالٌ مُشْتَرَكٌ كُلُّ مِنْهُمَا جَاهِلٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهُ، فَأَذِنَ كُلُّ مِنْهُمَا لِلْآخِرِ فِي التَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِهِ مِنْهُ يَصِحُّ الْإِذْنُ فِي الْأَصَحِّ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا مُبَهَمًا كَالْمُتَمَّنِّ، **(وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ فَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً وَلَا بَغِيرَ نَقْدِ الْبَلَدِ^(٤٥٤))**، وَلَا بَغْنٍ فَاحِشٍ، وَلَا يُسَافِرُ بِهِ، وَلَا يُبْضَعُهُ بِضَمِّ التَّحْنَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَي: يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا **(بَغَيْرِ إِذْنٍ)** هُوَ قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ، فَإِنْ أَبْضَعَهُ أَوْ سَافَرَ بِهِ ضَمِنَ، وَإِنْ بَاعَ بَغْنٍ فَاحِشٍ لَمْ يَصِحَّ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَفِي نَصِيبِهِ قَوْلًا تَفْرِيقُ الصَّفَقَةِ، فَإِنْ فَرَّقْنَاهَا انْفَسَخَتْ الشَّرْكَةُ فِي الْمَبِيعِ وَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ كَذَا فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُقَاسُ بِالْبَغْنِ الْبَيْعُ نَسِيئَةً، وَبَغِيرَ نَقْدِ الْبَلَدِ، **(وَلِكُلِّ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ فُسْخُهُ)** أَي: عَقْدُ الشَّرْكَةِ **(مَتَى شَاءَ)** كَالْوَكَالَةِ **(وَيَنْعَزِلَانِ عَنِ التَّصَرُّفِ جَمِيعًا)** **(بِفُسْخِهِمَا)** أَي: بِفُسْخِ كُلِّ مِنْهُمَا **(فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا) لِلْآخِرِ (عَزَلْتُكَ أَوْ لَا تَتَصَرَّفُ فِي نَصِيبِي لَمْ يَنْعَزِلِ الْعَازِلُ)** فَيَتَصَرَّفُ فِي نَصِيبِ الْمَعْرُولِ.

[ما تنفسخ به الشركة]

(وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ) كَالْوَكَالَةِ

[مقدار الربح للشريكين في العمل]

(وَالرَّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ تَسَاوِيًا) أَي: الشَّرِيكَانِ **(فِي الْعَمَلِ، أَوْ تَفَاوُتًا)** فِيهِ **(فَإِنْ شَرَطًا خِلَافَهُ)** أَي: التَّسَاوِي فِي الرَّبْحِ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْمَالِ، أَوْ التَّفَاوُتِ فِي الرَّبْحِ مَعَ التَّسَاوِي

(٤٥٣) أشار إلى أن المراد من عبارة المصنف، ما في أصله لا إنها مساوية لها، كما قيل: إذ لا تصح نسبة التفاعل للمفرد.

(٤٥٤) وإن راج بخلاف عامل القراض؛ لأنه لا يضييق عليه في حصته من الربح، والمراد بنقد البلد ما يتعامل به فيها، ولو عروضاً فيصح به البيع وإن لم يرج. ولا يسافر به أي لغير ضرورة كنهب.

فِي الْمَالِ (فَسَدَ الْعَقْدُ، فَيَرْجِعُ كُلٌّ عَلَى الْآخَرِ بِأَجْرَةِ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ، وَتَنْفُذُ التَّصَرُّفَاتِ) مِنْهُمَا لِلْإِذْنِ (وَالرِّبْحِ) بَيْنَهُمَا (عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ) رُجُوعًا إِلَى الْأَصْلِ

[الشريك أمين]

(وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ^(٤٥٥)) إِلَى شَرِيكِهِ (وَالْخُسْرَانُ وَالتَّلَفُ) إِنْ ادَّعَاهُ بِلَا سَبَبٍ، أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيَ كَالسَّرِقَةِ (فَإِنْ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ) كَالْحَرِيقِ وَجَهْلٍ (طَوْلَبَ بَيِّنَةً بِالسَّبَبِ، ثُمَّ) بَعْدَ إِقَامَتِهَا (يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ) وَسَيَأْتِي فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ غَيْرُ الْخُسْرَانِ فِي الْمَوْدِعِ الْيَمِينِ، وَأَنَّهُ إِنْ عَرَفَ الْحَرِيقَ وَعُمُومَهُ صَدَقَ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ عَرَفَ دُونَ عُمُومِهِ صَدَقَ بِيَمِينِهِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا وَكَذَا الْيَمِينُ فِي الْخُسْرَانِ.

[التنازع بين الشريكين في مال الشركة]

(وَلَوْ^(٤٥٦)) قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (هُوَ لِي، وَقَالَ الْآخَرُ:) هُوَ (مُشْتَرِكٌ أَوْ) قَالَا (بِالْعَكْسِ) أَيُّ: قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ: هُوَ مُشْتَرِكٌ وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ لِي (صَدِيقٌ صَاحِبُ الْيَدِ) عَمَلًا بِهَا.

[تنازع الشريك مع شريكه في التقسيم]

(وَلَوْ قَالَ) صَاحِبُ الْيَدِ: (اِفْتَسَمْنَا وَصَارَ) مَا فِي يَدِي (لِي) وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَقَالَ هُوَ مُشْتَرِكٌ (صَدِيقُ الْمُنْكَرِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ

[ادعى الشريك أنه اشترى شيئًا للشركة أو لنفسه وكذبه شريكه]

(وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا، وَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِي وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ) بِأَنْ عَكَسَ مَا قَالَهُ (صَدِيقُ الْمُشْتَرِي)؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمَ بِقَصْدِهِ، وَتَأْتِي الْيَمِينُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَيْضًا.

(٤٥٥) أي لحصة شريكه فلو ادعى أن حصته في المردود باقية، لم يقبل سواء رد الكل أو البعض.

(٤٥٦) في نسخة الزحيلي [وإن].

كتاب الإقرار (٤٥٧)

أَي: الاعْتِرَافِ (٤٥٨)

[إقرار مطلق التصرف]

(يَصِحُّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ) (٤٥٩) أَي: الْبَالِغُ الْعَاقِلُ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، وَسَيِّئَاتِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ مُكْرَهٍ.

[إقرار الصبي والمجنون]

(وَأَقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا غ) ذَكَرَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا أَوْ أُنْتَى

[إدعاء الصبي البلوغ بالاحتلام]

(فَإِنْ ادَّعَى) الصَّبِيُّ (الْبُلُوغَ بِالِاخْتِلَامِ مَعَ الْإِمْكَانِ) لَهُ بِأَنْ اسْتَكْمَلَ تِسْعَ سِنِينَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ صَدَقَ فِي ذَلِكَ. (وَلَا يَخْلِفُ) عَلَيْهِ إِذَا فُرِضَ ذَلِكَ فِي خُصُومَةٍ بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَدَعَاى الصَّبِيَّةُ الْبُلُوغَ بِالْحَيْضِ فِي وَقْتِ إِمْكَانِهِ وَهُوَ تِسْعَ سِنِينَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَيْضِ كَذَلِكَ

[إدعاء البلوغ بالسن]

(وَإِنْ ادَّعَى بِالسِّنِّ) بِأَنْ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَمَا تَقَدَّمَ (طُولِبَ بَيِّنَةٌ) عَلَيْهِ لِإِمْكَانِهَا (وَالسَّفِيَّةُ وَالْمُفْلِسُ سَبَقَ حُكْمُ إِقْرَارِهِمَا) فِي بَابِ الْحَجْرِ وَالنَّفْلِيسِ

(٤٥٧) في اللغة: الإثبات، من قولهم: قر الشيء يقر قرارًا إذا ثبت.

وفي الشرع: إخبار عن وجوب حق عليه بسبب سابق، فإن كان بحق له على غيره .. فهو الدعوى، وإن كان بحق لغيره على غيره .. فهو الشهادة، هذا إذا كان خاصًا، فإن اقتضى شرعًا عامًا، فإن كان عن أمر محسوس .. فهو الرواية، وإن كان عن حكم شرعي .. فهو الفتوى، ويسمى الإقرار اعتراقًا. والأصل في الباب: قوله تعالى: {قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا}. النجم الوهاج في شرح المنهاج (٧٩ / ٥)

(٤٥٨) تفسير بالمرادف لدفع توهم إرادة التقرير، أو عدم الاعتراض، أو لموافقة حديث: «فإن اعترفت فارجمها».

(٤٥٩) يعني: المقر، وهو أحد أركانه الأربعة التي هي: المقر والمقر له، والمقر به والصيغة.

[إقرار الرقيق بمُوجب عقوبة]

(وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الرَّقِيقِ^(٤٦٠) بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ كَالْقَتْلِ وَقَطْعِ الطَّرْفِ، وَالزَّئِي وَشُرْبِ
الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ، لِبُعْدِهِ عَنِ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَجْبُودَةٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ،
وَالِاخْتِرَارِ عَنِ الْأَلَامِ وَأَظْهَرَ الْقَوْلَيْنِ، أَنَّهُ يَضْمَنُ مَالَ السَّرِقَةِ فِي ذِمَّتِهِ تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ
أَوْ يَدِ السَّيِّدِ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهَا، فَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَالثَّانِي: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ

[إقرار الرقيق بدين جنابة لا يوجب عقوبة]

(وَلَوْ أَقَرَّ بَدَيْنِ جَنَابَةٍ لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً) كَجَنَابَةِ الْخَطَا وَإِتْلَافِ الْمَالِ (فَكَذَبَهُ السَّيِّدُ) فِي ذَلِكَ
(تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ) يُتَّبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ وَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ
السَّيِّدُ بِأَقْلٍ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَقَدَرِ الدَّيْنِ، وَإِذَا بَاعَ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ لَا يُتَّبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ

[إقرار الرقيق بدين معاملة]

(وَإِنْ أَقَرَّ بَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى السَّيِّدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَادُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ) بَلْ يَتَعَلَّقُ الْمُقَرُّ
بِهِ بِذِمَّتِهِ يُتَّبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ أَمْ لَا (وَيُقْبَلُ) عَلَى السَّيِّدِ (إِنْ كَانَ) مَادُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ
(وَيُؤَدِّي مِنْ كَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ
كَالْقَرْضِ فَلَا يُقْبَلُ عَلَى السَّيِّدِ وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ حَجْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ أَصَافَهُ إِلَى حَالِ الْإِذْنِ
لَمْ تُقْبَلْ إِصَافَتُهُ فِي الْأَصَحِّ قَبْلَ الْحَجْرِ لَوْ أُطْلِقَ الْإِقْرَارُ بِالَّذِينَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَى دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ فِي
الْأَصَحِّ.

[إقرار المريض مرض الموت]

(وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضِ الْمَوْتِ^(٤٦١) لِأَجْنَبِيٍّ) بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ^(٤٦٢) (وَكَذَا الْوَارِثُ عَلَى
الْمَذْهَبِ^(٤٦٣)) وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ بِجُرْمَانِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي:

(٤٦٠) خلافا للمزني والإمام أحمد، والمكاتب كالحر والمبعض في بعضه الحر كالحر، وفي الرقيق كالرقيق وإن كانت مهابة، ولا يلزمه دفع ما يقابل الرق من ماله نعم إن كان عن معاملة يصح تصرفه فيها فهو كالحر فيقضي مما في يده على ما فيه.

(٤٦١) ويحسب ما أقر به من رأس المال إلا نحو هبة أو إبراء أطلقه، فيحمل على وقوعه في المرض فيحسب من الثلث.

الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِيِ الْإِعْتِبَارُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِحَالِ الْمَوْتِ، وَفِي قَوْلِ بِحَالِ الْإِقْرَارِ، وَعَلَيْهِ
لَوْ أَقَرَّ لِرَوْجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا وَمَاتَ لَمْ يُعْمَلْ بِإِقْرَارِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَاتَ عَمِلَ بِإِقْرَارِهِ

[الإقرار بالدين في الصحة والمرض]

(وَلَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ بِدَيْنٍ) لِلْإِنْسَانِ (وَفِي مَرَضِهِ) بِدَيْنٍ (لَا خَرَّ لَمْ يُقَدِّمُ الْأَوَّلُ) بَلْ
يَنْتَسَاوِيَانِ^(٤٦٤)، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ، (وَلَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ) بِدَيْنٍ
لِرَجُلٍ (وَأَقَرَّ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) بِدَيْنٍ (لَا خَرَّ لَمْ يُقَدِّمُ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ^(٤٦٥))؛ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْوَارِثِ
كَإِقْرَارِ الْمُوَرِّثِ، فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِالَّذَيْنِ^(٤٦٦). وَالثَّانِي: يُقَدِّمُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ تَعَلَّقَ بِالتَّرَكَةِ فَلَيْسَ
لِلْوَارِثِ صَرْفُهَا عَنْهُ (وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ مُكْرَهٍ^(٤٦٧)) عَلَى الْإِقْرَارِ^(٤٦٨)

[أهلية المقر لاستحقاق المقر به]

(٤٦٢) قيد بهما؛ لأنهما محل الخلاف في الإقرار للوارث المعطوف عليه، فلا يرد أنه يصح إقراره بموجب عقوبة
ونكاح وغيرهما.

(٤٦٣) خلافاً للأئمة الثلاثة، ولغيره من الورثة تحليفه أن الإقرار عن حقيقة، وكذا لهم تحليف الأجنبي على
المعتمد وإذا نكل من طلب تحليفه حلفوا وبطل الإقرار. ومنه إقراره بقبض دين له على وارث، وقبضها
صداقها من زوجها.

(٤٦٤) خلافاً لأبي حنيفة، نعم يقدم إقرار بعين على دين ولو قضى دين بعض الغرماء لم يشاركه غيره فيه.
(٤٦٥) أي فيتساويان من حيث صحة الإقرار وإن كان المقر له بالعين يقدم بأخذها ولو على نحو مؤنة تجهيزه
مثلاً.

(٤٦٦) فلو كان المقر به ديناً واحداً أقر به المريض لشخص، والوارث لشخص آخر، لم يصح الإقرار للثاني ولا
غرم له. وكذا يقال في العين، وكذا لو أقر المريض بعين لواحد ثم لآخر، ولا غرم للثاني أيضاً على
المعتمد.

(٤٦٧) لقوله تعالى: [مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ] [النحل: ١٠٦] ولما رواه
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ابن حبان.

(٤٦٨) ويقبل قوله في الإكراه مع قرينة، وتقدم ببينته على بينة الاختيار إن لم تشهد بتقدم إكراه عليه.

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرَّرِ لَهُ أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ^(٤٦٩) الْمُقَرَّرِ بِهِ فَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ الدَّابَّةُ عَلَيَّ كَذَا فَلَعُوْ)؛
لَأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلِاسْتِحْقَاقِ **(فَلَوْ قَالَ):** عَلَيَّ **(بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا) كَذَا (وَجَبَ)** وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ جَنَى
عَلَيْهَا أَوْ اكْتَرَاهَا

[الإقرار للحمل]

(وَلَوْ قَالَ لِحَمَلِ هُنْدٍ) عَلَيَّ أَوْ عِنْدَهُ (وَكَذَا بِإِثْرِ) عَنْ أَبِيهِ مَثَلًا (أَوْ وَصِيَّةً) لَهُ مِنْ فُلَانٍ
(لَزِمَهُ) ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا أَسْنَدَ إِلَيْهِ مُمَكِّنٌ **(وَإِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ) كَقَوْلِهِ:** أَقْرَضَنِيهِ
أَوْ بَاعَنِي بِهِ شَيْئًا **(فَلَعُوْ) وَقِيلَ:** صَحِيحٌ وَيَلْعُو الْإِسْنَادُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ. وَقِيلَ: فِيهِ قَوْلًا تَعْقِبُ
الْإِقْرَارَ بِمَا يَرْفَعُهُ وَفِي الشَّرْحِ تَصْحِيحُ الطَّرِيقِ الثَّانِي: وَتُسَبِّهُ فِي الرُّوْضَةِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ الْبُطْلَانُ
وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ. **(وَإِنْ أُطْلِقَ) أَي:** لَمْ يُسْنَدْ إِلَى شَيْءٍ **(صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ).** وَيُحْمَلُ عَلَى
الْجِهَةِ الْمُمَكِّنَةِ فِي حَقِّهِ وَالثَّانِي: يَقُولُ لَا ضَرُورَةَ إِلَى ذَلِكَ، وَعَلَى الصِّحَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ إِنَّمَا
يَسْتَحَقُّ الْحَمْلُ إِذَا انفصلَ حَيًّا^(٤٧٠) لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ^(٤٧١) أَوَّلُهَا فَأَكْثَرُ إِلَى دُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَأُمُّهُ
غَيْرُ فِرَاشٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَصَايَا ثُمَّ إِنْ أُسْتُحِقَّ بِوَصِيَّةٍ فَلَهُ الْكُلُّ أَوْ بِإِثْرِ عَنْ الْأَبِ وَهُوَ
ذَكَرَ فَكَذَلِكَ أَوْ أَنْتَى فَلَهَا النِّصْفُ أَوْ أَنْتَى فَلَهَا النِّصْفُ

(إِذَا كَذَبَ الْمُقَرَّرُ لَهُ الْمُقَرَّرُ) بِمَالٍ كَثُوبٍ (تَرَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ^(٤٧٢) فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ يَدَهُ تُشْعِرُ
بِالْمِلْكِ ظَاهِرٌ أَوْ سَقَطَ إِقْرَارُهُ بِمُعَارَضَةِ الْإِنْكَارِ، وَالثَّانِي: يَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ وَيَحْفَظُهُ إِلَى ظُهُورِ
مَالِكِهِ.

[رجوع المقرَّر في قوله في حال تكذيبه]

(٤٦٩) وكذا تعيينه ولو في محصور كأحد هؤلاء أو أهل البلد وهم محصورون، ويعين من شاء ممن ذكر فإن
قال أحدهم هو أنا وخالفه المقر صدق المقر ولو لم ينحصر ولم يصح، وينزعه الحاكم منه؛ لأنه مال
ضائع ما لم يدع أنه لقطة.

(٤٧٠) فإن انفصل ميتا فالوجه أن يسأل المقر، فإن أسنده لنحو إرث أو وصية عمل بتفسيره، فإن تعذر بطل
ولو ولدت حيا وميتا فالميت كالعدم.

(٤٧١) أي من وقت الوصية أو الموت إن علم وإلا فمن وقت الإقرار.

(٤٧٢) على جهة الملكية فله التصرف فيه لو كان عينا حتى لو كان أمة فله وطؤها إلا إن علم أنه للمقر له.

(فَإِنْ رَجَعَ الْمُقَرُّ فِي حَالِ تَكْذِيبِهِ^(٤٧٣) وَقَالَ: غَلِطْتُ) فِي الْإِقْرَارِ (قُبْلَ قَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَالَ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ، وَالثَّانِي: لَا بِنَاءَ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْتَرِعُهُ مِنْهُ وَإِنْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ وَصَدَّقَ الْمُقَرَّرُ، وَبَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ يُعْمَلُ فِي يَدِهِ لَا يُسَلَّمُ لِلْمُقَرَّرِ لَهُ إِلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ، وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْتَرِعُهُ لَا يُسَلَّمُ إِلَيْهِ، وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ مُلْكُهُ لَمْ تُسْمَعْ.

(٤٧٣) ليس قيدا فبعد رجوع المقر له كذلك.

(فصل) [في صيغة الإقرار]

[صيغة الإقرار بالدين والعين]

(قَوْلُهُ: لَزَيْدٍ كَذَا) عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي (صِيغَةُ إِقْرَارٍ^(٤٧٤))، وَقَوْلُهُ: عَلَيَّ وَفِي ذِمَّتِي لِلدَّيْنِ وَمَعِي وَعِنْدِي لِلْعَيْنِ) أَي: مَحْمُولٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ حَتَّى إِذَا ادَّعَى أَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَأَنَّهَا تَلَقَّتْ قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ الرَّوْضَةُ عَنِ الْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّهُ.

[من صيغ الإقرار: الإجابة ببلى ونعم]

(وَلَوْ قَالَ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ، فَقَالَ: زَنْ، أَوْ خُذْ أَوْ زِنْهُ أَوْ خُذْهُ أَوْ اخْنَمْ عَلَيْهِ أَوْ اجْعَلْهُ فِي حَبْسِكَ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُذَكِّرُ لِلِاسْتِهْزَاءِ (وَلَوْ قَالَ: بَلَى أَوْ نَعَمْ أَوْ صَدَقْتَ أَوْ أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ أَوْ قَضَيْتَهُ، أَوْ أَنَا مُقَرَّرٌ بِهِ فَهُوَ إِقْرَارٌ) بِالْأَلْفِ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ، وَلِلرَّافِعِيِّ فِي الْآخِرِ بَحْثٌ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْإِقْرَارَ لِغَيْرِهِ، فَيَضُمُّ إِلَيْهِ لَكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّوْضَةِ.

[صيغ للإقرار مختلف فيها]

(وَلَوْ قَالَ: أَنَا مُقَرَّرٌ، أَوْ أَنَا أَقَرُّ بِهِ، فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ) بِالْأَلْفِ؛ لِاخْتِمَالِ الْأَوَّلِ [لِلْإِقْرَارِ] بِغَيْرِهِ كَوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالثَّانِي: لِلْوَعْدِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ بَعْدُ.

[الجواب بنعم وبلى، هل هو إقرار؟]

(وَلَوْ قَالَ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا؟ فَقَالَ: بَلَى أَوْ نَعَمْ فَأِقْرَارٌ، وَفِي نَعَمْ وَجْهٌ) أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلتَّصَدِيقِ فَيَكُونُ مُصَدِّقًا لَهُ فِي النَّفْيِ بِخِلَافِ بَلَى فَإِنَّهُ لِرَدِّ النَّفْيِ، وَنَفْيُ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْإِقْرَارِ إِلَى الْعُرْفِ وَأَهْلُهُ يَفْهَمُونَ الْإِقْرَارَ بِنَعَمْ فِيمَا ذَكَرَ.

(وَلَوْ قَالَ: اقْضِ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ أَوْ أَقْضِي غَدًا، أَوْ أَمْهَلْنِي يَوْمًا أَوْ حَتَّى أَقْعُدَ أَوْ أَفْتَحَ الْكَيْسَ أَوْ أَجِدَ) أَي: الْمِفْتَاحَ مَثَلًا (فَأِقْرَارٌ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يَقُولُ: لَيْسَ بِصَرِيحَةٍ فِيهِ.

(٤٧٤) أي إن لم يقل فيما أعلم أو أظن، وإلا فلعنو.

(فصل): [في شروط المقر به]

(يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَلَكًا لِلْمُقَرِّ) حِينَ يَقَرُّ (فَلَوْ قَالَ: دَارِي، أَوْ ثَوْبِي أَوْ دِينِي
الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو فَهُوَ لَعَوٌّ)؛ لِأَنَّ الْإِصَافَةَ [لِلْيَدِ] تَقْتَضِي الْمَلِكَ لَهُ فَتَتَأْفَى الْإِقْرَارُ لِغَيْرِهِ إِذْ هُوَ
إِحْبَارٌ بِسَابِقٍ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْوَعْدِ بِالْهَبَةِ، وَلَوْ قَالَ: مَسْكَنِي لِزَيْدٍ فَهُوَ إِقْرَارٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ
يَسْكُنُ مَلِكٌ غَيْرَهُ.

(وَلَوْ قَالَ: هَذَا) التَّوْبُ (لِفُلَانٍ وَكَانَ مِلْكِي إِلَى أَنْ أَفْرَزْتُ) بِهِ (فَأَوَّلُ كَلَامِهِ إِقْرَارٌ وَآخِرُهُ لَعَوٌّ)
فَيُطْرَحُ آخِرُهُ وَيُعْمَلُ بِأَوَّلِهِ.

(وَلَيْكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ) الْمُعَيَّنُ (فِي يَدِ الْمُقَرِّ لِيُسَلَّمَ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ) فِي الْحَالِ،

[أقر بشيء ليس في يده ثم صار في يده]

(فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ثُمَّ صَارَ) فِي يَدِهِ (وَعَمَلٌ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ) بِأَنْ يُسَلَّمَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فِي
الْحَالِ،

[أقر بحرية عبد ثم اشتراه]

(فَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكْمَ بِحُرِّيَّتِهِ) فَتَرْفَعُ يَدُهُ عَنْهُ. (ثُمَّ إِنْ كَانَ قَالَ)
فِي صِيغَةِ إِقْرَارِهِ (هُوَ حُرٌّ الْأَصْلُ فَشِرَاؤُهُ افْتِدَاءٌ) لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ،
(وَإِنْ) كَانَ (قَالَ اعْتَقَهُ) وَهُوَ يَسْتَرْفُهُ (فَافْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ)
وَقِيلَ: بَيْعٌ مِنْ الْجِهَتَيْنِ (فَيُثَبِّتُ فِيهِ) عَلَى الْأَوَّلِ (الْخِيَارَانِ) أَيُّ: خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ
(لِلْبَائِعِ فَقَطْ) وَكَذَا يَثْبُتَانِ لَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ.

[حكم الإقرار بالمجهول]

(وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ^(٤٧٥)) وَيُطْلَبُ مِنَ الْمُقَرِّ تَفْسِيرُهُ

(٤٧٥) بالمجهول الشامل للمبهم كأحد العبدین.

[قال له عليّ شيءٌ وفسره بما لا يتمول]

(فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِكُلِّ مَا يَتَمُولُ، وَإِنْ قَالَ) كَرِغِيفٍ، وَفَلْسٍ (وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَا لَا يَتَمُولُ لَكِنَّهُ مِنْ جَنْسِهِ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ، أَوْ بِمَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ كَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ) لِلصَّيْدِ (وَسِرْجَيْنِ) أَي: زَبْلٍ (٤٧٦) (قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ اخْذُهُ وَيَجِبُ عَلَى اخْذِهِ رَدُّهُ^(٤٧٧)، وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا قِيَمَةَ لَهُ فَلَا يَصِحُّ التَّزَامُهُ بِكَلِمَةِ عَلَيَّ، وَالثَّانِي: لَيْسَ بِمَالٍ وَظَاهِرُ الْإِقْرَارِ لِلْمَالِ (وَلَا يُقْبَلُ) تَفْسِيرُهُ (بِمَا لَا يُقْتَنَى) كَكَلْبٍ وَخَنْزِيرٍ لَا نَفْعَ فِيهِ مِنْ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ إِذَا لَا يَجِبُ رَدُّهُ فَلَا يُصَدَّقُ بِهِ قَوْلُهُ عَلَيَّ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ فَيُصَدَّقُ بِهِ

[الإقرار بفضائل الأعمال]

(وَلَا) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ أَيْضًا (بِعِيَادَةٍ، وَرَدٍّ سَلَامٍ) لِبُعْدِ فَهْمِهِمَا فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ إِذَا لَا مُطَابَقَةَ بِهِمَا.

[أقر بمال عظيم أو كبير]

(وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ أَوْ مَالٍ عَظِيمٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِمَا قَلَّ مِنْهُ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ، وَيَكُونُ وَضْعُهُ بِالْعَظَمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّمَا غَاصِبُهُ وَكُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ

[الإقرار بالمستولدة]

(وَكَذَا) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (بِالْمُسْتَوْلَدَةِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَتُسْتَأْجَرُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَبَاعُ، وَالثَّانِي: يَنْظَرُ إِلَى امْتِنَاعِ بَيْعِهَا

[الإقرار بما لا يتمول كجلد ميتة أو خنزير]

(لَا بِكَلْبٍ وَجِلْدٍ مَيِّتَةٍ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَصَدَّقُ عَلَيْهِمَا اسْمُ الْمَالِ، وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ إِذَا قَالَ لَهُ: عَلَيَّ مَالٌ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْهُ الْمَقْبُولُ بِالْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْمُنَاسِبُ فِيهَا أَنْ يَقُولَ لَهُ: عِنْدِي مَالٌ.

[الإقرار بجملة له كذا]

(٤٧٦) السرجين والسرقين بكسر السين وفتحها عجمي معرب وهو الزبل. دقائق المنهاج (ص: ٦٣)

(٤٧٧) ومنه ميتة لمضطر وخمرة غير محترمة لذمي.

(وَقَوْلُهُ) لَهُ (كَذَا) عَلَيَّ (كَقَوْلِهِ) لَهُ (شَيْءٌ) عَلَيَّ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ.

[الإقرار بتكرار الجملة على سبيل التأكيد أو التعدد]

(وَقَوْلُهُ شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ كَذَا كَذَا كَمَا لَوْ لَمْ يُكَرَّرْ)؛ لِأَنَّ الثَّانِي: تَأْكِيدٌ.

(وَلَوْ قَالَ شَيْءٌ وَشَيْءٌ أَوْ كَذَا وَكَذَا وَجَبَ شَيْئَانِ) يُقْبَلُ كُلُّ مِنْهُمَا فِي تَفْسِيرِهِ شَيْءٌ لِاقْتِصَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايِرَةِ (فَإِنْ قَالَ) لَهُ (كَذَا دِرْهَمًا أَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ جَزَّهُ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) وَالْمَنْصُوبُ تَمْيِيزٌ، وَالْمَرْفُوعُ عَطْفٌ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٍ، وَالْجَرُّ لَحْنٌ. (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا بِالنَّصْبِ دِرْهَمَانِ) وَفِي قَوْلِ دِرْهَمٍ، وَفِي قَوْلِ دِرْهَمٍ وَشَيْءٌ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الدِّرْهَمَ تَفْسِيرٌ لِكُلِّ مِنْ الْمُبْهَمَيْنِ أَوْ لِمَجْمُوعِهِمَا أَوْ الثَّانِي: فَقَطُّ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ (وَ) الْمَذْهَبُ (أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ أَوْ جَرَّ) الدِّرْهَمَ (فَدِرْهَمٌ) وَالْمَعْنَى فِي الرَّفْعِ هُمَا دِرْهَمٌ وَالْجَرُّ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، وَقِيلَ فِي صُورَةِ الرَّفْعِ: قَوْلَانِ، ثَانِيهِمَا: يَجِبُ دِرْهَمَانِ وَنَقَلَ الْمَاوَرِدِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَجُوبَ دِرْهَمَيْنِ فِي الْجَرِّ.

(وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ فَدِرْهَمٌ فِي الْأَحْوَالِ) الثَّلَاثِ النَّصْبِ وَالرَّفْعِ وَالْجَرِّ لِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ.

[لو أقر بألف ودرهم أو وثوب أو غير ذلك]

(وَلَوْ قَالَ: أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ قَبْلَ تَفْسِيرِ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ^(٤٧٨)) مِنْ الْمَالِ كَأَلْفِ فَلْسٍ.

[أقر بخمسة وعشرين درهماً، فالجميع دراهم]

(وَلَوْ قَالَ: خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمٌ) عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: الْخَمْسَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى

الْإِبْهَامِ

[لو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن]

(وَلَوْ قَالَ: الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَقْرَرْتُ بِهَا نَاقِصَةُ الْوِزْنِ^(٤٧٩)) فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ الَّذِي أَقَرَّ فِيهِ (تَامَةً الْوِزْنِ فَالصَّحِيحُ قَبُولُهُ إِنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا) بِالْإِقْرَارِ (وَمَنْعُهُ إِنْ فَصَلَهُ عَنِ الْإِقْرَارِ)

(٤٧٨) لأن العطف للزيادة لا للتفسير الذي قال به أبو حنيفة، وألزمه به في معطوف مكمل أو موزون أو معدود، ورد عليه أيضا بعكس الصورة المذكورة كألف حبة حنطة ودرهم.

كَالِاسْتِثْنَاءِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقَةٍ فِي الْمُتَّصِلِ لَا يُقْبَلُ عَمَلًا بِأَوَّلِ الْكَلَامِ. وَفِي وَجْهِ فِي الْمُتَفَصِّلِ يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ (وَإِنْ كَانَتْ) دَرَاهِمُ الْبَلَدِ (نَاقِصَةً قَبْلَ) قَوْلُهُ: (إِنْ وَصَلَهُ) بِالْإِقْرَارِ (وَكَذَا إِنْ فَصَلَهُ) عَنْهُ (فِي النَّصِّ) حَمَلًا عَلَى وَزْنِ الْبَلَدِ، وَفِي وَجْهِ لَا حَمَلًا عَلَى وَزْنِ الْإِسْلَامِ.

[أقر بدراهم مغشوشة أو بسكة غير سكة البلد]

(وَالْتَفْسِيرُ بِالْمَغْشُوشَةِ كَهُوَ بِالنَّاقِصَةِ) فَفِيهَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ.

[أقر بدراهم من درهم إلى عشرة]

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَى مَنْ دَرَاهِمٌ إِلَى عَشْرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ) وَقِيلَ: عَشْرَةٌ إِدْخَالًا لِلطَّرْفَيْنِ، وَقِيلَ: ثَمَانِيَّةٌ إِخْرَاجًا لِهُمَا وَالْأَوَّلُ أَخْرَجَ الثَّانِي: دُونَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الْإِقْرَارِ (وَإِنْ قَالَ) لَهُ: (دَرَاهِمٌ فِي عَشْرَةٍ، فَإِنْ أَرَادَ الْمَعْيَةَ لَزِمَهُ أَحَدُ عَشَرَ) دَرَاهِمًا. وَوَرَدَتْ فِي بَعْضِ مَعْنَى مَعَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ} أَي: مَعَهُمْ (أَوْ الْحِسَابُ فَعَشْرَةٌ)؛ لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ (وَالْأَيُّ) بِأَنْ أَرَادَ الظَّرْفُ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا (فَدَرَاهِمٌ)؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ.

(فصل): [بيان أنواع الإقرار]

[الإقرار بالمظروف إقرار بالظرف]

إِذَا (قَالَ لَهُ: عِنْدِي سَيْفٌ فِي غَمْدٍ^(٤٨٠)) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ (أَوْ ثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ) بِضَمِّ الصَّادِ (لَا يَلْزِمُهُ الظَّرْفُ) أَخَذًا بِالْيَقِينِ، (أَوْ غَمْدٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ صُنْدُوقٌ فِيهِ ثَوْبٌ لَزِمَهُ الظَّرْفُ

(٤٧٩) أي عن الدراهم الإسلامية كما سيذكر الشارح، فالدراهم المطلقة محمولة عليها لا على الدراهم الفلوس نعم إن هجرت، أو قال: نقرة حمل على الفلوس؛ لأنها المعروفة في بلاد مصر، والدينار يحمل على الشرعي من الذهب، والأشرفي يحمل على ذلك أيضا.

(٤٨٠) ومثله فص في خاتم، ونعل في حافر، وحمل في بطن دابة، وثمره على شجرة، وسرج على دابة، وحكم عكسه عكس حكمه، نعم إذا أطلق في الخاتم دخل فحسه؛ لأنه اسم للجميع وبذلك فارق ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها؛ لأنه يصح استثناءه منها نحو له علي دابة إلا حملها، وبذلك فارق ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها؛ لأنه فيه. قال الإمام القفال وغيره: والضابط أن ما لا يدخل في البيع لا يدخل هنا، وما يدخل فيه يدخل هنا لا الحمل والثمره غير المؤبرة وأس الجدار نظرا للعرف هنا.

وَحَدَهُ) لِمَا ذُكِرَ (أَوْ الْعَبْدُ عَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةً^(٤٨١)) لَمْ تَلْزِمُهُ الْعِمَامَةُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِمَا ذُكِرَ،
وَالثَّانِي: تَلْزِمُهُ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ يَدٌ عَلَى مَلْبُوسِهِ، وَيَدُهُ كَيْدٌ سَيِّدِهِ، (أَوْ دَابَّتُهُ بِسَرَجِهَا أَوْ ثَوْبٌ مُطَرَّرٌ)
بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ (لَزِمَهُ الْجَمِيعُ)؛ لِأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مَعَ وَالطَّرَارُ جُزْءٌ مِنَ الثَّوْبِ.

[إقرار بالدين]

(وَلَوْ قَالَ) لَهُ: (فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٍ فَهُوَ إِقْرَارٌ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَلَوْ قَالَ) لَهُ:

[إقرار بوعد بهبة]

(فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي) أَلْفٌ (فَهُوَ وَعْدٌ هِبَةً) نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ
وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ إِقْرَارٌ مِنْ نَصِّهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ لَهُ فِي مَالِي أَلْفٌ إِقْرَارٌ

[لو أقر وكرر الدرهم عدة مرات]

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَى دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) حَمَلًا عَلَى التَّأْكِيدِ (فَإِنْ قَالَ: وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ
دِرْهَمَانِ) لِإِفْتِضَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايِرَةِ.

[أقر وكرر الدرهم عدة مرات بحرف العطف الواو]

(وَلَوْ قَالَ لَهُ: دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ وَدِرْهَمٌ بِالْأَوَّلَيْنِ دِرْهَمَانِ) كَمَا تَقَدَّمَ، (وَأَمَّا الثَّالِثُ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ
تَأْكِيدَ الثَّانِي) (لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى) بِهِ (الِاسْتِثْنَاءَ لَزِمَهُ ثَالِثٌ وَكَذَا إِنْ نَوَى) بِهِ
(تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ أَطْلَقَ) يَلْزِمُهُ دِرْهَمٌ (فِي الْأَصَحِّ) ثَالِثٌ أَخْذًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَنِيَّةِ التَّأْكِيدِ مَعَ تَحَلُّلِ
الْفَاصِلِ مُلْغَاءً، وَفِي وَجْهِ يُعْمَلُ بِهَا وَفِي قَوْلِهِ مِنْ طَرِيقَةِ الْإِطْلَاقِ لَا يَلْزِمُهُ ثَالِثٌ، وَيُحْمَلُ عَلَى
التَّأْكِيدِ أَخْذًا بِالْيَقِينِ

(وَمَتَى أَقَرَّ بِمُبْنِهِمْ كَشَيْءٍ وَثَوْبٍ وَطَوْبٍ بِالْبَيَانِ فَاِمْتَنَعَ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحْبَسُ) لِامْتِنَاعِهِ
مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: لَا يُحْبَسُ لِإِمْكَانِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِدُونِ الْحَبْسِ،

[لو بين المؤثر المبهمة وكذبه المقر له]

(وَلَوْ بَيَّنَّ) الْمُتَبَهَّمُ بِمَا يُقْبَلُ (وَكَذَبَهُ الْمُقَرَّرُ لَهُ) فِي أَنَّهُ حَقُّهُ (فَلْيُبَيِّنْ) جِنْسَ الْحَقِّ وَقَدْرَهُ (وَلْيُذِغْ) بِهِ (وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرَّرِ فِي نَفْسِهِ)، فَإِذَا بَيَّنَّ الْمُقَرَّرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُقَرَّرُ لَهُ مَا لِي عَلَيْكَ إِلَّا مِائَةُ دِينَارٍ وَادَّعَى بِهَا حَلْفَ الْمُقَرَّرِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا، وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ^(٤٨٢) بِرَدِّ الْمُقَرَّرِ لَهُ، وَإِنْ قَالَ لِي عَلَيْكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ حَلْفَ الْمُقَرَّرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ.

[لو أقر له بألف ثم أقر بألف في يوم آخر]

(وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ) فِي يَوْمٍ (ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ لَزِمَهُ أَلْفٌ فَقَطْ)؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ وَتَعَدُّهُ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّ الْمُخْبِرِ عَنْهُ

[لو أقر له بمقدار من المال ثم أقر له بأقل أو أكثر]

(وَلَوْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ) كَانَ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ عَكْسَ (دَخَلَ الْأَقْلُ فِي الْأَكْثَرِ) لِجَوَازِ الْإِقْرَارِ بِبَعْضِ الشَّيْءِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِكُلِّهِ أَوْ قَبْلَهُ، (فَلَوْ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ) كَصِحَاحٍ وَمُكْسَرَةٍ، (أَوْ أَسْنَدَهُمَا إِلَى جِهَتَيْنِ) كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ (أَوْ قَالَ: قَبَضْتُ يَوْمَ السَّبْتِ عَشْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: قَبَضْتُ يَوْمَ الْأَحَدِ عَشْرَةَ لَزِمَا) أَي: الْقَدْرَانِ فِي الصُّورِ الثَّلَاثِ،

[تتعقب الإقرار بما يرفعه]

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ تَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ أَلْفٌ قَضَيْتَهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِأَوَّلِ الْكَلَامِ، وَالثَّانِي: لَا، عَمَلًا بِآخِرِهِ، لَكِنْ لِلْمُقَرَّرِ لَهُ تَحْلِيْفُ الْمُقَرَّرِ أَنَّهُ مِنَ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ أَنَّهُ قَضَاءٌ.

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (مِنْ تَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ إِذَا سَلَّمَهُ، سَلَّمْتُ قَبْلَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَجُعِلَ ثَمَنًا) وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: طَرَدُ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ، أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ عَمَلًا بِأَوَّلِ الْكَلَامِ

[تعليق الإقرار بالمشيئة]

(٤٨٢) بالمائة، أي: إن لم يصدقه عليها، وإلا ثبتت باتفاقها.

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ^(٤٨٣))، لَمْ يَلْزِمُهُ شَيْءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِقْرَارَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ غَيْبٌ عَنَّا، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: طَرَدُ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَحَدُهُمَا: يَلْزِمُهُ عَمَلًا بِأَوَّلِ الْكَلَامِ.

(وَلَوْ قَالَ) لَهُ: عَلَيَّ (أَلْفٌ لَا يَلْزِمُ لَزِمَهُ)؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَلْزِمُ لَا يَنْتَظِمُ مَعَ مَا قَبْلَهُ فَأُلْغِيَ.

[وَصَلَ الْإِقْرَارُ بِمَا يَرْفَعُهُ]

(وَلَوْ قَالَ): لَهُ (عَلَيَّ أَلْفٌ ثُمَّ جَاءَ بِالْأَلْفِ، وَقَالَ: أَرَدْتُ بِهِ هَذَا، وَهُوَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لِي عَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ) دَيْنًا (صَدَّقَ الْمُقَرُّ فِي الْأُظْهَرِ بِبَيْمِينِهِ) أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ. وَالثَّانِي: يُصَدِّقُ الْمُقَرُّ لَهُ بِبَيْمِينِهِ: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ نَظَرًا إِلَى أَنَّ عَلَيَّ لِلْجُوبِ، فَلَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْوَدِيعَةِ فِيهِ، وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ الْجُوبِ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ.

(فَإِنْ كَانَ قَالَ) أَلْفٌ (فِي ذِمَّتِي أَوْ دَيْنًا) إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا، (صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) بِبَيْمِينِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: وَجْهَانِ ثَانِيَهُمَا: يُصَدِّقُ الْمُقَرُّ بِبَيْمِينِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ. وَقَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ إِنْ تَلَفْتُ الْوَدِيعَةَ؛ لِأَنِّي تَعَدَّيْتُ فِيهَا: (قُلْتُ:) أَخَذًا مِنَ الشَّرْحِ: (فَإِذَا قَبِلْنَا التَّفْسِيرَ بِالْوَدِيعَةِ، فَلْأَصَحُّ أَنَّهَا أَمَانَةٌ، فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَدَعْوَى الرَّدِّ) بَعْدَهُ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ قَوْلُ الْإِمَامِ عَنِ الْأَصْحَابِ: إِنَّهَا مَضْمُونَةٌ نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ: عَلَى الصَّادِقِ بِالتَّعَدِّي فِيهَا، وَأُجِيبَ بِصَدَقِهِ بِجُوبِ حِفْظِهَا. وَقَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَيُّ: بِتَفْسِيرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّلَفِ، فَلَوْ ادَّعَى التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ وَالْمَرْدُودَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ، (وَإِنْ قَالَ لَهُ: عِنْدِي أَوْ مَعِيَ أَلْفٌ، صَدَّقَ فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَالرَّدِّ وَالتَّلَفِ قَطْعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُشْعِرٌ بِالْأَمَانَةِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيعَةٌ قَبْلَ، وَأُولَتْ عَلَيَّ بِجُوبِ الْحِفْظِ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ فِي قَوْلٍ، وَعَلَى قَبُولِهِ إِذَا ادَّعَى التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ قَبْلَ فِي الْأَصَحِّ.

[أَقْرَبُ بَبِيْعٍ أَوْ هَبَةٍ أَوْ إِقْبَاضٍ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ فَاسِدًا]

(وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هَبَةٍ وَإِقْبَاضٍ) فِيهَا (ثُمَّ قَالَ: كَانَ) ذَلِكَ (فَاسِدًا وَأَقْرَزَتْ لِيُظَنِّي الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ) فِي قَوْلِهِ بِفَسَادِهِ.

(٤٨٣) وكذا إن يشأ الله أو أراد، أو يريد أو شاء زيد أو يشاء زيد، أو أراد أو يريد زيدا، أو إذا جاء رأس الشهر، أو زيد مثلا نعم إن أراد برأس الشهر أو مجيء زيد التأجيل، فهو إقرار مؤجل إن صح الأجل، وإلا فحال.

[تحليف المقر له فيما ادعاه]

(وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَاسِدًا، (فَإِنْ نَكَلَ) عَنِ الْحَلْفِ (حَلَفَ الْمُقَرِّ) أَنَّهُ كَانَ فَاسِدًا، (وَبَرِيءٌ) مِنَ الْبَيْعِ وَالْهَبَةِ. وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَحُكْمُ بَيُّطْلَانَ الْبَيْعِ وَالْهَبَةِ، (وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدِ بْنِ لِعَمْرٍو، أَوْ غَصَبْتُهَا مِنْ زَيْدٍ، بَلْ مِنْ عَمْرٍو سَلِمَتْ لِزَيْدٍ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُقَرَّ يَغْرُمُ قِيَمَتَهَا لِعَمْرٍو)؛ لِأَنَّهُ حَالٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا (بِالْإِقْرَارِ) الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي: لَا يَغْرُمُ لَهُ لِمُصَادَقَةِ الْإِقْرَارِ بِهَا لَهُ مِلْكُ الْغَيْرِ

[الاستثناء في الإقرار]

(وَيَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ^(٤٨٤) إِنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ) الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ: لَهُ عَلَى عَشْرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً، بِخِلَافِ إِلَّا عَشْرَةً فَلَا يَصِحُّ، وَتَلَزُمُهُ عَشْرَةٌ، وَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ، ثُمَّ اسْتَثْنَى لَمْ يَصِحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٍ، وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ. (فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَى عَشْرَةٍ إِلَّا تِسْعَةً، إِلَّا ثَمَانِيَةً^(٤٨٥))، وَجَبَ تِسْعَةٌ) لِأَنَّ الْمَعْنَى إِلَّا تِسْعَةً لَا تَلَزُمُ، إِلَّا ثَمَانِيَةً تَلَزُمُ، فَتَلَزُمُ الثَّمَانِيَةُ وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي مِنَ الْعَشْرَةِ.

[الاستثناء من غير الجنس]

(وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَأَنَّكَ إِذَا ثَوَّبًا، وَيُبَيِّنُ بِثَوْبٍ قِيَمَتَهُ دُونَ أَلْفٍ)، فَإِنْ بَيَّنَّ بِثَوْبٍ قِيَمَتَهُ أَلْفٌ فَالْبَيَانُ لَعَوٍّ، وَيَبْطُلُ الْإِسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَّ مَا أَرَادَ بِهِ، فَكَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِهِ وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ فَيُبَيِّنُهُ بِغَيْرِ مُسْتَغْرَقٍ،

[استثناء المعين من المعين]

(٤٨٤) سواء في الخبر أو الإنشاء خلافا للحنفية في الأمر مأخوذ من الشيء، وهو الرجوع لرجوع المقر عن مقتضى لفظه. ولو قال: أخط أو أستثني أو أخرج، ففيه وجهان في الحاوي.

(٤٨٥) أي بغير عطف؛ لأنه مع العطف يرجع الجميع للأول، ويلغو منه ما حصل به الاستغراق سواء ذكر إلا مع العطف أو سكت عنها. ونقول إلا مقام العطف إن لم يذكره. ولو قال: علي ثلاثة إلا درهما إلا درهما لزمه درهم، ولو قال: له علي عشرة إلا خمسة أو ستة لزمه أربعة لطرح الشك. ولو قال: له عشرة فيما أظن فليس بإقرار أصلا.

(و) يَصِحُّ (مِنَ الْمُعَيَّنِ كَهَذِهِ الدَّارِ لَهُ إِلَّا هَذَا النَّيْتِ، أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لَهُ إِلَّا هَذَا الدِّرْهَمُ)، أَوْ هَذَا الْقَطِيعُ لَهُ إِلَّا هَذِهِ الشَّاةُ، (وَفِي الْمُعَيَّنِ وَجْهٌ شَادٌّ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ، وَالْمُعْتَادُ الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْمُطْلَقِ.

(قُلْتُ:) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ (لَوْ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ لَهُ إِلَّا وَاحِدًا قَبْلَ، وَرُجِعَ فِي النَّبَيَانِ إِلَيْهِ^(٤٨٦))، فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى صَدَقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ الَّذِي أَرَادَهُ بِالْإِسْتِثْنَاءِ (عَلَى الصَّحِيحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَالثَّانِي: لَا يُصَدَّقُ لِلتُّهْمَةِ.

(فصل): [في الإقرار بالنسب^(٤٨٧)]

[شروط الإقرار بالنسب]

إِذَا (أَقَرَّ^(٤٨٨) بِنَسَبِ إِنْ الْحَقُّهُ بِنَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ: هَذَا ابْنِي (أَشْطَرُ لِصِحَّتِهِ^(٤٨٩)) أَيْ: الْإِلْحَاقُ،

١- (أَنْ لَا يُكْذِبُهُ الْحَسُّ) وَتَكْذِيبُهُ بِأَنْ يَكُونَ فِي سِنٍّ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ أَبًا لِلْمُسْتَلْحَقِ (وَلَا الشَّرْعُ)، وَتَكْذِيبُهُ (بِأَنْ يَكُونَ) أَيْ: الْمُسْتَلْحَقُ (مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، [٢-] وَأَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ إِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصَدِيقِ) بِأَنْ كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي نَسَبِهِ

[استلحاق البالغ العاقل]

(فَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَكَذْبُهُ لَمْ يَنْبُتْ) نَسَبُهُ (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَهُ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَتَبَتْ نَسَبُهُ، وَلَوْ سَكَتَ عَنِ التَّصَدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ لَمْ يَنْبُتْ نَسَبُهُ، كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: إِنَّهُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ التَّصَدِيقِ. وَشَمِلَ السُّكُوتُ قَوْلَ الرُّوَصَةِ: فَإِنْ اسْتَلْحَقَ بَالِغًا فَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يَنْبُتْ النَّسَبُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

[استلحاق الصغير]

(٤٨٦) ويجبر عليه ويخلفه وارثه فيه لو مات.

(٤٨٧) وهو واجب على الصادق وحرام على غيره، وما ورد من أنه كفر يراد به كفران النعمة أو لمن استحلها.

(٤٨٨) أي ذكر بالغ عاقل غير ممسوح مختار ولو سفيا، أو كان رقيقا أو كافرا.

(٤٨٩) أي الإلحاق أي من حيث النسب، وأما العتق فينفذ مطلقا ما لم يكذبه الحس سواء كذبه الشرع أو لا،

ظاهرا وباطنا. ولا يحكم بكفر من استلحقه الكافر إلا إن ثبت نسبه ببينة.

(وَإِنْ اسْتَلْحَقَّ صَغِيرًا ثَبَتَ نَسَبُهُ (فَلَوْ بَلَغَ، وَكَذَّبَهُ لَمْ يَبْطُلْ) نَسَبُهُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لَهُ، فَلَا يَنْدَفِعُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ.

وَالثَّانِي: يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهِ لِكُونِهِ غَيْرَ أَهْلِ لِلْإِنْكَارِ، وَقَدْ صَارَ أَهْلًا لَهُ وَأَنْكَرَ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ اسْتَلْحَقَّ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ وَأَنْكَرَ.

[استلحاق الميت الصغير وكذا كَبِيرًا]

(وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحَقَّ مَيِّتًا صَغِيرًا وَكَذَا كَبِيرًا فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: لَا، لِقَوَاتِ التَّصَدِيقِ **(و)** عَلَى الْأَوَّلِ **(يَرْتَبُهُ)** أَي: الْمَيِّتِ الْمُسْتَلْحَقِّ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى التَّهْمَةِ^(٤٩٠).

[لَوْ اسْتَلْحَقَّ اثْنَانِ بَالِغًا]

(وَلَوْ اسْتَلْحَقَّ اثْنَانِ بَالِغًا ثَبَتَ نَسَبُهُ (لِمَنْ صَدَقَهُ) مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا^(٤٩١)) عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ -كَمَا سَيَأْتِي قَبْلَ كِتَابِ الْعِنَقِ- **(وَحُكْمُ الصَّغِيرِ)** الَّذِي يَسْتَلْحَقُّهُ اثْنَانِ **(يَأْتِي فِي) كِتَابِ (الَلْقِيطِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)** كَمَا سَيَأْتِي فِيهِ حُكْمُ اسْتِلْحَاقِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ.

[قَالَ لَوْلِدِ أُمِّتِهِ: هَذَا وَلَدِي]

(وَلَوْ قَالَ لَوْلِدِ أُمِّتِهِ^(٤٩٢)): هَذَا وَلَدِي ثَبَتَ نَسَبُهُ) بِشَرْطِهِ، (وَلَا يَثْبُتُ الْإِسْتِيلَادُ فِي الْأَظْهَرِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَوْلَدَهَا بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ أَوْلَدَهَا بِالْمِلْكِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ النِّكَاحِ **(وَكَذَا لَوْ قَالَ) فِيهِ: هَذَا (وَلَدِي وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِ)** لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِسْتِيلَادُ فِي الْأَظْهَرِ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا، وَالثَّانِي: يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِالْمِلْكِ، **(فَإِنْ قَالَ: عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِ ثَبَتَ الْإِسْتِيلَادُ) وَانْقَطَعَ الْإِحْتِمَالُ، (فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ) بِأَنَّ أَقَرَّ بَوَاطِنِهَا^(٤٩٣) (لِحَقَّة)**

(٤٩٠) بِالْإِثْرِ وَلَا يَاسْقَاطُ الْقَصَاصُ لَوْ وَجَدَ.

(٤٩١) بِأَن كَذِبَهُمَا أَوْ سَكَتَ أَوْ صَدَقَهُمَا، أَوْ كَذَبَ أَحَدَهُمَا وَسَكَتَ عَنِ الْآخَرِ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً، وَإِلْحَاقُ الْقَائِفِ حَكْمَ لَا اسْتِلْحَاقَ فَلَا يَنَافِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِيمَا مَرَّ عِنْدَ عَدَمِ التَّنَازُعِ.

(٤٩٢) أَيِ الَّتِي لَيْسَتْ فِرَاشًا.

(٤٩٣) لِأَنَّ الْأُمَّةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إِلَّا بِذَلِكَ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْإِمَاءِ الِاسْتِخْدَامَ بِالْأَصَالَةِ.

الْوَلَدُ (بِالْفِرَاشِ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ) قَالَ ː فِي ابْنِ أُمِّةٍ زَمْعَةٌ^(٤٩٤): « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٤٩٥)

[استلحاق ولد المَرْوَجَةِ]

(وَإِنْ كَانَتْ مَرْوَجَةٌ فَأَلْوَدُ لِلزَّوْجِ)؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ.

(وَاسْتِلْحَاقُ السَّيِّدِ بَاطِلٌ) أَي: لَا اعْتِبَارَ بِهِ

[إلحاق النسب بالغير]

(وَأَمَّا إِذَا أُلْحِقَ النَّسَبَ بِغَيْرِهِ كَهَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي، فَيُنْتَبِثُ نَسَبُهُ مِنَ الْمُلْحَقِ بِهِ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ^(٤٩٦) فِيمَا ذَكَرَ (بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ) فِي الْإِلْحَاقِ بِنَفْسِهِ. (وَيُشْتَرَطُ) أَيْضًا (كَوْنُ الْمُلْحَقِ بِهِ مَيِّتًا، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ نَفَاهُ فِي الْأَصَحِّ)، فَيَجُوزُ إِلْحَاقُهُ بِهِ بَعْدَ نَفْيِهِ إِيَّاهُ، كَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ هُوَ بَعْدَ أَنْ نَفَاهُ بِلَعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ مَا ذَكَرَ، فَلَا يَجُوزُ الْإِلْحَاقُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ فِي الْإِلْحَاقِ مَنْ نَفَاهُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلْحَاقٌ عَارٍ بِنَسَبِهِ.

[شروط صحة إلحاق النسب بالغير]

(وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُقَرَّرِ) فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ (وَارِثًا حَائِزًا) لِتَرْكِهِ الْمُلْحَقِ بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، كَابْنَيْنِ أَقْرًا بِثَالِثٍ فَيُنْتَبِثُ نَسَبُهُ وَيَرِثُ مَعَهُمَا.

[هل يرث المستلحق؟]

(وَالْأَصَحُّ) فِيمَا إِذَا أَقْرَ أَحَدُ الْحَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ (أَنَّ الْمُسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَبِثْ نَسَبُهُ،

[عدم مشاركة المستلحق المقرَّر في حصته]

(٤٩٤) بفتح المعجمة وسكون الميم وفتح المهملة، اسم رجل صحابي.

(٤٩٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣ / ٥٤) برقم: (٢٠٥٣) ومسلم في "صحيحه" (٤ / ١٧١) برقم:

(١٤٥٧)

(٤٩٦) أي وإن كان الأب حيا حيث قام به مانع من الإرث.

(وَلَا يُشَارِكُ الْمُقَرَّرُ فِي حَصَّتِهِ^(٤٩٧)) وَالثَّانِي: يَرِثُ بِأَنْ يُشَارِكَ الْمُقَرَّرُ فِي حَصَّتِهِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ عَدَمُ الْمُشَارَكَةِ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ إِذَا كَانَ الْمُقَرَّرُ صَادِقًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكُهُ فِيمَا يُرِيهِ فِي الْأَصَحِّ بِثَلَاثِهِ، وَقِيلَ: بِنِصْفِهِ

[عدم انفراد البالغ من الورثة بالإقرار]

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّ النَّبَالَغَ مِنَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْإِقْرَارِ)، بَلْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ، وَالثَّانِي: يَنْفَرِدُ بِهِ وَيُحْكَمُ بِثُبُوتِ النَّسَبِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ حَاطِرٌ لَا يُجَارَفُ فِيهِ

[لو أقر أحد الوارثين ومات المنكر]

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ) الْحَاضِرَيْنِ بِثَالِثٍ، (وَأَنْكَرَ الْآخَرَ وَمَاتَ وَلَمْ يَرِثْهُ إِلَّا الْمُقَرَّرُ ثَبَتَ النَّسَبُ)؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ صَارَ لَهُ، وَالثَّانِي: لَا يَثْبُتُ نَظَرًا إِلَى إِنْكَارِ الْمُورِثِ الْأَصْلِ.

[إقرار الابن الحائز بإخوة مجهول]

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ابْنٌ حَاضِرٌ بِأَخَوَةٍ مَجْهُولٍ، فَأَنْكَرَ الْمَجْهُولُ نَسَبَ الْمُقَرَّرِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ) إِنْكَارُهُ^(٤٩٨). (وَيَثْبُتُ أَيْضًا نَسَبُ الْمَجْهُولِ) وَالثَّانِي: يُؤَثِّرُ الْإِنْكَارُ فَيَحْتَاجُ الْمُقَرَّرُ إِلَى الْبَيِّنَةِ عَلَى نَسَبِهِ، وَالثَّلَاثُ: لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْمَجْهُولِ لِزَعْمِهِ أَنَّ الْمُقَرَّرَ لَيْسَ بِوَارِثٍ،

[إقرار الوارث الظاهر بمن يحجب]

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ الظَّاهِرُ يَحْجُبُهُ الْمُسْتَلْحَقُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ثَبَتَ النَّسَبُ) لِلابْنِ (وَلَا إِرْثَ) لَهُ، وَالثَّانِي: لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ الْإِرْثُ، وَلَوْ وَرِثَ الْإِبْنُ لَحَبِبَ الْأَخُ فَيَخْرُجُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِقْرَارِ فَيَنْتَقِي نَسَبُ الْإِبْنِ وَالْمِيرَاثُ، وَالثَّلَاثُ: يَثْبُتَانِ وَلَا يَخْرُجُ الْأَخُ بِالْحَبَبِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِقْرَارِ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُ الْمُقَرَّرِ حَاضِرًا لِلتَّرِكَةِ لَوْلَا إِقْرَارُهُ.

(٤٩٧) خلافا للأئمة الثلاثة فإنهم قالوا بالمشاركة ظاهرا وباطنا مع عدم ثبوت النسب اتفاقا.

(٤٩٨) ويرث معه في هذه؛ لأنه لم يحجب حرمانا.

كِتَابُ الشُّفْعَةِ (٤٩٩)

[١] تعريف الشُّفْعَةِ لُغَةً (٥٠٠):

[٢] تعريف الشُّفْعَةِ اصطلاحاً (٥٠١):

[٣] حكم الشُّفْعَةِ: أنها جائزة.

[٤] دليل الشُّفْعَةِ (٥٠٢):

(٤٩٩) تعليق على شرح (كنز الراغبين) لجلال الدين المحلى، وهو شرح على متن (منهاج الطالبين) للإمام محيي الدين النووي، أ.د/ ياسر عبدالعظيم/أستاذ الفقه المساعد/ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

(٥٠٠) لُغَةً: هِيَ بِضَمِّ النَّيْنِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَحُكِّيَ ضَمُّهَا لُغَةً: مَأْخُذَةٌ مِنَ الشُّفْعِ بِمَعْنَى الضَّمِّ عَلَى الْأَشْهُرِ، مِنْ شَفَعْتُ الشَّيْءَ أَي ضَمَمْتُهُ، وَمِنْهُ شَفَعُ الْأَذَانِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِضَمِّ الْإِنْسَانِ نَصِيبَ الشَّرِيكِ إِلَى نَصِيبِهِ، أَوْ بِمَعْنَى التَّقْوِيَةِ أَوْ الزِّيَادَةِ، وَقِيلَ: هِيَ مِنَ الشَّفَاعَةِ.

(٥٠١) وَشَرْعًا: حَقٌّ تَمْلُكُ قَهْرِيٌّ يَنْبُثُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْخَادِثِ فِيمَا مِلَكَ بِعَوَضٍ.

(٥٠٢) فمن القرآن الكريم قوله تعالى: { ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ^(١) } سورة المائدة] ووجه الدلالة من الآية أن منع أسباب الخصومة والنزاع بين الناس من باب التعاون على البر والتقوى ، ومن ذلك منع خبطة الشركة في المال والاستقلال بها.

ومن السنة النبوية: ما روي عن جابرٍ ر : { جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسِّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُذُودُ، وَصُرِّقَتِ الطَّرِيقُ، فَلَا شُفْعَةَ } صحيح البخاري ج٣/ ٢٩/ ٢٢١٣/ كتاب البيوع/ بابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ، وج٣/ ٨٧/ ٢٢٥٧/ كِتَابُ الشُّفْعَةِ / بابُ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسِّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُذُودُ فَلَا شُفْعَةَ. وفي رواية عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: { وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمَسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ، قَوَّضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَتَكِبَتِي، إِذْ جَاءَ أَبُو زَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَغِ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ؟ فَقَالَ سَعْدُ: وَاللَّهِ مَا ابْتَاغُهُمَا، فَقَالَ الْمَسُورُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَهُمَا، فَقَالَ سَعْدُ: وَاللَّهِ لَا أَرِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُتَجَمَّةً، أَوْ مَقْطَعَةً، قَالَ أَبُو زَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةٍ دِينَارٍ، وَلَوْ لَا أَتَيْ سَمِيعُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِيهِ، مَا أُعْطِيتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَأَنَا أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةٍ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ } . صحيح البخاري ج٣/ ٨٧/ ٢٢٥٧/ كِتَابُ الشُّفْعَةِ / بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ/. وقال البخاري: قَالَ الْحَكَمُ: «إِذَا أُذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «مَنْ بَاعَ شُفْعَتَهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُعْزِرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ».

وفي رواية عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: { مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رِبْعَةٍ، أَوْ تَحْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهٗ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ } ، وفي رواية أخرى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ر، قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِيكَةٍ لَمْ تُقَسِّمْ، رِبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهٗ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ قَهْوًا أَحَقُّ بِهِ } صحيح مسلم ج٣/ ١٢٢٩/ ١٦٠٨/ كتاب البيوع/ بابُ الشُّفْعَةِ/. وأما دليل الإجماع، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إِبْثَابِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمَ، فِيمَا بَاعَ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَائِطٍ. وأما دليل المعقول: أَنَّ الشُّفْعَةَ جَعَلَتْ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الشَّرِيكِ،

[٥] طبيعة عقد الشُّفْعَةِ (٥٠٣):

[٦] وَأَرْكَانُ الشُّفْعَةِ ثَلَاثَةٌ: مَاخُودٌ، وَآخِذٌ، وَمَاخُودٌ مِنْهُ، وَالصَّيْغَةُ إِنَّمَا تَجِبُ فِي التَّمْلِكِ.

[٧] مَحَلُّ الشُّفْعَةِ: وَمَحَلُّهَا فِي الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ عَقَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، مَثَلًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ، فَيَنْبُتُ لِشَرِيكِهِ حَقُّ تَمَلُّكِ الْمَبِيعِ قَهْرًا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ، كَمَا سَيَأْتِي فَحَقُّ التَّمَلُّكِ فِيمَا ذَكَرَ، هُوَ مُسَمَّى الشُّفْعَةِ شَرْعًا.

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الْمَاخُودُ

[١] (لَا تَنْبُتُ فِي مَقُولٍ (٥٠٤))

(بَلْ) تَنْبُتُ (فِي أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ تَبَعًا) لَهَا (٥٠٥).

(وَكَذَا ثَمَرٌ لَمْ يُؤْبَرْ) تَنْبُتُ فِيهِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ (فِي الْأَصَحِّ) كَشَجَرِهِ (٥٠٦). وَالثَّانِي: يَقْبِضُهُ عَلَى الْمُؤَبَّرِ، فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ مَعَ الشَّجَرِ وَالْأَرْضِ لَا تَنْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ وَالشَّجَرَ بِحَصْنَتِهِمَا مِنَ الثَّمَنِ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ ر، قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرَكَةٍ لَمْ تُقَسَّمْ، رُبْعَةً أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَحَدٌ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذَنَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } ، وَحَائِطُ الْأَوَّلِ الْمَنْزِلِ وَالثَّانِي الْبُسْتَانُ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ لِانْتِقَاءِ التَّبَعِيَّةِ

(وَلَا شُفْعَةَ فِي حُجْرَةٍ بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ) بَأَنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا، أَوْ غَيْرُهُمَا إِذْ لَا أَرْضَ لَهَا (٥٠٧). (وَكَذَا مُشْتَرَكٍ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا ذَكَرَ.

وذلك لأن الشريك يريد إلحاق الضرر به بأن يبيع نصيبه دون يعرفه فلذا جعل الشرع له حق مقدم على المشتري.

(٥٠٣) أن الشفعة من العقود الجائزة وليس اللازمة وهي التي يجوز للشريك أن يأخذ بها أو أن يتركها، فإذا أَرَادَهَا فالشرع بأح له ذلك، وذلك لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ قَهْرًا فَكَأَنَّهَا مُسْتَنْثَاءَةٌ مِنْ تَحْرِيمِ أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا.

(٥٠٤) الشرط الأول في المأخوذ بالشفعة: أن يكون عقاراً. أي أن الشُّفْعَةُ تَنْبُتُ فِي الْعَقَارِ، وَلَا تَنْبُتُ فِي الْمَنْقُولِ كَالْحَيَوَانَ وَالسَّيَّارَاتِ وَالتَّيَّابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، سَوَاءً أُبِيعَتْ وَخَذَهَا أَمْ بَاعَتْ مَضْمُونَةً إِلَى أَرْضٍ أَوْ عَقَارٍ، وَذَلِكَ لِإِحْدِيثِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ يَخْصُهَا بِمَا تَدْخُلُهُ الْقِسْمَةُ وَالْحُدُودُ وَالطَّرِيقُ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الْمَنْقُولَاتِ؛ كَمَا أَنَّ الْمَنْقُولَ لَا يَدُومُ، بِخِلَافِ الْعَقَارِ فَيَتَأَبَّدُ فِيهِ ضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ ثَابِتًا مُحْتَمَلًا لِلْقِسْمَةِ بِدُونِ ضَرَرٍ.

(٥٠٥) أي أنها تثبت في الأرض وما فيها من البناء وتوابعه الدَّاخلَةِ فِي مَطْلَقِ الْبَيْعِ مِنْ أَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ وَرُقُوفٍ مُسَمَّرَةٍ وَمَسَامِيرَ وَمَقَاتِيحَ غَلَقٍ مُتَبَتِّ وَدُولَابٍ ثَابِتٍ وَحَجَرٍ الطَّاحُونَةِ وَنَحْوَهَا كَغِطَاءِ تَنْوِيرٍ ، وَ تَنْبُتُ فِي الشَّجَرِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ.

(٥٠٦) وذلك لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ فَيَشْتَبِعُهُ فِي الْأَخْذِ، وَهَذَا قِيَاسًا عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَتَّفَقْ الْأَخْذُ لَهَا حَتَّى أُبْرِثَ لِخَوْلِهَا فِي مَطْلَقِ الْبَيْعِ.

(٥٠٧) وذلك لأنها بنيت على سقف لم تبنى على الأرض ، فَهِيَ كَالْمَنْقُولَاتِ.

وَالثَّانِي: يَجْعَلُهُ كَالْأَرْضِ.

(وَكُلُّ مَا لَوْ قُسِمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ كَحَمَامٍ وَرَحَى) أَي طَاحُونَةٍ صَغِيرَتَيْنِ. (لَا شُفْعَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ) ^(٥٠٨) هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمُنْقَسِمِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، أَيِ أُجْرَةِ الْقَاسِمِ وَالْحَاجَةِ إِلَى إِفْرَادِ الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ لَهُ، بِالْمَرْفَقِ كَالْمُضْعَدِ وَالْمُنُورِ وَالْبَالُوعَةِ وَنَحْوِهَا، وَالثَّانِي: مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ دَفْعُ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِيمَا يَدُومُ وَكُلُّ مَنْ الضَّرَرَيْنِ حَاصِلٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِيهِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخْلَصَ صَاحِبُهُ مِنْهُمَا بِالْبَيْعِ لَهُ، فَإِذَا بَاعَ لِغَيْرِهِ سَلَّطَهُ الشَّرْعُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ.

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْأَخْذُ

[١] الشرط الأول: (وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكَ) ^(٥٠٩) بِخِلَافِ الْجَارِ ^(٥١٠) رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ τ قَالَ: { جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ρ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسِّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ }.

(وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِهَا) التَّابِعِ لَهَا بِأَنْ كَانَ بِدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ. (فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا) لِانْتِقَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا ^(٥١١).

(وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهَا فِي الْمَمَرِ إِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ آخَرُ إِلَى الدَّارِ، أَوْ أَمَكَنَ فَتُحُ بَابٍ لَهَا (إِلَى شَارِعٍ وَإِلَّا) أَيِ وَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ فَتُحُ بَابٍ وَلَا طَرِيقٍ (فَلَا) تَثْبُتُ فِيهِ حَدَرًا مِنَ الْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي، وَالثَّانِي ^(٥١٢): تَثْبُتُ فِيهِ، وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمُضَرُّ بِنَفْسِهِ بِشِرَائِهِ هَذِهِ الدَّارَ، وَالثَّلَاثُ ^(٥١٣): لِلشَّرِيكَ

(٥٠٨) هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ هِيَ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِخْدَاثِ الْمَرْفَقِ الْخِ، وَالثَّانِي: مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ دَفْعُ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِيمَا يَدُومُ، وَكُلُّ مَنْ الضَّرَرَيْنِ حَاصِلٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِيهِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخْلَصَ صَاحِبُهُ مِنْهُمَا بِالْبَيْعِ لَهُ، فَإِذَا بَاعَ لِغَيْرِهِ سَلَّطَهُ الشَّرْعُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ.

(٥٠٩) الشرط الأول: أَنْ يَكُونَ الْآخِذُ شَرِيكًا فِي رَقَبَةِ الْعَقَارِ. والشرط الثاني: لَا يَشْتَرِطُ فِي الْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ الْأَهْلِيَّةُ فَتَثْبُتَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَالْمَغْمَى عَلَيْهِ وَالسَّكَانِ. والشرط الثالث: لَا يَشْتَرِطُ الْإِسْلَامُ فِي الْآخِذِ فَتَصَحُّ مِنَ الْمُسْلِمِ وَمِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.

(٥١٠) أَمَّا ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فَالْشَّافِعِيَّةُ لَا يَقُولُونَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لَهُ، وَلَكِنْ يَوْجِدُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ وَاسْتَدْلُوا: بِمَا رَوَى عَنْ جَابِرٍ τ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : { الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا } وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ τ ، أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ: { الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْيِهِ } سَنَنَ ابْنُ مَاجَةَ ج-٢/٨٣٣/٢٤٩٤/٢ كِتَابُ الشُّفْعَةِ / بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجَوَارِ.

(٥١١) فَأَشْبَهَ هَذَا مَا لَوْ بَاعَ عَقَارًا غَيْرَ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا.

(٥١٢) أَيِ الْقَوْلِ الثَّانِي مُقَابِلَ الصَّحِيحِ.

الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ إِنْ مُكِّنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُرُورِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، وَالْحَقَّ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْإِمْكَانِ فِي الْخِلَافِ، مَا إِذَا كَانَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِ الْحَادِثِ عُسْرٌ، أَوْ مُؤَنَّةٌ لَهَا وَقَعٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ وَجْهٌ بَعْدَ الثَّبُوتِ فِي الشَّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ فِيهِ الْمُعَبَّرُ بِهِ فِي أَصْلِ الرِّوَايَةِ أَيْضًا وَوُجْهٌ بَأَنَّ فِي الثَّبُوتِ ضَرَرًا لِلْمُشْتَرِي وَالصَّحِيحُ يَقُولُ يَنْتَفِي بِمَا شَرِطَ، وَحَيْثُ قِيلَ بِالثَّبُوتِ فَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَمَرِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ، أَمَّا الدَّرَبُ النَّافِذُ فَعَبْرٌ مَمْلُوكٌ فَلَا شُفْعَةَ فِي مَمَرِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مِنْهُ قَطْعًا.

الرُّكْنُ الثَّلَاثُ، وَهُوَ الْمَأْخُودُ بِالشُّفْعَةِ

[١] الشرط الأول (٥١٤):

(وَإِنَّمَا تَنْتَبِثُ) الشُّفْعَةُ (فِيمَا مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ مَلَكًا لَا زِمًا مُتَأَخِّرًا عَنْ مَلِكِ الشَّفِيعِ كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعَوَضٍ خُلِعٍ وَصُلْحٍ دَمٍ وَنُجُومٍ وَأَجْرَةٍ وَرَأْسِ مَالٍ سَلَمٍ) فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا مَلَكَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِزْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْهَبَةِ بِلَا ثَوَابٍ وَسَيَأْتِي مَا أُخْتَرِرَ عَنْهُ بِاللَّازِمِ وَمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَصُلْحٍ دَمٍ هُوَ فِي الْجَنَائَةِ عَمْدًا فَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَالْوَجِبُ فِيهَا الْإِبْلُ، وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهَا لِجَهَالَةِ صِفَاتِهَا، وَقَوْلُهُ وَنُجُومٍ عَطْفٌ عَلَى دَمٍ يَغْنِي وَالصُّلْحُ عَنْ نُجُومٍ الْكِتَابَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ بِصِحَّتِهِ.

[٢] الشرط الثاني: (وَلَوْ شَرِطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارَ لَهُمَا) (٥١٥) أَيُّ لِلْمُتَبَايِعِينَ (أَوْ لِلْبَائِعِ) وَحْدَهُ (لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ) سَوَاءً قُلْنَا الْمَلِكُ فِي زَمَنِهِ لِلْبَائِعِ أَمْ لِلْمُشْتَرِي أَمْ مَوْقُوفٌ. (وَإِنْ شَرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَلَا لَظْهَرُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ) بِالشُّفْعَةِ (إِنْ قُلْنَا الْمَلِكُ) فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (لِلْمُشْتَرِي) نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ آيِلٌ إِلَى اللُّزُومِ وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ الْآنَ (وَالْإِلَّا) أَيُّ وَإِنْ قُلْنَا الْمَلِكُ فِي

(٥١٣) أَيُّ الْقَوْلِ الثَّلَاثُ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ: وَفِي مَغْنِي الْمَحْتَاجِ لِلشَّرِيبِنِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّلَاثَ هُوَ: الْمَنْعُ مُطْلَقًا إِذَا كَانَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِ عُسْرٌ أَوْ مُؤَنَّةٌ لَهَا وَقَعٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا. وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّلَاثُ فِي النِّجْمِ الْوَهَّاجِ لِلدِّمِيرِيِّ فَقَالَ: وَالثَّلَاثُ: أَنَّهُ يُقَالُ لَهُمْ: إِنْ أَخَذْتُمُوهُ عَلَى أَنْ تَمَكَّنُوا الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُرُورِ.. فَلَكُمْ الْأَخْذُ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ تَمَكِّينَهُ مِنْهُ.. فَلَا شُفْعَةَ لَكُمْ جَمِيعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، وَهَذَا يَبْطُلُ بِبَيْعِ دَارٍ لَا مَمَرٍ لَهَا. كُلُّ هَذَا عِنْدَ ضَيْقِ الْمَمَرِ، فَإِنْ اتَّسَعَ وَأَمَكَّنَ مِنْهُ مَمَرٌ لِلْمُشْتَرِي.. ثَبَتَ فِي الْبَاقِي قَطْعًا، وَفِيمَا لَا يَتَأْتِي الْمُرُورُ بِهِ الْأُوجُهُ.

(٥١٤) الشرط الأول: أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ قَدْ انْتَقَلَ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ الْمَخْصُصَةِ كَالْبَيْعِ، أَوْ غَيْرِ الْمَخْصُصَةِ كَالْمَهْرِ، فَإِنْ انْتَقَلَ بِالْمِيرَاثِ أَوْ الْهَبَةِ أَوْ الْوَقْفِ لَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ أَيُّ فِي شَيْءٍ مَلَكَهُ الشَّرِيكَ الْحَادِثُ بِغَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ.

(٥١٥) والشرط الثاني: أَنْ يَكُونَ مَلِكُ الْمُعَاوَضَةِ مَلَكًا لَا زِمًا، فَإِنْ كَانَ الْمَلِكُ غَيْرَ لَازِمٍ كَالْمَلِكِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَا يَصِحُّ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ. الشرط الثالث: أَنْ يَكُونَ مَلِكُ الْمُعَاوَضَةِ مُتَأَخِّرًا عَنْ مَلِكِ الشَّفِيعِ أَيُّ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ الشَّرِيكَ سَابِقَ عَلَى وَجُودِ الْمُعَاوَضَةِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْمَهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلِذَلِكَ عَبَّرَ فِي النَّصِّ لَوْ كَانَ مَلِكُهُمَا مَعًا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ

زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٍ (فَلَا) يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ زَوَالِ الْمَلِكِ. وَقِيلَ: يُؤْخَذُ^(٥١٦)،
لِانْقِطَاعِ سُلْطَنَةِ الْبَائِعِ، بِلُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَتِهِ.

(وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشَّفْعِ^(٥١٧) عَيْبًا، وَأَرَادَ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ، وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَهُ، وَيَرْضَى بِالْعَيْبِ،
فَالْأَظْهَرُ إِبْجَابَةُ الشَّفِيعِ) حَتَّى لَا يَبْطُلَ حَقُّهُ مِنَ الشَّفْعَةِ^(٥١٨)، وَالثَّانِي: إِبْجَابَةُ الْمُشْتَرِي. وَإِنَّمَا
يَأْخُذُ الشَّفِيعُ إِذَا اسْتَقَرَّ الْعَقْدُ، وَسَلِمَ عَنِ الرَّدِّ.

[٣] (وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا أَوْ بَعْضَهَا فَلَا شَفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ)^(٥١٩)، لِحُصُولِ الْمَلِكِ لَهُمَا
فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

(وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي شَرِكٌ) بِكُسْرِ الشَّيْنِ أَيْ نَصِيبٌ. (فِي الْأَرْضِ) كَأَنْ كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَثْلَاثًا
فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لِأَحَدٍ صَاحِبِيهِ. (فَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَأْخُذُ كُلَّ الْمَبِيعِ بَلْ) يَأْخُذُ (حِصَّتَهُ)
^(٥٢٠) وَهِيَ فِيمَا ذَكَرَ السُّدُسُ وَالثَّانِي: يَأْخُذُ كُلَّ الْمَبِيعِ، وَلَا حَقَّ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الشَّفْعَةَ تُسْتَحَقُّ
عَلَى الْمُشْتَرِي، فَلَا يَسْتَحَقُّهَا عَلَى نَفْسِهِ وَالْأَوَّلُ قَالَ لَا شَفْعَةَ فِي حِصَّةِ الْمُشْتَرِي فَمِلْكُهُ مُسْتَقَرٌّ
عَلَيْهِمَا بِالشِّرَاءِ.

كَيْفِيَّةُ التَّمْلِكِ بِالشَّفْعَةِ أَوْ كَيْفِيَّةُ الْأَخْذِ بِالشَّفْعَةِ

- [١] (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمْلِكِ بِالشَّفْعَةِ حُكْمُ حَاكِمٍ^(٥٢١) وَلَا إِحْصَارُ الثَّمَنِ^(٥٢٢) وَلَا حُضُورُ الْمُشْتَرِي)
وَلَا رِضَاهُ^(٥٢٣)، بَلْ يُوْجَدُ التَّمْلِكُ بِهَا مَعَ كُلِّ مِمَّا ذَكَرَ وَمَعَ غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي.
- [٢] (وَيُشْتَرَطُ لَفْظٌ مِنَ الشَّفِيعِ كَتَمَلَّكَتُ أَوْ أَخَذْتُ بِالشَّفْعَةِ) وَإِنْ لَمْ يَغْلَمْ الثَّمَنُ^(٥٢٤).
- [٣] (وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ إِمَّا تَسْلِيمُ الْعَوَضِ إِلَى الْمُشْتَرِي،)^(٥٢٥).

(٥١٦) وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِالشَّفْعَةِ ؛ وَذَلِكَ لِانْقِطَاعِ سُلْطَنَةِ الْبَائِعِ.

(٥١٧) وَمَعْنَى الشَّفْعِ - بِكُسْرِ الْمُعْجَمَةِ -: هُوَ اسْمٌ لِلْقِطْعَةِ مِنَ الشَّيْءِ.

(٥١٨) وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِالْبَيْعِ، وَحَقُّ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ ثَابِتٌ بِالْإِطْلَاعِ.

(٥١٩) الشَّرْطُ الثَّلَاثُ: أَنْ يَكُونَ مَلِكٌ الْمَعَاوِضَةِ مُتَأَخِّرًا عَنْ مَلِكِ الشَّفِيعِ أَيْ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ الشَّرِيكَ سَابِقًا عَلَى

وُجُودِ الْمَعَاوِضَةِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْمَهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلِذَلِكَ عَبَّرَ فِي النَّصِّ لَوْ كَانَ مَلِكُهُمَا مَعًا فَلَا شَفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا
عَلَى الْآخَرِ.

(٥٢٠) أَيْ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ أَوْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَهِيَ فِي هَذَا الْمِثَالِ السُّدُسُ ؛ وَذَلِكَ لِاسْتَوَائِهِمَا فِي
الشَّرِكَةِ.

(٥٢١) الْأَوَّلُ: لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمْلِكِ بِالشَّفْعَةِ حُكْمُ حَاكِمٍ، وَذَلِكَ لِثُبُوتِ الشَّفْعَةِ بِالنَّصِّ.

(٥٢٢) الثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمْلِكِ بِالشَّفْعَةِ إِحْصَارُ أَوْ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَثَاءَ الْاِخْذِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّفْعَةَ تَمْلِكُ بِعَوَضٍ.

(٥٢٣) الثَّلَاثُ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمْلِكِ بِالشَّفْعَةِ حُضُورُ الْمُشْتَرِي أَوْ رِضَاهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّفْعَةَ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ وَهِيَ

حَقٌّ تَمْلِكُ قَهْرِي.

(٥٢٤) الرَّابِعُ: يُشْتَرَطُ فِي التَّمْلِكِ بِالشَّفْعَةِ لَفْظٌ مِنَ الشَّفِيعِ كَتَمَلَّكَتُ أَوْ أَخَذْتُ بِالشَّفْعَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَيَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ

إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُمَةِ.

[٤] (فَإِذَا تَسَلَّمَهُ. أَوْ أَلَزَمَهُ الْقَاضِي التَّسْلِيمَ) إِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ، أَوْ قَبِضَ الْقَاضِي عَنْهُ كَمَا زَادَهُ فِي الرُّوْضَةِ. (مَلَكَ الشَّفِيعُ الشَّقْصَ. وَإِمَّا رِضَا الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الْعَوْضِ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الشَّفِيعُ (٥٢٦).

[٥] (وَإِمَّا قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ إِذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأُثْبِتَ حَقَّهُ) فِيهَا وَطَلَبَهُ. (فِيمَلِكُ بِهِ) أَيْ بِالْقَضَاءِ. (فِي الْأَصَحِّ) (٥٢٧) وَالثَّانِي: لَا يَمْلِكُ بِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الْعَوْضَ، أَوْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي بِتَأْخِيرِهِ.

[٦] (وَلَا يَتَمَلَّكُ شَقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهَبِ) (٥٢٨) وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنَ الرُّوْيَةِ، وَفِي قَوْلٍ يَتَمَلَّكُهُ قِيلَ الرُّوْيَةُ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ، وَلَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُّوْيَةِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ قَهْرِيٌّ لَا يُنَاسِبُهُ اثْبَاتُ الْخِيَارِ فِيهِ.

الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ النَّمْنِ وَبَيَانُ مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشَّقْصُ

فَصُلِّ إِنْ اشْتَرَى بِمِثْلِيٍّ كُنْفِدٍ وَجَبَ. (أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِهِ) (٥٢٩) أَوْ بِمُتَقَوِّمٍ (٥٣٠) كَنْوَبٍ وَعَبْدٍ. (فَبِقِيَمَتِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ) (٥٣١) وَقِيلَ: يَوْمَ اسْتِقْرَارِهِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ (٥٣٢). وَالْمُرَادُ بِاليَوْمِ الْوَقْتُ، وَمِمَّا يُصَدَّقُ بِهِ الْمِثْلِيُّ أَوْ الْمُتَقَوِّمُ أَنْ يَكُونَ مُسَلَّمًا فِيهِ بِالشَّقْصِ، أَوْ مُصَالِحًا عَنْهُ بِالشَّقْصِ، أَوْ نُجُومَ كِتَابَةِ مُعَوَّضًا عَنْهَا بِالشَّقْصِ، وَيُصَدَّقُ الدَّيْنُ مِمَّا ذُكِرَ بِالْحَالِ، وَيُقَابَلُهُ قَوْلُهُ. (أَوْ بِمُوجَلٍّ فَلَا يُظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ الشَّفِيعُ. (مُخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يُعَجَّلَ وَيَأْخُذَ فِي الْحَالِ أَوْ يَصْبِرَ إِلَى الْمَجَلِّ) بِكُسْرِ الْحَاءِ أَيْ

(٥٢٥) الخَامِسُ: وَيُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ مَعَ وجود اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ إِمَّا تَسْلِيمَ الْعَوْضِ إِلَى الْمُشْتَرِي أَوْ التَّخْلِيَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.

(٥٢٦) أَوْ أَلَزَمَهُ الْقَاضِي التَّسْلِيمَ حَيْثُ امْتَنَعَ مِنْهُ، أَوْ قَبِضَهُ الْقَاضِي عَنْهُ، فَقَدْ مَلَكَ الشَّفِيعُ الشَّقْصَ. (٥٢٧) وَثَبِتَ الشُّفْعَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِثَبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ لَا بِالْمَلِكِ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ قَدْ تَأَكَّدَ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ.

(٥٢٨) وَلَا يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ شَقْصًا لَمْ يَرَهُ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ، وَقِيلَ: يَتَمَلَّكُهُ قَبْلَ الرُّوْيَةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ، وَلَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ وجود الرُّوْيَةِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنَ الرُّوْيَةِ.

(٥٢٩) الْمِثْلِيُّ: هُوَ مَا لَهُ مِثْلٌ أَوْ شَبِيهِ فِي السُّوقِ وَهُوَ مَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مُوزُونًا أَوْ مَعْدُودًا. فَإِنْ أَخَذَهُ بِنَقُودٍ دَفَعَ نَقُودًا مِثْلَهَا أَوْ أَخَذَهُ بِحَبُوبِ قَمْحٍ أَوْ شَعِيرٍ دَفَعَ مِثْلَهَا إِنْ تَنَسَّرَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَنَسَّرْ وَقُتَ الْأَخْذُ فَبِقِيَمَتِهِ.

(٥٣٠) الْقِيَمِيُّ: مَا لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ شَبِيهِ فِي السُّوقِ. بَلْ لَهُ قِيَمَةٌ مُخْتَلِفَةٌ.

(٥٣١) وَتُعْتَبَرُ الْقِيَمَةُ يَوْمَ أَوْ وَقْتُ الْبَيْعِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَقْتُ اثْبَاتِ الْعَوْضِ وَاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا يَخْدُثُ بَعْدَهَا، وَذَلِكَ لِخُدُوثِهِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ.

(٥٣٢) وَقِيلَ: تُعْتَبَرُ الْقِيَمَةُ يَوْمَ اسْتِقْرَارِهِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ.

الْخُلُولِ (٥٣٣) (وَيَأْخُذُ) وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالتَّأخِيرِ لِلْعُدْرِ وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِمُؤَجَّلٍ، وَالثَّانِي (٥٣٤): لَهُ ذَلِكَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي، وَالثَّلَاثُ: يَأْخُذُهُ بِسَلْعَةٍ تُسَاوِي الثَّمَنَ إِلَى أَجَلِهِ.

(وَلَوْ بَيْعَ شِقْصٍ وَغَيْرُهُ) كَتُوبٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً. (أَخَذَهُ) أَيِ (الشَّفِيعُ بِحِصَّتِهِ) (٥٣٥) أَيِ بِمِثْلِ حِصَّتِهِ (مِنْ الْقِيَمَةِ) مِنْ الثَّمَنِ فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَقِيَمَةُ الشَّقْصِ ثَمَانِينَ، وَقِيَمَةُ الْمَضْمُونِ إِلَيْهِ عَشْرِينَ أَخَذَ الشَّقْصُ بِأَرْبَعَةِ أَحْمَاسِ الثَّمَنِ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيَمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِيهَا عَالِمًا بِالْحَالِ: وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَرَعَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ قِيَمَتَيْهِمَا، وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشَّقْصَ بِحِصَّتِهِ، أَيِ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَالرُّوْضَةِ.

(وَيُؤْخَذُ) الشَّقْصُ (الْمُطَهَّرُ) لِامْرَأَةٍ. (بِمَهْرٍ مِثْلِهَا) (٥٣٦)، وَكَذَا عَوَضُ الْخُلْعِ (٥٣٧).

يُؤْخَذُ بِمَهْرٍ مِثْلِ الْمَخْلُوعَةِ، وَالْإِعْتِبَارُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ يَوْمَ النِّكَاحِ، وَيَوْمَ الْخُلْعِ.

(وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزْأَيْهِ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ (٥٣٨) دَرَاهِمَ، أَوْ جَنْطَةً أَوْ غَيْرِهَا (وَتَلَفَ) الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِقَدْرِهِ (اِمْتَنَعَ الْأَخْذُ) (٥٣٩). فَإِنْ عَيَّنَ الشَّفِيعُ قَدْرًا، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَمْ يَكُنْ مَعْلُومَ الْقَدْرِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَيِ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ (٥٤٠).

(وَإِنْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِهِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ قَدْرًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ فِي الْأَصَحِّ) (٥٤١) وَالثَّانِي: تُسْمَعُ وَيَخْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفِ الثَّمَنُ ضَبْطًا وَأَخَذَ الشَّفِيعُ بِقَدْرِهِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يُكَلَّفْ

(٥٣٣) وَاشْتَرَى بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ لَا يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعْجَلَ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَيَأْخُذَ الشَّقْصُ فِي الْحَالِ، أَوْ يَصْبِرَ إِلَى وَقْتِ الْخُلُولِ لِلثَّمَنِ.

(٥٣٤) يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي. وَالثَّلَاثُ: يَأْخُذُهُ بِسَلْعَةٍ لَوْ بِيَعَتْ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ لَبِيعَتْ بِذَلِكَ الْقَدْرِ.

(٥٣٥) وَلَوْ بَيْعَ شِقْصٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا شَفْعَةَ فِيهَا مِنْ مَنَقُولٍ كَنَقْدٍ أَوْ أَرْضٍ أُخْرَى لَا شَرِكَةَ فِيهَا لِلشَّفِيعِ صَفْقَةً وَاحِدَةً. أَخَذَهُ الشَّفِيعُ الشَّقْصَ لِتَحَقُّقِ وُجُودِ سَبَبِ الْأَخْذِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الْقِيَمَةِ وَقَفْتُ الْبَيْعَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَقَفْتُ الْمُقَابَلَةَ.

(٥٣٦) وَيُؤْخَذُ الشَّقْصُ الْمَعْطَى مَهْرًا لِامْرَأَةٍ بِمِثْلِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَقَفْتُ نِكَاحَهَا.

(٥٣٧) كَمَا يُؤْخَذُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَقَفْتُ خُلْعَهَا سَوَاءً أَكَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيَمَتِهِ أَمْ لَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبُضْعَ مَنَقُومٌ، وَقِيَمَتُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

(٥٣٨) الْجُزْأَيْ: هُوَ بَيْعُ الشَّيْءِ لَا يَعْلَمُ كَيْلُهُ وَلَا وَزْنُهُ، وَهُوَ موجودٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَهُوَ مَبْنِي عَلَى الْحَدْسِ الْمَجْهُولِ الْقَدْرِ فَالْمُشْتَرِي يَشْتَرِي الشَّيْءَ دُونَ مَعْرِفَةِ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ صِفَتِهِ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْمُسَاهَلَةِ.

(٥٣٩) أَيِ أَنَّ الثَّمَنَ تَلَفَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ فَذَلِكَ اِمْتَنَعَ الْأَخْذُ بِالشَّفْعَةِ، وَذَلِكَ لِتَعَدُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى الثَّمَنِ، وَالْأَخْذُ بِالْمَجْهُولِ غَيْرُ مُمَكِّنٍ. وَهَذَا يَعْتَبَرُ مِنَ الْجِيلِ الْمُسْقِطَةِ لِلشَّفْعَةِ، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ لِمَا فِيهَا مِنْ إِنْقَاءِ الضَّرَرِ، وَلَيْسَ فِي دَفْعِ شَفْعَةِ الْجَارِ الَّذِي يَأْخُذُ بِهَا عِنْدَ الْقَائِلِ بِهَا.

(٥٤٠) وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ لَدِي، فَإِنَّهُ يَخْلَفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهِ بِهِ.

الْبَائِعِ إِخْصَارُهُ وَلَا الْإِخْبَارَ عَنْهُ. (وَإِذَا ظَهَرَ الثَّمَنُ مُسْتَحَقًّا) بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ. (فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا) كَأَن اشْتَرَى بِهِذِهِ الْمِائَةَ (بَطَلَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ) لِتَرْتِبِهَا عَلَيْهِ ^(٥٤٢) (وَالْأَلَا) بِأَن اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَدَفَعَ عَمَّا فِيهَا (أُبْدِلَ) الْمُدْفُوعُ (وَبَقِيَا) أَيِ الْبَيْعِ وَالشُّفْعَةِ ^(٥٤٣). (وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحَقًّا لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ إِنْ جَهِلَ) كَوْنُهُ مُسْتَحَقًّا بِأَن اشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ، وَعَلَيْهِ إِبْدَالُهُ. (وَكَذَا) أَيِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ. (إِنْ عَلِمَ) كَوْنُهُ مُسْتَحَقًّا. (فِي الْأَصَحِّ) ^(٥٤٤) **وَالثَّانِي:** نَزَلَ دَفْعُ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ مَنْزِلَةَ التَّرَكِّ لِلشُّفْعَةِ ^(٥٤٥). ثُمَّ قِيلَ الْخِلَافُ فِي الْأَخْذِ بِمُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ أَخَذْتُ بِالشُّفْعَةِ بِهِذِهِ الْمِائَةِ، فَإِنْ قَالَ بِمِائَةِ ثُمَّ دَفَعَ الْمُسْتَحَقَّ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ قَطْعًا وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي الْحَالَيْنِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الصَّحِيحِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ، وَظَاهِرُ السُّكُوتِ عَنْ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْجَهْلِ، أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ. (وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّقْصِ كَبَيْعٍ وَوَقْفٍ وَإِجَارَةٍ) وَهَبَةٍ (صَحِيحٍ) ^(٥٤٦)؛ لِأَنَّهُ مُلْكُهُ. (وَالشَّفِيعُ نَقَضَ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَالْوَقْفِ) وَالْهَبَةِ وَالْإِجَارَةِ ^(٥٤٧). (وَأَخَذَهُ) أَيِ الشَّقْصِ ^(٥٤٨). (وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ) وَصَدَاقٍ. (بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي) وَالْإِضْداقِ. (أَوْ يَنْقُضَهُ وَيَأْخُذَ بِالْأَوَّلِ)؛ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ ^(٥٤٩).

(٥٤١) وَإِنْ ادَّعَى الشَّفِيعُ عِلْمَ الْمُشْتَرِي بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ قَدْرًا ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ حَقًّا لَهُ.

(٥٤٢) أَيِ إِذَا ظَهَرَ الثَّمَنُ الَّذِي دَفَعَهُ مُشْتَرِي الشَّقْصِ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ بَيِّنَةً أَوْ بِتَصَدِيقٍ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشَّقْصِ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَطَلَ الْبَيْعُ وَبَطَلَتْ الشُّفْعَةُ لِتَرْتِبِهَا عَلَى الْبَيْعِ.

(٥٤٣) وَإِذَا اشْتَرَى بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ وَدَفَعَ عَمَّا فِيهِ، وَدَفَعَ عَمَّا فِيهَا، فَخَرَجَ الْمُدْفُوعُ مُسْتَحَقًّا أُبْدِلَ الْمُدْفُوعُ وَبَقِيَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ لَمْ يَبْطُلَا؛ لِأَنَّ إِعْطَاءَهُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ، فَكَانَ وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَلِلْبَائِعِ اسْتِزْدَادُ الشَّقْصِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَّعَ بِتَسْلِيمِهِ وَحَنَسِهِ إِلَى أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ.

(٥٤٤) وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ ثَمَنًا مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ جُزْمًا، حَتَّى وَإِنْ جَهِلَ كَوْنُهُ مُسْتَحَقًّا، بِأَن اشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِبْدَالُهُ ، وَأَيْضًا لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إِنْ عَلِمَ كَوْنُهُ مُسْتَحَقًّا فِي (الْأَصَحِّ) إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا بِهِذِهِ أَوْ الدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُرْ فِي الطَّلَبِ وَالْأَخْذِ.

(٥٤٥) يَبْطُلُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ فَكَأَنَّهُ تَرَكَ الْأَخْذَ مَعَ الْقُدْرَةِ.

(٥٤٦) وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّقْصِ الْمَشْفُوعِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْهَبَةِ أَوْ الْوَقْفِ أَوْ بِالْإِجَارَةِ أَوْ بِالرَّهْنِ أَوْ بغيرِ ذَلِكَ تَصَرَّفَ صَحِيحٌ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مُلْكِهِ.

(٥٤٧) وَيَحِقُّ لِلشَّفِيعِ نَقْضُ أَيِ تَصَرُّفٍ صَادَرَ مِنَ الْمُشْتَرِي مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا يُسْتَحَقُّ بِهَا الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فِي حَالِ مَا لَوْ وَجَدَ هَذَا التَّصَرُّفَ ابْتِدَاءً كَالْوَقْفِ وَالْهَبَةِ وَالْإِجَارَةِ أَوْ حُكْمٍ جَعَلَهُ مَسْجِدًا فَهُوَ كَالْوَقْفِ.

(٥٤٨) أَيِ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشَّقْصِ بِالشُّفْعَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ عَلَى هَذَا التَّصَرُّفِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ.

(٥٤٩) وَيَتَخَيَّرُ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ كَالْبَيْعِ وَإِعْطَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّدَاقِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَوْ الْإِضْداقِ أَوْ يَنْقُضَهُ أَوْ يَأْخُذَ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ. وَقَائِدُهُ أَنَّ الثَّمَنَ فِي الْأَوَّلِ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ أَوْ جِنْسَ الثَّمَنِ فِيهِ أَسهَل.

اِخْتِلَافُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ

(وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي، وَالشَّفِيعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ صَدَّقَ الْمُشْتَرِي) بِيَمِينِهِ ^(٥٥٠)؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ بِمَا بَاشَرَهُ. (وَكَذًا لَوْ أَنْكَرَ الشِّرَاءُ ^(٥٥١) أَوْ كَوَّنَ الطَّالِبُ شَرِيكًا) يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ بَلْ وَرِثَهُ أَوْ اتَّهَبَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الطَّالِبَ شَرِيكَ ^(٥٥٢).

(فَإِنْ اعْتَرَفَ الشَّرِيكَ) فِي صُورَةِ إِنْكَارِ الشِّرَاءِ (بِالْبَيْعِ فَالْأَصَحُّ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ) لِلْآخِرِ وَمُقَابِلُهُ يُنْظَرُ إِلَى إِنْكَارِ الشِّرَاءِ ^(٥٥٣).

(وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ إِلَى الْبَائِعِ إِنْ لَمْ يَعْتَرَفْ بِقَبْضِهِ) مِنَ الْمُشْتَرِي ^(٥٥٤). (وَإِنْ اعْتَرَفَ) بِقَبْضِهِ مِنْهُ. (فَهَلْ يُنْزَكُ فِي يَدِ الشَّفِيعِ أَمْ يَأْخُذُهُ الْقَاضِي، وَيَحْفَظُهُ فِيهِ خِلَافَ سَبَقِ فِي الإِقْرَارِ نَظِيرُهُ) فِيمَا إِذَا كَذَّبَ الْمُقَرَّرُ لَهُ الْمُقَرَّرَ بِمَا لِكَتُوبٍ وَأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يُنْزَكُ فِي يَدِهِ ^(٥٥٥).

(وَلَوْ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةُ جَمْعٌ أَخَذُوا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ وَفِي قَوْلِ عَلَى الرُّءُوسِ) فَإِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ النِّصْفِ وَالْآخَرِ الثُّلُثُ وَالْآخَرِ السُّدُسُ مِنْ دَارٍ، فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ أَخَذَهُ الْآخَرَانِ أَثْلَاثًا عَلَى الْأَوَّلِ وَنِصْفَيْنِ عَلَى الثَّانِي، وَجَهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمَلِكِ فَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ، وَوَجَهُ الثَّانِي أَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ أَصْلُ الشَّرِكَةِ، وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ^(٥٥٦).

(٥٥٠) وَإِذَا اِخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الشُّفْعَ أَوْ فِي قِيمَتِهِ إِنْ تَلَفَ وَلَا تَوْجِدَ بَيِّنَةٌ تَثْبُتُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ مِنَ الشَّفِيعِ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَدَّعِ مَا يَكْذِبُهُ الْحَسُّ.

(٥٥١) وَأَيْضًا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي حَالَةِ مَا لَوْ أَنْكَرَ الشِّرَاءَ لِلشُّفْعِ بِأَنْ قَالَ: لَمْ أَشْتَرِهِ سَوَاءً أَقَالَ: مَعَهُ وَرِثَتُهُ عَنْ أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ اتَّهَبْتُهُ مِنْ فُلَانٍ أَمْ لَا.

(٥٥٢) وَأَمَّا إِذَا أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي كَوَّنَ الطَّالِبُ لِلشُّفْعِ شَرِيكًا، أَوْ كَوَّنَ مَلِكُ الشَّفِيعِ مُقَدَّمًا عَلَى مَلِكِهِ، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ أَيْضًا بِيَمِينِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَحَقُّقِ ذَلِكَ. وَلَكِنْ يَخْلُفُ هُنَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

(٥٥٣) فَإِنْ اعْتَرَفَ الشَّرِيكَ الْقَدِيمُ. وَهُوَ الْبَائِعُ بِحُصُولِ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي الْمُنْكَرِ لِلشِّرَاءِ، وَالْمُشْفُوعُ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ: إِنَّهُ وَدِيعَةٌ لَهُ أَوْ هُوَ عَارِيَّةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (فَالْأَصَحُّ) ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لِطَّالِبِ الشُّفْعِ؛ لِأَنَّ إِفْرَازَهُ يَتَصَمَّنُ إِثْبَاتَ حَقِّ الْمُشْتَرِي وَحَقِّ الشَّفِيعِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِ الشَّفِيعِ. وَالثَّانِي: لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الشِّرَاءُ لَمْ يَثْبُتْ مَا يَنْفَرُ عَلَيْهِ.

(٥٥٤) وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ إِلَى الْبَائِعِ إِنْ لَمْ يَعْتَرَفْ بِقَبْضِهِ مِنَ الْمُشْتَرِي. وَعَلَيْهِ عَهْدُ الشُّفْعِ لِتَلْقَى الْمَلِكُ مِنْهُ، وَكَأَنَّ الشَّفِيعَ هُوَ الْمُشْتَرِي، فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ مِنَ الشَّفِيعِ، كَانَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِهِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ.

(٥٥٥) أَيْ يَأْخُذُهُ الْقَاضِي، وَيَحْفَظُهُ لَهُ لِأَنَّهُ مَالٌ صَائِعٌ.

(٥٥٦) وَلَوْ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةُ جَمْعٌ مِنَ الشُّرَكَاءِ أَخَذُوا بِهَا فِي (الْأَظْهَرِ) عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ الْمَخْصُصَةِ لَهُمْ مِنَ الْمَلِكِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ بِالْمَلِكِ. وَفِي قَوْلٍ: أَنَّهُمْ يَأْخُذُوا عَلَى قَدْرِ الرُّؤُوسِ الَّتِي لِلشُّرَكَاءِ دُونَ النِّظَرِ عَلَى مَقْدَارِ الْحِصَصِ الَّتِي لَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ أَصْلُ الشَّرِكَةِ.

(وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَ حِصَّتِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ بَاقِيَهَا لِآخَرَ، فَالشُّفْعَةُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ) وَقَدْ يَعْفُو عَنْهُ ^(٥٥٧). (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ عَفَا عَنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَإِلَّا فَلَا) يُشَارِكُهُ فِيهِ ^(٥٥٨).

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُشَارِكُهُ فِيهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ حَالَةً بِنَعْيِهِ. وَالثَّلَاثُ: لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لِلْمَبِيعِ مُزَلَّزٌ بِتَسْلُطِ الْآخَرِ عَلَيْهِ، وَظَاهِرٌ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْعَفْوِ وَالْأَخْذِ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إِنْ عَفَا قَبْلَهُ ثَبَّتَتْ الْمُشَارَكَةُ قَطْعًا أَوْ أَخَذَ قَبْلَهُ انْتَقَتْ قَطْعًا.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ سَقَطَ حَقُّهُ، وَتَخَيَّرَ الْآخَرُ بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ، وَتَرْكِهِ، وَلَيْسَ لَهُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ) لِئَلَّا تَتَبَعَضَ الصَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ^(٥٥٩). وَالثَّانِي: لَهُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ، الثَّلَاثُ: يَسْقُطُ حَقُّ الْإِثْنَيْنِ كَالْقِصَاصِ وَالرَّابِعُ: لَا يَسْقُطُ حَقٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغْلِيبًا لِلثَّبُوتِ.

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ سَقَطَ كُلُّهُ) كَالْقِصَاصِ ^(٥٦٠) وَالثَّانِي: لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ. كَحَدِّ الْقَذْفِ، وَالثَّلَاثُ: يَسْقُطُ مَا أَسْقَطَهُ وَيَبْقَى الْبَاقِي قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفَقَةِ فَإِنْ أَبَى، وَقَالَ خُذْ الْكُلَّ أَوْ دَعَا فَلَهُ ذَلِكَ، وَالْخِلَافُ قَالَ الْإِمَامُ إِذَا لَمْ نَحْكَمْ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْقَوْرِ، فَإِنْ حَكَمْنَا بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ طَرَدَهُ إِذَا بَادَرَ إِلَى طَلَبِ الْبَاقِي، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالسُّقُوطِ فِي الْكُلِّ.

(وَلَوْ حَضَرَ أَحَدُ شَفِيعَيْنِ فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ فِي الْحَالِ) ^(٥٦١) فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ) وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ الْإِقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ، لِئَلَّا تَتَبَعَضَ الصَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْغَائِبُ، وَمَا اسْتَوْفَاهُ الْحَاضِرُ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَحَصَلَ لَهُ مِنَ الْأَجْرَةِ وَالثَّمَرَةِ لَا يُزَاجِمُهُ فِيهِ الْغَائِبُ ^(٥٦٢).

(٥٥٧) وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي عَقَارٍ وَهُوَ مُنَاصِفَةٌ بَيْنَهُمَا، نِصْفَ حِصَّتِهِ لِرَجُلٍ، ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّرِيكَ الْأَوَّلُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ الْعَفْوِ عَنْهَا بَاعَ هَذَا الشَّرِيكَ بَاقِيَهَا لِرَجُلٍ آخَرَ، فَالشُّفْعَةُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ تَكُونُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ فِي حَالِ الْبَيْعِ شَرِيكَ إِلَّا الْبَائِعُ، وَالْبَائِعُ لَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ مَا بَاعَهُ.

(٥٥٨) (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ فِي حَالِهِ مَا إِذَا عَفَا الشَّرِيكَ الْقَدِيمُ عَنِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلَ يَشَارِكُهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ سَبَقَ الْبَيْعَ الثَّانِي، وَاسْتَقَرَّ بِعَفْوِ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَنْهُ، وَمَنْ ثَمَ فَيَسْتَحِقُّ مُشَارَكَتَهُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْفُ الشَّرِيكَ الْقَدِيمُ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَلْ أَخَذَهُ مِنْهُ فَلَا يُشَارِكُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ الْقَدِيمَ لِرَوَالِ مِلْكَهِ.

(٥٥٩) وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ عَنِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ سَقَطَ حَقُّهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ.

(٥٦٠) (وَالْأَصَحُّ) أَنَّ الشَّفِيعَ الْوَاحِدَ إِذَا أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ أَوْ جُزْءَ مِنْهُ، فَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُ كُلُّهُ كَحَقِّ الْقِصَاصِ.

(٥٦١) وَكَانَ الْآخَرُ غَائِبًا لَمْ يَحْضُرْ أَتَاءَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ.

(٥٦٢) فَإِذَا أَخَذَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ فَحُضُورُهُ الْآنَ، كَحُضُورِهِ مِنْ قَبْلُ، وَأَمَّا مَا اسْتَوْفَاهُ الْحَاضِرُ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالثَّمَرَةِ وَالْأَجْرَةِ فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْغَائِبُ.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْأَخْذِ إِلَى قُدُومِ الْغَائِبِ) لِعُذْرِهِ فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ، وَالثَّانِي لَا لِمَكْنِهِ مِنَ الْأَخْذِ وَالْخِلَافِ مَبْنِيٍّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ^(٥٦٣). (وَلَوْ اشْتَرَى شَقْصًا فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِهِمَا، وَنَصِيبِ أَحَدِهِمَا) وَخَذَهُ وَلَوْ اشْتَرَى وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ فَلَهُ أَيُّ الشَّفِيعِ. (أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) لِيَتَعَدَّ الصَّفَقَةُ بِتَعَدُّ الْبَائِعِ^(٥٦٤)، وَالثَّانِي: لَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَّ مَلَكَ الْحِصَّتَيْنِ مَعًا فَلَا يَفَرِّقُ مِلْكُهُ عَلَيْهِ.

هل الشُّفْعَةُ ثابتة عَلَى الْفَوْرِ أَمْ عَلَى التَّرَاخِي؟ ^(٥٦٥)

(وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الصَّرَرِ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ^(٥٦٦). وَالثَّانِي: تَمْتَدُّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَإِنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَتَأْمُلٍ فَتَقْدَرُ بِالثَّلَاثَةِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ^(٥٦٧).

(فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ) عَلَى الْأَوَّلِ (فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ) فِي طَلِبِهَا ^(٥٦٨). (إِنْ قَدَرَ) (فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُؤَكِّلْ) فِي طَلِبِهَا. (إِنْ قَدَرَ) التَّوَكُّيلَ فِيهِ ^(٥٦٩). (وَالْأَوْلَى فَلْيُشْهَدْ عَلَى الطَّلَبِ) لَهَا (فَإِنْ تَرَكَ الْمُقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أَيُّ مِنَ التَّوَكُّيلِ

(٥٦٣) (وَالْأَصَحُّ) أَنَّ لِلشَّفِيعِ تَأْخِيرَ الْأَخْذِ إِلَى قُدُومِ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ لِعُذْرِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا ظَاهِرًا فِي أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَئِنَّهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى أَخْذِ النُّبْضِ الْآنَ. (٥٦٤) وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَقْصًا مِنْ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِهِمَا وَنَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، إِذْ لَا تَفْرِيقَ عَلَيْهِ، وَلَوْ اشْتَرَى وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي (الْأَصَحِّ)؛ وَذَلِكَ لِيَتَعَدَّ الصَّفَقَةُ بِتَعَدُّ الْبَائِعِ فَصَارَ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَئِهِ.

(٥٦٥) يَقْصَدُ بِالْفَوْرِ: هُوَ وَجُوبُ الْأَدَاءِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ بَحِثَ يَلْحَقُهُ الذَّمُّ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ. وَأَمَّا التَّرَاخِي: فَهُوَ التَّمَهُّلُ وَامْتِدَادُ الزَّمَانِ وَتَرَاخِي الْأَمْرِ امْتِدَادُ زَمَانِهِ.

(٥٦٦) أَيُّ أَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ بَعْدَ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْفَوْرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الصَّرَرِ، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا عَلَى الْفَوْرِ هُوَ طَلِبُهَا وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّمْلِكُ بِهَا.

(٥٦٧) وَالثَّانِي وَهُوَ مَقَابِلُ الْأَظْهَرِ: أَنَّهَا تَمْتَدُّ مَدَّةً تَسَعُ التَّأْمُلَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الشَّقْصِ فَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ التَّأْمُلِ. وَثَابِتُهَا: أَنَّهَا عَلَى التَّأْيِيدِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِإِسْقَاطِهَا أَوْ يُعْرِضَ بِهِ كَيْفُهُ لِمَنْ شِئْتُ.

(٥٦٨) فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ بِالْبَيْعِ مِثْلًا فَلْيُبَادِرْ عَقِبَ عِلْمِهِ بِالشَّرَاءِ عَلَى حَسَبِ الْعَادَةِ، وَمَنْ ثُمَّ فَلَا يَكْلَفُ الْبِدَارَ عَلَى خِلَافِهَا بِالْعَدُوِّ وَنَحْوِهِ، بَلْ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ الْمَتَّبَعِ فِي ذَلِكَ، فَمَا عَدُوُّهُ تَقْصِيرًا وَتَوَانِيًا كَانَ مُسْقَطًا، وَمَا لَا فَلَا.

(٥٦٩) فَإِنْ كَانَ لِلشَّفِيعِ عُذْرٌ مَعْتَبَرٌ شَرعًا كَكُونِهِ مَرِيضًا مَرَضًا يَمْنَعُ مِنَ الْمَطَالَبَةِ لَا كَصُدَاعٍ يَسِيرٍ يُمْكِنُ تَحْمَلُهُ، أَوْ كَانَ مَحْبُوسًا ظُلْمًا، أَوْ بَدِينٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَعَاجِزٌ عَنِ الْبَيْتَةِ أَوْ كَانَ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي غَيْبَةً خَائِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُبَاشَرَةِ الطَّلَبِ أَوْ كَانَ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُؤَكِّلْ غَيْرَهُ فِي طَلِبِهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّوَكُّيلِ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُمْكِنُ لَهُ، وَيُعْذَرُ الْغَائِبُ فِي تَأْخِيرِ الْحُضُورِ لِلْخَوْفِ مِنَ الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَجِدْ رُقْعَةً تُعْتَمَدُ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ الْمُفْرِطَيْنِ.

وَالْإِشْهَادِ ^(٥٧٠) (بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِتَقْصِيرِهِ ^(٥٧١). وَالثَّانِي: لَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَلَحُّقَهُ مِنْهُ أَوْ مُؤَنَّةٌ فِيْمَا ذَكَرَ ^(٥٧٢)، وَفِي تَغْيِيرِهِ بِالْأَظْهَرِ تَغْلِيْبٌ لِلثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى، الْمُعَبَّرُ فِيهَا فِي الرُّوْضَةِ، كَأَصْلِهَا بِالْأَصَحِّ.

(قَلَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَامٍ أَوْ طَعَامٍ) أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ (فَلَهُ الْإِتْمَامُ) وَلَا يُكَلِّفُ قَطْعَهَا وَلَا يُلْزِمُهُ الْإِقْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَقَلِّ مَا يَجْزِي، وَلَوْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ الْأَكْلِ أَوْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، جَازَ لَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ ^(٥٧٣). (وَلَوْ أَحْرَ) الطَّلَبَ لَهَا (وَقَالَ لَمْ أَصْدَقِ الْمُخْبِرَ) بِنَيْعِ الشَّرِيكِ. (لَمْ يُعْذَرْ إِنْ أَخْبَرَهُ غَدْلَانِ) ذَكَرَانِ أَوْ ذَكَرَ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ (وَكَذَا ثِقَّةٌ فِي الْأَصَحِّ) حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ ^(٥٧٤)، وَالثَّانِي يُعْذَرُ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ بِوَاحِدٍ ^(٥٧٥).

(وَيُعْذَرُ إِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ) ككَافِرٍ وَفَاسِقٍ وَصَبِيٍّ، وَلَا يُعْذَرُ إِنْ أَخْبَرَهُ عَدَدٌ مِنَ الْفُسَاقِ، لَا يُحْتَمَلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذْبِ.

(وَلَوْ أَخْبِرَ بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ فَتَرَكَ فَبَانَ بِخَمْسِمِائَةٍ بَقِيَ حَقُّهُ)؛ لِأَنَّ التَّرْكَ لِحَبْرِ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ ^(٥٧٦). (وَإِنْ بَانَ بِأَكْثَرِ بَطَلَ) حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ بِأَلْفٍ فَبِأَكْثَرِ أُولَى ^(٥٧٧).

(٥٧٠) فَإِنْ عَجَرَ عَنِ التَّوَكُّلِ فَلْيُشْهَدْ عَلَى الطَّلَبِ بِالشُّفْعَةِ رَجُلَيْنِ غَدْلَيْنِ أَوْ رَجُلًا غَدْلًا وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا يَكْفِي رَجُلٌ وَاحِدٌ لِيُخْلِفَ مَعَهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَ الْقَضَاءِ لَا يَحْكُمُ بِهِ فَلَمْ يَسْتَوْثِقْ لِنَفْسِهِ.

(٥٧١) فَإِنْ تَرَكَ الشَّفِيعَ فَعَلَ الشَّيْءَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوَكُّلِ وَالْإِشْهَادِ فِي مَحَلِّهِ وَتَرْتِيبِهِ، فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ فِي (الْأَظْهَرِ) لِتَقْصِيرِهِ فِي الْأُولَى، وَلِإِشْعَارِ السُّكُوتِ وَالرِّضَا بِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِشْهَادِ فِي الثَّانِيَةِ.

(٥٧٢) وَالثَّانِي: لَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَلْحَقُهُ فِي الْأُولَى مِنْهُ أَوْ مُؤَنَّةٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ: أَنَّ الْإِشْهَادَ إِنَّمَا هُوَ لِاثْبَاتِ الطَّلَبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ..

(٥٧٣) أَيَّ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَوْثِرُ فِي تَأْخُرِ الْمَطَالِبَةِ بِالشُّفْعَةِ فَلَوْ حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْدِمَهَا، وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَهُ فَإِذَا فَرَّغَ طَالِبَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي لَيْلٍ فَحَتَّى يُصْبِحَ لِأَنَّ هَذَا لَا يُلْغِي الْفَوْرَ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَبَرَ مِنَ التَّرَاخِي.

(٥٧٤) وَلَوْ أَحْرَ الطَّلَبَ بِالشُّفْعَةِ وَقَالَ: لَمْ أَصْدَقِ الْمُخْبِرَ بِنَيْعِ الشَّرِيكِ الشَّفِصَ لَمْ يُعْذَرْ جُزْأً إِنْ كَانَ قَدْ أَخْبَرَهُ رَجُلَانِ غَدْلَانِ أَوْ عَدْلًا وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مَقْبُولَةٌ. وَكَذَا إِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَّةٌ حُرٌّ أَوْ امْرَأَةٌ فِي (الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ وَإِخْبَارُ الثِّقَّةِ مَقْبُولٌ.

(٥٧٥) وَالثَّانِي: يُعْذَرُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَثْبُتُ بِالْوَاحِدِ.

(٥٧٦) وَلَوْ أَخْبِرَ الشَّفِيعُ بِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ تَمَّ بِأَلْفٍ فَتَرَكَ الْمَطَالِبَةَ بِالشُّفْعَةِ فَبَانَ بِأَنَّ الثَّمَنَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ كَأَنَّ بَانَ بِأَنَّهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ بَاقٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ زُهْدًا فِيهِ، بَلْ تَرَكَهُ لِلْغَلَاءِ فِي ثَمَنِهِ، وَمَنْ ثُمَّ فَلَيْسَ مُقْصِرًا، وَيَبْقَى حَقُّهُ أَيْضًا لَوْ كُذِبَ عَلَيْهِ فِي تَعْيِينِ الْمُشْتَرِي أَوْ عَدَدِهِ أَوْ قَدْرِ الْمَبِيعِ أَوْ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ حُلُولِهِ أَوْ قَصْرِ أَجَلِهِ.

(٥٧٧) وَإِنْ بَانَ الثَّمَنُ بِأَكْثَرِ مِمَّا أَخْبِرَ بِهِ أَوْ أَخْبِرَ بِبَيْعِ جَمِيعِهِ بِأَلْفٍ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهُ بِأَلْفٍ بَطَلَ حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ بِأَلْفٍ فَبِأَكْثَرِ يَكُونُ أُولَى، وَيَبْطُلُ أَيْضًا لَوْ أَخْبِرَ بِبَيْعِ الشَّفِصِ بِكَذَا مُوجَّلاً فَتَرَكَ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَهُ خَالًا؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ التَّعْجِيلِ إِنْ كَانَ يَقْصِدُهُ.

(وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِيَ فُسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ) لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ) لَكَ (فِي صَفَقَتِكَ لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ (٥٧٨)؛ لِأَنَّ السَّلَامَ سُنَّةٌ قَبْلَ الْكَلَامِ، وَقَدْ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفَقَتَهُ مُبَارَكَةً. (وَفِي الدَّعَاءِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّهُ، لِإِشْعَارِهِ بِتَقْرِيرِ بَيْعِهِ (٥٧٩). (وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ) أَوْ وَهَبَهَا. (جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ فَأَلْصَحُّ بِطُلَانِهَا) لِزَوَالِ سَبَبِهَا (٥٨٠) ، **وَالثَّانِي:** لَا تَبْطُلُ لُجُودُ سَبَبِهَا حِينَ الْبَيْعِ، وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِهَا بَطْلَ حَقِّهِ قَطْعًا وَإِنْ قُلْنَا الشُّفْعَةُ عَلَى التَّرَاخِي، لِزَوَالِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ (٥٨١).

(B B B)

كِتَابُ الْقِرَاضِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ (٥٨٢)

(٥٧٨) أَمَّا السَّلَامُ فَهُوَ سُنَّةٌ قَبْلَ الْكَلَامِ. وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ: فَلِأَنَّ جَاهِلَ النَّمَنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَقَدْ يُرِيدُ الْعَارِفُ إِفْرَارَ الْمُشْتَرِي. وَأَمَّا فِي الثَّلَاثَةِ: فَلِأَنَّهُ قَدْ يَدْعُو لَهُ بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفَقَتَهُ مُبَارَكَةً، وَكَذَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالْدَّعَاءِ.

(٥٧٩) وَفِي الدَّعَاءِ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَةِ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، وَذَلِكَ لِإِشْعَارِهِ بِإِقْرَارِ بَيْعِهِ. (٥٨٠) أَيْ زَوَالِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ وَهُوَ الشَّرِكَةُ.

(٥٨١) خَاتِمَةٌ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الشُّفْعَةِ بِحَالٍ كَالرَّدِّ بِالْغَيْبِ وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إِنْ عَلِمَ بَفْسَادِهِ فَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا فِي الْكُلِّ عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ بَطْلَ الصُّلْحِ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُقَابِلُ بِعَوَضٍ وَكَذَا الشُّفْعَةُ إِنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهِ.

(٥٨٢) تعليق على شرح (كنز الراغبين) لجلال الدين المحلي، وهو شرح على متن (منهاج الطالبين) للإمام النووي أ.د/ ياسر عبدالعظيم/ أستاذ الفقه المساعد/ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

[١] تعريف القِرَاض لغة ^(٥٨٣): (القِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةُ) وَالْمُقَارَضَةُ.

[٢] تعريف القِرَاض اصطلاحاً: هو (أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ) أَي إِلَى شَخْصٍ. (مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ) بَيْنَهُمَا ^(٥٨٤).

[٣] تعريف الْمُضَارَبَةِ ^(٥٨٥):

[٤] حكم القِرَاضِ أو الْمُضَارَبَةِ: جائز.

[٥] دليل مشروعية القِرَاضِ ^(٥٨٦): وَدَلِيلُ صِحَّتِهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - ١٧-.

(٥٨٣) القِرَاضُ هُوَ بِكْسْرِ الْقَافِ لُغَةً أَهْلُ الْحِجَازِ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَرْضِ، وَهُوَ الْقَطْعُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَقْطَعُ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ لِكِي يَتَصَرَّفَ فِيهَا، كَمَا يَقْطَعُ قِطْعَةً مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ هُوَ مِنَ الْمُقَارَضَةِ، وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ؛ وَذَلِكَ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرِّبْحِ، أَوْ لِأَنَّ الْمَالَ مِنَ الْمَالِكِ، وَالْعَمَلَ مِنَ الْعَامِلِ، وَمِنْهُ الْمُقَارَضُ؛ لِأَنَّهُ آتَى لِلْقَطْعِ وَتَطْلُقُ الْمُقَارَضَةُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ كَمَا فِي الرِّبْحِ.

وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُ الْمُضَارَبَةَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ، وَلَمَّا فِيهِ غَالِبًا مِنَ السَّفَرِ، وَالسَّفَرُ يُسَمَّى ضَرْبًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا. قَالَ تَعَالَى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ... (١٠١) } سورة النساء [أَي سَافَرْتُمْ].

(٥٨٤) القِرَاضُ أو الْمُضَارَبَةُ: هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى آخَرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ بِهِ ، وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: القِرَاضُ. وَالْمُضَارَبَةُ: أَنْ تُعْطِيَ إِنْسَانًا مِنْ مَالِكَ مَا يَتَّجَرُ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَكُمَا، أَوْ يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ مِنَ الرِّبْحِ. وَاحْتَرَزَ بِ (الاشْتِرَاكِ فِي الرِّبْحِ) عَنِ الْوَكِيلِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِيَامِ بِالتَّجَارَةِ لِحَسَابِ سَيِّدِهِ.

(٥٨٥) وَقَوْلُ: ضَارَبَهُ فِي الْمَالِ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَهِيَ الْقِرَاضُ. وَاشْتِقَاقُ الْمُضَارَبَةِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ: قَطْعُهَا بِالسَّفَرِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يَدْفَعُونَ أَمْوَالَهُمْ لِلْعَمَالِ يَسَافِرُونَ بِهَا ابْتِغَاءَ الرِّبْحِ، ثُمَّ لَزِمَهُ هَذَا الْأَسْمُ وَإِنْ لَمْ يَسَافِرِ الْعَامِلُ.

(٥٨٦) الْأَدِلَّةُ: يَسْتَدِلُّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (٢٠) } سورة المزمّل [وَمِنَ السَّنَةِ النَّبَوِيَّةِ مَا رَوَى فِي مَعْنَى الْاِقْتِرَاضِ، وَهُوَ مَا رَوَى عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ ٢، قَالَ: { شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ: أَعَلَيْتَا حَرْجٌ فِي كَذَا؟ أَعَلَيْتَا حَرْجٌ فِي كَذَا؟ } فَقَالَ لَهُمْ: عِبَادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرْجَ، إِلَّا مَنْ اقْتَرَضَ، مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا تَتَدَاوَى؟ قَالَ: تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ، سُبْحَانَهُ، لَمْ يَضَعْ دَاءً، إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْهَرَمَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ } سنن ابن ماجه ج ٢ / ١١٣٧ / ٣٤٣٦ / كِتَابُ الطِّبِّ / بَابُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً/، وَلَكِنْ دَلِيلُهَا الْمُتَّفِقُ عَلَيْهِ هُوَ: الْإِجْمَاعُ عَلَى التَّعَامُلِ بِهِ. وَمِنَ الْآثَارِ الْمَرْوِيَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ ١٧ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ٢ قَالَ: { كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ٢ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجَازَهُ { المعجم الأوسط للطبراني ج ١ / ٢٣١ / ٧٦٠ / بَابُ مَنْ اسْمُهُ أَحْمَدُ / وَقَالَ الطَّبْرَانِيُّ: لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَقَرَّرَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ. وَقَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي سَنَنِهِ ج ٤ / ٥٢ / ٣٠٨١ / كِتَابُ الْبَيْعِ / فِي إِسْنَادِهِ أَبُو الْجَارُودِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَمِنَ الْآثَارِ مَا رَوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ ١٧، أَنَّهُ قَالَ: { حَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا

[٦] حقيقة هذا العقد (٥٨٧):

[٧] أَرْكَانَ عقد الْقِرَاضِ (٥٨٨):

[أ] الركن الأول: المال

[١] الشرط الأول: (وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ كَوْنُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ خَالِصَةً، فَلَا يَجُوزُ عَلَى تَبَرٍّ وَحَلِيِّ وَمَغْشُوشٍ) مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ (٥٨٩). (وَعُرُوضٍ) وَفُلُوسٍ (٥٩٠).

وَقِيلَ: يَجُوزُ عَلَى الْمَغْشُوشِ الرَّائِجِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ عَلَى الْفُلُوسِ (٥٩١).

[٢] الشرط الثاني: (وَمَعْلُومًا) (٥٩٢) فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَجْهُولِ الْقَدْرِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ أَوْ الصِّفَةِ. (مُعَيَّنًا) (٥٩٣). وَقِيلَ: يَجُوزُ عَلَى إِحْدَى الصَّرْتَيْنِ (الْمُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي الْقَدْرِ، وَالصِّفَةِ كَأَنَّ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَ مَرًّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: لَوْ أَقْدَرْتُ لَكُمْ عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعَكُمْ بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُرِيدُ أَنْ أُبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسَلِّفُكُمْاهُ فَنَبْتَائِعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ فَنَبْتَائِعَانِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمْ الرِّبْحُ، فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلْ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ: أَنْ خُذْ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا وَرَبِحَا، فَلَمَّا رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلَّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفُكُمْاهُ؟ فَقَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسَلِّفُكُمْاهُ؟ أَدَيَا الْمَالَ وَرَبِحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ هَلَكَ الْمَالَ أَوْ نَقَصَ لَصِمْنَاهُ. قَالَ: أَدَيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا. فَأَخَذَ عُمَرُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ { السنن الصغير للبيهقي ج-٢/ ٢١٦/٣١٤ كتاب البيوع/ بَابُ الْقِرَاضِ. ومن المعقول: إِنَّمَا جُوزَ الْقِرَاضُ لِلْحَاجَةِ لِإِنَّ مَالِكَ الْمَالِ قَدْ لَا يُحْسِنُ الاستفادة منه، أَوْ لَا يَتَقَرَّغُ لَهُ التفرغ المناسب لاستثماره وتنميته، ويوجد إنسان آخر لَا يَمْلِكُ مَالًا، وَيُحْسِنُ الْعَمَلَ لَذَا أُبِيحَ الْقِرَاضُ لِلْحَاجَةِ الداعية وللتعاون بين الناس بالمعروف.

(٥٨٧) واختلف الفقهاء في حقيقة هذا العقد فقيل: أوله وكالة وآخره شركة. وقيل: أوله وكالة وآخره جعالة.

ويترتب على القول الأول: أنه يملك الربح بالظهور، وعلى القول الثاني: على أنه يملك الربح بالقسمة.

(٥٨٨) أَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ: مَالٌ وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ وَصِيعَةٌ وَعَاقِدَانِ: مَالِكٌ لِلْمَالِ وَعَامِلٌ.

(٥٨٩) التبر: هو حجر الذهب أو الفضة غير المصوغ أو غير المضروب أو هو المعدن في ترابه. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: لَا يُقَالُ: تَبَرٌّ إِلَّا لِلذَّهَبِ فَقَط. والحلي: هو الزينة المصنوعة من الذهب أو من الفضة غالبًا، وهي التي تلبسها المرأة وغيرها. ومعنى مَغْشُوشٍ: أي مزيف من الدَّرَاهِمِ وَالْدَّنَانِيرِ أَوْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَدْ أَضِيفَ إِلَى الذَّهَبِ نَحَاسٌ، وَإِلَى الْفِضَّةِ مَعْدَنٌ آخَرُ كَالْأَلْمُونِيَوْمِ وَغَيْرِهِ. حَتَّى وَإِنْ رُوجِعَتْ وَعُلِمَ قَدْرُ غِشِّهَا وَجَوَزْنَا التَّعَامُلَ بِهَا؛ لِأَنَّ الْغِشَّ الَّذِي فِيهَا عَرَضٌ

(٥٩٠) ويقصد بِالْعُرُوضِ: أَنْ تَكُونَ مِثْلِيَّةً أَوْ مُتَقَوِّمَةً. وَالمثلي: هو ما له مثل أو شبيه في السوق وهو ما كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا. وَالْقِيَمِي: ما ليس له مثل أو شبيه في السوق. ويقصد بِالْفُلُوسِ هي المصنوعة من المعادن غير الذهب والفضة، وتشبه الآن النقود الورقية والمعدنية.

(٥٩١) وذلك لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ غَرَرٌ، حَيْثُ إِنْ الْعَمَلُ فِيهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ، كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ، وَإِنَّمَا جُوزَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ فَاحْتَصَّ بِمَا يَرْجُو غَالِبًا بَيْنَ النَّاسِ، وَيَسْهُلُ التَّجَارَةُ بِهِ أَوْ فِيهِ، وَهُوَ الْأَثْمَانُ.

يَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا أَلْفًا صِحَاحًا، قَالَ فِي الرُّوضَةِ فَعَلَى هَذَا يَتَصَرَّفُ الْعَالِمُ فِي أَيَّهِمَا شَاءَ، فَيَتَعَيَّنُ لِلْقِرَاضِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا، لَوْ قَارَضَ عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ قَطَعَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ بِجَوَازِهِ، كَالصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَقَطَعَ الْبُعْثِيُّ بِالْمَنْعِ وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ جَازٌ، وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَفِي الْمَحَرَّرِ وَغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَهُ عَلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ ذِمَّةٍ غَيْرِهِ.

[٣] الشرط الثالث: (وَمُسْلَمًا إِلَى الْعَامِلِ) ^(٥٩٤).

[٤] فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ ^(٥٩٥) يُوقَى مِنْهُ ثَمَنٌ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

[٥] (وَلَا) شَرْطُ (عَمَلِهِ مَعَهُ) ^(٥٩٦)؛ لِأَنَّ انْقِسَامَ التَّصَرُّفِ يُفْضِي إِلَى انْقِسَامِ الْيَدِ.

[٦] (وَيَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ) وَالثَّانِي: لَا كَشَرْطِ عَمَلِ الْيَدِ؛ لِأَنَّ يَدَ عَبْدِهِ يَدُهُ، وَفُرِقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ تَبَعًا لِلْمَالِكِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ، نَعَمْ إِنْ ضَمَّ إِلَى عَمَلِهِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْمَالِ فِي يَدِهِ أَوْ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ الْعَامِلُ، دُونَهُ فَسَدَ الْعَقْدُ قَطْعًا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوُصْفِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا فَسَدَ الْعَقْدُ.

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْعَمَلُ

[١] الشرط الأول: (وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التِّجَارَةُ وَتَوَابِعُهَا، كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا) ^(٥٩٧) وَذَرَعُهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّهُ عَلَيْهِ. (فَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً فَيَطْحَنَ وَيَخْبِزَ) وَيَبِيعُهُ. (أَوْ غَزَلَ يَنْسِجُهُ، وَيَبِيعُهُ فَسَدَ الْقِرَاضُ)؛ لِأَنَّ الطَّحْنَ وَالْخَبْزَ وَالْغَزَلَ وَالنَّسِجَ، لَيْسَتْ مِنْ وَظِيفَةِ الْعَامِلِ، وَهِيَ أَعْمَالٌ مَضْبُوطَةٌ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهَا فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْقِرَاضِ عَلَيْهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى جَهَالَةِ الْعَوَظِينَ لِلْحَاجَةِ ^(٥٩٨).

(٥٩٢) الشرط الثاني: أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مَعْلُومًا، فَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ عَلَى مَالٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ، وَذَلِكَ دَفْعًا لَجَهَالَةِ الرِّبْحِ.

(٥٩٣) وَمَعْنَى أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَيْ لَا يَكُونُ دَيْنًا، فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ أَوْ ذِمَّةٍ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.

(٥٩٤) الشرط الثاني: وَأَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُسْلَمًا إِلَى الْعَامِلِ وَذَلِكَ لِكَيْ يَسْتَقِلَّ الْعَامِلُ بِالْيَدِ عَلَيْهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِمَا يَحَقُّ الرِّبْحَ لَهَا.

(٥٩٥) لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَسْتَقِلَّ الْعَامِلُ بِالْيَدِ عَلَى الْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ.

(٥٩٦) أَيْ عَمَلِ الْمَالِكِ مَعَ الْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ.

(٥٩٧) الشرط الأول: وَهِيَ وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التِّجَارَةُ مِنْ خِلَالِ الْإِسْتِزْبَاحِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَهِيَ عَمَلٌ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(٥٩٨) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِرَاضَ شَرْعٌ رُخْصَةٌ لِلْحَاجَةِ، وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ مَضْبُوطَةٌ يُمَكِّنُ الْإِسْتِزْبَاحَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَشْمَلْهَا الرُّخْصَةُ، وَالْعَامِلُ لَيْسَ فِيهَا مُتَّجِرًا بَلْ مُحْتَرِفًا، وَمِنْ ثَمَّ فَلَيْسَتْ مِنْ وَظِيفَةِ الْعَامِلِ.

[٢] الشرط الثاني: (٥٩٩) ... (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرَطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ) كَقَوْلِهِ لَا تَشْتَرِ إِلَّا هَذِهِ السِّلْعَةَ. (أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودَهُ) قَوْلُهُ لَا تَشْتَرِ إِلَّا الْخَيْلَ الْبُلْقَ. (أَوْ مُعَامَلَةً شَخْصٍ) بِعَيْنِهِ كَقَوْلِهِ لَا تَبِعْ إِلَّا لِزَيْدٍ أَوْ لَا تَشْتَرِ إِلَّا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَتَاعَ الْمُعَيَّنَ قَدْ لَا يَرِبُحُ فِيهِ، وَالنَّادِرُ قَدْ لَا يَجِدُهُ، وَالشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ قَدْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ جِهَتِهِ رِبْحٌ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعَيُّنُ نَوْعٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ.

[٣] الشرط الثالث: (وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مُدَّةِ الْقِرَاضِ) (٦٠٠) فَإِنَّ الرِّبْحَ الْمُقْصُودَ مِنْهُ لَا يَنْصَبُطُ وَقْتُهُ. (فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفُ) أَوْ الْبَيْعَ كَمَا فِي الْمَحَرِّ وَغَيْرِهِ. (بَعْدَهَا فَسَدَ) الْعَقْدُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَرِبُحُ فِيهَا. (وَأِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءُ بَعْدَهَا فَلَا) يَفْسُدُ الْعَقْدُ (فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ الْإِسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا. وَالثَّانِي (٦٠١): يَفْسُدُ لِلتَّاقِيَةِ وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي قَوْلِهِ: لَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا وَلَكَ الْبَيْعُ، وَمَا هُنَا كَالْمَحَرِّ وَالتَّنْبِيهِ يُصَدَّقُ مَعَ ذَلِكَ، وَمَعَ السُّكُوتِ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَارَضْتُكَ سَنَةً، فَسَدَ الْعَقْدُ وَقِيلَ يَجُوزُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الشِّرَاءِ.

[ج] الرُّكْنُ الثَّلَاثُ: الرِّبْحُ

[١] الشرط الأول: (وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) (٦٠٢) فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِهِمَا إِلَّا عَبْدَ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلَ فَمَا شَرَطَهُ لَهُ مَضْمُونٌ إِلَى مَا شَرَطَ لِسَيِّدِهِ. (وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ كُلَّ الرِّبْحِ لَكَ، فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ. وَقِيلَ قِرَاضٌ صَحِيحٌ، وَإِنْ قَالَ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَسَادٌ وَقِيلَ: إِبْضَاعٌ) أَيُّ تَوَكُّلٍ بِلا جُعْلٍ (٦٠٣)، الْأَوَّلُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ: نَاطِرٌ إِلَى اللَّفْظِ. وَالثَّانِي إِلَى الْمَعْنَى، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْأُجْرَةِ فِي ذَلِكَ.

[٢] الشرط الثاني: (و) يُشْتَرَطُ (كَوْنُهُ) أَيُّ الْمُشْتَرَطِ مِنَ الرِّبْحِ. (مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ) (٦٠٤) كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ. (فَلَوْ قَالَ): قَارَضْتُكَ. (عَلَى أَنْ لَكَ فِيهِ شَرِكَةٌ أَوْ نَصِيبًا فَسَدَ) الْقِرَاضُ (أَوْ) أَنَّهُ (بَيْنُنَا

(٥٩٩) الشرط الثاني: يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُضَيَّقَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ فِي التَّصَرُّفِ.

(٦٠٠) الشرط الثالث: عدم تحديد مُدَّةِ الْقِرَاضِ؛ وذلك لِأَنَّ مُقْصُودَ الْقِرَاضِ هُوَ الرِّبْحُ، وَالرِّبْحُ لَيْسَ لَهُ وَقْتُ مَعْلُومٌ.

(٦٠١) أي مقابل القول الأصح عند الشافعية.

(٦٠٢) الشرط الأول: وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُ الْمَالِكِ الْعَامِلِ بِالرِّبْحِ، فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ مِنْهُ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ إِلَّا عَبْدَ الْمَالِكِ أَوْ عَبْدَ الْعَامِلِ. وَلَا يَوْجَدُ عبيد الآن.

(٦٠٣) أَيُّ تَوَكُّلٍ بِلا جُعْلٍ أي بلا مقابل لقيامه بالبيع أو بالشراء. وَالْإِبْضَاعُ: هُوَ بَعْثُ مَالٍ مَعَ مَنْ يَتَجَرُّ أَوْ يَتَاجَرُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا، وَالْإِبْضَاعَةُ هِيَ الْمَالُ الْمُبْعُوثُ.

(٦٠٤) الشرط الثاني: يُشْتَرَطُ الْأَشْتِرَاكُ فِي الرِّبْحِ وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ. فَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ مَجْهُولَ التَّوْزِيعِ بَطُلَ الْقِرَاضُ وَفَسَدَ.

فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ. وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ) لِتَبَادُرِهِ إِلَى الْفَهْمِ وَالثَّانِي: يَفْسُدُ لَاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِغَيْرِ الْمُنَاصَفَةِ، فَلَا يَكُونُ الْجُزْءُ مَعْلُومًا.

(وَلَوْ قَالَ لِي النِّصْفُ فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيَكُونُ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْعَامِلِ. (وَأِنْ قَالَ: لَكَ النِّصْفُ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ) وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ الْمَالِ، فَهُوَ لِلْمَالِكِ إِلَّا مَا يُنسَبُ مِنْهُ، لِلْعَامِلِ، وَلَمْ يُنسَبْ لَهُ فِي الْأَوَّلَى شَيْءٌ مِنْهُ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا لِلْمَالِكِ كَالْعَامِلِ. (وَلَوْ) (شَرِطَ لِأَحَدِهِمَا) أَيَّا كَانَ (عَشْرَةً) مِنَ الرِّبْحِ، وَالْبَاقِي مِنْهُ بَيْنَهُمَا (أَوْ رِبْحٌ صِنْفٌ) (فَسَدَ)؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ قَدْ يَنْحَصِرُ فِي الْعَشْرَةِ، أَوْ فِي ذَلِكَ الصَّفِّ فَيَقُوتُ عَلَى الْآخَرِ الرِّبْحِ.

[د] الرُّكْنُ الرَّابِعُ، الصِّيغَةُ

[١] الشرط الأول: يُشْتَرَطُ إيجابٌ وَقَبُولٌ فِي الْقَرَضِ ^(٦٠٥)، كَغَيْرِهِ مِنَ الْعُقُودِ. (وَقِيلَ: يَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ) ^(٦٠٦) فِيمَا إِذَا قَالَ لَهُ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مَثَلًا، وَاتَّجِرْ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ، فَأَخَذُوا مِنَ الْإِيجَابِ ضَارِبَتَكَ وَعَامِلَتُكَ.

الرُّكْنُ الْخَامِسُ: الْعَاقِدَانِ

[١] الشرط الأول: (وَشَرَطُهَا كَوَكِيلٍ وَمُتَوَكِّلٍ) ^(٦٠٧) أَيُّ الْعَامِلِ كَالْوَكِيلِ وَالْمَالِكِ كَالْمُوكِّلِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَفِيهًا وَيَجُوزُ لَوْلِيِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ أَنْ يُقَارِضَ بِمَالِهِمَا.

(٦٠٥) وَالصِّيغَةُ: هِيَ إيجابٌ من المالك للمال: كَقَارَضْتُكَ أَوْ ضَارِبْتُكَ أَوْ عَامِلْتُكَ أَوْ بَعْتُ وَاشْتَرَيْتُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ، فَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَيْعَ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ، ووجود وَقَبُولٌ من العامل بالموافقة على العمل ، وأن يكون مُتَّصِلًا بِالْإِيجَابِ بِالطَّرِيقِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْبَيْعِ، وَلَوْ فِي قَوْلِهِ: خُذْهُ وَاتَّجِرْ فِيهِ، أَوْ اْعْمَلْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ.

والشرط الثاني: أن يكون القبول موافقًا للإيجاب.

(٦٠٦) كَمَا فِي الْوُكَالَةِ وَالْجَعَالَةِ إِنْ كَانَتْ صِيغَةُ الْإِيجَابِ لَفْظَ أَمْرٍ كَخُذْ، فَيَكْفِي أَخْذُ الدَّزَاهِمِ مَثَلًا، فَلَوْ كَانَتْ بِلَفْظِ عَقْدٍ كَقَارَضْتُكَ فَلَا بُدَّ فِي الْقَبُولِ مِنْ وَجُودِ اللَّفْظِ كَمَا يَقْتَضِيهِ (وَالْأَصَحُّ) الْمَنْعُ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ إلخ، فَلَا يُشَبِّهُ الْوُكَالَةَ؛ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ إِذْنٍ، وَلَا الْجَعَالَةَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ.

(٦٠٧) الشرط الأول: فَيُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ فِي الْمَالِكِ، وَأَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ فِي الْعَامِلِ، فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَفِيهًا وَلَا صَبِيًّا وَلَا مَجْنُونًا ، وَيَجُوزُ لَوْلِيِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ أَنْ يُقَارِضَ مِنْ مَالِهِمَا ، أَوْ يُقَارِضَ مَنْ يَجُوزُ إِيدَاعُهُ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ، سَوَاءً أَكَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَمْ جَدًّا أَمْ وَصِيًّا أَمْ حَاكِمًا أَمْ أَمِينًا.

[٢] الشرط الثاني: شَرَطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكٍ أَوْ وَلَايَةٍ. فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ. وَشَرَطُ الْوَكِيلِ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ، لَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ.

[٣] الشرط الثالث: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ الشَّيْءُ الْمَرْهُونُ أَوْ الْمَوْقُوفُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مَا تَكُونُ الْمِلْكِيَّةُ فِيهِ مُتَنَازِعَةً فِيهَا.

(وَلَوْ قَارِضَ الْعَامِلُ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، لِيُشَارِكُهُ فِي الْعَمَلِ وَالرَّيْحَ لَمْ يَجُزْ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يَجُوزُ كَمَا لَوْ قَارِضَ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ ابْتِدَاءً وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَغْدَلَ الْمَالِكُ، وَالْعَامِلُ فَلَا، يَغْدَلُ إِلَى أَنْ يَغْدَهُ عَامِلَانِ وَلَوْ قَارِضَهُ بِالْإِذْنِ لَيَنْفَرِدَ بِالرَّيْحِ وَالْعَمَلِ جَارًا.

(وَيُغَيِّرُ إِذْنَهُ فَاسِدٌ^(٦٠٨).. فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي فَتَصَرَّفُ غَاصِبٍ) تَصَرَّفُهُ فَيُضْمَنُ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ. (فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ)^(٦٠٩) وَسَلَّمُ الْمَالِ فِي الثَّمَنِ وَرَبَحَ فِيمَا اشْتَرَى (وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ)^(٦١٠) فِيمَا إِذَا اشْتَرَى الْغَاصِبُ فِي الذِّمَّةِ وَسَلَّمُ الْمَغْضُوبِ فِي الثَّمَنِ، وَرَبَحَ فِيمَا اشْتَرَى أَنَّ الرَّيْحَ لَهُ (فَالرَّيْحُ) هُنَا (لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الثَّانِي وَكَيْلٌ عَنْهُ. (وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أَجْرَتُهُ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَانًا. (وَقِيلَ هُوَ لِلثَّانِي) كَالْغَاصِبِ، وَالْقَدِيمُ^(٦١١) فِي الْغَاصِبِ أَنَّ الرَّيْحَ لِلْمَالِكِ، وَعَلَى هَذَا فَالرَّيْحُ هُنَا فِي الْأَصَحِّ نِصْفُهُ لِلْمَالِكِ، لِرِضَاهُ بِهِ فِي الْأَصْلِ، وَنِصْفُهُ بَيْنَ الْعَامِلَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ، عَمَلًا بِالشَّرْطِ بَعْدَ خُرُوجِ نِصْبِ الْمَالِكِ. (وَإِنْ اشْتَرَى بَعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَبَاطِلٌ) شِرَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ فَضُولِيٌّ.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ الْوَاحِدَ اثْنَيْنِ مُتَقَاضِلًا وَمُتَسَاوِيًا)^(٦١٢) فِي الْمَشْرُوطِ لَهُمَا مِنَ الرَّيْحِ، كَأَنْ يَشْرَطَ لِأَحَدِهِمَا الْمُعَيَّنَ ثُلُثَ الرَّيْحِ، وَلِلْآخَرِ الرَّبْعَ أَوْ يَشْرَطَ لَهُمَا النِّصْفَ بِالسَّوِيَّةِ. قَالَ الْإِمَامُ: وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ اثْنَيْنِ إِذَا أُثْبِتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ الْإِسْتِقْلَالُ فَإِذَا شَرَطَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مُرَاجَعَةَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمَا أَظُنُّ الْأَصْحَابَ يُسَاعِدُونَهُ عَلَيْهِ، وَفِي الْمَطْلَبِ الْمَشْهُورِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا كَمَا ظَنَّهُ الرَّافِعِيُّ

(وَالِاثْنَانِ وَاحِدًا وَالرَّيْحُ بَعْدَ نِصْبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْمَالِ) فَإِذَا شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرَّيْحِ، وَمَالٌ أَحَدُهُمَا مِائَتَانِ، وَمَالُ الْآخَرِ مِائَةٌ افْتَسَمَا النِّصْفَ الْآخَرَ اثْنَلَاثًا، فَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ مَا تَقْتَضِيهِ النِّسْبَةُ، فَسَدَ الْعَقْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ الرَّيْحِ، لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.

ما يؤدي إلى فساد القراض^(٦١٣)

(٦٠٨) أَي فَاسِدٌ مُطْلَقًا، سَوَاءً أَقْصَدَ الْمُشَارِكَةَ فِي عَمَلٍ وَرَبِيحٍ، أَمْ قَصَدَ الرَّيْحَ فَقَطْ، أَمْ قَصَدَ الْإِنْشِلَاحَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِمَنَّ عَلَى الْمَالِ غَيْرُهُ.

(٦٠٩) فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَلَّمَ مَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فِيمَا اشْتَرَاهُ وَرَبِيحٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ صَحِيحٌ، وَالتَّسْلِيمَ فَاسِدٌ، فَيُضْمَنُ الثَّمَنُ الَّذِي سَلَّمَهُ، وَيُسَلِّمُ لَهُ الرَّيْحَ، سَوَاءً أَعْلِمَ بِالْحَالِ أَمْ لَا.

(٦١٠) أَي بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَدِيدِ: فَيَكُونُ الرَّيْحُ كُلُّهُ لِلْغَاصِبِ.

(٦١١) أَي بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ قَبْلَ مَجِيئِهِ إِلَى مِصْرَ.

(٦١٢) أَي أَنَّ يُقَارِضَ الْمَالِكُ فِي الْإِبْتِدَاءِ الْوَاحِدَ أَوِ الْاثْنَيْنِ كَرِيزٍ وَعَمْرٍو وَسَوَاءٌ أَكَانَ الرَّيْحُ مُتَقَاضِلًا أَوْ مُتَسَاوِيًا، فَيَجُوزُ كُلُّ ذَلِكَ فِيمَا شَرَطَ لَهُمَا مِنَ الرَّيْحِ.

(٦١٣) الْأَوَّلُ: مَا سَبَقَ مِنْ مَخَالَفَةِ شَرْطِ تَقْسِيمِ الرَّيْحِ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ الْمَتَّقَى عَلَيْهَا فَهَذَا يُوْدِي غُلَّ فِسَادِ الْقِرَاضِ وَإِعْطَاءِ الْعَامِلِ أَجْرَةَ الْمِثْلِ كَأَنَّهُ إِجَارَةٌ.

(وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ نَقَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ لِإِلَازِنِ فِيهِ. (وَالرِّبْحُ) جَمِيعُهُ (لِلْمَالِكِ)؛ لِأَنَّهُ نَمَاءٌ مِلْكِهِ (وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ مِثْلُ عَمَلِهِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَانًّا وَقَدْ فَاتَهُ الْمُسَمَّى. (إِلَّا إِذَا قَالَ قَارِضُكَ، وَجَمِيعُ الرِّبْحِ لِي وَقَبْلَ فَلَا شَيْءَ فِي الْأَصَحِّ) لِرِضَاهُ بِالْعَمَلِ مَجَانًّا وَالثَّانِي: لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُورِ الْفَسَادِ.

(وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ مُحْتَاطًا) فِي تَصَرُّفِهِ (لَا يَغِبُّ) فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (وَلَا نَسِيئَةً) فِي ذَلِكَ (بَلَا إِذْنِ) (٦١٤) أَيِ فِي النَّسِيئَةِ وَالْعَبْنِ. وَالْمُرَادُ بِهِ الْفَاحِشُ كَمَا فِي الْوَكِيلِ، وَبِالِإِذْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَأْتِي فِي تَقْدِيرِ الْأَجْلِ وَإِطْلَاقِهِ فِي الْبَيْعِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكِيلِ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ وَوَجَّهَ مَنْعُ الشِّرَاءِ نَسِيئَةً أَنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَدْ يُتْلَفُ رَأْسُ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهُدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ أَيِ فَتَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكِ.

(وَلَهُ الْبَيْعُ بَعْرُضٍ) (٦١٥)؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ فِي الْإِسْتِزْبَاحِ (و) لَهُ (الرَّدُّ بِغَيْبٍ تَقْتَضِيهِ) أَيِ الرَّدُّ (مُصْلَحَةً) (٦١٦) وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْغَيْبِ؛ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقَّهُ فِي الْمَالِ، وَجُمْلَةً تَقْتَضِيهِ صِفَةُ الرَّدِّ، وَلَامَهُ لِلْجِنْسِ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ} (٣٧) {سورة يس}.

(فَإِنْ أَقْتَضَتْ) (٦١٧) الْإِمْسَاكَ فَلَا يَرُدُّ (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: لَهُ الرَّدُّ كَالْوَكِيلِ. وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ شِرَاءٌ الْمَعِيبِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ إِذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا، فَلَا يَرُدُّ مَا فِيهِ مُصْلَحَةٌ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ.

(وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ) حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ (٦١٨). (فَإِنْ اخْتَلَفَا) فِيهِ. فَأَرَادَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبَاهُ الْآخَرُ (عُمِلَ) بِالْمُصْلَحَةِ (فِي ذَلِكَ) (٦١٩).

(وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكُ) بِأَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ (٦٢٠).

(٦١٤) أَيِ أَنَّ الْعَامِلَ يَتَصَرَّفُ مُحْتَاطًا فِي تَصَرُّفِهِ كَالْوَكِيلِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَ الْمُبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ الْحَالَّ.

(٦١٥) أَيِ أَنَّ الْعَامِلَ لَهُ الْحَقُّ فِي الْبَيْعِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالْدَنَانِيرِ أَوْ بِالْعُرُوضِ وَهِيَ السَّلْعُ وَالْبِضَاعُ. وَأَمَّا الْبَيْعُ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ الْبَلَدِ فَلَا يَجُوزُ.

(٦١٦) وَلِلْعَامِلِ عِنْدَ الْجَهْلِ الرَّدُّ بِغَيْبٍ تَقْتَضِيهِ مُصْلَحَةُ الْمُضَارَبَةِ وَالْحَصُولُ عَلَى الرِّبْحِ، حَتَّى وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الْمَالِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ رِضَا الْمَالِكِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَالِ.

(٦١٧) أَيِ إِنْ أَقْتَضَتْ الْمُصْلَحَةُ الْإِمْسَاكَ لِلسَّلْعَةِ الْمَعِيبَةِ فَلَا يَرُدُّهَا الْعَامِلُ (فِي الْأَصَحِّ).

(٦١٨) أَيِ يَحِقُّ لِلْمَالِكِ الرَّدُّ لِكُلِّ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ مَعِيبًا ، حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ الرَّدُّ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَالِكٌ مَالِ الْأَصْلِ، أَيِ الْمُضَارَبَةِ.

(٦١٩) فَإِنْ اخْتَلَفَا: أَيِ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ ، عُمِلَ فِي ذَلِكَ بِالْمُصْلَحَةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا حَقٌّ فِيهِ.

(وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ مَا زَادَ عَنْ جِهَةِ الْقِرَاضِ (٦٢١). (وَلَا يَشْتَرِي (مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ) مِنْ أَصُولِهِ وَفُرُوعِهِ (بِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَكَذَا زَوْجُهُ) لَا يَشْتَرِيهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (فِي الْأَصَحِّ (٦٢٢). وَلَوْ فَعَلَ (٦٢٣) أَيِ اشْتَرَى الْقَرِيبَ أَوْ الزَّوْجَ (لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ) لِيُتْلَى يَنْصَرَّرَ بِتَقْوِيَةِ الْمَالِ، أَوْ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ.

(وَيَقَعُ) الشِّرَاءُ (لِلْعَامِلِ أَنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) فَإِنْ اشْتَرَى بَعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ بَطَلَ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِي الرُّوحِ يُنْظَرُ إِلَى تَوَقُّعِ الرِّبْحِ فِي شِرَائِهِ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْأُنْثَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ } (٣٥) { سورة البقرة} وقال تعالى: { فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْعَرُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } (٩٠) { سورة الأنبياء}

التصرفات الممنوعة للعامل أن يفعلها

[١] (وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إِذْنٍ) (٦٢٤) لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ وَالتَّغْرِيبِ لِلتَّلَفِ، فَلَوْ سَافَرَ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ ضَمِنَهُ قَالَ فِي الرُّوضَةِ، وَإِذَا سَافَرَ بِالْإِذْنِ لَمْ يَجْزِ سَفَرُهُ فِي الْبَحْرِ إِلَّا بِنَصِّ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ الْمَلْحُ.

[٢] (وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا وَكَذَا سَفَرًا فِي الْأَظْهَرِ) (٦٢٥) ؛ لِأَنَّ لَهُ نَصِيبًا مِنَ الرِّبْحِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا آخَرَ، وَالثَّانِي (٦٢٦): يُنْفِقُ مِنْهُ مَا يَزِيدُ بِسَبَبِ السَّفَرِ، كَالْخُفِّ وَالْإِدَاوَةِ قَالَ: فِي الرُّوضَةِ وَزِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَاللِّبَاسِ وَالْكِرَاءِ وَتَحْوِهَا. اهـ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُخَسَّبُ مِنَ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ بِالسَّفَرِ عَنِ التَّكْسِبِ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ فَهُوَ خُسْرَانٌ لِحَقِّ الْمَالِ وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ السَّفَرِ فِي الْعَقْدِ صَحَّ عَلَى الثَّانِي، وَقَسَدَ عَلَى الْأَوَّلِ كَشَرَطِ نَفَقَةِ الْحَضَرِ.

(٦٢٠) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَامِلُ الْمَالِكِ بِمَالِ الْقِرَاضِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَا، فَإِنْ عَامَلَهُ بِغَيْرِهِ صَحَّ.

(٦٢١) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَرَبْحِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِأَنْ يَشْغَلَ الْعَامِلُ ذِمَّتَهُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ الْمَالُ الرَّائِدَ عَلَى جِهَةِ الْقِرَاضِ.

(٦٢٢) وَذَلِكَ لِإِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْمَالِكِ بِسَبَبِ انْفِسَاخِ نِكَاحِهِ. وَالثَّانِي أَيِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ: يَجُوزُ إِذْ قَدْ يَكُونُ مُرَبِّحًا، وَأَمَّا الضَّرَرُ فِي حَقِّهِ فَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، بِخِلَافِ شِرَاءِ الْقَرِيبِ لِقَوَاتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ..

(٦٢٣) أَيِ وَلَوْ فَعَلَ الْعَامِلُ مَا مُنِعَ مِنْهُ مِنَ الشِّرَاءِ بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَشِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَشِرَاءِ زَوْجِ الْمَالِكِ ، لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ الشِّرَاءُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْمَالِكِ. لِيُتْلَى يَنْصَرَّرَ بِذَلِكَ..

(٦٢٤) الممنوع الأول: وهو أن لا يسافر العامل بِلَا إِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَطْنَةُ الْخَطَرِ.

(٦٢٥) الممنوع الثاني: وهو أن لا ينفق من مال المضاربة على نفسه.

(٦٢٦) ويقصد بالثاني: أنه مقابل الأظهر هنا عند الشافعية: وهو يعني أن يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَزِيدُ بِسَبَبِ السَّفَرِ.

[٣] (وَعَلَيْهِ فِعْلٌ مَا يُعْتَادُ كَطَيِّ الثَّوْبِ) ^(٦٢٧) وَقَدْ تَقَدَّمَ (وَوَزُنَ الْخَفِيفُ) بِالرَّفْعِ (كَذَهَبَ وَمِنْكَ لَا الْأَمْتَعَةُ الثَّقِيلَةُ) فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزْنُهَا (وَنَحْوُهُ) بِالرَّفْعِ بِضَبِّ الْمُصَنَّفِ أَيْ نَحْوُ وَزْنِهَا، كَحَمَلِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ الْخَانِ إِلَى الْخَانُوتِ

[٤] (وَمَا لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الْإِسْتِجَارُ عَلَيْهِ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ، فَلَا أَجْرَةَ لَهُ وَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْ فِعْلِهِ فَلَا أَجْرَةَ مِنْ مَالِهِ ^(٦٢٨).

[٥] (وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرَّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ) ^(٦٢٩). **وَالثَّانِي:** بِالظُّهُورِ لِلرَّبْحِ كَالْمَالِكِ لَكِنَّهُ مَلِكٌ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ ^(٦٣٠)، وَلَا يَتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ لِاحْتِمَالِ الْخُسْرَانِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ يُورَثُ عَنْهُ، وَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرْمَاءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ. [٦] (وِثْمَارُ الشَّجَرِ وَالنَّبَاتِ وَكَسْبُ الرَّقِيقِ وَالْمَهْرُ الْحَاصِلَةُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ يُفَوَّرُ بِهَا الْمَالِكُ)؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ ^(٦٣١). (وَقِيلَ): هِيَ (مَالُ الْقِرَاضِ)؛ لِأَنَّهَا مِنْ فَوَائِدِهِ، وَعَلَى هَذَا فِيهِ مِنَ الرَّبْحِ . وَقِيلَ: هِيَ شَائِعَةٌ فِي الرَّبْحِ وَرَأْسُ الْمَالِ، وَالنَّبَاتُ يَشْمَلُ وَلَدَ الْبَهِيمَةِ وَالْجَارِيَةَ وَالْمَهْرَ، بِوَطْنِهَا بِشَبْهَةٍ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ وَطْنُهَا وَلَا تَرْوِجُهَا.

[٧] (وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ بِالرُّخْصِ مَحْسُوبٌ مِنَ الرَّبْحِ مَا أَمَكَّنَ وَمَجْبُورٌ بِهِ) لِإِقْتِصَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ وَالْحَقُّ بِهِ النَّقْصُ، بِالْمَرَضِ وَالنَّعِيبِ الْحَادِثَيْنِ ^(٦٣٢).

(وَكَذَا لَوْ تَلَفَ بَعْضُهُ) أَيْ مَالُ الْقِرَاضِ (بِأَقَةِ) سَمَاوِيَّةٍ كَحَرِيقٍ. (أَوْ غَضَبٍ أَوْ سَرِقَةٍ) بِأَنْ تَعَدَّرَ أَخْذَهُ أَوْ أَخْذُ بَدَلِهِ (بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ) بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَحْسُوبٌ مِنَ الرَّبْحِ (فِي الْأَصَحِّ) **وَالثَّانِي:**

(٦٢٧) **الممنوع الثالث:** وهو أن لا يقصر في عمله بل يتبع العرف ، فالعامل يجب عليه فعل ما يُعتَادُ فِعْلُهُ مِنْ أُمْتَالِهِ مِنْ عُمَالِ الْقِرَاضِ، وذلك بِحَسَبِ الْعُرْفِ.

(٦٢٨) **الممنوع الرابع:** وهو أن كل ما لا يَلْزَمُهُ كَأَجْرَةِ كَيْلٍ وَحِفْظٍ لَيْسَ لَهُ الْإِسْتِجَارُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ؛ وذلك لِأَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ تِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا، وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْتَحِقْ أَجْرَةً عَلَيْهِ.

(٦٢٩) **الممنوع الخامس:** أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرَّبْحِ الْحَاصِلِ بِعَمَلِهِ لِلْمَالِ بِالظُّهُورِ لِلرَّبْحِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا بِالْقِسْمَةِ ، إِذْ لَوْ مَلَكَ بِالظُّهُورِ لَكَانَ شَرِيكًا فِي الْمَالِ وَلَيْسَ عَامِلًا، حَتَّى لَوْ هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ هَلَكَ مِنَ الْمَالَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الرَّبْحُ يَعْتَبَرُ وَقَايَةً لِرَأْسِ الْمَالِ.

(٦٣٠) أَيْ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرَّبْحِ بِالظُّهُورِ قِيَاسًا عَلَى الْمُسَاقَاةِ.

(٦٣١) **الممنوع السادس:** أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ شَيْءًا مِنْ وِثْمَارِ الشَّجَرِ، وَالنَّبَاتِ الْحَاصِلِ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوْ الْبَهِيمَةِ، وَأَيْضًا كَسْبُ الرَّقِيقِ أَوْ الْعَبْدِ مِنْ صَيِّدٍ وَاحْطِطَابٍ، وَقَبُولِ وَصِيَّةٍ، وَالْهَبَةِ وَالْمَهْرُ وَأَجْرَةُ الْأَرْضِيِّ وَالذَّوَابِ الْحَاصِلَةُ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الْمُشْتَرَى بِهِ شَجَرٌ وَرَقِيقٌ وَأَرْضٌ وَحَيَوَانٌ لِلتِّجَارَةِ، يُفَوَّرُ بِهَا الْمَالِكُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ وذلك لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ..

(٦٣٢) وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ بِالرُّخْصِ فِي السَّعَرِ أَوْ بِالْعَيْبِ أَوْ بِالْمَرَضِ الْحَادِثَيْنِ مَحْسُوبٌ مِنَ الرَّبْحِ مَا أَمَكَّنَ الْحِسَابُ مِنْهُ، وَمَجْبُورٌ ذَلِكَ النَّقْصُ بِهِ ، أَيْ الرَّبْحُ لِإِقْتِصَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ

لَا يُحْسَبُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالتَّجَارَةِ بِخِلَافِ الرُّخْصِ، وَلَيْسَ نَاشِئًا مِنْ نَفْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْمَرَضِ وَالْعَيْبِ.

(وَأِنْ تَلَفَ) بِمَا ذُكِرَ. (قَبْلَ تَصَرُّفِهِ) بِنَيْعٍ وَشِرَاءٍ. (فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ، وَالثَّانِي: مِنَ الرَّيْحِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبُضُهُ صَارَ مَالٌ قِرَاضٍ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ تَلَفَ جَمِيعُهُ ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ.

أسباب فسخ القراض أو المضاربة

فَصْلٌ: لِكُلِّ مِنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (٦٣٣) (فَسْخُهُ) أَيُّ الْقِرَاضِ مَتَى شَاءَ (٦٣٤).

(وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ انْفُسَخَ) كَالْوَكَالَةِ (٦٣٥). (وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ الْإِسْتِيفَاءُ) لِلذَّيْنِ (إِذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَتَنَضُّيْضُ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ كَانَ) الْمَالُ (عَرَضًا) بِأَنْ يَبِيعَهُ بِنَقْدٍ (٦٣٦) (وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ التَّنَضُّيْضُ إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ فِي عَهْدَةٍ أَنْ يَرُدَّ الْمَالُ كَمَا أَخَذَ ثُمَّ، مَا اسْتَوْفَاهُ أَوْ نَضَّضَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ، حَصَّلَهُ بِهِ وَتَقْيِيدُ التَّنَضُّيْضِ بِرَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُ عَرَضٍ مُشْتَرَكٍ فِيهِ، أَثْنَانِ لَا يُكَلَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، بِنَيْعِهِ. (وَلَوْ) (اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَهُ) أَيُّ الْمَالِ (قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ وَخُسْرَانٍ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ إِلَى الْبَاقِي) بَعْدَ الْمُسْتَرَدِّ (وَإِنْ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الرَّيْحِ، فَالْمُسْتَرَدُّ شَائِعٌ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ) عَلَى التَّسْبِةِ الْحَاصِلَةِ لَهُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا (مِثَالُ رَأْسِ الْمَالِ مِائَةٌ وَالرَّيْبُ عِشْرُونَ وَاسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَالرَّيْبُ سُدُسُ الْمَالِ) جَمِيعُهُ (فَيَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ سُدُسَهُ) بِالرَّفْعِ (مِنْ الرَّيْبِ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَتُلْتِ (فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوطُ مِنْهُ) وَهُوَ وَاحِدٌ وَتُلْتَانِ، إِنْ شَرِطَ لَهُ نِصْفُ الرَّيْبِ، حَتَّى لَوْ عَادَ مَا فِي يَدِهِ إِلَى ثَمَانَيْنِ، لَمْ يَسْقُطْ مَا اسْتَقَرَّ لَهُ. (وَبَاقِيهِ) أَيُّ الْمُسْتَرَدِّ وَهُوَ سِتَّةٌ عَشَرَ وَتُلْتَانِ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) فَيَعُودُ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانَيْنِ وَتُلْتِ. (وَإِنْ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الْخُسْرَانِ، فَالْخُسْرَانُ مُورَعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ، وَالْبَاقِي فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ، لَوْ رِبْحٌ بَعْدَ ذَلِكَ. مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالْخُسْرَانُ عِشْرُونَ ثُمَّ اسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَرُبُعُ الْعِشْرِينَ) بِالْخُسْرَانِ. (حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ) مِنْهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ. (وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) فَلَوْ بَلَغَ ثَمَانَيْنِ قُسِمَتِ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِنْ شَرِطَ الْمُنَاصَفَةَ.

كيفية إثبات القراض أو المضاربة

(٦٣٣) عقد القراض من العقود جائزة: التي يجوز للمالك أو العامل فسخه متى شاء. وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ بِقَوْلِهِ: فَسَخْتُ عَقْدَ الْقِرَاضِ أَوْ رَفَعْتُهُ أَوْ أَبْطَلْتُهُ أَوْ لَا تَتَصَرَّفُ بَعْدَ هَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِاسْتِرْجَاعِ الْمَالِ، فَإِنْ اسْتَرْجَعَ بَعْضُهُ انْفَسَخَ فِيهِ، وَبَقِيَ الْقِرَاضُ فِي الْبَاقِي.

(٦٣٤) وذلك لِأَنَّ الْقِرَاضَ فِي ابْتِدَائِهِ وَكَالَهُ، وَفِي انْتِهَائِهِ إِذَا شَرِكَةً وَإِمَّا جَعَالَةً، وَكُلُّهَا عُقُودٌ جَائِزَةٌ.

(٦٣٥) فَالْمَوْتُ وَالْجُنُونُ الْإِغْمَاءُ أَسْبَابٌ تَوْدِي عَلَى فسخ القراض أو المضاربة ، وقد سبق فسخ أحدهما له بإرادته

(٦٣٦) يقصد بتنضيض رأس المال من السلع أو العروض. من خلال تحويلها إلى دراهم أو دنانير.

[١] (وَيُصَدِّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَرْبَحْ) شَيْئًا (أَوْ لَمْ أَرْبَحْ إِلَّا كَذَا) ^(٦٣٧). لِمُوَافَقَتِهِ فِيمَا نَفَاهُ لِلأَصْلِ (أَوْ اشْتَرَيْتَ هَذَا لِلْقَرَضِ) وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا (أَوَّلَى) وَكَانَ رَابِحًا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ. (أَوْ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا) ^(٦٣٨)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ (وَفِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ) ^(٦٣٩)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزَّائِدِ عَلَى مَا قَالَهُ. (وَدَعَوَى التَّلْفِ) ^(٦٤٠)؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ. فَإِنْ ذُكِرَ سَبَبُهُ فَهُوَ عَلَى التَّقْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ.

(وَكَذَا دَعَوَى الرَّدِّ) عَلَى الْمَالِكِ (فِي الْأَصَحِّ) ^(٦٤١)؛ لِأَنَّهُ انْتَمَنَهُ كَالْمُودِعِ. وَالثَّانِي ^(٦٤٢): لَا كَالْمُرْتَهِنِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بَيِّنَاتِ الْمُرْتَهِنِ قَبْضَ الْعَيْنِ لِمَنْفَعَتِهِ وَالْعَامِلِ قَبْضَ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ وَانْتِفَاعِهِ بِالْعَمَلِ.

(وَلَوْ) (اخْتَلَفَا) ^(٦٤٣) فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ. كَأَنْ قَالَ شَرِطْتُ لِي النِّصْفَ. وَقَالَ الْمَالِكُ بَلْ الثُّلُثُ ^(٦٤٤) (تَحَالَفَا) كَاخْتِلَافِ الْمُتَبَايَعِينَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ. (وَلَهُ أَجْرَةُ الْمُثَلِّ) لِعَمَلِهِ ^(٦٤٥) وَلِلْمَالِكِ الرِّبْحُ قَالَ فِي الرُّوضَةِ: وَهَلْ يَنْفَسَخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ أَمْ بِالْفَسْخِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ قَالَهُ فِي النَّبَيَانِ.

(٦٣٧) الْأَصْلُ أَنْ الْقَرَضَ يَعْتَبَرُ أَمَانَةً عِنْدَ الْعَامِلِ وَمَنْ ثَمَّ فَيُصَدِّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَرْبَحْ شَيْئًا. إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ الْمَالِكُ عَكْسَ قَوْلِهِ. مَعَ جَوَازِ إِثْبَاتِهِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ أَوْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْقَرَأَنِ.

(٦٣٨) وَيُصَدِّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ أَيْضًا فِي عَدَمِ النَّهْيِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ. إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ الْمَالِكُ عَكْسَ قَوْلِهِ.

(٦٣٩) وَيُصَدِّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزِّيَادَةِ. إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ الْمَالِكُ عَكْسَ قَوْلِهِ.

(٦٤٠) وَأَيْضًا يُصَدِّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْمَالَ تَلَفٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ. إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ الْمَالِكُ عَكْسَ قَوْلِهِ.

(٦٤١) وَيُصَدِّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ فِي دَعَوَى الرَّدِّ لِمَالِ الْقَرَضِ عَلَى الْمَالِكِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ انْتَمَنَهُ كَالْوَكِيلِ. إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ الْمَالِكُ عَكْسَ قَوْلِهِ.

(٦٤٢) أَيْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ: لَا يَصْدُقُ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ.

(٦٤٣) أَيْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الْعَامِلَ وَكَيْلٌ أَوْ مُقَارِضٌ صَدَقَ الْمَالِكُ وَلَا أَجْرَةَ لِلْعَامِلِ.

(٦٤٤) أَيْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِلُ.

(٦٤٥) أَيْ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ أَجْرَةُ الْمُثَلِّ لِعَمَلِهِ بِالِغَةِ مَا بَلَغَتْ، وَذَلِكَ لِتَعَدُّ رُجُوعِ عَمَلِهِ إِلَيْهِ، فَوَجِبَ لَهُ قِيَمَتُهُ وَهُوَ الْأُجْرَةُ.

أقسام الإجارة: هي قسمان: (القسم الأول): إجارة واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين) والتثنية بعد العطف أو، كما في قوله تعالى { إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما... } [النساء: ١٣٥].

(والقسم الثاني): وإجارة واردة (على الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء) (٦٥١).

وأقتصر في العقار على إجارة العين؛ لأنه لا يثبت في الذمة. (ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين) للإضافة إلى مخاطب. (وقيل) إجارة (ذمة)؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة، المخاطب فله تخصيصه بغيره. (ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس) كراس مال السلم؛ لأنها سلم في المنافع، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة. (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها) كالثمن في البيع.

أركانها: فلا بد فيها من عاقدين وصيغة (٦٥٢):

[أ] الركن الأول العاقدان: (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر (٦٥٣) (كبايع ومشتري) أي كشرطهما من الرشد، وعدم الإكراه كما تقدم في البيع (٦٥٤).

[ب] الركن الثاني: الصيغة (٦٥٥):

وصيغة الإجارة: (والصيغة: كأجزتك هذا أو أكريتك هذا أو ملكتك منافع سنة كذا فيقول) على الاتصال. (قبلت أو استأجرت أو اكرتيت) إلخ (والأصح انعقادها بقوله أجزتك منفعتها) أي الدار إلخ.

الناس في جميع الأزمان والأعصار، وفي كل البلدان والأصهار إلى يومنا هذا، يقومون بالإجارة المشروعة وغير المشروعة، فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأغذية.

(٦٥١) ودليلها ما روي أبو بريدة، عن أبيه أبي موسى الأشعري ع ، قال: قال النبي ﷺ : { الحارن الأمين، الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أخذ المتصدقين } [صحيح البخاري ج ٣ / ٨٨ / ٢٢٦٠ / كتاب الإجارة / باب استئجار الرجل الصالح].

(٦٥٢) أركان الإجارة أربعة: عاقدان، وصيغة، وأجرة، ومنفعة، وقد اقتصر المصنف على ركنين فقط من الأربعة حيث إنهما الأهم.

(٦٥٣) فالمؤجر: هو المالك للعين أي كانت. والمستأجر: هو من يطلب إيجارها والانتفاع بمنفعتها.

(٦٥٤) ويشترط في العاقدان: ويشترط فيهما، العقل والبلوغ، والاختيار وعدم الإكراه، كسائر التصرفات. وأما إسلام المتعاقدين فليس بشرط.

(٦٥٥) والصيغة: هي اللفظ الدال على وقوع الإجارة بين المتعاقدين، وهو اللفظ المشتمل على الإيجاب من طرف والقبول من الطرف الثاني.

حكم الإجارة بصيغة البيع :

(وَمَنْعُهَا) أَي مَنَعَ انْعِقَادَهَا (بِقَوْلِهِ بَعْتُكَ مَنَفَعَتَهَا) إلخ؛ لِأَنَّ الْمَنَفْعَةَ مَمْلُوكَةٌ بِالْإِجَارَةِ، فَذَكَرَهَا فِيهَا تَأْكِيدًا، وَلَفْظُ الْبَيْعِ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ، فَذَكَرَهُ فِي الْمَنَفْعَةِ مُفْسِدًا لَهَا.
(وَالثَّانِي) فِي الْأُولَى قَالَ لَفْظُ الْإِجَارَةِ وَضِعَ مُضَافًا لِلْعَيْنِ فَذَكَرَ الْمَنَفْعَةَ مَعَهُ مُفْسِدًا وَفِي الثَّانِيَةِ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّ الْإِجَارَةَ صِنْفٌ مِنَ الْبَيْعِ.
[ج] الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْأُجْرَةُ (٦٥٦).

[١] (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ مَعْلُومَةً) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ (فَلَا تَصِحُّ) إِجَارَةُ الدَّارِ وَالذَّابَّةِ (بِالْعِمَارَةِ وَالْعُلْفِ) . (وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا) أَي الْمَرْأَةُ (لَتَرَضَعَ رَقِيقًا بِنَعْضِهِ فِي الْحَالِ جَارَ عَلَى الصَّحِيحِ) لِلْعِلْمِ بِهِ، وَالثَّانِي قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ عَمَلُ الْأَجِيرِ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ بِنَعْضِهِ، بَعْدَ الْقِطَامِ لَمْ تَصَحَّ جِزْمًا لِلْجَهْلِ بِهِ إِذْ ذَاكَ.

[٢] (وَيَجُوزُ) فِي الْأُجْرَةِ. (فِيهَا التَّعْجِيلُ وَالتَّأْخِيلُ إِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ) بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ فَإِنَّهَا مَا تُوجَلُ (وَإِذَا أُطْلِقَتْ تَعَجَّلَتْ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً مُلِكَتْ فِي الْحَالِ) أَي بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَفِي الرُّوَضَةِ وَأَصْلُهَا أَنَّ الْمُطْلَقَةَ تُمْلِكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ أَيْضًا، وَفِي التَّتِمَّةِ تُمْلِكُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، سَوَاءً كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ عَيْنٍ مَالٍ، وَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ.

[د] الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمَنَفْعَةُ: وَيُشْتَرَطُ فِيهَا خَمْسَةٌ شُرُوطٌ.

[١] الشرط الأول: يشترط (كَوْنُ الْمَنَفْعَةِ مُتَقَوِّمَةً) أَي لَهَا قِيَمَةٌ. (فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ بَيَّاعٍ عَلَى كَلِمَةٍ لَا تَتَعَبُ وَإِنْ رُوجِبَتِ السَّلْعَةُ) إِذْ لَا قِيَمَةَ لَهَا. (وَكَذَا دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ لِلتَّرْتِينِ وَكَلْبٌ لِصَيْدٍ) أَوْ حِرَاسَةٍ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِمَا ذُكِرَ. (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ التَّرْتِينَ بِالْقَدْرِ لَا يُقْصَدُ إِلَّا نَادِرًا، وَالنَّادِرُ كَالْمَعْدُومِ فَلَا قِيَمَةَ لَهُ، وَالْكَلْبُ لَا قِيَمَةَ لَعَيْنِهِ فَكَذَا الْمَنَفْعَةُ وَالثَّانِي يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ.
[الشرط الثاني] (وَكَوْنُ الْمُؤَجَّرِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا) أَي الْمَنَفْعَةِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا.

[١] (وَالِامْتِنَاعُ الْحِسِّيِّ) مِثْلُ (فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ آبِقٍ وَمَغْصُوبٍ وَأَعْمَى لِلْحِفْظِ) أَي حِفْظِ الْمَتَاعِ. (وَأَرْضٍ لِلزَّرَاعَةِ لَا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ، وَلَا يَكْفِيهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ) وَفِي الرُّوَضَةِ كَأَصْلِهَا، وَلَا تُشَقَّى بِمَاءٍ غَالِبِ الْحُصُولِ مِنَ الْجَبَلِ، وَإِنْ أَمَكْنَ زَرْعُهَا بِإِصَابَةِ مَطَرٍ عَظِيمٍ أَوْ سَيْلٍ نَادِرٍ. (وَيَجُوزُ إِنْ كَانَ لَهَا مَاءٌ دَائِمٌ) مِنْ نَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بئرٍ. (وَكَذَا إِنْ كَفَاهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ أَوْ مَاءُ الثَّلُوجِ الْمُجْتَمِعَةِ

(٦٥٦) الشرط الأول: يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ مَعْلُومَةً جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً، كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ. الشرط الثاني: عدم تحقق الجهالة في الأجرة.

وَالْغَالِبُ حُصُولُهَا فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِحُصُولِ مَا ذُكِرَ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي أَرْضِ مِصْرَ الَّتِي تُرَوَّى مِنْ زِيَادَةِ النَّيْلِ غَالِبًا قَبْلَ رَيْثِهَا.

[٢] (وَالِامْتِنَاعُ الشَّرْعِيِّ) لِلتَّسْلِيمِ (كَالْحِسِّيِّ) الْمُنْقَدِّمِ (فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ لِقْلَعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ) بِخِلَافِ الْوَجْعَةِ (وَلَا حَائِضٍ لِحِدْمَةِ مَسْجِدٍ) لِحُرْمَةِ الْمُكْتَبِ (وَكَذَا مِنْكَوَحَةٍ لِرِضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ أَوْقَاتَهَا مُسْتَعْرِفَةٌ بِحَقِّهِ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَلِلزَّوْجِ فَسْخُهُ حِفْظًا لِحَقِّهِ، وَيُذِنُهُ يَصِحُّ جَزْمًا، وَالْكَلَامُ فِي الْحُرَّةِ أَمَّا الْأُمَةُ الْمُزَوَّجَةُ، فَلِلْمُسَيِّدِ إِيجَارُهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّ لَهُ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا.

[٣] (وَيَجُوزُ تَأْجِيلُ الْمَنْفَعَةِ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ كَالَّذِي ذِمَّتَكَ الْحَمَلُ) لِكَذَا (إِلَى مَكَّةَ أَوَّلِ شَهْرِ كَذَا) أَيْ مُسْتَهْلِهِ كَالسَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ .

[٤] (وَلَا يَجُوزُ إِجَارَةُ عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ) كِإِجَارَةِ الدَّارِ السَّنَةِ الْآتِيَةِ (فَلَوْ أَجَرَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ لِمُسْتَأْجِرِ الْأُولَى قَبْلَ انْقِضَائِهَا جَازَ فِي الْأَصَحِّ) وَهَذَا كَالْمُسْتَنْتَنَى مِمَّا قَبْلَهُ لِاتِّصَالِ الْمُدَّتَيْنِ، وَالثَّانِي لَا يَسْتَشْتَبِيهِ.

[٥] (وَيَجُوزُ كِرَاءُ الْعَقَبِ) ^(٦٥٧). أَيْ الثُّوبِ (فِي الْأَصَحِّ وَهُوَ أَنْ يُوجَرَ دَابَّةٌ رَجُلًا لِيَرْكَبَهَا بَعْضُ الطَّرِيقِ) أَيْ وَالْمُؤَجَّرُ يَرْكَبُهَا الْبَعْضُ الْآخَرُ عَلَى التَّنَاقُوبِ. (أَوْ) يُوجَرُهَا (رَجُلَيْنِ لِيَرْكَبَ هَذَا أَيَّامًا وَذَا أَيَّامًا) عَلَى التَّنَاقُوبِ (وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ (ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ) أَيْ الْمُكْتَرِي وَالْمُكْرِي ^(٦٥٨) فِي الْأُولَى، أَوْ الْمُكْتَرِيَانِ فِي الثَّانِيَةِ مَا لَهُمَا مِنَ الرُّكُوبِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ كَفَرَسَخٍ، لِهَذَا، ثُمَّ فَرَسَخٍ لِلْآخَرِ فِي الْأُولَى، وَيَوْمٌ لِهَذَا ثُمَّ يَوْمٌ لِلْآخَرِ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْمَنْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا إِجَارَةُ أَزْمَانٍ مُتَقَطَّعَةٍ، وَالْوَجْهُ الثَّلَاثُ: الْمَنْعُ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا لَمْ يَتَّصِلْ زَمَنُ الْإِجَارَةِ فِيهَا بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ، وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: الْمَنْعُ فِيهِمَا فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ، لِاشْتِمَالِهَا عَلَى إِجَارَةِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَدُفِعَ بِأَنَّ التَّأَخَّرَ الْوَاقِعَ فِي ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةِ الْقِسْمَةِ فَلَا يَصْرُ. (الشَّرْطُ الثَّلَاثُ): يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً ^(٦٥٩).

[١] كَالْمَبِيعِ فَمَا لَهُ مَنَافِعُ يَجِبُ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْهَا (ثُمَّ تَارَةً تُقَدَّرُ) الْمَنْفَعَةُ (بِزَمَانٍ كَذَا) لِلِسُكْنَى (سَنَةً وَتَارَةً) تُقَدَّرُ (بِعَمَلٍ كَذَابَةٍ) لِلرُّكُوبِ (إِلَى مَكَّةَ وَكَخِيَاطَةِ ذَا الثُّوبِ) وَالْمَعْنَى بِمَحَلِّ الْعَمَلِ، كَمَا فِي الْمَحَرَّرِ (فَلَوْ جَمَعَهُمَا) أَيْ الزَّمَانُ وَالْعَمَلُ. (فَاسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيْطَهُ بَيَاضَ النَّهَارِ، لَمْ يَصَحَّ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ قَدْ لَا يَفِي بِالْعَمَلِ، وَالثَّانِي يَقُولُ ذِكْرُ الزَّمَانِ لِلتَّعْجِيلِ.

(٦٥٧) وَيَجُوزُ كِرَاءُ الْعَقَبِ جَمْعُ عُقْبَةٍ - وَهِيَ النَّوْبَةُ عَلَى الشَّيْءِ كَالسَّيَارَةِ وَالِدَابَّةِ وَالْحَصَانِ.

(٦٥٨) الْمُكْتَرِي: هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ، وَالْمُكْرِي: هُوَ الْمُؤَجِّرُ.

(٦٥٩) وَيُشْتَرَطُ فِي إِجَارَةِ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا مَعْلُومَةً عَيْنًا وَصِفَةً وَقَدْرًا.

[٢] (وَيَقْدَرُ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ بِمُدَّةٍ) ^(٦٦٠) كَشْهَرٍ قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْعَزَالِيُّ وَإِبْرَاهُ غَيْرُهُمَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ زَادَ فِي الرُّوْضَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ وَأَقْوَى (أَوْ تَعْيِينَ سُورَةٍ) أَوْ سُورَةٍ أَوْ آيَاتٍ بِأَنْ يَسْمَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ الْعَقْدِ، كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَقِيلَ يَكْفِي ذِكْرُ عَشْرِ آيَاتٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينَ سُورَةٍ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا.

[٣] (وَفِي الْبِنَاءِ بَيْنَ الْمَوْضِعِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالسَّمَكِ) يَفْتَحُ السَّيْنُ أَيْ الْإِرْتِفَاعُ ^(٦٦١). (وَمَا يُبْنَى بِهِ) مِنْ طِينٍ وَلَبْنٍ أَوْ آجَرٍ (إِنْ قُدِّرَ بِالْعَمَلِ) فَإِنْ قُدِّرَ بِالزَّمَانِ لَمْ يَخْتَجْ إِلَى بَيَانِ مَا ذَكَرَ.

[٤] (وَإِذَا صَلَحَتِ الْأَرْضُ لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغِرَاسٍ أَشْطَرُ تَعْيِينَ الْمَنْفَعَةِ) مِنْ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهَا اللَّاحِقَ لِلْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ، (وَيَكْفِي تَعْيِينَ الزِّرَاعَةِ عَنْ ذِكْرِ مَا يُزْرَعُ) فَإِنْ قَالَ أَجْرُنُكَهَا لِلزِّرَاعَةِ فَتَصَحَّ (فِي الْأَصَحِّ) وَيَزْرَعُ مَا شَاءَ، وَالثَّانِي لَا تَصَحُّ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الزَّرْعِ مُخْتَلِفٌ، وَدُفِعَ بِأَنْ اخْتِلَافَهُ يَسِيرٌ وَلَوْ قَالَ لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغِرَاسِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَبْنَى أَوْ يَغْرِسُ صَحَّتْ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا. (وَلَوْ قَالَ لِنَتَنَفَّعَ بِهَا مَا شِئْتُ صَحَّ) وَيَصْنَعُ مَا شَاءَ. (وَكَذَا لَوْ قَالَ إِنْ شِئْتُ فَازْرَعْ وَإِنْ شِئْتُ فَاغْرِسْ) فَإِنَّهُ يَصَحُّ (فِي الْأَصَحِّ) وَيَتَخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَهُمَا، وَالثَّانِي: لَا يَصَحُّ لِلْإِبْهَامِ، وَفِي الْأُولَى وَجْهٌ أَنَّهَا لَا تَصَحُّ.

[٥] (وَيُشْتَرَطُ فِي إِجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ) إِجَارَةٌ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةً. (مَعْرِفَةُ الرَّكَّابِ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ وَصْفٍ تَامٍ) لَهُ فِي ذَلِكَ. (وَقِيلَ: لَا يَكْفِي الْوَصْفُ) فِيهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَتَعَلَّقُ بِثَقْلِ الرَّكَّابِ وَخَفَّتِهِ، بِالضَّخَامَةِ وَالنَّحَافَةِ، وَكَثْرَةِ الْحَرَكَاتِ، وَقِلَّتِهَا وَالْوَصْفُ لَا يَفِي بِذَلِكَ، وَجَوَابُهُ الْمَنْعُ (وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا يُرَكَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمَلٍ) يَفْتَحُ الْمِيمُ الْأُولَى وَكَسَرَ الثَّانِي ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَعِيْرُهُ) كَزَامِلَةٍ (إِنْ كَانَ لَهُ) وَفِي الْمَحَرَّرِ مَعَهُ أَيْ وَذَكَرَ فِي الْإِجَارَةِ. فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَعْرِفَتُهُ بِمُشَاهَدَتِهِ، أَوْ وَصْفِهِ التَّامِّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الرَّكَّابِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهِ وَيُرَكَّبُهُ الْمُؤَجَّرُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ زَامِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

[٦] (وَلَوْ شَرَطَ فِي الْإِجَارَةِ (حَمَلَ الْمَعَالِيْقِ) ^(٦٦٢) كَالسُّفْرَةِ وَالْإِدَاوَةَ لِلْمَاءِ وَالْقَدْرَ وَنَحْوَهَا. (مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍ وَلَا وَصْفٍ. (فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ) لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مَقَادِيرِهَا، وَالثَّانِي يَصَحُّ، وَيُحْمَلُ الْمَشْرُوطُ عَلَى الْوَسْطِ الْمُعْتَادِ نَقْلُهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ عَقِبَ نَصِّهِ عَلَى الْأَوَّلِ، فَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إِنَّهُ عَلَى نَفْسِهِ وَجَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَأَنَّهُ

(٦٦٠) أي أن تعليم القرآن الكريم قد يكون بمدة زمنية كشهر أو سنة أو بتعليم سورة أو سورتين أو أكثر.
(٦٦١) سَمَكَ الشَّيْءُ ارْتَفَعَ وَبَابُهُ دَخَلَ. وَسَمَكَ الْبَيْتُ بِالْفَتْحِ سَقُفُهُ. وَسَمَكَ اللَّهُ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَبَابُهُ نَصَرَ. مختار الصحاح ص ١٥٤.

(٦٦٢) المعاليق جمع مغلول: وهو ما يعلّق عليه الشّيء، أو هو ما يعلّق على النّبيّر كسفرة وقدر وقصعة.
لسان العرب ج ١٠/٢٦٥.

عَنِ غَيْرِهِ أَيْ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ. (وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْهُ) أَيْ حَمْلُ الْمَعَالِيْقِ. (لَمْ يَسْتَحَقَّ) لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهِ، وَقِيلَ يَسْتَحَقُّ الْمُعْتَادَ.

[٧] (وَيُشْتَرَطُ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ) لِلرُّكُوبِ لِيَتَحَقَّقَ. (تَغْيِينُ الدَّابَّةِ وَفِي اشْتِرَاطِ رُؤْيَيْهَا الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْعَائِبِ) وَالرَّاجِحُ عَدَمُ صِحَّتِهِ فَيَكُونُ الرَّاجِحُ اشْتِرَاطُ الرُّؤْيَةِ.

[٨] (و) يُشْتَرَطُ (فِي إِجَارَةِ الدِّمَةِ) لِلرُّكُوبِ (ذَكَرُ الْجِنْسِ) لِلدَّابَّةِ كَالْإِبِلِ وَالْخَيْلِ. (وَالنُّوعِ) لَهُمَا كَالْبَحَاثِيِّ أَوْ الْعِرَابِ. (وَالذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنْثَى) فَالْأُنْثَى أَسْهَلُ سَيْرًا وَالذَّكَرُ أَقْوَى. (وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا) أَيْ فِي إِجَارَتِي الْعَيْنِ وَالْذِّمَّةِ (بَيَانُ قَدْرِ السَّيْرِ كُلِّ يَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالطَّرِيقِ مَنَازِلُ مَضْبُوطَةً فَيَنْزِلُ) قَدْرَ السَّيْرِ (عَلَيْهَا) إِنْ لَمْ يُبَيَّنْ.

[٩] (وَيَجِبُ فِي الْإِيجَارِ لِلْحَمْلِ) ^(٦٦٣) إِجَارَةُ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ. (أَنْ يَعْرِفَ الْمَحْمُولُ، فَإِنْ حَضَرَ رَأَهُ وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إِنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ) تَحْمِينًا لَوْزْنِهِ، (وَإِنْ غَابَ قُدِّرَ بِكَيْلٍ) فِي الْمَكِيلِ. (أَوْ وَزْنٍ) فِي الْمَوْزُونِ، وَالنَّقْدِيرُ بِالْوَزْنِ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَوَّلَى وَأَخْصَرُ.

[١٠] (و) أَنْ يَعْرِفَ (جِنْسَهُ) أَيْ الْمَحْمُولُ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهِ فِي الدَّابَّةِ، كَمَا فِي الْحَدِيدِ وَالْقُطْنِ فَإِنَّهُ يَتَنَاقَلُ بِالرَّيْحِ نَعَمَ لَوْ قَالَ: أَجْرْتُكَهَا لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رِطْلٍ، مِمَّا شِئْتَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَيَكُونُ رِضًا مِنْهُ بِأَصْرٍ الْأَجْنَسِ، وَلَوْ قَالَ عَشْرَةَ أَقْفَازٍ مِمَّا شِئْتَ فَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ السَّرْحَسِيِّ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ الْأَجْنَسِ فِي الثَّقَلِ مَعَ الْإِسْتَوَاءِ فِي الْكَيْلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ رِضًا بِثَقَلِ الْأَجْنَسِ كَمَا جُعِلَ فِي الْوَزْنِ رِضًا بِأَصْرٍ الْأَجْنَسِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الصَّوَابُ قَوْلُ السَّرْحَسِيِّ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ اخْتِلَافَ التَّأْثِيرِ بَعْدَ الْإِسْتَوَاءِ فِي الْوَزْنِ يَسِيرُ بِخِلَافِ الْكَيْلِ، وَأَيُّ ثَقَلِ الْمِلْحِ مِنْ ثَقَلِ الذَّرَّةِ. (لَا جِنْسَ الدَّابَّةِ وَصِفَتِهَا) أَيْ لَا يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَهَا. (إِنْ كَانَتْ إِجَارَةُ ذِمَّةٍ) بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِيهَا فِي الرُّكُوبِ؛ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ هُنَا. تَحْصِيلُ الْمَتَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَشْرُوطِ، فَلَا يَخْتَلِفُ الْعَرَضُ بِحَالِ حَامِلِهِ. (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ رُجَاجًا وَنَحْوَهُ) كَالْخَرْفِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حَالِ الدَّابَّةِ فِي ذَلِكَ. صَيَانَةٌ لَهُ أَمَّا إِجَارَةُ الْعَيْنِ لِلْحَمْلِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا تَغْيِينُ الدَّابَّةِ. وَرُؤْيَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ لِلرُّكُوبِ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ فِي الْمَنْفَعَةِ: وَهُوَ حُصُولُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ ^(٦٦٤): . [١] فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ لَوْجُوبِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّغَرِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ، فَتَصِحُّ إِجَارَتُهُ لِلْإِمَامِ، وَسَيَأْتِيَانِ فِي كِتَابِ السَّيْرِ. (وَلَا عِبَادَةٌ) أَيْ لَا يَصِحُّ إِجَارَةُ لِعِبَادَةِ (تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ) كَالصَّلَاةِ ^(٦٦٥)؛

(٦٦٣) أَنْ يَعْرِفَ مُوجِرَ الدَّابَّةِ أَوْ السَّيْرَةِ مِقْدَارَ الشَّيْءِ الْمَحْمُولِ.

(٦٦٤) الْأَصْلُ أَنَّ مَنَفْعَةَ الْإِجَارَةِ لَا بَدَّ مِنْ أَنْ تَعُودَ بِالنَّفْعِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَقَدْ تَكُونُ الْمَنَفْعَةُ الْمُتَحَصِّلَةُ مِنَ الْعَمَلِ مُتَعَدِيَةً فَتَشْمَلُ الْمُوجِرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ كَالْقِيَامِ بِعَمَلٍ مِثْلِ الْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ.

(٦٦٥) أَمَّا الْإِسْتِئْجَارُ لِلْقُرْبِ وَهِيَ أَدَاءُ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا الْإِنْسَانُ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَالْقُرْبُ عَلَى قِسْمَيْنِ: فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ مَا يَخْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، فَلَا يَصِحُّ الْإِسْتِئْجَارُ عَلَى فِعْلِهِ حَالِ حَيَاةٍ

لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا امْتِحَانُ الْمُكَلَّفِ، بِكَسْرِ نَفْسِهِ، بِالْفِعْلِ وَلَا يَقُومُ الْأَجِيرُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ. (إِلَّا الْحَجَّ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالْعَاجِزِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ. (وَتَقْرِقَةَ زَكَاةٍ) فَإِنَّهَا تَجُوزُ فِيهَا الْإِسْتِثْنَاءُ لِحُصُولِ الْمُقْصُودِ بِهَا، وَأَيْضًا مِثْلُهَا تَقْرِقَةُ الْكُفَّارَةِ.

[٢] (وَتَصِحُّ) الْإِجَارَةُ (لِتَجْهِيْزِ مَيِّتٍ وَدَفْنِهِ. وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ) ^(٦٦٦) وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهَا فَرَضٌ كِفَايَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّعَيْنْ عَلَى الْأَجِيرِ، وَهُوَ عِبَادَةٌ لَا تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ وَذَكَرَ التَّعْلِيمَ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عِبَادَةٌ مَعَ ذِكْرِهِ السَّابِقِ مِنْ حَيْثُ التَّقْدِيرِ لَا تَكَرَّرَ فِيهِ، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ ذِكْرُهُ السَّابِقُ صِحَّةَ الْإِسْتِثْنَاءِ لَهُ.

[٣] (و) تَصِحُّ الْإِجَارَةُ (لِحَصَانَةِ وَإِرْضَاعٍ مَعًا، وَلِأَحَدِهِمَا فَقَطْ) وَتُقَدَّرُ بِالْمُدَّةِ وَيَجِبُ تَعْيِينُ الرِّضْعِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ، وَتَعْيِينُ مَوْضِعِ الْإِرْضَاعِ مِنْ بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ، أَوْ بَيْتِ الْمُرْضِعَةِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ فِي ذَلِكَ، فَهُوَ فِي بَيْتِهَا أَسْهَلُ عَلَيْهَا، وَبَيْتُهُ أَشَدُّ وَثُوقًا بِهِ. (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَنْبِعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) فِي الْإِجَارَةِ لِإِفْرَادِ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ وَالثَّانِي يَسْتَنْبِعُ لِتَلَازُمِهِمَا عَادَةً، وَالثَّلَاثُ يَسْتَنْبِعُ الْإِرْضَاعُ الْحَصَانَةَ دُونَ عَكْسِهِ، وَفِي الْمَطْلَبِ حِكَايَةُ عَكْسِهِ. (وَالْحَصَانَةُ حِفْظُ صَبِيٍّ) أَيْ جِنْسِهِ الصَّادِقِ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. (وَتَعَهُدُهُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَدَهْنِهِ، وَكُحْلِهِ وَرَبْطِهِ فِي الْمَهْدِ، وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ وَنَحْوَهَا) مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَالْإِرْضَاعُ أَنْ تُلْقِمَهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي حَجْرِهَا مَثَلًا النَّدْيِ وَتَعَصْرَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيَنْبَغُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةُ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ، بِالْإِجَارَةِ اللَّبْنِ الْمُرْضَعُ بِهِ، وَقِيلَ الْأَصْلُ اللَّبْنُ، وَفِعْلُ الْمُرْضِعَةِ تَابَعٌ.

[٤] (وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لَهُمَا) أَيْ لِلْحَصَانَةِ وَالْإِرْضَاعِ ^(٦٦٧) (فَانْقَطَعَ اللَّبْنُ فَالْمَذْهَبُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِي الْإِرْضَاعِ دُونَ الْحَصَانَةِ)؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ، وَقِيلَ: يَنْفَسَخُ الْعَقْدُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَصَانَةَ تَابِعَةٌ

المؤجر، لأنها تكليف عيني واجب عليه. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: هُوَ مَا كَانَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فَهُوَ ضَرْبَانِ. (أَحَدُهُمَا): يَخْتَصُّ افْتِرَاضُهُ فِي الْأَصْلِ بِشَخْصٍ وَمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ غَيْرُهُ إِنْ عَجَرَ، كَتَجْهِيْزِ الْمَوْتَى بِالْكَفْنِ وَالْغَسْلِ وَالْحَفْرِ وَحَمْلِ الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ (الصَّرْبُ الثَّانِي): مَا يَتَّبَعُ فَرَضُهُ فِي الْأَصْلِ شَيْئًا غَيْرَ مُخْتَصٍّ، كَالْجِهَادِ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الصَّفَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ.

(٦٦٦) ودليل تعليم القرآن الكريم: ما روي عن ابن عباس ر قال: { أَنْ تَقْرَأَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ر مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيْمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيْمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِقَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، قَبْرًا، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكْرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ { صحيح البخاري ج ٧ / ١٣١ / ٥٧٣٧ / كتاب الطب / بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقْبَةِ بِقَطْعِ مِنَ الْعَنْمِ.

(٦٦٧) ودليله: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { ...وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلُكُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ^(١) } سورة الطلاق.. الآية.

. وَقِيلَ لَا يَنْقَسُخُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَ اللَّبَنِ عَيْبٌ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْقُطُ قِسْطُ الْإِرْضَاعِ مِنَ الْأُجْرَةِ، وَبَقَاءُ الْحَصَانَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ خِلَافِ تَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ.

[٥] (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حَبْرٌ وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ عَلَى وَرَاقٍ) ^(٦٦٨) أَي نَاسِخٍ (وَخِيَّاطٍ وَكَحَالٍ) فِي اسْتِئْجَارِهِمْ لِلنَّسْخِ وَالْخِيَّاطَةِ وَالْكُحْلِ، وَالثَّانِي يَجِبُ مَا ذَكَرَ لِحَاجَةِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ كَاللَّبَنِ فِي الْإِرْضَاعِ وَدَفْعِ بَأْنِ دُخُولِ اللَّبَنِ لِلضَّرُورَةِ، وَالثَّلَاثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: صَحَّ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الرَّجُوعَ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ) قَالَ (فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجِبَ الْبَيَانُ وَالْإِلَّا) أَي وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ (فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَعَبَّرَ فِي هَذَا بِالْأَشْبَهَةِ وَفِي الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّرِ، بِالْمَشْهُورِ وَحَكَى فِي الشَّرْحِ الْخِلَافَ طَرَفًا.

فَصْلٌ فِي: التَّزَامَاتِ الْمُؤْجَرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ

[أولاً] مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْجَرِ أَوْ مُكْرِي الدَّارِ أَوْ الدَّابَّةِ

يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِي (تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ) الدَّارِ إِلَى الْمُكْتَرِي. (لِيَتِمَّكَنَ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا) (وَعِمَارَتُهَا عَلَى الْمُؤْجَرِ) كِبْنَاءٍ وَتَطْيِينَ سَطْحٍ وَوَضْعِ بَابٍ، وَمِيرَابٍ وَإِصْلَاحِ مُنْكَسِرٍ، وَغَلْقٍ يَغْسُرُ فَتْحُهُ: (فَإِنْ بَادَرَ وَأَصْلَحَهَا) فَلَا خِيَارَ (وَالْإِلَّا فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ) لِتَضَرُّرِهِ بِنَقْصِ الْمَنْفَعَةِ. (وَكَسْحِ الثَّلْجِ عَنْ السَّطْحِ عَلَى الْمُؤْجَرِ)؛ لِأَنَّهُ كَعِمَارَةِ الدَّارِ (وَتَنْظِيفِ عَرَصَةِ الدَّارِ عَنْ ثَلْجٍ وَكُنَاسَةِ عَلَى الْمُكْتَرِي) أَمَّا الْكُنَاسَةُ فَلِحُصُولِهَا بِفِعْلِهِ إِذْ فَسَرُوهَا بِمَا يَنْقُطُ مِنَ الْقُشُورِ وَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ، وَأَمَّا الثَّلْجُ فَقَالَ فِي الرُّوضَةِ لَيْسَ الْمُرَادُ، أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ تَقْلُهُ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُؤْجَرَ، وَكَذَا التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ بِهَيُوبِ الرِّيَّاحِ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا اهـ.

(وَإِنْ أَجَرَ دَابَّةً لِرُكُوبٍ فَعَلَى الْمُؤْجَرِ إِكَافٌ وَبَرْدَعَةٌ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْإِكَافُ بِكَسْرِ الهمزة تَحْتَ الْبَرْدَعَةِ وَقَبْلَ فَوْقِهَا. (وَحِرَامٌ وَثَقْرٌ) بِالْمُثَلَّثَةِ (وَبُرَّةٌ) بِضَمِّ الْبَاءِ، وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ حَلْقَةً تُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ. (وَخِطَامٌ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَي زِمَامٌ يُجْعَلُ فِي الْحَلْقَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتِمَّكَنُ مِنَ الرُّكُوبِ بِدُونِهَا ^(٦٦٩).

(٦٦٨) أَي أَنَّهُ لَا يَجِبُ حَبْرٌ لِلْكَتَابَةِ - وَهُوَ اسْمٌ لِلْمِدَادِ - عَلَى وَرَاقٍ أَي: نَاسِخٍ. وَلَا يَجِبُ الْخَيْطُ الْمَخْصَصُ لِلْخِيَّاطَةِ عَلَى الْخِيَّاطِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ. وَأَيْضًا لَا يَجِبُ كُحْلٌ عَلَى كَحَالٍ فِي اسْتِئْجَارِهِ.

(٦٦٩) فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْجَرِ إِكَافٌ وَهُوَ الْحُلْسُ الَّذِي يُلْقَى تَحْتَ الرَّحْلِ، وَبَرْدَعَةٌ: وَهِيَ مَا يُوَضَعُ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ لِلْقُعُودِ عَلَيْهِ. وَحِرَامٌ: وَهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْإِكَافُ، وَثَقْرٌ: وَهُوَ مَا يُجْعَلُ تَحْتَ ذَنْبِ الدَّابَّةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَجَاوَرَتِهِ ثَقَرَ الدَّابَّةِ بِسُكُونِ الْفَاءِ وَهُوَ حَيَاؤُهَا، وَبُرَّةٌ: وَهِيَ حَلْقَةٌ تُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ، وَخِطَامٌ: خَيْطٌ يُشَدُّ فِي الثَّرَةِ ثُمَّ يُشَدُّ فِي طَرَفِ الْمُقْوَدِ - بِكَسْرِ الْمِيمِ -؛ لِأَنَّ التَّمَكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ، وَالْعُرْفُ مُطَرَّدٌ بِهِ.

(وَعَلَى الْمُكْتَرِي -المستأجر- مَحَلٌّ وَمِظْلَةٌ) بِكُسْرِ الْمِيمِ أَيُّ مَا يُظَلُّ بِهِ عَلَى الْمَحْمِلِ (وَوِطَاءٌ وَغِطَاءٌ) بِكُسْرِ أَوَّلِهِمَا وَالْوِطَاءُ مَا يُفَرَّشُ فِي الْمَحْمِلِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهِ. (وَتَوَابِعُهَا) كَالْحَبْلِ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْمَحْمِلُ عَلَى الْجَمَلِ، أَوْ أَحَدُ الْمَحْمِلَيْنِ إِلَى الْآخَرِ. (وَالْأَصْحُ فِي السَّرَجِ) لِلْفَرَسِ. (اتِّبَاعُ الْعُرْفِ) أَيُّ فِي مَوْضِعِ الْإِجَارَةِ، وَالثَّانِي عَلَى الْمُؤَجَّرِ كَالْإِكَاْفِ، وَالثَّلَاثُ لَيْسَ لِاضْطِرَابِ الْعُرْفِ فِيهِ. (وَوَظَرُ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجَّرِ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ التَّرَمُّ النَّقْلُ فَعَلَيْهِ تَهْيِئَةُ أَسْبَابِهِ.

[ثَانِيًا] مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ

(وَعَلَى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ) إِذْ لَيْسَ عَلَى الْمُؤَجَّرِ فِيهَا إِلَّا تَسْلِيمُ الدَّابَّةِ، كَمَا يَأْتِي. (وَعَلَى الْمُؤَجَّرِ فِي إِجَارَةِ لِدْمَةِ الْخُرُوجِ مَعَ الدَّابَّةِ لِنَعْهْدِهَا وَإِعَانَةِ الرَّكَّابِ فِي رُكُوبِهِ وَنُزُولِهِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ) فَيُنِيخُ الْبَعِيرَ لِلْمَرْأَةِ وَالضَّعِيفَ بِمَرَضٍ أَوْ شَيْخُوخَةٍ وَيَقْرُبُ الْبُغْلَ وَالْحِمَارَ مِنْ نَشْرِ لَيْسَهْلٍ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ.

(وَرَفْعُ الْحَمْلِ وَحِطُّهُ وَشَدُّ الْمَحْمِلِ وَحَلِّهِ) وَشَدُّ أَحَدِ الْمَحْمِلَيْنِ إِلَى الْآخَرِ، وَهُمَا بَعْدُ عَلَى الْأَرْضِ فِي وَجْهِ صَحَّحَهُ فِي الرُّوضَةِ، وَالثَّانِي هُوَ عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لِأَنَّهُ إِصْلَاحُ مَلِكِهِ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ) أَيُّ الْمُؤَجَّرِ (فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ إِلَّا التَّحْلِيَةَ بَيْنَ الْمُكْتَرِي وَالدَّابَّةِ) فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَانَتُهُ فِي رُكُوبٍ وَلَا حَمْلٍ.

انفساخ الإجارة

(وَتَنْفَسُخُ إِجَارَةُ الْعَيْنِ بِتَلَفِ الدَّابَّةِ) لِقَوَاتِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ (وَيَتَبَثُّ الْخِيَارُ بِعَيْبِهَا) كَأَن تَعَثَّرَ فِي الْمَشْيِ أَوْ تَعْرُجَ فَتَتَخَلَّفَ عَنِ الْقَافِلَةِ. (وَلَا خِيَارَ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ) بِعَيْبِ الدَّابَّةِ الْمُحْضَرَةِ. (بَلْ يُلْزَمُهُ الْإِبْدَالُ) وَلَا تَنْفَسُخُ بِتَلَفِهَا (وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولُ لِيُؤْكَلَ يُبَدَّلُ إِذَا أَكَلَ فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي لَا يُبَدَّلُ وَيَشْتَرِي الْمُكْتَرِي فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ قَدْرَ الْحَاجَةِ، وَلَوْ أَكَلَ بَعْضُهُ أَبَدًا فِي الرَّاحِجِ، وَالْخِلَافُ فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْكَلِّ وَجْهَانِ، وَفِي الْبَعْضِ قَوْلَانِ وَيُقَالُ وَجْهَانِ وَمَحْلُهُ، إِذَا كَانَ يَجِدُ الطَّعَامَ فِي الْمَنَازِلِ الْمُسْتَقْبَلَةِ بِسَعْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدْهُ أَوْ وَجَدَهُ بِأَعْلَى، فَلَهُ الْإِبْدَالُ قَطْعًا.

فَصْلٌ: مُدَّةُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ

[١] يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا فَيُؤَجَّرُ الْعَبْدُ وَالْدَّارُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَالدَّابَّةُ عَشْرَ سِنِينَ وَالثَّوْبُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ، وَالْأَرْضُ مِائَةً سَنَةً وَأَكْثَرَ.

[٢] (وَفِي قَوْلٍ لَا يُزَادُ عَلَى سَنَةٍ) لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِجَارَةِ بِهَا.

[٣] (وَفِي قَوْلٍ) عَلَى (ثَلَاثِينَ) سَنَةٍ؛ لِأَنَّهَا نِصْفُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ.

أحكام متنوعة في الإجارة كالاستيفاء والضمان والإثبات أولاً: الاستيفاء

[١] (وَلِلْمُكَتْرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، فَيَرْكَبُ وَيُسْكِنُ مِثْلَهُ، وَلَا يُسْكِنُ حَدَّادًا وَقِصَّارًا) لَزِيَادَةِ الضَّرَرِ بِذَقِّهِمَا.

[٢] (وَمَا يَسْتَوْفِي مِنْهُ كُدَّارٌ وَدَابَّةٌ مُعَيَّنَةٌ لَا يُبَدَّلُ) أَيُّ لَا يَجُوزُ إِبْدَالُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ.
[٣] (وَمَا يَسْتَوْفِي بِهِ كَثُوبٌ وَصِيٍّ عَيْنٍ) أَيُّ الْمَذْكُورُ (لِلْخِيَاطَةِ وَالْإِرْضَاعِ يَجُوزُ إِبْدَالُهُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِيفَاءِ كَالرَّاكِبِ لَا مَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ كَالْمُسْتَوْفَى مِنْهُ.

ثانياً: ثبوت الضمان

[١] (وَيُذِّمُ الْمُكَتْرِي عَلَى الدَّابَّةِ وَالتَّوْبِ) مِثْلًا (يَذُّ أَمَانَةً مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَكَذَا بَعْدَهَا فِي الْأَصَحِّ) تَبَعًا لَهَا فَيَكُونُ كَالْمُودِعِ وَالثَّانِي يَذُّ ضَمَانَ كَالْمُسْتَعِيرِ فَيَضْمَنُ مَا يَتَلَفُ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ وَفِي ضَمَانٍ مَا يَتَلَفُ مِنَ الْمَنَافِعِ وَجِهَانِ أَصْحَهُمَا الْمَنْعُ، أَخَذًا مِنَ الْأَصَحِّ السَّابِقِ.

[٢] (وَلَوْ رَبَطَ دَابَّةً أَوْ اكْتَرَاهَا لِحِمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا) فَتَلَفْتُ (لَمْ يَضْمَنْ إِلَّا إِذَا انْهَدَمَ عَلَيْهَا إِصْطَبْلٌ فِي وَقْتٍ) لِلِانْتِفَاعِ (لَوْ انْتَفَعَ) بِهَا فِيهِ (لَمْ يُصِبْهَا الْهَدْمُ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ جَاءَ مِنْ رَبْطِهَا وَقْتٍ لِانْتِفَاعِ بِهَا، كَبَعْضِ النَّهَارِ دُونَ جُنْحِ اللَّيْلِ فِي الشِّتَاءِ.

[٣] (وَلَوْ تَلَفَ الْمَالُ فِي يَدِ أَحَبَرٍ بِلَا تَعَدٍّ، كَثُوبٌ أَسْتَوْجَرَ لِحِيَاظَتِهِ أَوْ صَنْعِهِ لَمْ يَضْمَنْ إِنْ لَمْ يَتَقَرَّرْ بِالْيَدِ، بَأَنَّ قَعْدَ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَهُ) حَيَّ يَعْمَلُ (أَوْ أَحْضَرَهُ مَنْزِلَهُ) لِيَعْمَلَ؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا اسْتَعَانَ الْمَالِكُ بِهِ فِي شُغْلِهِ كَمَا يَسْتَعِينُ بِالْوَكِيلِ. (وَكَذَا إِنْ انْقَرَدَ) بِالْيَدِ لَا يَضْمَنُ. (فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ) وَالثَّانِي: يَضْمَنُ كَالْمُسْتَأْمَرِ^(٦٧٠)؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ لِمَنْفَعَةٍ نَفْسِهِ. وَدُفِعَ بِأَنَّهُ أَخَذَ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْتَأْجِرِ أَيْضًا، فَلَا يَضْمَنُ كَعَامِلِ الْفَرَّاسِ. (وَالثَّالِثُ يَضْمَنُ) الْأَجِيرُ (الْمُشْتَرِكُ وَهُوَ مَنْ التَّرَمَّ عَمَلًا فِي ذِمَّتِهِ لَا الْمُنْفَرِدُ وَهُوَ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لِعَمَلٍ)؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مُخْتَصَّةً، بِالْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمُدَّةِ فَيُذِّمُ كَيْدَ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُوَكَّلِ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرِكِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِلَا تَعَدٍّ عَمَّا إِذَا تَعَدَّى، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا قَطْعًا.

[٤] (وَلَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى قِصَّارٍ لِيَقْصِرَهُ^(٦٧١))، أَوْ خِيَّاطٍ لِيَخِيْطَهُ فَفَعَلَ) أَيُّ قَصَرَهُ أَوْ خَاطَهُ (وَلَمْ يَذْكُرْ أَجْرَهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ) لِعَدَمِ التَّزَامِهَا (وَقِيلَ لَهُ) الْأَجْرَةُ لِاسْتِهْلَاكِ الدَّافِعِ عَمَلَهُ. (وَقِيلَ إِنْ كَانَ

(٦٧٠) الْمُسْتَأْمَرُ : هو الشخص المساوم على السلعة.

(٦٧١) الْقِصَّارُ: هو الذي يضرب الثوب بعصية غليظة إذا غسله في النهر. أو هو الذي يُدَقُّ بها الثياب. العين

مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ (فَلَهُ) الْأُجْرَةُ (وَالَا فَلَا) أُجْرَةٌ لَهُ (وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ) هَذَا الْعَمَلُ فِيهِ بِالْعَادَةِ، وَالْمُرَادُ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ كَمَا أَفْصَحَ بِهَا فِي الرُّوضَةِ فِي الثَّانِي.

[٥] (وَلَوْ تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنْ ضَرَبَ الدَّابَّةَ أَوْ كَبَحَهَا) بِالْمُوحَّدَةِ وَالْمُهْمَلَةِ أَيْ نَحَعًا بِاللِّجَامِ (فَوْقَ الْعَادَةِ) هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْإِثْنَيْنِ. (أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسَكَنَ حَدَادًا أَوْ قَصَارًا) دَقَّ. (ضَمِنَ الْعَيْنَ) أَيْ صَارَ ضَامِنًا لَهَا.

أَمَّا الضَّرْبُ الْمُعْتَادُ وَنَحْوُهُ إِذَا قَضَى إِلَى تَلْفٍ فَلَا يُوجِبُ ضَمَانًا.

[٦] (وَكَذَا لَوْ اكْتَرَى) دَابَّةً (لِحَمَلِ مِائَةِ رِطْلٍ مِنْ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ مِائَةَ شَعِيرًا أَوْ عَكْسَ) أَيْ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ فَمَا أَحَدُهُ مِنْ ظَهْرِهَا أَكْثَرُ، وَالْحِنْطَةُ أَثْقَلُ فَيَجْتَمِعُ ثَقْلُهَا فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ. (أَوْ لِعَشْرَةِ أَقْفَازِ شَعِيرٍ فَحَمَلَ) عَشْرَةَ (حِنْطَةً) أَيْ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلدَّابَّةِ لِزِيَادَةِ ثَقْلِ الْحِنْطَةِ. (دُونَ عَكْسِهِ) لِحَقِّقَةِ الشَّعِيرِ مَعَ اسْتَوَائِهِمَا فِي الْجَحِيمِ.

[٧] (وَلَوْ اكْتَرَى) دَابَّةً (لِمِائَةِ فَحَمَلَ مِائَةَ وَعَشْرَةَ، لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ، وَإِنْ تَلَفَتْ بِذَلِكَ ضَمْنَهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا)؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا بِحَمْلِ الزِّيَادَةِ. (فَإِنْ كَانَ) صَاحِبُهَا مَعَهَا. (ضَمِنَ قِسْطَ الزِّيَادَةِ وَفِي قَوْلٍ نِصْفَ الْقِيَمَةِ)؛ لِأَنَّ التَّلْفَ بِمَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ، فَتَوَزَّعَ الْقِيَمَةُ بِالْقِسْطِ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ، الْأَوَّلُ أَقْرَبُ فِي الْمَحَرَّرِ، وَالشَّرْحُ وَأَظْهَرُ فِي الرُّوضَةِ.

[٨] (وَلَوْ سَلَّمَ الْمِائَةَ وَالْعَشْرَةَ إِلَى الْمُؤَجَّرِ، فَحَمَلَهَا جَاهِلًا) بِالزِّيَادَةِ بِأَنْ قَالَ لَهُ هِيَ مِائَةٌ كَاذِبًا فَتَلَفَتْ الدَّابَّةُ بِهَا. (ضَمِنَ الْمُكْتَرَى عَلَى الْمَذْهَبِ) كَمَا لَوْ حَمَلَهَا بِنَفْسِهِ، وَفِيمَا يَضْمَنُهُ الْقَوْلَانِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي ضَمَانِهِ قَوْلًا لِعَارِضِ الْغُرُورِ، وَالْمُبَاشَرَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَسَوَاءٌ ثَبَتَ الْخِلَافُ أَمْ لَا فَالظَّاهِرُ وَجُوبُ الضَّمَانِ وَإِنْ حَمَلَهَا عَالِمًا بِالزِّيَادَةِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا فَحُكْمُهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ

[٩] (وَلَوْ وَزَنَ الْمُؤَجَّرُ وَحَمَلَ) بِالشَّدِيدِ (فَلَا أُجْرَةَ لِلزِّيَادَةِ) لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي ثَقْلِهَا. (وَلَا ضَمَانَ إِنْ تَلَفَتْ) بِذَلِكَ الدَّابَّةُ سِوَاءِ غَلَطِ الْمُؤَجَّرِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ جَهَلَ الْمُسْتَأْجِرُ الزِّيَادَةَ أَمْ عَلِمَهَا وَسَكَتَ.

[١٠] (وَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ) بَعْدَ قِطْعِهِ. (فَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ: أَمَرْتَنِي بِقِطْعِهِ قَبَاءً فَقَالَ) الْمَالِكُ (بَلْ قَمِيصًا فَأَلْظَهَرُ تَصَدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ)؛ لِأَنَّهُ الْمُصَدِّقُ فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَكَذَا فِي صِفَتِهِ فَيُخْلِفُ أَنَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ فِي قِطْعِهِ قَبَاءً. (وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) إِذَا حَلَفَ (وَعَلَى الْخِيَّاطِ أَرَشَ النَّقْصِ) لِلثَّوْبِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيَمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا، أَوْ مَا بَيْنَ قِيَمَتِهِ مَقْطُوعًا قَمِيصًا وَمَقْطُوعًا قَبَاءً، وَجِهَانِ وَعَلَيْهِ الثَّانِي إِنْ لَمْ يَنْقُصِ الْقَبَاءَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمُ الْأَوَّلَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي تَصَدِيقُ الْخِيَّاطِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْغُرْمَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، فَيُخْلِفُ أَنَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ فِي قِطْعِهِ قَمِيصًا وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي قِطْعِهِ قَبَاءً قَالَهُ فِي الشَّامِلِ، وَفِي الرُّوضَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ الْإِقْتِصَارُ عَلَى الشَّقِّ الثَّانِي فَإِذَا حَلَفَ فَلَا أَرَشَ عَلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، بِيَمِينِهِ وَقِيلَ لَهُ الْمُسَمَّى وَقِيلَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ انْتِقَاءُ الْأُجْرَةِ لَهُ، أَنْ يَدَّعِي بِهَا عَلَى الْمَالِكِ، وَيُحْلِفُهُ فَإِنْ نَكَلَ فَعَلَى

تَجْدِيدِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ، وَجَهَانِ قَالَ فِي الرُّوضَةِ: يَنْبَغِي، أَنْ يَكُونَ أَصَحُّهُمَا التَّجْدِيدُ، وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ
مُسْتَأْنَفَةٌ، وَقَالَ فِيمَا قَدَّمَهُ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إِنَّهُ أَصَحُّ إِنْ لَمْ تَثْبُتِ الْأُجْرَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ كَافٍ
فِي نَفْيِ الْغُرْمِ، وَإِنْ أَثْبَتْنَاهَا فَقَوْلُ صَاحِبِ الشَّامِلِ هُوَ الصَّوَابُ.

فصل: فيما لا يؤدي إلى فسخ الإجارة

[١] لَا تَنْفَسُخُ الْإِجَارَةُ وَلَا تُفْسَخُ (بِعُذْرٍ) فِي غَيْرِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُؤْجِرِ الْأَوَّلِ (كَتَعَذُّرٍ وَقُدَّ حَمَامٍ) عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ (وَسَفَرٍ) عَرَضَ لِمُسْتَأْجِرٍ دَارٍ مَثَلًا .
 [٢] وَأَيْضًا (وَمَرَضٍ مُسْتَأْجِرٍ دَابَّةٍ لِسَفَرٍ) عَلَيْهَا وَالثَّانِي كَمَرَضٍ مُؤْجِرٍ دَابَّةٍ عَجَزَ بِهِ عَنِ الْخُرُوجِ مَعَهَا، وَتَأْهُلُ مَنْ أَكْرَى دَارِهِ أَوْ حُضُورِ أَهْلِهِ الْمُسَافِرِينَ .
 [٣] (وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِرِزَاعَةٍ فَزَرَعَ فَهَلَكَ الزَّرْعُ بِجَائِحَةٍ) مِنْ شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ كَثْرَةِ مَطَرٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ نَحْوِهَا . (فَلَيْسَ لَهُ الْفُسْخُ، وَلَا حَطُّ شَيْءٍ مِنَ الْأَجْرَةِ؛ لِأَنَّ الْجَائِحَةَ لَمْ تُؤَيِّرْ فِي مَنَفَعَةِ الْأَرْضِ .

[٤] (وَتَنْفَسُخُ) الْإِجَارَةُ (بِمَوْتِ الدَّابَّةِ وَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِينَ فِي) الزَّمَانِ (الْمُسْتَقْبَلِ) لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْمَنَفَعَةِ فِيهِ (لَا الْمَاضِي) إِذَا كَانَ لِمِثْلِهِ أَجْرَةٌ (فِي الْأَظْهَرِ) لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ (فَيَسْتَقَرُّ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى) أَيِّ بِاعْتِبَارِ أَجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِذَا كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ سَنَةً، وَمَضَى نِصْفُهَا، وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مَثَلًا أَجْرَةُ النِّصْفِ الْبَاقِي وَجَبَ مِنَ الْمُسَمَّى ثُلُثَاهُ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي تَنْفَسُخُ فِي الْمَاضِي مُسَاوَاةً بَيْنَ الزَّمَانَيْنِ، وَيَسْقُطُ الْمُسَمَّى، وَتَجِبُ أَجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِمِثْلِهِ أَجْرَةٌ تَنْفَسُخُ فِيهِ قَطْعًا، وَاحْتِرَزَ بِالْمُعَيَّنِينَ عَمَّا فِي الدِّمَّةِ، فَإِنَّهُمَا إِذَا أَحْضَرَا وَمَاتَا فِي خِلَالِ الْمُدَّةِ وَجَبَ إِبْدَالُهُمَا .

[٥] (وَلَا تَنْفَسُخُ) الْإِجَارَةُ (بِمَوْتِ الْعَاقِدِينَ) أَوْ أَحَدِهِمَا بَلْ تَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَيُخْلَفُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنَفَعَةِ .

[٦] (و) لَا تَنْفَسُخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ (مُتَوَلِّيِ الْوَقْفِ) الَّذِي أَجَرَهُ إِلَّا فِي صُورَةٍ ذَكَرَهَا فِي قَوْلِهِ . (وَلَوْ أَجَرَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ) أَيِّ مِنَ الْمُؤَقُوفِ عَلَيْهِمُ الْوَقْفُ (مُدَّةً وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا) وَكُلُّ بَطْنٍ لَهُ النَّظَرُ مُدَّةً اسْتِحْقَاقَهُ .

(أَوْ الْوَلِيِّ صَبِيًّا مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ قَبْلَغَ) فِيهَا (بِالِاخْتِلَامِ فَالْأَصَحُّ) انْفِسَاخُهَا فِي الْوَقْفِ لَا الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ انْتَقَلَ اسْتِحْقَاقُهُ بِمَوْتِ الْمُؤْجِرِ لِغَيْرِهِ، وَالصَّبِيُّ بَنَى الْوَلِيُّ تَصْرِفُهُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فَيَلْزَمُ .

(٦٧٢) تثبت الإجارة بهذه الأمور الثلاثة [١] تثبت الإجارة بالإقرار الواقع من المؤجر والمستأجر عن المدة وتحديدها وعن كيفية استيفاء المنفعة المتحصلة من العين وعن قيمة الأجرة المتفق على سداها وعلى كيفية السداد، وغير ذلك مما يتعلق بالإجارة. [٢] وتثبت الإجارة بشهادة الشهود أو بالبينة الموضحة لطبيعة عقدة الإجارة والمدة الزمنية المحددة المتفق عليها والأجرة وكيفية دفعها. [٣] وتثبت بمين المالك.

وَالثَّانِي فِي الْوَقْفِ لَا تَنْفَسُخُ كَالْمَلِكِ وَفِي الصَّبِيِّ تَنْفَسُخُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْوَلَايَةِ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ يَنْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ، بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِهِ، فِيمَا قَبْلَهُ قَوْلًا تَقْرِيقُ الصَّفَقَةَ، وَاسْتَبْعَدَ الصَّيْدَ لَا نِيَّ وَالْإِمَامَ وَطَائِفَةً تَغْيِيرِ الْجُمُهورِ فِي الْوَقْفِ بِالْإِنْفَسَاخِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْعَرُ بِسِنِّ الْإِنْعِقَادِ، وَجَعَلُوا الْخِلَافَ فِي أَنَا هَلْ نَبَيُّنُ الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي غَيْرِ مَلِكِهِ.

[٧] (و) الْأَصَحُّ (أَنَّهَا تَنْفَسُخُ بِإِنْهَادِ الدَّارِ) الْمُؤَجَّرَةُ لِرِوَالِ الْأَسْمِ بِقَوَاتِ السُّكْنَى. (لَا انْقِطَاعَ مَاءِ أَرْضٍ أُسْتُوجِرَتْ لِزِرَاعَةٍ) لِبَقَاءِ الْأَسْمِ وَإِمْكَانِ الزَّرْعِ بِسُقُوقِ الْمَاءِ إِلَيْهَا. (بَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ) (وَأِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ) لِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تَحْتَ يَدِهِ.

[٨] (وَكَذَا لَوْ اكْتَرَى دَابَّةً لِرُكُوبٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ (وَقَبَضَهَا، وَمَضَتْ مُدَّةُ إِمْكَانِ السَّيْرِ إِلَيْهِ) وَلَمْ يَسِرْ، فَإِنَّ الْأَجْرَةَ تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ. (وَسَوَاءٌ فِيهِ إِجَارَةُ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةُ إِذَا سَلَّمَ) الْمُؤَجَّرُ (الدَّابَّةَ الْمُوصُوفَةَ) فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ (وَتَسْتَقِرُّ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرَةُ الْمِثْلِ بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ) سَوَاءً انْتَفَعَ أَمْ لَا، وَسَوَاءً كَانَتْ أَجْرَةُ الْمِثْلِ أَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى أَمْ أَكْثَرَ.

[٩] (وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا حَتَّى مَضَتْ) أَيْ الْمُدَّةُ (انْفَسَخَتْ) أَيْ الْإِجَارَةُ لِقَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ. (وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ مُدَّةً وَاجَرَ) دَابَّةً (لِرُكُوبٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ) (وَلَمْ يُسَلِّمْهَا حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ السَّيْرِ) إِلَيْهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا) أَيْ الْإِجَارَةُ (لَا تَنْفَسُخُ) إِذْ لَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا.

وَالثَّانِي : تَنْفَسُخُ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْمُكْتَرَى كَالْمُكْتَرَى وَعَلَى الْأَوَّلِ فَفِي الْوَسِيطِ أَنَّ لِلْمُكْتَرَى الْخِيَارَ لِتَأْخُرِ حَقِّهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ لَا خِيَارَ لَهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ مَا تَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةُ مِنْهُ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا تَحْصِيلُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، فَلَا فَسْخَ وَلَا انْفَسَاخَ بِحَالٍ.

[١٠] (وَلَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تَنْفَسُخُ الْإِجَارَةُ. وَأَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْعَبْدِ) فِي فَسْخِهَا وَيَسْتَوْفِي الْمُسْتَأْجِرُ مَنْفَعَتَهُ.

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِأَجْرَةٍ مَا بَعْدَ الْعِنَقِ) وَالثَّانِي: يَرْجِعُ بِأَجْرَةٍ مِثْلِهِ لِتَقْوِيَةِ السَّيِّدِ لَهُ. وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ قِيَسٌ فِي الْأَوَّلَى عَلَى مَا إِذَا مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى مَا إِذَا عَقَّتْ تَحْتَ رَقِيقٍ وَيَنْدَفِعُ الثَّلَاثَةُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ تَنَاوَلَ الرَّقَبَةَ خَالِيَةً عَنِ الْمَنْفَعَةِ بِقِيَّةِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

[١١] (وَيَصِحُّ بَيْعُ) الْعَيْنِ (الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْمُكْتَرَى وَلَا تَنْفَسُخُ الْإِجَارَةُ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: تَنْفَسُخُ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَابِعَةٌ فِي الْبَيْعِ لِلرَّقَبَةِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّابِعَةَ هِيَ الْمَمْلُوكَةُ لِلْبَائِعِ حِينَ الْبَيْعِ.

(وَلَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ جَارَ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا تَنْفَسُخُ) الْإِجَارَةُ بَلْ تَسْتَوْفِي مُدَّتَهَا وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ مَانِعَةٌ مِنَ التَّسْلِيمِ وَأَجِيبَ بِمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ، إِنَّ الْعَيْنَ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ

تُعَادُ إِلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ بِذَلِكَ لِقَلَّةِ زَمَنِهِ، وَالْقَوْلَانِ أَذِنَ الْمُسْتَأْجِرُ أَمْ لَا وَلِلْمُشْتَرِي فسخُ الْبَيْعِ إِنْ جَهِلَ أَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ.

(B B B)

